



La Sucesión por Causa de Muerte

LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE Y DONACIONES ENTRE VIVOS¹

Manuel Somarriva Undurraga - Ramón Meza Barros

Capítulo I: GENERALIDADES

I. Ideas generales y definiciones

Diversas acepciones del término sucesión.

a. Sentido lato: ocupar el lugar de una persona y recoger sus derechos a cualquier título. Ej. El comprador sucede al vendedor.
Esta forma de entender la palabra sucesión es aplicable a todos los modos de adquirir derivativos.

b. Sentido estricto: la expresión evoca la idea de muerte, teniendo un triple significado:

- i- Transmisión de todo o parte del patrimonio de una persona fallecida a una o más personas vivas, señaladas en la ley.
- ii- Patrimonio mismo que se transmite: objeto de la transmisión.
- iii- Conjunto de sucesores. "Sucesión de Pedro o de Juan"

La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio.

Sucesión por causa de muerte: modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta, o sea, el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles, o una cuota de dicho patrimonio, o especies o cuerpos ciertos. 588 y 951.

- a. Es un modo de adquirir señalado en el 588 CC.
- b. Es un modo de adquirir derivativo, ya que el derecho del sucesor procede del causante. La transmisión que opera la sucesión por causa de muerte no modifica el contenido ni la extensión del derecho, ya que nadie puede transferir más derechos que los que tenía. **Importancia para probar el dominio.**
- c. Es un modo de adquirir gratuito: sucesor reporta un beneficio, que puede aceptar o rechazar libremente, sin que le imponga un gravamen de una contraprestación. **Esto no significa que el asignatario siempre se enriquecerá.**
- d. Es un modo de adquirir por causa de muerte.
- e. Puede ser a título universal o a título singular, según si se adquiere una universalidad jurídica o una cosa determinada.
- f. Es más que un modo de adquirir el dominio, siendo toda una institución jurídica, lo que se manifiesta en el extenso articulado del CC.

¹ Se incorporan algunos comentarios de clases del profesor Claudio Illanes (en cursiva). Asimismo se incorporan (con **marcador gris**), determinados comentarios del profesor Somarriva U., hasta que se señale que se seguirá su libro íntegramente.

Derechos que se adquieren por sucesión por causa de muerte.

Sirve para adquirir derechos reales y derechos personales. No pasan al sucesor, los derechos reales y personales, que la ley declara intransmisibles. Se transmiten los derechos personales activa y pasivamente. El traspaso de las obligaciones por acto entre vivos es sustancialmente diferente del que se verifica por causa de muerte: por acto entre vivos se traspasa el crédito, pero no la deuda.

- **Derechos intrasmisibles**

Son la excepción a la regla general de la transmisibilidad. Dado su carácter **personalísimo**, se extinguen por la muerte de su titular.

- a) Derecho de usufructo: se extingue con la muerte del usufructuario. Se puede transferir entre vivos, pero los derechos se extinguen de todos modos a la muerte del usufructuario. **No se trata de un derecho personalísimo, pero es intransmisible;**
- b) Uso y habitación. No pueden transmitirse y tampoco son transferibles entre vivos;
- c) Expectativa del fideicomisario, cuando fallece antes de la restitución;
- d) Expectativa del asignatario condicional, que fallece estando pendiente la condición suspensiva (1078 y 1492);
- e) Acción revocatoria de las donaciones por causa de ingratitud, salvo cuando haya sido intentada en vida del donante, que el hecho ofensivo haya producido su muerte, o se haya ejecutado después de ella (1430). En tales casos se transmite a los herederos;
- f) Derecho del comodatario para gozar de la cosa prestada, salvo que el préstamo se haya hecho para un servicio particular que no puede suspenderse o diferirse (2180 No. 1 y 2186);
- g) Derechos que por su naturaleza tienen fijado como término la muerte de la persona que los goza, como el censo vitalicio y la renta vitalicia;
- h) Generalmente los derechos derivados del contrato de sociedad. Por RG se disuelve por la muerte de uno de los socios, a menos que se haya convenido expresamente continuarla con sus herederos (2103); y
- i) Mandato termina con la muerte del mandante o del mandatario. Se exceptúa el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante.

- **Obligaciones intransmisibles.**

Las obligaciones son generalmente transmisibles. "Quien contrata lo hace para sí y para sus herederos".

Hay, sin embargo, obligaciones intransmisibles:

- i. Obligaciones cuya ejecución supone aptitudes especiales del deudor (1095 y 2005);
- ii. Obligaciones en que juega un rol preponderante la confianza entre el deudor y el acreedor (mandato o sociedad, por ejemplo);
- iii. Generalmente las obligaciones de los miembros de una corporación (549); y
- iv. Solidaridad (1523).

Sucesión testamentaria e intestada.

Siendo un modo de adquirir derivativo, la sucesión por causa de muerte requiere un título. Éste puede ser el testamento o la ley.

Art. 952. Si se sucede en virtud de un testamento, sucesión se llama testamentaria, y si en virtud ley, intestada o abintestato.

La sucesión testada es obra de la **voluntad del difunto**, expresada en el testamento. Por su parte, la intestada es obra de **la ley**, que a falta de testamento, designa a las personas llamadas a suceder. La voluntad del testador prevalece para regular la suerte de sus bienes, siempre que se ajuste a las reglas mínimas que establece la ley (asignaciones forzosas, principalmente).

Sucesión parte testada y parte intestada.

Art. 952 inciso 2º: La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria, y parte intestada.

Asignaciones por causa de muerte.

Art. 953. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley, o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes.

Con la palabra asignaciones se significan en este Libro las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley.

Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.

Al difunto se le llama **causante**, porque produce la causa de la adquisición.

Sucesión a título universal o singular.

Art. 951. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular.

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto.

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo.

Por tanto, la sucesión es a título UNIVERSAL, cuando:

- i- Se sucede en la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones del difunto;
- ii- Se sucede en una cuota de la totalidad.

Será a título SINGULAR, cuando:

- i- Se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos;
- ii- Se sucede en una o más especies indeterminadas de cierto género.

Asignaciones a título universal o singular. (954)

Las asignaciones por causa de muerte a título universal se llaman **herencias**.

Las asignaciones a título singular se llaman **legados**.

Las asignaciones testamentarias, pueden ser a título universal o singular. Las asignaciones que hace la ley **siempre son a título universal**.

Asignatarios a título universal o singular.

Asignatario a título universal: **heredero**.

Existen, según lo dispuesto en el 951, herederos universales y herederos de cuota.

- Pueden existir pluralidad de herederos universales.
- No se debe confundir heredero universal con asignatario universal. Asignatario universal es el género. Un heredero de cuota es asignatario universal. No todo asignatario universal será heredero universal.
- Puede ser mayor el beneficio en la herencia del heredero de cuota que del universal.
- Es importante en cuanto **al derecho de acrecer**, que favorece a los herederos universales, y no a los herederos de cuota.

Asignatario a título singular: **legatario**.

Para hacer la calificación, se atiende únicamente al contenido de la asignación, con prescindencia de la calificación que realice el testador en el testamento.

Los herederos podrán ser testamentarios o abintestato. Los legatarios, como la ley no instituye legados, no podrán ser abintestato.

Diferencias entre el heredero y el legatario.

1. Objeto y contenido de la asignación que les corresponde.
2. El heredero representa a la persona del difunto, jurídicamente se confunden sus patrimonios, salvo que se impetren los beneficios de inventario o de separación. El legatario no representa al difunto.
3. El heredero es responsable de las deudas del difunto, tanto las que tenía en vida (hereditarias) como de las que resultan del testamento mismo (testamentarias). Responde, aunque le resulte un gravamen superior al valor de los bienes que hereda. El legatario no responde de las deudas sino cuando se le haya impuesto expresamente la obligación. Por excepción responde de las deudas hereditarias, en subsidio de los herederos, limitándose en todo caso su responsabilidad, al monto del legado. Asimismo responderá el legatario por el ejercicio de la acción de reforma.
4. El heredero adquiere el dominio desde el fallecimiento del causante. El legatario de especie o cuerpo cierto también lo adquiere en dicho momento. Si el legado es de género, sólo adquiere un crédito contra los obligados a

cumplirlo y se hace dueño sólo al momento de efectuarse la tradición de los bienes legados²;

5. El heredero adquiere juntamente con el dominio, la posesión legal de la herencia desde el momento en que se le defiera, aunque ignore que le ha sido deferida. (688 y 722). El legatario, aunque sea de especie o cuerpo cierto, no adquiere la posesión de la cosa. Requiere del corpus y del animus.
6. La institución de la posesión efectiva es típica del heredero y no se concede al legatario; y
7. Los herederos son instituidos por el testamento o la ley; los legatarios sólo por el testamento.

II. APERTURA DE LA SUCESIÓN Y DELACIÓN DE LAS ASIGNACIONES.

CONCEPTO DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN.

Es un hecho jurídico, consecuencial de la muerte de una persona, y en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus sucesores.

Somarriva: hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad.

Causas de la apertura de la sucesión.

La sucesión se abre con la muerte. Por muerte se entiende tanto la *muerte natural*, como la *muerte presunta*. En virtud del decreto que concede la posesión provisoria de los bienes del desaparecido, se procederá a la apertura y publicación del testamento si lo hubiere. Decretada la posesión definitiva, todos los que tengan derechos subordinados a la muerte del desaparecido, podrán hacerlos valer (artículos 84 y 91).

MOMENTO DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN.

955: *la sucesión en los bienes de una persona se abre "al momento de su muerte".* Por ello, se exige como requisito esencial, que al inscribir la defunción, se exprese la "fecha del fallecimiento" (art. 50 ley del RC). En el caso de la muerte presunta hay normas especiales relativas al momento de la muerte.

Prueba de la muerte.

La prueba de la muerte debe ser suministrada por quienes reclaman derechos en la sucesión. Generalmente se efectuará por la partida de defunción del Registro Civil. Debe presentarse, para obtener la correspondiente inscripción, un certificado del médico encargado de comprobar las defunciones o del que asistió al difunto en su última enfermedad, la cual señala causa de muerte, día y hora de la muerte. La muerte presunta se acreditará con las resoluciones judiciales que concedan la posesión provisoria o definitiva.

² Una diferencia entre el legatario de especie o cuerpo cierto y el legatario de género, es que el primero se hace dueño de los frutos desde el fallecimiento del causante. Los legatarios de género sólo se harán dueño de los frutos desde que se les haga la tradición o los herederos estén en mora de cumplir el legado.

Comurientes.

Art. 958. Si dos o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del artículo 79, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras.

Importancia del momento de la apertura de la sucesión.

- a. Determina las personas que son hábiles para suceder al difunto. 962. La persona debe ser capaz y digna de suceder al causante en ese momento.
- b. Se determinan los derechos en que ha de sucederse, siendo los que tenía el causante a ese momento;
- c. Comienza el estado de indivisión y los efectos declarativos del acto de partición se remontarán a dicho momento.
- d. Los efectos de la aceptación y de la repudiación de una herencia o legado de especie o cuerpo cierto se retrotraen al momento de la delación, que será generalmente el momento en que la sucesión se abre (1239 CC).
- e. La validez de las disposiciones testamentarias se determina en relación con la legislación vigente al momento de la muerte del testador. Artículos 18 y 19 de la LERL³.
- f. Pueden celebrarse pactos sobre derechos en una sucesión. No se incurre en un pacto sobre sucesión futura sino sobre una sucesión actual, siendo perfectamente posible actos respecto a estos derechos. (art 1909 y 1910 CC)
- g. Rigen las leyes vigentes al momento de su apertura.

LUGAR DE APERTURA DE LA SUCESIÓN.

955: *la sucesión de una persona se abrirá en el momento de su muerte, en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados.* El término domicilio debe tomarse en su sentido legal (59).

Reglas de excepción

La única excepción se refiere a la apertura de la sucesión del desaparecido, declarado muerto presuntivamente. En tal caso, se abre la sucesión en el último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile.

a. Importancia del lugar de la apertura de la sucesión.

- a. Fija la competencia de los tribunales. Apertura y publicación del testamento, deben hacerse ante el juez del último domicilio del testador (1009). El mismo juez conocerá de los inventarios, tasaciones, desheredamientos, petición de herencia, entre otras (148 COT).

³ En lo relativo a la capacidad de testar se debe estar al art. 1006 CC.

Cuando una sucesión es abierta en el extranjero y comprende bienes situados en Chile, la posesión efectiva de la herencia deberá pedirse en el último domicilio del causante en el territorio chileno o en el domicilio del solicitante su aquél no hubiere tenido en el país (149 COT);

b. Fija la ley que regirá la sucesión.

LEY QUE RIGE LA SUCESIÓN.

Art. 955. *La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvos los casos expresamente exceptuados.*

La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvo las excepciones legales.

El CC se aparta en cierto sentido de lo dispuesto en el Art. 16. La ventaja de esto es que se somete la sucesión a una ley única.

Excepciones a la regla que somete la sucesión a la ley del último domicilio.

A- Art. 15 no. 2: el chileno queda obligado a observar las leyes sucesorias chilenas. Se aplicará sólo respecto del cónyuge⁴ o parientes chilenos. La aplicación práctica de la norma se subordina a la existencia de bienes en Chile.

B- Art. 998: *causante extranjero que fallece dentro o fuera de la República. Los chilenos tendrán a título de herencia, o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían en la sucesión intestada de un chileno.*

Críticas a la norma:

- Debió hablar del lugar en que el extranjero tenía el domicilio y no el de la muerte;
- Es lógico que si muere en Chile, se apliquen las normas chilenas.
- Se discute su aplicación en caso que el causante haya dispuesto por medio del testamento que perjudique a los asignatarios forzosos.

El derecho de los parientes chilenos, supone que el causante haya dejado bienes en Chile. Con el objeto de satisfacer sus derechos "podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero existentes en Chile todo lo que le corresponde en la sucesión del extranjero. En el evento de que no existan bienes en Chile deberá estarse a lo que prescriba la legislación del lugar de la apertura de la sucesión respecto al derecho de los sucesores chilenos.

⁴ El art. 16 de la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil, establece "Cada conviviente civil será heredero intestado y legitimario del otro y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente". Así podemos señalar que en cada mención que el legislador hace al cónyuge sobreviviente se tendrá que considerar al conviviente civil sobreviviente. Con todo los artículos 17 y siguientes de esta ley señalan expresamente derechos específicos que se le conceden al conviviente civil sobreviviente y serán reconocidos de forma expresa en el apunte.

C- Muerte presunta: se regirá por la ley del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile.

D- Persona que deja bienes en Chile (efectos tributarios): aunque se aplicase una ley extranjera, habrá de pedir en Chile la posesión efectiva de la herencia, respecto de los bienes situados en el país (Art. 27 de la ley 16.271). Su objeto es cobrar el impuesto de herencia de esos bienes dejados en Chile.

LA DELACIÓN DE LAS ASIGNACIONES.

Abierta la sucesión tiene lugar, por regla general, la **delación** de las asignaciones.

*956 inciso primero: La **delación** de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla.*

La herencia o el legado son ofrecidos a los asignatarios, surgiendo para ellos la opción de aceptar o de repudiar. 1255: "Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente".

Esto se explica por una razón histórica: en Roma existían **herederos necesarios** que adquirirían la herencia y sus responsabilidades aún contra su voluntad⁵

No se debe confundir la delación con la apertura de la sucesión. La delación es una consecuencia de la apertura de la sucesión.

Somarriva señala que deben distinguirse 3 etapas:

1. Apertura de la sucesión
2. Delación de las asignaciones
3. Pronunciamiento del asignatario, en orden a aceptar o repudiar.

La delación opera normalmente al momento de la muerte del causante.

Generalmente apertura y delación se producen a la muerte. Esto sólo tendrá lugar cuando la asignación sea pura y simple. 956 inciso 2º: La herencia o legado se defiende al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente; **o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional.**

La excepción siempre se refiere a las asignaciones testamentarias, ya que las asignaciones que hace la ley siempre son puras y simples. Asimismo se

⁵ Nace la cuestión sobre en qué estado se encuentra el asignatario respecto a la asignación cuando aún pende su aceptación de esta. Existen dos teorías que explican la cuestión. Teoría Romana: Con la delación de la herencia nace el derecho de opción para aceptar o repudiar y mientras no se manifiesta la voluntad del asignatario este nada ha adquirido. Teoría Germánica: Con la aceptación se adquiere la calidad de sucesor. Durante el periodo en que pende la aceptación o repudiación se tiene un derecho provisional sobre la asignación conferida.

entiende que se tratan de condiciones suspensivas, ya que de ser resolutorias, no se posterga la delación.

Condición negativa y meramente potestativa del asignatario.

La excepción anterior no tiene lugar cuando la condición sea negativa y meramente potestativa del asignatario.

956 inciso 3º: "Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, pues en este caso la asignación se defiere en el momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos, en caso de contravenirse a la condición.

Lo anterior, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada. 956 inciso final.

Por lo anterior, Somarriva distingue 3 tipos de condiciones para los efectos de la delación: condición suspensiva, condición resolutoria y condición suspensiva que consista en no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario.

Efectos que produce la Delación.

a) Nace un derecho potestativo de opción en favor del asignatario, quien pasa a ser titular de la potestad de aceptar o repudiar la asignación.

b) El asignatario no adquiere la asignación por la aceptación. La adquiere al abrirse la sucesión si es una herencia o un legado de especie; o al hacérsele la tradición si es legado de género.

c) La aceptación es, en consecuencia, sólo la renuncia al derecho de repudiar.

d) Si el asignatario no acepta ni repudia nada pasa a menos que se le constituya en mora de declarar si acepta o repudia (art 1233).

e) Los efectos de la aceptación o repudio se retrotraen al momento de la delación (art. 1239).

III. EL DERECHO DE HERENCIA

Concepto.

Herencia: universalidad jurídica que comprende derechos y deudas, elementos activos y pasivos de carácter transmisible.

El concepto de Herencia puede ser entendido desde un punto de vista objetivo y subjetivo. Desde el primero puede ser entendido como todo el patrimonio del difunto, involucrando todas sus relaciones jurídicas transmisibles, independientemente de su contenido efectivo.

Desde una perspectiva subjetiva la herencia es un derecho. Puede ser definido como el **derecho real que confiere la facultad o aptitud de una persona para suceder y en el patrimonio del causante o una cuota de este (Somarriva).**

Características.

1. Derecho Real
2. Constituye una universalidad jurídica distinta de los bienes que la componen (incidencia al no considerarla como inmueble).
3. Tiene una vida efímera. Practicada la división, el derecho pasa a ser de dominio⁶.

La herencia es un derecho real. (577)

En nuestra legislación es incontrovertible esta afirmación, ya que hay disposición expresa. Es un derecho absoluto que posee una acción oponible erga omnes: acción de petición de herencia.

El derecho real de herencia se puede adquirir por tres modos de adquirir:

1. Por sucesión por causa de muerte;
2. Por la tradición: cesión de derechos hereditarios;
3. Prescripción.

Adquisición de la herencia por sucesión por causa de muerte.

En nuestro CC, siguiendo a Francia y al sistema germánico medieval, se adquiere la herencia por el solo ministerio de la ley. Si opera por el ministerio de la ley la adquisición ¿no debería sólo hablarse de la repudiación de la herencia y no de la aceptación? La aceptación en nuestro derecho consolida la adquisición verificada por el ministerio de la ley y la hace definitiva. Con este sistema, se pretende evitar una solución de continuidad en el dominio⁷.

Posesión legal de la herencia.

La sucesión por causa de muerte otorga al heredero el dominio de la herencia, de los bienes hereditarios. ¿Qué ocurre con la posesión de la herencia?

⁶ Sobre críticas al carácter real y vida efímera del derecho real de herencia. Consultar: Soza Ried, María de los Ángeles. (2004). La Cesión del "Derecho Real" de Herencia y de una Cuota Hereditaria. Revista de derecho (Valdivia) Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502004000200004

⁷ Ello implica la necesidad de que un sujeto- el heredero- asuma la titularidad de las relaciones jurídicas transmisibles de otro- el causante- una vez que éste muera, sin solución de continuidad. Esta exigencia de continuidad presenta tres aspectos- el de los derechos, el de las obligaciones y el de la posesión-: a) la extinción de la propiedad sobre las cosas privaría a éstas del sujeto, convirtiéndolas en res nullius y haciendo que puedan ser adquiridas por el primer ocupante. b) la extinción de las obligaciones del causante, aparte del perjuicio particular de sus acreedores, destruiría las bases del crédito- esenciales en la sociedad moderna- y haría imposible el tráfico jurídico. c) Por último, si se extinguiera la posesión de las cosas del causante, estas quedarían en situación de no ser poseídas por nadie (...) Todo esto provocaría el trastorno y el caos social, que la figura del heredero impide con su función continuadora de las relaciones jurídicas del causante. (Pérez Lazala, J.L. *Curso de Derecho Sucesorio*, Buenos Aires, 1989, p. 41, obra citada por Elorriaga de Bonis).

Posesión legal

722: La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. **688:** En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero. *Al tener la posesión legal, nace el derecho para aceptar o repudiar la herencia, teniendo transcendencia fundamental en lo que dice relación con el Derecho de Transmisión. Se trata de una posesión distinta a la material, siendo la ley la que la otorga y teniendo caracteres distintos a los requeridos por el 700.* El heredero puede carecer de corpus y de animus y sin embargo, tener la posesión legal. La posesión de los herederos, será distinta de la del causante, debido a que la posesión no se transmite (ni se transfiere), principiando en el sucesor (717). Se ha fallado que la posesión legal de la herencia sólo corresponde al heredero verdadero, y no al putativo.

De la posesión legal, adquirida por el ministerio de la ley, se derivan dos consecuencias:

- i. El heredero puede tomar la posesión material inmediata de todos los bienes sucesorios; y
- ii. Puede ejercitar toda suerte de acciones posesorias relativamente a bienes que nunca ha poseído de hecho.

*El profesor Illanes analiza junto a la posesión legal, el concepto de posesión **real o material**: se produce en el momento en que el heredero o legatario toma posesión material de los bienes de la herencia o del legado, entendiendo que se acepta en el mismo momento. Así, nos encontramos con dos posesiones: legal: no buscada por el asignatario (habilita para aceptar o repudiar); y material: buscada por el asignatario (se entiende aceptada). Esta posesión material equivale a la definida en el 700, debiendo concurrir el corpus y el animus. Lo frecuente es que se radique conjuntamente con la legal en manos del verdadero heredero. Habilita para adquirir por prescripción adquisitiva.*

Posesión efectiva. Se trata de un mecanismo de orden *procesal* que busca **organizar a la sucesión**. Sufrió una importante modificación, por ley 19.903 de 2003. Se distingue entre sucesiones testadas e intestadas. Las testadas se dejaron en sede jurisdiccional, ya que se podrían presentar más problemas con las asignaciones forzosas y con los márgenes de disposición.

- La tramitación de las sucesiones intestadas se radica en el Registro Civil (sede administrativa).

- Las testadas abiertas en Chile y las testadas e intestadas abiertas en el extranjero, cuando afecten a chilenos o sea sobre bienes situados en Chile, se radican en sede judicial.

Somarriva la define diciendo que es aquella que se otorga por resolución judicial o administrativa a quien tiene la apariencia de ser heredero. Requiere de una sentencia judicial o de una resolución de la Dirección Regional respectiva del Registro Civil.

*El decreto de posesión efectiva **no confiere la calidad de heredero, sino sólo la de heredero putativo**. La persona a cuyo nombre se otorga se considera heredero putativo, pudiendo realizar una serie de gestiones (por ejemplo, solicitar inscripciones) y estando beneficiado por un plazo menor de prescripción adquisitiva: 5 años y no 10 como es la regla general.*

La afirmación de que la posesión efectiva no otorga la calidad de heredero, se infiere de los siguientes artículos:

- 877 CPC;
- El falso heredero que está en posesión efectiva, puede adquirir por prescripción de 5 años y si la tiene que adquirir por este medio, es porque no tiene la calidad definitiva.

Sin embargo, en las herencias intestadas abiertas en Chile, hay normas que buscan obtener que la posesión efectiva se otorgue a todos los que tengan la calidad de herederos.

Art. 6 de la ley 19.903: se otorga a todos los que, en conformidad a los Registros del Registro Civil posean la calidad de herederos, aun cuando no hayan sido incluidos en la solicitud y sin perjuicio de su derecho a repudiar la herencia de acuerdo a las reglas generales. También se aplica a los que acrediten esa calidad, si no se encuentran inscritos en Chile.

La importancia de la posesión efectiva, radica en su función en torno a:

1. Mantención de la historia de la propiedad raíz.
2. Validez del pago. 1576.
3. Prescripción más breve.

A raíz de la reforma de la ley 19.903, es preciso distinguir:

- a. Posesiones efectivas intestadas abiertas en Chile: se sujetan a las disposiciones de la mencionada ley, tramitándose y otorgándose en el Registro Civil;
- b. Posesiones efectivas correspondientes a sucesiones testamentarias y abiertas en el extranjero: se siguen tramitando en la justicia ordinaria.

Según Somarriva y según el SII, si la sucesión es parcialmente testada, la posesión efectiva se tramita ante la justicia ordinaria.

Posesiones efectivas otorgadas por la justicia. Ver normas del CPC.

1. Solicitud. Ante el juez del último domicilio del causante.

2. Quienes la solicitan. No es necesario que la pidan todos y cada uno de los herederos. Pero debe pedirse para todos. El tribunal, en virtud del 881 inciso 1º, solicitará informe al Registro Civil respecto de las personas que posean presuntamente la calidad de herederos y de los testamentos que aparezcan otorgados por el causante en el Registro Nacional de Testamentos.

3. Inventario y valorización de los bienes. 880 CPC. Se confecciona un inventario y se valorizan las partidas del mismo. Puede no ser solemne si todos los herederos, siendo capaces de administrar sus bienes, lo determinan unánimemente (1284).

4. El auto de posesión efectiva y trámites posteriores a su concesión. Publicación del auto. Se denomina generalmente auto, pero se trata de una sentencia definitiva. 882 CPC: la resolución que concede la posesión efectiva de la herencia se

publicará en extracto por 3 veces en un diario de la comuna, de la capital de la provincia o de la capital de la región cuando allí no lo haya.

5. Inscripción de la posesión efectiva. Dictado el auto, publicados los avisos y protocolizado el inventario simple o solemne, el peticionario solicita al tribunal que ordene la inscripción de la resolución que concedió la posesión efectiva en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del territorio jurisdiccional en que haya sido pronunciada la resolución de posesión efectiva, con indicación de la notaría en que se protocolizó el inventario y la enumeración de los bienes raíces que en él se comprenden. Si existen inmuebles en la masa hereditaria, el auto de posesión efectiva también debe inscribirse en el territorio jurisdiccional en que éstos se ubiquen.

6. Oposición a la posesión efectiva. La gestión de posesión efectiva es de carácter no contencioso, pudiendo aplicársele el 823: un legítimo contradictor puede oponerse a que se conceda la posesión efectiva a quien la está solicitando, en cuyo caso el asunto pasa a ser contencioso y se sujeta a los trámites del juicio correspondiente, que generalmente será el ordinario. Si la oposición la hace quién no es legítimo contradictor, el tribunal rechazará de plano. El legítimo contradictor es aquel cuyo derecho a la herencia es de tal naturaleza que le permite obtener en forma exclusiva o por lo menos en igualdad de condiciones con el solicitante la posesión efectiva de la herencia que pretende.

Deducida la oposición, se paraliza la gestión de posesión efectiva y transforma el asunto en contencioso. Al hacerse contencioso el asunto termina toda actuación no contenciosa y deben entablarse los juicios controvertidos correspondientes, sin que la oposición obre como demanda.

7. Revocación de la posesión efectiva. En materia no contenciosa las sentencias son revocables o modificables, a petición del interesado, y siempre que hayan variado las circunstancias que la motivaron. 821 CPC. Si fue denegada la posesión efectiva, el auto puede modificarse o revocarse en cualquier momento, variando las circunstancias. Pero si se ha concedido, sólo puede modificarse o revocarse si está pendiente su ejecución. Para entender que está pendiente, la jurisprudencia ha hecho un distingo: si el auto no está inscrito en el CBR, se puede pedir su modificación o revocación. Si está inscrito, se requerirá de un nuevo juicio, por no encontrarse pendiente la ejecución. La CS dictó un fallo que está en contradicción con lo mencionado: autoriza a la ampliación de la posesión efectiva ejecutoriada a otros herederos de igual derecho que aquellos a los que se les había concedido.

Según Somarriva, hasta la inscripción, se puede oponer. Luego de ella, sólo cabe hacerse efectivas las acciones de petición de herencia, refirma de testamento, nulidad, etc.

Posesiones efectivas ante el Registro Civil.

Debe tratarse de (1) sucesiones intestadas; y (2) abiertas en Chile.

Tramitación ante el Registro Civil.

- 1. Solicitud.** En formulario confeccionado por el Servicio de RC en el que deberán individualizarse los herederos, nombre, apellidos, roles únicos nacionales, domicilio, calidad en que heredan.
- 2. Inventario y valorización.** Art. 4 de la ley 19.903. El inventario se considerará solemne, pero para entender que el solicitante acepta con beneficio de inventario, debe declararlo así en el formulario de solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en el 1252 y 1256 CC.
- 3. Resolución que otorga la posesión efectiva.** La posesión efectiva será otorgada por resolución fundada del Director Regional respectivo. La resolución que la concede contiene las mismas menciones requeridas para la solicitud. Asimismo contendrá el inventario y valorización de los bienes presentados y dispondrá la publicación. Estas resoluciones se encontrarán exentas del trámite de la toma de razón.
- 4. Publicaciones.** La resolución que concede la posesión efectiva será publicada en extracto por el Servicio en un diario regional correspondiente a la región en que se inició el trámite de la posesión efectiva, el día 1º o 15º de cada mes o el hábil siguiente, si caen sábado o feriado.
- 5. Inscripciones.** Efectuada la publicación, el Director Regional competente ordenará inmediatamente la inscripción de la resolución en el **Registro Nacional de Posesiones Efectivas.**

6. **Aranceles.** El trámite de la posesión efectiva no es gratuito y está sujeto a un arancel, cuyo pago es un ingreso para el Servicio.
7. **Oposiciones y rectificaciones.** No está reglamentada la oposición por legítimo contradictor, porque se trata de una tramitación administrativa, y no de una gestión no contenciosa. Sin embargo, de acuerdo a las normas del Derecho Administrativo, cualquier interesado puede hacerse presente antes de la inscripción de la posesión efectiva, invocando, por ejemplo, que la herencia es testada, o que se le ha omitido u otorgado a herederos que no corresponden.
8. **Revocación de la posesión efectiva.** Lo que no es posible es hacerlo una vez inscrita la resolución que se pronuncie sobre la solicitud. En tal caso, sólo quedará accionar con las correspondientes acciones de nulidad y de petición de herencia.

Requisitos para que los asignatarios puedan disponer de los bienes asignados.

Deben cumplir con 2 requisitos:

A) Pagar o asegurar el pago del impuesto de herencia, requisito común a los legatarios.

Se prohíbe a los notarios autorizar escrituras públicas de adjudicaciones de bienes hereditarios o de enajenaciones o disposiciones en común que hagan los asignatarios y a los Conservadores inscribirlas sin que en dichas escrituras se inserte el comprobante de pago del impuesto de herencia, comprobante de haberse garantizado el pago, o autorización para enajenar del SII. El servicio de RC deberá determinar la forma en que se pruebe el pago del impuesto de herencia.

B) Efectuar determinadas inscripciones. 688

Para disponer de los bienes muebles de la herencia, basta la inscripción de la posesión efectiva. Pero, para poder disponer de los **inmuebles hereditarios**, el artículo 688, además de la inscripción de la posesión efectiva, exige otras inscripciones.

Art. 688. En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda:

1º La inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva: el primero ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento, y la segunda en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas;

2º Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente: en virtud de ellas podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles hereditarios, y

3º La inscripción prevenida en el inciso tercero: sin ésta no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido.

- El inciso 1º reproduce el 722, en el sentido de que en el momento de deferirse la herencia, la posesión se confiere por el ministerio de la ley al heredero. La posesión legal, sin embargo, no habilita para disponer de los inmuebles hereditarios, sin que se efectúen las inscripciones señaladas.
- La expresión "disponer" debe entenderse en el sentido de "enajenar": transferencia del dominio o constitución de derecho real.
- Las inscripciones exigidas son 3:

- 1. Posesión efectiva y testamento en su caso.** Las posesiones efectivas que se tramitan en tribunales deben inscribirse (la resolución que la otorga) y el testamento en el CBR de la comuna en que fue pronunciada la resolución⁸. En el caso de que la otorgue el Registro Civil, se inscribe la resolución administrativa en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas.
- 2. Inscripción especial de herencia.** Inscribir los distintos inmuebles dejados por el causante a nombre de todos los herederos: a nombre de la comunidad. Se realiza (la inscripción) en el lugar en que están ubicados los inmuebles. Se hacen tantas inscripciones como inmuebles hayan. En virtud de esta inscripción los herederos podrán disponer de consuno de los inmuebles hereditarios. No hay que confundirse: aun cuando la tramitación de la sucesión haya sido llevada a cabo en el Registro Civil, deberá hacerse esta 2ª inscripción en el CBR correspondiente.
- 3. Acto de partición o adjudicación.** Debe inscribirse la adjudicación de los diferentes inmuebles, hecha en virtud de la partición, a nombre del correspondiente adjudicatario. Con ésta, se podrá disponer libremente.

Estas inscripciones tienen por objeto conservar la historia de la propiedad raíz, y no constituyen tradición. Pese a la errada ubicación en el CC ("De las otras especies de tradición"), no puede considerarse que son tradición, ya que las cosas sólo pueden adquirirse por un modo de adquirir y, en este caso, ya operó la sucesión por causa de muerte. Sólo buscan darle continuidad a la historia de la propiedad raíz. Sin la inscripción de la posesión efectiva, no podría entenderse cómo adquirieron la propiedad los comuneros. Sin la inscripción de la adjudicación, tampoco podría entenderse como pasó a un 3º.

Sanción por la omisión de las inscripciones hereditarias.

El art. 688 se limitó a señalar que los herederos no podían disponer sin las inscripciones, pero no determinó que ocurriría si los herederos violaban la prohibición, es decir, enajenaban un inmueble sin efectuar las inscripciones del 688. Distintas etapas:

- a. Nulidad absoluta:** el 688 era una norma prohibitiva, con lo cual se cae en la sanción del art. 10. Sumado a esto se señalaba que todo lo referido a la propiedad raíz era de orden público. Ampliando esta tesis, la CS llegó

⁸ El CC debió hablar de resolución judicial y no de decreto judicial, ya que se trata de una sentencia en materia no contenciosa.

a afirmar que los actos que contravenían la norma eran nulos, fueran enajenaciones voluntarias o forzadas. El fallo era erróneo, porque les dejaba abierta las vías a los herederos para burlar a los acreedores. Luego, frente a las protestas de las instituciones de crédito, la CS rectifica y determina que sólo se aplican a las voluntarias.

La sanción del 688 no puede ser la nulidad absoluta. (1) El 688 no se trata de un precepto prohibitivo, porque permite realizar el acto bajo ciertas condiciones. Se trata de un precepto imperativo de requisitos. (2) La nulidad absoluta no puede ratificarse y la omisión del 688 puede sanearse por voluntad de las partes (herederos inscriben posteriormente: efecto retroactivo de la tradición, 682). (3) La nulidad absoluta se sana por el tiempo y la omisión de las inscripciones del 688 jamás podrá sanearse, mientras no se practiquen las correspondientes inscripciones.

b. Nulidad de la tradición, siendo válido el contrato: por los contratos no se dispone (enajena). La tradición es la forma de enajenar. Es errada esta tesis, en virtud del 1810. El fallo, precisamente recaía en una compraventa. Si no recayera en una compraventa, sería válido.

c. La sanción está indicada en el 696, o sea, el adquirente queda como mero tenedor. Es ésta la solución que acepta generalmente la doctrina.

Críticas a la última doctrina.

1. 714: el mero tenedor reconoce dominio ajeno. En este caso, el adquirente no reconocería ningún dominio ajeno.
2. Los herederos continuarían como dueños y poseedores del inmueble. Sin embargo, es absurdo porque los herederos carecen del corpus y del animus, habiendo realizado tradición con intención de transferir el dominio.
3. El 696 es una sanción aplicable cuando las inscripciones actúan como tradición y en este caso no ocurre ello, debido a la mala ubicación de la norma.

d. La nulidad relativa como sanción. (no es una tendencia jurisprudencial). Podría afirmarse que sería esta sanción por el hecho de poder sanearse y por estar establecido en atención al estado o calidad de las partes. Sin embargo, tropieza con el hecho de que la nulidad relativa se sana por el tiempo, cuestión que no ocurre con la omisión de las inscripciones del 688.

e. Somarriva: la sanción sería que el adquirente quedaría como poseedor. Si bien los herederos no pueden transferir la propiedad, no hay inconveniente de que puedan dejar como poseedores a los adquirentes.

Adquisición de la herencia por otros medios (modos).

A. POR LA TRADICIÓN:

Fallece el causante, se abre la sucesión y uno de los herederos cede el derecho real de herencia. De no haber fallecido, hay objeto ilícito por

tratarse de pactos sobre sucesiones futuras (1463). Se trata de la cesión del derecho de herencia. La cesión de los derechos hereditarios requieren: 1) Que el causante hubiera fallecido; 2) Supone la existencia de un título traslativo de dominio; y 3) No deben cederse bienes determinados, sino una universalidad o una cuota, so pena de degenerar en otro contrato (por ejemplo, compraventa del bien determinado). No se requiere hacer las inscripciones del 688. La tradición se efectuará conforme a las reglas de los muebles. Asimismo, y producto del hecho de que no se traspasen bienes determinados, no se requiere cumplir con formalidades habilitantes. El punto se ha controvertido. Era controvertido principalmente cuando la mujer casada en SC era incapaz relativa. Hoy, el marido requiere de autorización de la mujer para gravar o enajenar los derechos hereditarios de la mujer.

Efectos de la cesión de derechos: el cesionario pasa a ocupar el lugar jurídico que tenía el cedente.

- i. Puede solicitar la posesión efectiva;
 - ii. Puede solicitar la partición de bienes;
 - iii. Puede intervenir en la partición;
 - iv. Puede ejercitar las acciones de petición de herencia y de reforma de testamento;
 - v. Tiene derecho al acrecimiento 1910.
 - vi. Responde de las deudas de la herencia⁹
- Somarriva creía que el acreedor hereditario puede dirigir la acción contra el cedente o contra el cesionario.
- vii. **1910 incisos 1º y 2º:** derecho a indemnizaciones entre el cedente y el cesionario.
 - viii. El heredero cesionario, no responderá nunca del evento incierto de ganancia o pérdida: **la cesión de derechos hereditarios es un acto típicamente aleatorio.** En las cesiones a título oneroso, sólo respondería de su calidad de asignatario. En las cesiones a título gratuito, ni siquiera de dicha calidad.

Las normas anteriores se aplican a los legados, siempre que se legue una cosa indeterminada (1909 primera parte).

⁹ Cabe mencionar que se estima que en virtud de la regla *semel heres semper heres* (el que es heredero continúa como heredero) no se traspasaría la posición jurídica de heredero al cedente. Según Elorriaga, no hay por tanto una subrogación en la calidad de heredero que tenía el cedente, sino que en rigor, lo que existe es solo un traspaso del activo sucesorial al cesionario, los efectos de ser heredero, pero la calidad de heredero y la responsabilidad que de ella deriva ante los acreedores hereditarios y testamentarios permanece en el cedente.

Frente al cedente, el cesionario adquiere la universalidad, pero frente a los acreedores solamente el activo y ellos no tienen por qué, necesariamente, perseguir al cesionario.

El acreedor testamentario no ha prestado su consentimiento expreso de dar por libre al primitivo deudor (cedente) y en consecuencia no ha podido operar la novación (art. 1635).

B. POR PRESCRIPCIÓN:

Regularmente al cabo de 10 años. Excepción: heredero putativo a quien se le concedió la posesión efectiva: 5 años, sirviendo el decreto o la resolución administrativa como justo título (704 inciso final) (1269).

Operará este medio cuando esté siendo poseída por un falso heredero.

Los 5 años se cuentan desde la inscripción del auto o resolución administrativa de posesión efectiva. Los 10 años se cuentan desde que se entra en posesión material.

La prescripción de 5 años se trata de una prescripción ordinaria. 2512 y 704. Con esto, según Somarriva, se suspendería a favor de los herederos incapaces. Hay sentencias contradictorias.

Se estima entonces que es requisito para adquirir por dicho plazo de posesión además de contar con el decreto la buena fe al momento de adquirir la posesión, cumpliendo los requisitos de la posesión regular del derecho.

IV. INCAPACIDADES E INDIGNIDADES PARA SUCEDER.

Requisitos generales para suceder.

Para suceder se requiere generalmente ser capaz y digno. El asignatario, sea a título universal o singular, sea testamentario o abintestato, debe ser capaz y digno de suceder¹⁰.

1. Incapacidades para suceder

Concepto.

Capacidad: aptitud legal para suceder una persona a otra, la habilidad para adquirir por causa de muerte, para poder ser heredero o legatario. Esta capacidad constituye la RG: 961. Por ello, el estudio se reduce a analizar las excepciones a la RG, esto es, las incapacidades para suceder.

La incapacidad para suceder es una incapacidad de goce.

Se trata de una incapacidad especial, porque sólo importa una falta de aptitud para ser titular de los derechos que implican las calidades de heredero o legatario.

Incapacidad absoluta o relativa.

Absoluta: pone al incapaz en imposibilidad de suceder a toda persona.

Relativa: impide al incapaz suceder a determinado causante.

¹⁰ Es necesario también la determinación del asignatario y del objeto de la asignación, principalmente en la sucesión testamentaria. 1051: debe tratarse de persona cierta y determinada.

A diferencia de lo que ocurre con el 1682, que sanciona con nulidad relativa los actos de los incapaces relativos y con nulidad absoluta la de los incapaces absolutos, las consecuencias de la incapacidad para suceder siempre son las mismas, sean absolutas o relativas.

Incapacidades Absolutas.

- A.** Falta de existencia natural;
- B.** Falta de personalidad jurídica.

Incapacidad del que no existe naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión.

962: Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión.

Toda asignación lleva envuelta la condición de existir el asignatario al tiempo del fallecimiento del causante, que es el momento en que la apertura se produce. No pueden suceder, por tanto:

1. Los que han dejado de existir al abrirse la sucesión, es decir, fallecen antes del causante (a menos que tenga lugar el derecho de representación);
2. Los que no han comenzado a existir cuando falleció el causante.

34. Excepciones a la Regla General

1. Personas concebidas al abrirse la sucesión. La persona que esté concebida al momento de abrirse la sucesión puede suceder. Los derechos permanecen suspensos hasta que el nacimiento se efectúe (77). El nacimiento no podrá efectuarse más allá de los 300 días posteriores al fallecimiento. Meza Barros, según mi modo de entender, incurre en una contradicción: establece como excepción a la RG que la persona esté concebida al abrirse la sucesión, cuando la regla general precisamente es existir naturalmente al momento de abrirse. Somarriva establece que del 962, se extrae que es capaz el que existe naturalmente.
2. Personas cuya existencia se espera. (962 inciso 3º). La asignación se sujeta a la condición de existir el asignatario. Es necesario que el asignatario llegue a existir antes de expirar los 10 años subsiguientes a la apertura de la sucesión. Mientras se espera la existencia, los bienes quedan en poder de la persona designada por el testador o de los herederos, pudiendo importar un fideicomiso.
3. Asignaciones en premio de servicios importantes. 962 inciso 4º. Tienen la misma limitación del plazo de 10 años. Es condicional subordinada al hecho futuro e incierto de que se preste el servicio señalado por el testador.
4. Asignaciones condicionales. Cuando la asignación es condicional, sujeta a condición suspensiva, no es suficiente que el asignatario exista al tiempo de la apertura de la sucesión, sino también se requiere que exista en el momento de cumplirse la condición. 962 inciso 2º. 1078.
5. Sucesores por derecho de transmisión. **No es verdaderamente una excepción.** El transmitido no existe en el momento del fallecimiento del primer causante, pero no sucede al primer causante sino al transmitente. El transmitido debe existir al momento de abrirse la sucesión del transmitente. Más que una excepción, es una aplicación de las reglas generales.

Incapacidad de las entidades que no son personas jurídicas.

963: Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios, o establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas.

Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal, y obtenida ésta, valdrá la asignación.

Las personas que carecen de personalidad jurídica no existen ante el derecho.

El CC francés exige una autorización del Presidente de la República para que puedan suceder por testamento diversas entidades, aunque estén dotados de personalidad jurídica.

Personas jurídicas extranjeras.

No se discute que las personas jurídicas extranjeras de derecho público, puedan ser capaces de suceder.

En cambio, se discute la cuestión para las personas jurídicas extranjeras de derecho privado. Para algunos, no son capaces, a menos de que su existencia haya sido autorizada conforme al 546 CC. Para otros, la autorización es innecesaria, rigiendo sólo para las personas jurídicas constituidas en Chile.

Incapacidades Relativas.

- I.** El que antes de deferírsele la herencia o legado hubiera sido condenado judicialmente por el crimen de daño ayuntamiento con dicha persona y no hubiere contraído matrimonio que produzca efectos civiles.

Lo mismo se extiende a la persona que antes de deferírsele la herencia o legado hubiere sido acusada de dicho crimen, si se siguiere condenación judicial.

- El crimen de daño ayuntamiento no está contemplado en el Código Penal.
- Es relativa porque impide suceder a la persona con quién delinquiró;
- Se comprende la sucesión testamentaria y abintestato;
- Es necesario que medie condena judicial o al menos acusación de la que se siga condenación (hoy debe entenderse como que se hubiera formalizado la investigación). Se busca que las acusaciones no tengan por objeto aumentar la cuota en la herencia. Por ello, se requiere formalización o condena.
- Debe entenderse como delitos de incesto o de adulterio (derogado como delito penal).
- Puede purgarse con el matrimonio. Sin embargo, no se explica dicha excepción, ya que existen incapacidades para contraer matrimonio con las personas con las que se cometen los mencionados delitos.

- II.** Art. 965. Por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir herencia o legado alguno, ni aun como albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al difunto durante la

misma enfermedad, o habitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento; ni la orden, convento, o cofradía de que sea miembro el eclesiástico; ni sus deudos por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.

Pero esta incapacidad no comprenderá a la iglesia parroquial del testador, ni recaerá sobre la porción de bienes que el dicho eclesiástico o sus deudos habrían heredado abintestato, si no hubiese habido testamento.

- Es necesario que el testamento haya sido otorgado durante la última enfermedad, es decir, la que le ocasionó la muerte al testador.
- La incapacidad sólo rige para la sucesión **testada**.

III. Art. 1061. No vale disposición alguna testamentaria en favor del escribano que autorizare el testamento, o del funcionario que haga las veces de tal, o del cónyuge de dicho escribano o funcionario, o de cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados, empleados o asalariados del mismo.

No vale tampoco disposición alguna testamentaria en favor de cualquiera de los testigos, o de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o cuñados.

La incapacidad es de orden público.

Es indeleble y no puede sanearse, circunstancia que la diferencia de la indignidad. La incapacidad existe de pleno derecho, sin que sea necesario que se demande judicialmente ni que sea declarada por sentencia firme. **Miran el interés general de la sociedad, por lo cual no puede perdonarse.**

El incapaz puede adquirir la asignación por prescripción de 10 años.

Sanción de la incapacidad.

Art. 966: Será nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o por interposición de persona.

La nulidad de la incapacidad acarrea la nulidad absoluta, por estar violándose una prohibición.

La ley se pone en ambos casos de fraude: simular contrato oneroso, o interpósita persona.

Además se declara indigno de suceder al testaferro (972).

2. Indignidades para suceder

Concepto. La indignidad es la falta de mérito para suceder.

Es una sanción que consiste en excluir de la sucesión a un asignatario, como consecuencia de haber cometido actos que importen un grave atentado contra el difunto o un serio olvido de los deberes para con éste.

Está estrechamente relacionada con el desheredamiento. Se diferencian en que la indignidad es pronunciada por la ley, mientras que el desheredamiento tiene su origen en el testamento.

Causas de indignidad.

Son taxativamente establecidas por la ley. 968 a 972; 114, 1300, 1327, etc.

1. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla.
 - Es necesario la sentencia judicial.
 - Debe ser condenado como autor del crimen.
 - En caso de que haya existido desidia pudiendo salvarlo, no se requiere sentencia criminal, ya que no es constitutivo de delito
2. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada;
 - Debe ser un atentado grave.
 - Puede ser contra la vida del causante, su honor o sus bienes. También puede ser víctima el cónyuge, los descendientes o los ascendientes.
 - Se requiere de sentencia penal condenatoria (además de la civil que pronunciará la indignidad).
3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo.
 - Se extiende hasta el 6º grado porque hasta este límite son llamados a suceder los consanguíneos.
4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió testar.
5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación.
 - Es uno de los casos excepcionales en que el dolo se presume.
6. Es indigno de suceder el que siendo mayor de edad, no hubiere acusado a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto, tan presto como le hubiere sido posible. Cesará esta indignidad, si la justicia hubiere empezado a proceder sobre el caso. Pero esta causa de indignidad no podrá alegarse, sino cuando constare que el heredero o legatario no es cónyuge de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, ni es del número de sus ascendientes y descendientes, ni hay entre ellos deudo de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.
 - Sólo pesa sobre los mayores de edad.
 - No se formula un plazo para que actúe el mayor de edad.
7. Es indigno de suceder al impúber, demente, sordo o sordomudo que no pueda darse a entender claramente, el ascendiente o descendiente que, siendo llamado a sucederle abintestato, no pidió que se le nombrara un tutor o curador, y permaneció en esta omisión un año entero: a menos que aparezca haberle sido imposible hacerlo por sí o por procurador.

Si fueren muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechará a los demás.

Transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo grado a la sucesión intestada.

La obligación no se extiende a los menores, ni en general a los que viven bajo tutela o curaduría.

Esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega a la pubertad, o el demente sordo o sordomudo toman la administración de sus bienes.

- No se hace indigno el sucesor que no solicita nombramiento de guardador de su pariente menor adulto o pródigo.
 - La obligación de solicitar el nombramiento pesa sobre los ascendientes o descendientes, pero pasado un año recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo grado a la sucesión intestada.
8. Son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por el testador se excusaren sin causa legítima.
El albacea que nombrado por el testador se excusare sin probar inconveniente grave, se hace igualmente indigno de sucederle.
No se extenderá esta causa de indignidad a los asignatarios forzosos en la cuantía que lo son, ni a los que, desechada por el juez la excusa, entren a servir el cargo.
- Se aplica sólo a los guardadores testamentarios y no a los legítimos o dativos.
9. Finalmente, es indigno de suceder el que, a sabiendas de la incapacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos, bajo cualquier forma, a una persona incapaz.
Esta causa de indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona de las que por temor reverencial hubieren podido ser inducidas a hacer la promesa al difunto; a menos que hayan procedido a la ejecución de la promesa
10. A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude de falso parto o de suplantación, aprovechará en manera alguna el descubrimiento del fraude, ni aun para ejercer sobre el hijo los derechos de patria potestad, o para exigirle alimentos, o para suceder en sus bienes por causa de muerte.
La sentencia que sancione el fraude o la suplantación deberá declarar expresamente esta privación de derechos y se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo.
11. El albacea removido judicialmente de su cargo por dolo. (1300)
12. Partidor designado en testamento que no acepta el cargo (1327)
13. Partidor condenado por delito de prevaricación (1329)

Somarriva considera que existen 4 situaciones que se asemejan a las indignidades.

1. El viudo o divorciado o quien hubiere anulado su matrimonio por cuya negligencia hubiere dejado de hacerse en tiempo oportuno el inventario prevenido en el artículo 124, perderá el derecho de suceder como legitimario o como heredero abintestato al hijo cuyos bienes ha administrado (127).
2. Menor de edad que contrajo matrimonio sin consentimiento de un ascendiente estando obligado a obtenerlo, es parcialmente indigno: no tendrá más que la mitad de la porción que le hubiera correspondido (114).
3. Cónyuge que da lugar a la separación judicial por su culpa.
4. Padres cuya filiación se determinó judicialmente.

Forma como adquiere el incapaz la asignación.

El incapaz no puede adquirir por el modo sucesión por causa de muerte, pero podrá adquirir por prescripción (967). El verdadero dueño pierde su derecho porque otro lo adquiere y no por el no uso.

La incapacidad pasa contra terceros.

Éstos no pueden adquirir más derechos que el incapaz y éste no tenía ninguno. La nulidad de la asignación, judicialmente declarada, da acción reivindicatoria contra terceros poseedores.

La indignidad no opera de pleno derecho.

Requiere de una sentencia judicial. 974 inciso 1º: la indignidad no produce efecto alguno, si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno.

Mientras no se declare judicialmente la indignidad, el asignatario es reputado heredero o legatario.

Quiénes pueden pedir la declaración de indignidad.

974 inciso 1º: puede pronunciarse a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno.

- Sería el caso del sustituto, designado cuando llegue a faltar el que se persigue como indigno.
- Coherederos: aumentará su porción.
- Herederos pueden pedir la indignidad del legatario para eximirse del pago de la deuda testamentaria.
- Acreedores de un heredero o legatario, a fin de que aumente la cuota de su deudor que es a su vez, heredero digno.

La indignidad pasa a los herederos.

977: Fallecido el indigno, la acción podrá interponerse contra sus herederos para que éstos sean excluidos de la sucesión¹¹.

La indignidad no pasa contra terceros poseedores de buena fe.

El legislador, hace prevalecer el interés de los terceros que están de buena fe. (976).

Restitución de la herencia o legado.

Pronunciada la indignidad, no puede el indigno conservar la asignación. 974 inciso 2º. Deberá reputársele como poseedor de mala fe para todos los efectos de restituir, tanto en contra como a su favor. Implícitamente esto se establece en el 974: se le obliga a restituir los frutos.

Extinción de la indignidad

A) Perdón del ofendido: 973.

B) Por prescripción: 975: la indignidad se purga en 5 años de posesión de la herencia o legado.

Reglas comunes a la incapacidad e indignidad. 978 y 979.

¹¹ En el caso que estemos frente al derecho de representación esto no ocurrirá porque se estima que el representante sucede de forma directa respecto al causante.

La excepción de incapacidad y de indignidad.

Art. 978. Los deudores hereditarios o testamentarios no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o indignidad.¹²

- Se justifica que el deudor no pueda oponer la excepción de indignidad, ya que ésta debe ser declarada judicialmente.
- No se justifica por qué los deudores no pueden oponer la incapacidad, ya que ésta opera de pleno derecho.

La incapacidad y la indignidad en relación con el derecho de alimentos.

Art. 979. La incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario excluido, de los alimentos que la ley le señale; pero en los casos del artículo 968 no tendrán ningún derecho a alimentos.

324: en el caso de injuria atroz cesará la obligación de prestar alimentos. La ley no ha definido lo que se entiende por injuria atroz. Del 979 se infiere: en los casos del 968 existe injuria atroz. No se justifica la referencia a la incapacidad, porque no se entiende cómo un testigo en el testamento, pierda su derecho de alimentos.

Paralelo entre incapacidad e indignidad.

INCAPACIDAD	INDIGNIDAD
a. Impide adquirir derecho hereditario. Con ello, nada puede transmitir a sus herederos.	Impide conservar derecho hereditario. Puede transmitir a sus herederos, siempre con el vicio de indignidad.
b. Puede ser absoluta o relativa.	Siempre es relativa, refiriéndose a una determinada sucesión.
c. No requiere de declaración judicial.	Requiere de declaración judicial.
d. Pasa contra terceros.	Pasa a herederos y a terceros de mala fe.
e. No puede ser perdonada	Puede ser perdonada.
f. Se purga por la prescripción adquisitiva extraordinaria, porque el incapaz no tiene título alguno.	Se purga en 5 años de posesión.
g. Es de orden público.	Mira al interés particular.

¹² Según las clases del profesor Illanes, esta norma se ha entendido en 2 sentidos: " Deudores hereditarios":
a. Deudas debidas al causante. No se puede oponer la incapacidad o indignidad para eximirse del pago debido al causante.
b. Somarriva: deudas del causante.

EL DERECHO DE TRANSMISIÓN.

Planteamiento del tema.

Deferida la asignación, nace para el asignatario el derecho de aceptarla o repudiarla; la delación es justamente el llamamiento que hace la ley con tal objeto. Ante ello, se pueden presentar 3 situaciones:

- a. El asignatario acepta la asignación y luego fallece: transmite la asignación;
- b. El asignatario repudia y fallece en seguida: nada transmite, porque como consecuencia de haber repudiado, se entiende que nunca ha tenido derecho alguno; y

c. El asignatario fallece sin haber expresado su voluntad de aceptar o repudiar la asignación: el asignatario transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar, teniendo lugar el derecho de transmisión.

Concepto del derecho de transmisión.

Art. 957. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite.

Derecho de transmisión: es la facultad que tiene el heredero, que acepta la herencia, de aceptar o repudiar la herencia o legado que se defirió a su causante fallecido sin haber aceptado o repudiado.

El derecho de transmisión es aplicación de los principios generales.

El derecho que tenía el causante de aceptar o repudiar, es uno de los derechos que son transmitidos a los herederos.

Personas que intervienen en el derecho de transmisión.

- A.** Primer causante: deja la herencia o legado que no fue aceptada o repudiada;
- B.** Transmitente o transmisor: después de deferida la herencia o legado, fallece sin haber expresado si acepta o repudia;
- C.** Transmitido: habiendo aceptado la herencia del transmitente, adquiere el derecho de aceptar la herencia o legado dejados por el primer causante.

Requisitos del derecho de transmisión.

- a. El transmitente debe haber fallecido sin aceptar o repudiar la asignación.

- b. El transmitente debe ser capaz y digno de suceder al primer causante. Sin ella, no hubiera tenido opción de transmitir el derecho de aceptar o repudiar.
 - c. El transmitido debe ser, a su vez, capaz y digno de suceder al transmitente.
 - d. El transmitido debe ser heredero, bien sea testamentario o abintestato del transmitente. Esta condición le permite adquirir todos los derechos y dentro de ellos, la facultad de aceptar o repudiar.
- 957: el transmitente puede ser heredero o legatario del primer causante, pero el transmitido **debe necesariamente ser herederos del transmitente.**
- e. El transmitido debe aceptar la herencia del transmitente. 957 inciso 2º.
 - f. Es preciso que los derechos del transmitente a la herencia o legado no hayan prescrito.

TEORÍA DE LOS ACERVOS

1. Acervo común o bruto;
2. Acervo ilíquido;
3. Acervo líquido;
4. Primer acervo imaginario;
5. Segundo acervo imaginario.

Acervo bruto o cuerpo común de bienes.

Los bienes del difunto suelen encontrarse confundidos o mezclados con bienes pertenecientes a otras personas por muy diversas causas (Sociedad conyugal, contrato de sociedad, por ejemplo). El acervo bruto es el patrimonio del difunto unido a otros bienes que no le pertenecen. En este acervo existen bienes que no son del causante o que lo son, pero sólo en parte.

Necesidad de la separación previa de patrimonios.

Para determinar el patrimonio del difunto es necesario separarlo de los otros patrimonios.

1341: Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas, u otro motivo cualquiera, se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes.

Acervo ilíquido.

Una vez operada la separación de patrimonios, queda formado el **acervo ilíquido**. De este acervo deberán hacerse ciertas deducciones, denominadas bajas generales.

Acervo ilíquido: patrimonio del causante, separado de otros bienes con que se encontraba confundido y al que aún no se le han deducido las bajas generales.

Acervo líquido

Acervo líquido: patrimonio del difunto, separado de otros patrimonios, deducidas las bajas generales.

En virtud del 959 inciso final, es posible afirmar que las asignaciones se calculan, sobre la base del acervo líquido. Se deben tomar en cuenta, en todo caso, según Meza Barros, el cálculo del acervo imaginario.

Se le llama también "acervo partible" porque es la masa de bienes que se divide entre los herederos.

Bajas generales¹³. 959.

Deducciones que es necesario hacer para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley.

Se les llama bajas generales porque gravitan sobre todos los asignatarios.

Art. 959. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios:

- 1º Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión;
- 2º Las deudas hereditarias;
- 3º Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria;
- 4º Las asignaciones alimenticias forzosas.

Se agregan por ley 16.271: gastos de última enfermedad y entierro del causante. Por ley 19.585 se derogó la porción conyugal como baja general de la herencia, pasando el cónyuge a ser legitimario.

El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley.

Orden o prelación de las bajas.

Las bajas generales señaladas, deben efectuarse en el orden en que las enumera el Código.

Gastos de la apertura de la sucesión (959 No. 1)

Se incluyen los gastos de la apertura del testamento cerrado, los gastos para poner por escrito el testamento verbal, los gastos que demanden los avisos de la apertura de la sucesión (1285), los gastos del trámite de la posesión efectiva de la herencia, los gastos de guarda y aposición de sellos y de la facción de inventario. Se incluyen los gastos de la partición, incluso los honorarios de albaceas y partidores que no excedan los aranceles vigentes. La enumeración se obtiene de la ley 16.271.

¹³ Ver art. 4 de ley 16.271. Completa y modifica el 959.

Deudas Hereditarias (959 No. 2)

Son las deudas que el causante tenía en vida. Si los bienes son insuficientes para pagar las deudas hereditarias, nada recibirán los asignatarios. Los bienes, en tal caso, "pertenecían" a los acreedores, en virtud del derecho de prenda general. Los herederos responden ilimitadamente de las deudas hereditarias, a menos que gocen del beneficio de inventario.

Para propender al pago de las deudas, la ley impone a los albaceas la obligación de dar aviso al público de la apertura de la sucesión (1285) y de exigir que en la partición se forme un lote o hijuela suficiente para el pago de las deudas conocidas (1286). El partidor deberá formarlo, aunque no sea requerido por los herederos (1336).

Las deudas hereditarias se pagan primero que las testamentarias. 1374: pagados los acreedores hereditarios, se satisfarán los legados.

Impuestos que gravan toda la masa. (959 No. 3)

Hoy no existe un impuesto que grave a toda la masa. La ley 16.271, no grava a la masa global sino cada una de las asignaciones en particular. Art. 2.

Anteriormente existía un tributo doble: uno que gravaba la masa total y otro que gravaba cada asignación en particular.

Asignaciones Alimenticias Forzosas (959 No. 4)

Son aquellos alimentos que el difunto ha debidos por ley a ciertas personas (1168). Son una baja general, con las siguientes salvedades:

- a- Cuando el testador haya impuesto la obligación de pagarlas a determinados partícipes (1168);
- b- Cuando fueren excesivas, atendidas las fuerzas del patrimonio del causante, caso en que el exceso se extraerá del acervo líquido, imputándose a la parte de bienes que pudo disponer libremente (1171 inc. 2º)

Las asignaciones alimenticias no forzosas, no son baja general y se imputan a la parte de libre disposición (1171 inc. 1º).

Como la asignación de alimentos debidos por ley es forzosa, si el testador omite hacerla en el testamento, la ley ordena que se supla.

Hay autores que señalan que las asignaciones alimenticias forzosas son deudas hereditarias.

Bajas para el cálculo de la contribución de herencias.

Ley 16.271 dispone que el tributo se aplicará sobre las asignaciones líquidas, una vez deducidos de la masa de bienes que el difunto ha dejado:

1. Los gastos de la última enfermedad adeudados a la fecha de la delación de la herencia y los de entierro del causante;
2. Las costas de publicación del testamento si lo hubiere, las demás anexas a la apertura de la sucesión, las de posesión efectiva y las de partición, incluso los honorarios de albaceas y partidores, en cuanto no excedan los aranceles vigentes;
3. Las deudas hereditarias, incluso aquellas deudas que provengan de la última enfermedad del causante, pagadas antes de la fecha de la delación de la herencia, con tal que los herederos acrediten haber cancelado con su propio peculio o con dinero facilitado por terceros;

4. Las asignaciones alimenticias forzosas, sin perjuicio de lo dispuesto en el No. 3 del Art. 18. Este artículo declara exentas de impuestos las asignaciones alimenticias a personas a las que el causante esté obligado a alimentar.

Bajas generales de la herencia y regímenes matrimoniales.

- Existen algunas bajas generales que al mismo tiempo serán bajas de la liquidación de la sociedad conyugal: gastos de partición, deudas hereditarias que pueden ser a la vez sociales, entre otras. Las bajas generales deberán efectuarse sólo en la proporción que correspondían al cónyuge difunto.
- En el régimen de participación en los gananciales, habrá que determinar si el cónyuge causante es acreedor o deudor del crédito.

Acervo imaginario

No siempre existirán en la sucesión (a diferencia de los 3 anteriores).

No siempre las asignaciones se calculan en el acervo líquido.

El legislador ha debido establecer los mecanismos para garantizar las asignaciones forzosas, siendo la creación del acervo imaginario (son 2 en doctrina), reglamentado en el 1185 y 1186, una de las herramientas para dicho objeto. Se procura reconstruir imaginariamente el patrimonio del causante al tiempo en que se hicieron las liberalidades.

- 1185: **1º acervo imaginario**: acumulación imaginaria al acervo líquido, de todas las donaciones revocables o irrevocables hechas en razón de legítimas o mejoras.

- 1186: **2º acervo imaginario**: el que tenía a la sazón legitimarios ha hecho donaciones entre vivos a extraños y el valor de éstas excede de la cuarta parte de la suma de ellas y del acervo líquido o imaginario. El exceso deberá acumularse y esta acumulación, en verdad, es real y no imaginaria.

Capítulo II: SUCESIÓN INTESTADA

Concepto.

En virtud del artículo 952, se puede definir la **sucesión intestada**, como la transmisión que hace la ley de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta.

Las normas legales de la sucesión intestada son el testamento tácito o presunto del causante.

Personas llamadas a suceder.

Art. 983. Son llamados a la sucesión intestada los descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado, en su caso, y el Fisco¹⁴.

Los derechos hereditarios del adoptado se rigen por la ley respectiva.

La ley no considera el sexo, la edad ni el origen de los bienes.

- a. 981: la ley no atiende al origen de los bienes para reglar la sucesión intestada o gravarla con restituciones o reservas. (Razón histórica de reservas de determinados bienes a ciertas personas: por ejemplo a los herederos paternos o maternos).
- b. 982: en la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura.

Cuándo tiene lugar la sucesión intestada.

980: *Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han tenido efecto sus disposiciones.*

A) Casos en que el testador no dispuso:

- i. Falleció sin hacer testamento o revocó el otorgado;
- ii. Otorgó testamento pero se limitó a hacer declaraciones, sin regular la suerte de los bienes;
- iii. Instituyó herederos de cuota que no completan la unidad; la cuota que falte corresponderá a los abintestato;
- iv. El testamento sólo hace asignaciones a título singular;
- v. El testador instituye un usufructo sin expresar a quien corresponde la nuda propiedad;
- vi. Se constituye en el testamento un fideicomiso y no se designa fiduciario o falta el designado antes de que se cumpla la condición; la persona del fiduciario será señalada por las normas de la sucesión abintestato.

¹⁴ En virtud de la ley 20.830 debe considerarse también al conviviente civil sobreviviente.

- B) Casos en que el testador no dispuso conforme a derecho.
- i. El testamento es nulo por defectos de forma o fondo;
 - ii. Es nula determinada cláusula. Si el testamento es parcialmente nulo, deberá verse si procede la sustitución o el acrecimiento entre los llamados a un mismo objeto o si la voluntad del testador ha querido que la asignación nula pase a incrementar el haber del heredero universal o del remanente;
 - iii. Cuando el testamento viola las asignaciones forzosas y es atacado por medio de la acción de reforma.
- C) Casos en que no tienen efectos las disposiciones.
- i. Asignación condicional, cuando falla la suspensiva o se cumple la resolutoria, sin que el testador haya previsto dichos casos;
 - ii. Cuando el asignatario designado repudia o se hace indigno o incapaz;
 - iii. Cuando se otorga un testamento privilegiado y éste caduca.

El Derecho de Representación

Formas de suceder abintestato.

Se puede suceder abintestato de dos formas: sea por derecho personal, sea por derecho de representación (984 inciso 1º).¹⁵

Suceder por derecho personal, significa hacerlo a nombre propio, como consecuencia de la situación que realmente se ocupa dentro de la familia del difunto.

Suceder por representación, significa suceder en lugar de otra persona, ocupando su sitio, sustituyéndola en virtud de la autorización de la ley.

Caso: Una persona deja un hijo y un nieto (cuyo padre, hijo del causante, falleció anteriormente). Hijo y nieto son descendientes, pero de distinto grado, y la regla es que los parientes de grado más próximo excluyan a los de grado más remoto, con lo que el hijo excluiría al nieto. Para que suceda el nieto, es necesario acercarlo al abuelo, ocupando el lugar de su padre, vacante por la muerte.

Antes de la ley 19.585 sólo podían representar las descendencias legítimas.

Definición.

984: La **representación** es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder.

¹⁵ Somarriva señala que puede haber sucesión **directa**: se sucede personalmente, por uno mismo y sin intervención de otra persona; o sucesión **indirecta**: en el derecho de transmisión y en el derecho de representación.

- a. Es una ficción porque supone un hecho irreal: una persona ocupa un lugar y tiene el grado de parentesco, que realmente no tiene;
- b. El lugar se confunde con el grado y los derechos son consecuencia del grado: definición legal redundante;
- c. Tiene lugar cuando el padre o la madre no pueden o no quieren suceder: por esto se puede **representar a una persona viva**.

Personas que intervienen en la representación.

- a. Causante: persona en cuya herencia se sucede.
- b. Representado: persona que no puede o no desea suceder y cuyo lugar queda vacante;
- c. Representante: descendiente del representado que ocupa el lugar de éste.

Requisitos del derecho de representación.

A) Que se trate de una sucesión intestada. Esto fluye de la ubicación del 984, confirmándose con el texto de la disposición. En la testada, si falta el asignatario, no ocupan su lugar sus descendientes, sino que recogen la asignación los herederos abintestato. 1162. No se puede adquirir, mediante el derecho de representación, legados o asignaciones a título singular.

Excepcionalmente, tiene lugar el derecho de representación en la sucesión testada, cuando:

- i- se haga una asignación testamentaria hecha indeterminadamente a los parientes: se entienden llamados los consanguíneos de grado más próximo, según el orden de la sucesión intestada, teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a las reglas generales. 1064.
- ii- 1183: los legitimarios concurren, son excluidos y representados según las reglas generales de la sucesión abintestato. (véase el No. 443).

B) Debe faltar el representado, sea porque no quiere o no puede suceder. No puede: incapaz, indigno, desheredado. No quiere: repudia. (987 inciso 2º). Normalmente faltará por haber fallecido antes que el causante. El legislador pensó, por otro lado, que no era justo que los hijos respondieran por los pecados de los padres (por eso permite representar al indigno).¹⁶

C) El representante debe ser descendiente del representado. Jamás operará a favor de los ascendientes. Habiendo un pariente de grado más próximo siempre se excluirán los de grado más remoto (989), sin operar la representación (por ejemplo del abuelo paterno respecto de su hijo que murió antes de la muerte de su nieto. Sobreviviendo la madre del hijo muerto, excluye a todos los demás).

¹⁶ Los bienes que el hijo adquiere representando al padre incapaz, indigno o desheredado constituyen el **peculio adventicio extraordinario**. El padre no tiene ni el usufructo ni la administración de estos bienes.

La representación tiene lugar en la descendencia hasta el infinito.
984 inciso 3ª.

D) Parentesco entre el representado y el causante. El representante necesariamente debe ser descendiente del representado. Entre el representado y el causante debe mediar alguno de los parentescos que señala la ley: 986: descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos. El representado debe ser, respecto del causante: o descendiente o hermano.

E) El representante debe ser capaz y digno de suceder al causante. Aun ocupando el lugar del representado, quien sucede es el representante.

El representante sucede directamente al causante, sin suceder por intermedio del representado. El representante sucede directamente, en virtud de un llamado especial que la ley formula. (Es una de las diferencias con el derecho de transmisión). Consecuencias:

- a- El representante puede repudiar la herencia del representado y, no obstante, representarle. 987;
- b- El representante puede ser incapaz o indigno de suceder al representado y sucederá con tal que sea capaz y digno de suceder al causante;
- c- El representante no es responsable de las deudas del representado, a menos que haya aceptado su herencia. Perseguido por los acreedores del representado, puede interponer una tercería (520 No. 2 CPC).

Efectos de la Representación

El representante ocupa el lugar y se reputa que tiene el parentesco y los derechos hereditarios del representado, sin poder tener más de los que a éste le hubieran correspondido.

- a. Los que suceden por representación heredan por **estirpes o troncos**: cualquiera que sea el número de representantes les tocará entre todos la porción que le hubiera correspondido al representado (985 inciso 1º).
- b. Los que heredan por derecho personal, **suceden por cabezas**: toman entre todos y por partes iguales la porción a que la ley los llama, salvo que la misma ley señale otra forma de división. Por ejemplo, el 990 establece una forma distinta: distribución entre hermanos de simple y de doble conjunción.

Impuesto a la herencia adquirida por representación.

Como el impuesto se eleva mientras el parentesco es más lejano, la representación, que trae como consecuencia un acercamiento al causante, debe disminuir la cuantía del tributo.

Art. 3 Ley 16.271: Cuando se suceda por derecho de representación, se pagará el impuesto que habría correspondido a la persona representada.

El impuesto lo pagarán los representantes sobre el monto de la asignación que habría correspondido al representado y no sobre la que a cada uno de ellos corresponda. Así si al representado le correspondería 100, cada uno de los 4 representantes, deberán pagar el impuesto sobre 100 y no sobre 25. Los herederos, se ven perjudicados porque se trata de una tasa progresiva. Puede haber ocurrido que estuvieran exentos del impuesto, pero igualmente tengan que dividirse el impuesto que debió pagar el representado.

Efecto retroactivo de las leyes y derecho de representación. Art. 20: la representación es una mera expectativa, quedando sujeta al cambio de legislación.

Diferencias entre los derechos de transmisión y de representación.

DERECHO DE TRANSMISIÓN	DERECHO DE REPRESENTACIÓN
1. Es aplicación de las normas generales.	Es una ficción, por tanto una excepción legal.
2. El derecho del transmitido emana de su calidad de heredero del transmisor.	El derecho emana directamente del causante.
3. Se aplica en las sucesiones testamentarias e intestada.	Procede generalmente en la intestada, salvo los casos del 1064 y 1183.
4. No exige parentesco alguno y aprovecha a cualquier heredero.	Exige parentesco: representante debe ser descendiente y el representado hijo o hermano del causante.
5. Transmitente debe sobrevivir a la muerte del primer causante.	No es necesario que el representado sobreviva al causante, porque tiene lugar, entre otros casos, cuando el padre o madre es incapaz de suceder por haber fallecido.
6. El transmitido debe ser capaz y digno de suceder al transmisor.	Basta que el representante sea capaz y digno de suceder al causante, prescindiéndose del representado.
7. Tiene lugar a condición de que se acepte la herencia del transmisor.	No es necesario que se acepte la herencia del representado, porque se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado.
8. Supone la muerte del transmisor, sin expresar la voluntad de aceptar o repudiar.	No supone la muerte del representado, porque se puede representar al vivo.
9. Se pueden adquirir herencias y legados.	Se adquieren herencias porque sólo cabe en la intestada y la ley no instituye asignaciones a título singular. (Salvo excepciones mencionadas).

ÓRDENES DE SUCESIÓN

Diversas clases de sucesión intestada.

Hasta antes de la entrada en vigencia de la ley 19.585, el CC distinguía 2 órdenes de sucesión, atendiendo si el causante era hijo legítimo (orden regular) o hijo natural (orden irregular). La ley mencionada, deroga las diferencias, subsistiendo sólo un orden de sucesión intestada.

Mecanismo de la sucesión intestada.

Órdenes de sucesión: conjunto de herederos que considerados colectivamente excluyen o son excluidos por otros herederos, considerados también colectivamente.

Por ello, para determinar los derechos hereditarios de una persona es preciso examinar a qué orden pertenecen y no al grado de parentesco.

Pero, dentro de cada orden, el grado de parentesco es decisivo. Los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano, salvo que intervenga el derecho de representación en favor de la descendencia que la hace mejorar de grado.

Parientes que fijan el orden.

Dentro de cada orden hay herederos que fijan el orden y le dan su nombre y otros que simplemente concurren con ellos. *(Al parecer esta distinción entre herederos determinantes y concurrentes tendrá limitada aplicación hoy en día¹⁷).*

Para pasar de un orden al siguiente es menester que falten todos los parientes que fijan el orden.

Cuáles son los órdenes de sucesión.

1. Primer orden de sucesión: De los hijos (más preciso: De los descendientes)

Art. 988. Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquéllos.

El cónyuge sobreviviente (Y a partir de la ley 20.830 también el conviviente civil sobreviviente) recibirá una porción que, por regla general, será equivalente al doble de lo que por legítima rigurosa o efectiva corresponda a cada hijo. Si hubiere sólo un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigurosa o efectiva de ese hijo. Pero en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia, o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso.

Correspondiendo al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos por partes iguales.

La aludida cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 996.

- Por ley 10.271 se otorgaron derechos a los hijos naturales: concurrían en la mitad de lo que le correspondería a uno legítimo. Hoy no se distingue, tras la modificación de la ley 19.585.

Comprende:

- h.** Hijos de filiación matrimonial.
- i.** Hijos cuyos padres contraen matrimonio.
- j.** Hijos de filiación legalmente determinada.
- k.** Hijos cuya filiación quedó determinada antes de la vigencia de la Ley 19.585.
- l.** Representantes del hijo (derecho de representación).

¹⁷ No así en el primer orden de sucesión en que el cónyuge o conviviente civil concurren pero no fijan el orden. Si estos asignatarios fijaran el primer orden no obstante haber ascendientes no se podría pasar al segundo orden de sucesión.

- No se incluye a los hijos cuya filiación no esté determinada, por la misma razón.
- Adoptado: la ley 19.620 le otorga el carácter de hijo al adoptado. Sin embargo, los adoptados simplemente de la ley 18.703 no tienen derechos hereditarios, a menos que se sometan a un procedimiento especial.
- Como pueden concurrir representados, se dice que puede denominarse "de los descendientes".
- A este orden se le seguirá llamando de los descendientes, por cuanto son éstos los que determinan su aplicación. Con ellos, concurre el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil sobreviviente y el adoptado.
- El cónyuge, existiendo 1 hijo, recibirá una cuota igual a la del hijo.
- Si existen varios hijos, el cónyuge tiene derecho a recibir el doble de lo que le corresponde a cada hijo.
- En ningún caso la porción del cónyuge bajará del 25% de la herencia o de la mitad legítima. Se aplicará cuando el cónyuge concorra con más de 6 hijos. En una sucesión intestada en que todos los bienes sean de la sociedad conyugal, el cónyuge sobreviviente tiene asegurado el 62, 5% de los bienes.
- Si sólo concurren hijos, se dividirá por igual entre ellos.
- El cónyuge separado judicialmente, que hubiere dado motivo a la separación por su culpa, no tendrá parte alguna en la herencia abintestato de su mujer o marido. Sin culpa, no procederá la sanción.
- El cónyuge cuyo matrimonio fue anulado, aunque éste haya sido putativo, no tiene derechos hereditarios abintestato.
- No hay herencia abintestato respecto de los cónyuges, simplemente porque ya no son cónyuges. (Art. 60 NLMC)
- La separación de hecho no produce efecto hereditario.

Situación del cónyuge sobreviviente.

- Poco a poco se ha ido mejorando su situación, llegando a un panorama actual de absoluta protección. Se elimina la porción conyugal y la odiosa distinción entre cónyuge rico y pobre, pasando el cónyuge a tener calidad de legítimo.

2. Segundo orden de sucesión: Del cónyuge sobreviviente y de los ascendientes¹⁸.

Art. 989. Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximo.

En este caso, la herencia se dividirá en tres partes, dos para el cónyuge y una para los ascendientes. A falta de éstos, llevará todos los bienes el cónyuge, y, a falta de cónyuge, los ascendientes.

Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste en todos los bienes, o en toda la porción hereditaria de los ascendientes.

- 2/3 para el cónyuge y 1/3 para el ascendiente.

¹⁸ Incluir al conviviente civil sobreviviente.

- Si concurre el cónyuge solo o el ascendiente solo: 100% para ellos, teniéndose presente que la representación no opera respecto de los ascendientes.
- El cónyuge separado judicialmente, que hubiere dado motivo a la separación por su culpa, no tendrá parte alguna en la herencia abintestato de su mujer o marido.
- Tampoco sucederán abintestato los padres del causante si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra su oposición, salvo que mediare el restablecimiento a que se refiere el artículo 203¹⁹. **Los ascendientes no siempre tendrán el derecho de suceder abintestato a sus descendientes. La exclusión no milita para el hijo:** el hijo es heredero aunque su reconocimiento haya sido forzado. Tampoco se extiende a los ascendientes del padre o madre cuya maternidad o paternidad se determinó judicialmente (es curiosa la solución, ya que contradice la lógica del 1182 CC).
- **Adoptante:** Somarriva considera que sería heredero abintestato, porque al adoptado se le otorga el estado civil de hijo, con todos los derechos y deberes recíprocos.

3. Tercer orden de sucesión: De los hermanos.

Art. 990. Si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos.

Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aun los que solamente lo sean por parte de padre o de madre; pero la porción del hermano paterno o materno (simple conjunción) será la mitad de la porción del hermano carnal.

Se aplica el derecho de representación, de modo que los sobrinos, en ausencia del hermano, se comprenden en este orden.

4. Cuarto orden de sucesión: De los demás colaterales.

Art. 992. A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive.

¹⁹ Art. 203. Cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre, aquél o ésta quedará privado de la patria potestad y, en general, de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del hijo o de sus descendientes. El juez así lo declarará en la sentencia y de ello se dejará constancia en la subinscripción correspondiente.

El padre o madre conservará, en cambio, todas sus obligaciones legales cuyo cumplimiento vaya en beneficio del hijo o sus descendientes.

Sin embargo, se restituirán al padre o madre todos los derechos de los que está privado, si el hijo, alcanzada su plena capacidad, manifiesta por escritura pública o por testamento su voluntad de restablecerle en ellos. El restablecimiento por escritura pública producirá efectos desde su subinscripción al margen de la inscripción de nacimiento del hijo y será irrevocable. El restablecimiento por acto testamentario producirá efectos desde la muerte del causante.

Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, tendrán derecho a la mitad de la porción de los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre. El colateral o los colaterales del grado más próximo excluirán siempre a los otros.

Los colaterales por afinidad no son herederos abintestato. En 1951 la CA de Santiago resolvió que los parentescos de la sucesión intestada son por consanguinidad y no por afinidad.

5. Quinto orden de sucesión: El Fisco.

Art. 995. A falta de todos los herederos abintestato designados en los artículos precedentes, sucederá el Fisco.

Se habla de herencias **vacantes**. En los demás órdenes de sucesión, el Fisco está representado en la masa hereditaria por el impuesto de herencia que establece la Ley 16.271.

Estado civil del adoptado.

La ley 19.620 otorga al adoptado la calidad y estado civil de hijo del o de los adoptantes.

Sucesión parte testada y parte intestada.

La sucesión en los bienes de una persona puede ser parte testada y parte intestada (952 inciso 2º).

Las normas legales son supletorias de la voluntad del causante que no llegó a expresarse o se frustró. Por ello, las normas testamentarias, arregladas a derecho, prevalecen.

Art. 996. Cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por testamento y abintestato, se cumplirán las disposiciones testamentarias, y el remanente se adjudicará a los herederos abintestato según las reglas generales. Se aplicará primero el testamento y en lo que reste rigen las reglas de la intestada.

Pero los que suceden a la vez por testamento y abintestato, imputarán a la porción que les corresponda abintestato lo que recibieren por testamento, sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria, si excediere a la otra.

Prevalecerá sobre todo ello la voluntad expresa del testador, en lo que de derecho corresponda.

En todo caso la regla del inciso primero se aplicará una vez enteradas totalmente, a quienes tienen derecho a ellas, las legítimas y mejoras de la herencia.

El inciso 2º debe interpretarse de la siguiente forma: la asignación testamentaria se entiende hecha a cuenta de los que debe tocar al

heredero sucediendo abintestato. La asignación testamentaria se supone hecha en pago total o parcial de la asignación legítima. Si la asignación es superior, puede retener toda la porción testamentaria, si excede a la otra.

Sin embargo, si el testador lo ha querido, el asignatario no imputará a lo que le corresponda abintestato lo que reciba por testamento, aplicándose sin atenuante la regla del inciso 1º. (996 inciso 3º)²⁰.

Somarriva: debe interpretarse de la siguiente forma: si el testador lo quiere, puede disponer de sus bienes en el testamento, sin privar a los asignatarios testamentarios, del derecho de concurrir a la intestada, como si nada hubieran recibido. El CC exige declaración expresa para hacer compatible la sucesión testamentaria íntegra con la abintestato íntegra.

Capítulo III: SUCESIÓN TESTADA

Concepto.

952: si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria. La **sucesión testada** es la transmisión que hace el causante de sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles a las personas que designa en su testamento.

Definición y caracteres del testamento.

Art. 999. El testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.

1) El testamento es un acto jurídico unilateral personalísimo. El testamento es un "acto", es decir, una manifestación unilateral de voluntad, obra solamente de la voluntad del testador. El testador es quien debe manifestar esa voluntad en persona.

- 1003: El testamento es un acto de una sola persona.

Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes, o de una tercera persona.

- La ley prohíbe los testamentos conjuntos o de hermandad. 1003 y 1059

²⁰ Ejemplo: Si el causante le suceden dos hermanos en una sucesión (A y B) con un activo de 10 millones. Al hermano "A" le asigna 4 millones por testamento. Este monto se imputará a lo que le correspondería en virtud de las reglas de la sucesión intestada. En este caso ambos hermanos recibirán 5 millones por concurrir por partes iguales. En el caso de que le haya asignado 6 millones prevalecerá la voluntad del testador, recibiendo "B" 4 millones.

Por otro lado en el caso que el testador asigna a "A" 4 millones señalando expresamente que desea que no se impute a lo que le correspondería por la sucesión intestada, "B" terminará recibiendo 3 millones y "A" 7 millones. Así prevalece la voluntad del testador. En este caso sería posible porque no concurren asignatarios forzosos circunstancia que haría prevalecer la asignación legal por sobre la voluntaria.

- El testamento es uno de los escasísimos actos en que **no tiene cabida la representación**. 1004: La facultad de testar es indelegable. (Artículo más breve del CC).
- Los relativamente incapaces pueden otorgar libremente testamentos.

2) El testamento es un acto más o menos solemne. (1000 y 1002) Está sujeto a la observancia de ciertas formalidades, de manera que sin ellas no produce efectos civiles. "Más o menos solemne": siempre es solemne. La expresión alude a la clasificación entre testamentos solemnes y testamentos menos solemnes o privilegiados.

La exigencia de solemnidad se explica por dos razones:

- i. Queda pre constituida la prueba de cuál fue la voluntad real del testador;
- ii. El testamento es un acto importante en la vida jurídica.

3) El testamento es un acto mortis causa. El testador dispone para después de su muerte; está llamado a producir pleno efecto después de sus días.

En vida, el testamento es sólo un proyecto, reputándose que se persevera en él, mientras no se manifieste la voluntad contraria. La muerte transforma el proyecto en la definitiva expresión de la voluntad del testador. Se puede disponer de los bienes futuros. Esto lo diferencia de la donación entre vivos (no se extiende a los bienes futuros del donante).

4) El objeto fundamental (pero no único) del testamento es disponer de los bienes. El 999 caracteriza el testamento como un acto en que se dispone de los bienes. La norma legal ha querido señalar que la finalidad fundamental es disponer de los bienes, pero que puede servir para otros efectos: reconocer a un hijo (187), nombramiento de partidor (1324), entre otros. La norma no señala que exista opción de que el testamento tenga otro objetivo.

5) El testamento es esencialmente revocable. La facultad de revocarlo es esencial en el testamento. Art. 1001: Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, sin embargo de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con juramento.

Si en un testamento anterior se hubiere ordenado que no valga su revocación si no se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta disposición como no escrita.

Sólo son revocables las disposiciones testamentarias. Las declaraciones son irrevocables (189 inciso 2º).

6) El testamento produce sus plenos efectos fallecido el causante, pero puede producir otros efectos en vida de éste.

Casos en que produce efectos en vida del causante:

1. Reconocimiento del hijo: otorga al hijo esa calidad.

2. Donaciones revocables y legados entregados por el causante en vida a los beneficiados con ellos. Da nacimiento a un derecho de usufructo.

El objetivo de la revocabilidad es ser la medida más eficaz que asegura la **libertad de testar**.

Registro de testamentos. La ley 18.181, modifica el COT y establece un Registro de Testamentos a cargo del Archivero Judicial de Santiago, con dos índices, uno para los testamentos abiertos y otro para los cerrados.

La ley 19.903 modifica lo anterior y establece que el Registro Nacional de Testamentos, estará a cargo y bajo la responsabilidad del Registro Civil. Existen por tanto 2 registros: Registro de Posesiones Efectivas y Registro de Testamentos.

Los testamentos deben inscribirse no sólo en el CBR, sino también en el Registro Civil. Se busca con dicha inscripción, impedir que por desconocimiento o mala fe se tramite como intestada una posesión efectiva que no lo es.

Es **obligatoria la inscripción en el Registro de Testamentos del Registro Civil**, respecto de 3 tipos de testamentos: abiertos, cerrados y protocolizados.

Sanción por no inscripción: es una medida de publicidad que tiene por objeto permitir a los posibles asignatarios ubicar si el causante ha dejado algún testamento. En virtud de ello el testamento es plenamente válido más allá de las responsabilidades que se pueden hacer valer contra el notario u otro funcionario público que haga las veces de este. 439 COT.

REQUISITOS DEL TESTAMENTO.²¹

I) Internos:

1. Capacidad del testador

2. Voluntad exenta de vicios

Son iguales en todo testamento, cualquiera sea su forma. Su incumplimiento genera la nulidad e ineficacia total del testamento.

II) Externos o solemnidades:

Varían conforme a las clases de testamentos. Su sanción también es la nulidad integral del testamento. (En esa sede serán analizados)

III) Respecto a las disposiciones testamentarias:

Su infracción no produce sino la nulidad de la respectiva cláusula testamentaria, pudiendo tener validez o vigor las demás disposiciones que no se vean afectadas por algún vicio legal.

²¹ De aquí en adelante se sigue íntegramente el libro de Somarriva.

I) Requisitos internos:

1. Capacidad para testar

Por regla general todas las personas son capaces para testar, siendo sólo incapaces los que la ley declara tales.

Art. 1005. No son hábiles para testar:

- 1. Derogado;*
- 2. El impúber. Su incapacidad se deriva del hecho de ser incapaz absoluto, carente de toda voluntad;*
- 3. El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. El demente que no se encuentra interdicto, quedará incluido en el número 4. La interdicción, en virtud del 465 posibilitará que el que quiera alegar la incapacidad, se exonere de probar la demencia;*
- 4. El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa. La falta de razón debe ser referida al momento en que se otorgue el testamento. (1016, 1023, 1038)²²;*
- 5. Todo el que no pudiese expresar su voluntad claramente.*

Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar. La capacidad debe existir al momento de otorgarse el testamento.

Art. 1006. (1) El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente **es nulo**, aunque posteriormente deje de existir la causa.

(2) Y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad.

2. Voluntad exenta de vicios.

Importancia fundamental de la voluntad en el testamento. Al igual que en el matrimonio, el legislador, rodea a la voluntad del testador de una serie de garantías. Eso se ve por ejemplo, en que el legislador establece indignidades e incapacidades para suceder a los que pudieron influir en dicha voluntad o que atentaron contra ella. Se oponen a la libre manifestación de voluntad del testador los vicios de la voluntad: fuerza, dolo y error.

1. La fuerza en el testamento

1007: el testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza, es nulo en todas sus partes.

La fuerza en el testamento debe cumplir con los requisitos generales: gravedad, injusticia y ser determinante.

²² CS: determinar si una persona está o no en su sano juicio es una cuestión de hecho.

Algunos han pretendido señalar que la expresión “de cualquier modo”, quiere significar que en este caso no es necesario que la fuerza reúna los requisitos legales señalados. La CS falló contra esa interpretación.

Sanción. La fuerza tiene como sanción aparejada la nulidad relativa. Sin embargo, parte de la doctrina ha estimado que la expresión “es nulo en todas sus partes”, estaría indicando que la nulidad con la cual se sanciona es la absoluta. En igual sentido se ha interpretado el 2453. Además la voluntad, con su carácter fundamental, ha sido desvirtuada, razón por la cual debe dársele la máxima sanción.

Parece más lógico interpretar “nulo en todas sus partes” como que el testamento es nulo **en su totalidad**, y no sólo en aquella cláusula obtenida por la fuerza. En el mismo sentido habría que entender la frase “de cualquier modo”.

2. El dolo en el testamento

El legislador nada ha dicho. Deben aplicarse las reglas generales con una salvedad: siendo el testamento un acto jurídico unilateral, no puede exigirse que provenga de la contraparte. Basta que cualquier tercero obre con dolo.

Es indigno para suceder el que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria. Por otro lado el testador puede desheredar al legitimario quien por fuerza o dolo le ha impedido testar.

3. El error en el testamento

Tampoco se regula con especialidad en el testamento. El legislador lo trata al hablar de las disposiciones testamentarias.

CLASIFICACIÓN DEL TESTAMENTO

La clasificación del testamento se hace en atención a las solemnidades de que está revestido. El testamento, siendo siempre solemne, puede ser solemne o menos solemne-privilegiado.

I) TESTAMENTO SOLEMNE: aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere (1008 inciso 2º).

a. Testamento solemne otorgado en Chile.

- i. Abierto: el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos.
- ii. Cerrado: aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones.

b. Testamento solemne otorgado en país extranjero.

- i. Extendido en conformidad a la ley chilena (pudiendo ser abierto o cerrado);
- ii. Extendido en conformidad a la ley extranjera (1027 y 1028).

II) TESTAMENTO MENOS SOLEMNE O PRIVILEGIADO: es aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades, por consideración a circunstancias

particulares expresamente determinadas por la ley (1008 inciso 3º). Son especies de testamentos privilegiados: el testamento verbal, el militar y el marítimo.

La ley que rige las solemnidades externas de los testamentos es la coetánea a su otorgamiento.

❖ **TESTAMENTO SOLEMNE**

I) TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN CHILE

Requisitos comunes a todo testamento solemne.

Todo testamento solemne, cualquiera que sea la forma que revista, debe cumplir con dos solemnidades generales:

1. Escrituración. Art. 1011. El testamento solemne es siempre escrito.
2. Presencia de testigos. El número es variable: la regla general es 3, pero la ley exige 5 en un caso: testamento abierto que no es otorgado ante funcionario.

Habilidad de los testigos. Los testigos de un testamento deben reunir determinados requisitos, y en primer lugar deben ser hábiles para ser tales.

Art. 1012. No podrán ser testigos en un testamento solemne, otorgado en Chile:

1. Derogado;
2. Los menores de dieciocho años;
3. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia;
4. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón;
5. Los ciegos;
6. Los sordos;
7. Los mudos;
8. Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 267, número 7º, y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos;²³
9. Los amanuenses del escribano que autorizare el testamento;
10. Los extranjeros no domiciliados en Chile;
11. Las personas que no entiendan el idioma del testador; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1024.²⁴

Dos a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento y uno a lo menos deberá saber leer y escribir, cuando sólo concurren tres testigos, y dos cuando concurren cinco.

La habilidad putativa de un testigo no anula el testamento.

Art. 1013. *Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente no se manifestare en el aspecto o comportamiento de un testigo, y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo.*

Pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos.

Es una aplicación del principio de que "el error común constituye derecho. También lo es de la llamada teoría de la apariencia.

Otros requisitos de los testigos. Además de ser hábiles, es necesario que:

²³ Debe entenderse hecha la referencia al art. 271 no. 3.

²⁴ Se refiere al testamento cerrado otorgado por algún testador que no pudiera entender o ser entendido a viva voz.

1. Dos testigos a lo menos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento.
2. Si el testamento se otorga ante 3 testigos, 1 por lo menos deberá saber leer y escribir, y si se otorga ante 5, 2 por lo menos deben cumplir tal requisito.

❖ **TESTAMENTO SOLEMNE ABIERTO (PÚBLICO O NUNCUPATIVO)**

Es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos (1015).

Según el artículo 1014, el testamento abierto puede otorgarse de 2 formas:

- a. Ante funcionario público competente y 3 testigos;
- b. Ante 5 testigos, sin intervención de funcionario público alguno.

a. Ante funcionario público competente y 3 testigos;

- Funcionarios públicos competentes para autorizar testamentos abiertos, siempre en presencia de 3 testigos:
 1. Notario público (escribano): RG
 2. Juez de letras del territorio jurisdiccional en que se otorga el testamento.

Anteriormente el Oficial del Registro Civil en las comunas donde no existía notario, estaba facultado para otorgar estos testamentos. Hoy sólo pueden actuar como ministros de fe, pero solo en las autorizaciones que firmen en documentos privados. Hoy no deben llevar protocolos.
- El testamento abierto puede ser otorgado en protocolo o en hoja suelta. El juez no lleva protocolos para insertar los testamentos. Ante el notario, Somarriva cree que puede ser otorgado tanto en protocolo como en hoja suelta. Cuando se otorga en el protocolo mismo es instrumento público en cuanto a testamento, pero también lo es en cuanto a escritura pública. El testamento en tal caso, no será sino una escritura pública, ya que cumple con todos los requisitos de la misma.
- No es forzoso que el testamento se incorpore en el protocolo del notario, pues puede otorgarse en hoja suelta: razones:
 1. 1017 dispone que el testamento puede escribirse previamente, lo que indica que puede no ingresar al protocolo, ya que lo contrario equivale a decir que éste saliese de notaría, cuestión jurídicamente imposible;
 2. 886 CPC y 420 COT, se refieren a la protocolización del testamento abierto otorgado en hoja suelta, sin distinguir cuál funcionario lo haya autorizado.

b. Ante 5 testigos, sin intervención de funcionario público alguno.

Este testamento no está revestido de la misma autenticidad que el anterior y por ello la ley, para proceder a la ejecución de un testamento ante 5 testigos, exige previamente su publicación, trámite contemplado en el 1020 del CC.

- El juez competente para conocer de la publicación del testamento, es el del último domicilio del testador.
- Puede pedir la publicación cualquier persona capaz de parecer en juicio.
- Fallecido el causante, se lleva su testamento abierto ante el juez designado, quien debe previamente cerciorarse de la muerte del testador, salvo en los casos en que se presume. Debe exhibirse la partida de defunción.
- El juez cita a su presencia a los testigos del testamento para que reconozcan sus firmas y la del testador. Los testigos proceden a efectuar dicho reconocimiento, y si alguno se ausenta, los presentes abonarán sus firmas. Si el juez lo estima conveniente, puede

solicitar declaración jurada acerca del reconocimiento de la firma del testador o de un testigo ausente.

- Reconocidas las firmas, el juez rubrica el testamento al principio y fin de cada hoja y lo manda a protocolizar a una notaría (1020).
- La publicación del testamento no reconoce validez al testamento, dejando a salvo las acciones de nulidad que pueden hacerse valer en su contra.

Protocolización del testamento otorgado en hoja suelta. Si el testamento se ha otorgado en hoja suelta, será necesario proceder antes de la ejecución, a la protocolización. 886 CPC. La protocolización del testamento otorgado ante 5 testigos, la ordena el propio 1020.

PROTOCOLIZACIÓN: hecho de agregar un documento al final del registro de un notario, a pedido de quien lo solicita.

Plazo para efectuar la protocolización. En el CC no existía plazo para protocolizar la hoja suelta otorgada ante notario. CPC señaló que debía realizarse en el menor tiempo posible luego del fallecimiento del testador. Hoy se resuelve por normas del Código del Notariado inserto en el COT. 420: establece que protocolizados valdrán como instrumentos públicos los testamentos solemnes abiertos otorgados en hojas sueltas, siempre que su protocolización se haya efectuado a más tardar dentro del primer día siguiente hábil al de su otorgamiento. La CA de Santiago resolvió que el plazo no se aplica al testamento otorgado ante 5 testigos. Es lógico, porque antes de la protocolización se requiere de publicación.

Se ha fallado que la nulidad de la protocolización no anula el testamento. La sanción, si ya transcurrió el plazo, sería que no valdrá como instrumento público.

Declaraciones que debe contener el testamento abierto. El testamento abierto no sólo tiene disposiciones de bienes, sino también declaraciones tendientes a individualizar al testador, testigos y funcionarios. Art. 1016. Es complementado por el 414 COT: señalamiento de la hora y del lugar en que se autoricen. Se ha fallado que no es requisito de los otorgados ante 5 testigos.

414 COT: la identidad del testador deberá ser acreditada en la forma establecida para las escrituras públicas.

Otorgamiento mismo del testamento abierto.

1. Escrituración y lectura del testamento.

Art. 1017. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente.

Pero sea que el testador lo tenga escrito, o que se escriba en uno o más actos, será todo él leído en alta voz por el escribano, si lo hubiere, o a falta de escribano por uno de los testigos, designado por el testador a este efecto.

Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones. (La lectura del testamento **es un acto continuo e ininterrumpido**). (Relacionado con el 1015 inciso final)

Si interviene el funcionario, debe ser él quién lo lea. En caso de ser ante 5 testigos, es nulo el testamento otorgado sin indicar quién debe leerlo.

Se discutió si debía dejarse constancia del trámite de la lectura. Quienes estimaban que era necesario, decían que se trataba de un acto solemne que debía bastarse a sí mismo. La doctrina contraria (acertada según Somarriva), señala que son dos cosas distintas la solemnidad y la prueba de la solemnidad. Además se agrega un argumento de texto: 1019: si se exige en el testamento del ciego, que deba dejarse constancia, es porque la RG es la inversa.

2. Firma del testamento.

Art. 1018. Termina el acto por las firmas del testador y testigos, y por la del escribano, si lo hubiere.

Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se mencionará en el testamento esta circunstancia expresando la causa.

Si se hallare alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él y a ruego suyo, expresándolo así.

Es distinta por tanto, la situación del testador y de los testigos.

Por regla general, una persona puede otorgar a su elección testamento abierto o cerrado. Esta libertad, tiene algunas limitaciones, ya que existen ciertas personas que están obligadas a otorgar testamento abierto, y otras que no pueden hacerlo, es decir, que deben otorgar testamento cerrado.

Personas obligadas a otorgar testamento abierto.

1. Art. 1022. *El que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado.*
2. Art. 1019. *El ciego, el sordo o el sordomudo que puedan darse a entender claramente, aunque no por escrito, sólo podrán testar nuncupativamente y ante escribano o funcionario que haga las veces de tal. (deberá ser ante funcionario).*

En el caso del ciego, el testamento deberá leerse en voz alta dos veces: la primera por el escribano o funcionario, y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador.

Tratándose del sordo o del sordomudo, la primera y la segunda lectura deberán efectuarse, además, ante un perito o especialista en lengua de señas, quien deberá, en forma simultánea, dar a conocer al otorgante el contenido de la misma.

Deberá hacerse mención especial de estas solemnidades en el testamento.

Personas que no pueden otorgar testamento abierto.

Art. 1024. Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz, sólo podrá otorgar testamento cerrado.

El testador escribirá de su letra, sobre la cubierta, la palabra testamento, o la equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo la designación de su persona, expresando, a lo menos, su nombre, apellido y domicilio, y la nación a que pertenece; y en lo demás se observará lo prevenido en el artículo precedente.

❖ TESTAMENTO SOLEMNE CERRADO O SECRETO

Es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones testamentarias.

Personas ante quienes debe otorgarse. 1021: debe otorgarse ante un escribano y ante 3 testigos, pudiendo hacer las veces de escribano el respectivo juez letrado. Siempre debe otorgarse ante funcionario público.

Otorgamiento del testamento cerrado. 1023: 3 etapas:

1. Escrituración y firma del testamento: éste debe estar escrito o, a lo menos, firmado por el testador. Se ha discutido lo que ocurre con el testamento escrito por el testador pero no firmado por él.

2. Introducción del testamento en sobre cerrado: debe cerrarse exteriormente, en términos tales, que si se quiere extraer el testamento, deba romperse la cubierta. 1023 inciso 3º.

3. Redacción y firma de la carátula. Hecho lo anterior, el notario deberá redactar la carátula, comenzando con el epígrafe "testamento". La firma del testador en la carátula es esencial

El otorgamiento del testamento debe ser ininterrumpido. 1023 inciso final: Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo escribano y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere.

Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado. Es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el escribano y testigos le vean, oigan y entiendan (salvo el caso del artículo siguiente), que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del escribano y testigos.

Testamento de los que no pueden ser entendidos de viva voz.

Art. 1024. *Cuando el testador no pudiese entender o ser entendido de viva voz, sólo podrá otorgar testamento cerrado.*

El testador escribirá de su letra, sobre la cubierta, la palabra testamento, o la equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo la designación de su persona, expresando, a lo menos, su nombre, apellido y domicilio, y la nación a que pertenece; y en lo demás se observará lo prevenido en el artículo precedente.

El testador puede llevarse el testamento cerrado o dejarlo en la notaría.

Índice de testamentos cerrados. 431 del COT obliga a llevar el índice y siendo secreto, sólo puede ser exhibido en virtud de resolución judicial.

Apertura del testamento cerrado.

Fallecido el testador, para la ejecución del testamento cerrado es necesario proceder a la apertura de él, tramite reglado en los artículos 1025 CC y 886 y 889 CPC. (Ver dichas normas)

El juez citará al notario y los testigos que concurrieron al otorgamiento, no habiendo necesidad de notificarlos personalmente o por cédula.

El funcionario y los testigos depondrán sobre 2 hechos:

1. Reconocerán su firma y la del testador; y
2. Reconocerán si el testamento está tal cual fue otorgado, si está cerrado, sellado o marcado como en el acto de la entrega.

En caso necesario y cuando el juez lo estime conveniente, podrán ser abonadas las firmas del notario y testigos por la declaración jurada de otras personas fidedignas.

Se ha declarado que los vicios en la apertura del testamento, no traen consigo la nulidad del testamento.

Protocolización del testamento cerrado. Reconocidas las firmas y la integridad del testamento, se abre el sobre y el juez rubrica el testamento al fin y al principio de cada hoja y lo manda protocolizar ante el notario que lo autorizó o ante el que designe. Además, según el 417 COT se protocolizan los antecedentes que lo acompañan,

correspondientes a los trámites de apertura. Desde la protocolización, el testamento adquiere carácter de instrumento público.

NULIDAD DEL TESTAMENTO SOLEMNE

La omisión de cualquier solemnidad del testamento acarrea su nulidad.

Art. 1026. El testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que deba respectivamente sujetarse, según los artículos precedentes, no tendrá valor alguno.

Con todo, cuando se omitiere una o más de las designaciones prescritas en el artículo 1016, en el inciso 5º del 1023 y en el inciso 2º del 1024, no será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o testigo.

Causales de nulidad del testamento solemne:

1. Testamento abierto o cerrado que no se otorga por escrito;
2. Testamento que no se otorga ante el número de testigos hábiles exigidos por la ley (no es nulo si hay más testigos de los exigidos, según lo señala la jurisprudencia);
3. Testamento otorgado ante un funcionario que no sea de los autorizados por ley para intervenir en el acto.
4. Infracción de reglas dadas para el otorgamiento:
 - 1) Abierto que no es leído;
 - 2) Concurriendo funcionario, lo lee un testigo;
 - 3) Para algunos, la falta de constancia de haberse dado cumplimiento al trámite de lectura;
 - 4) Testamento abierto en el cual no se deja constancia de que el testador no supo o no pudo firmar;
 - 5) Firma por algún testigo una persona extraña al otorgamiento;
 - 6) Testamento del ciego, cuando no se proceda a la doble lectura;
 - 7) Testamento cerrado cuando aparezca violada la cubierta;
 - 8) Testamento de persona que debiendo otorgar testamento cerrado, otorga el abierto o viceversa.

Se trataría de nulidad **absoluta**.

La nulidad en las declaraciones del testamento no anula éste si no hay duda sobre la identidad de las personas que intervienen en él. 1026 inciso 2º.

Sanción por la omisión de la indicación del lugar de otorgamiento del testamento. Tanto en el abierto como en la carátula del cerrado, el CC exige que se indique el lugar del otorgamiento. Se aplica el 1026.

Sanción por la omisión de la indicación de la hora del otorgamiento del testamento. Somarriva considera que la nulidad no es aplicable y que sólo se puede perseguir la responsabilidad del notario.

Habilidad putativa del funcionario. CS ha fallado en ambos sentidos. Somarriva argumenta que no se comunica el vicio, en virtud del error común, *facit ius*. De otro modo sería necesario tener certeza de la legalidad del nombramiento del funcionario, de que no esté sujeto a inhabilidades entre otros, que dificultarían en demasía el tráfico jurídico.

II) TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN EL EXTRANJERO

1. Testamento otorgado en el extranjero en conformidad a la ley extranjera

1027: Requisitos:

- 1) Debe otorgarse por escrito. Si el testamento verbal otorgado en Chile es peligroso, mucho más es el otorgado en el extranjero.
- 2) Debe acreditarse que se han cumplido las solemnidades exigidas por la ley extranjera (sería aparentemente uno de los casos en que deba probarse el derecho, por ser extranjero).
- 3) Debe acreditarse la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria (Art. 17 CC)

El artículo 1027 aplica el principio del *locus regit actum*. Contiene sin embargo, una excepción: el testamento en todo caso debe ser **escrito**, no reconociendo el verbal, cualquiera sea su eficacia en el extranjero.

- **Validez del testamento ológrafo otorgado en el extranjero:** son aquellos escritos, fechados y firmados de puño y letra por el testador, sin necesidad de cumplir otra solemnidad que la indicada. Nuestro CC no reconoce validez al testamento ológrafo otorgado en Chile. El grueso de la doctrina acepta la eficacia del otorgado en el extranjero, cuando la ley del país en que se otorgó le reconozca validez: la única exigencia es que sea escrito. La CS lo ha reconocido como válido.

2. Testamento otorgado en el extranjero conforme a la ley chilena

1028: Requisitos:

- 1) El testador debe ser chileno o extranjero domiciliado en Chile.
- 2) Los testigos que intervienen en este testamento deberán ser chilenos o extranjeros domiciliados en la ciudad en que se otorgue el instrumento.
- 3) Debe ser otorgado ante un cónsul o representante diplomático chileno.
- 4) En lo demás se observarán las reglas del testamento solemne otorgado en Chile. Puede ser abierto o cerrado, debiendo respetarse las normas del caso.

- El testamento que no haya sido ante un jefe de Legación, llevará el visto bueno de este jefe.

- El testamento en estudio, debe ser ejecutado en nuestro país. Por ello, deberá remitirse una copia del testamento abierto o una copia de la carátula del cerrado al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual remitirá una copia al juez del último domicilio del difunto en Chile, para que la haga incorporar en los protocolos de un notario del mismo domicilio.

- **Apertura del cerrado.** Será difícil la comparecencia del funcionario y de los testigos. La falta de funcionario es suplida por el notario que el juez designe.

❖ **TESTAMENTO MENOS SOLEMNE O PRIVILEGIADO**

1008: el testamento menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades establecidas por la ley, por consideración a circunstancias especiales, determinadas expresamente por el legislador.

1030: son privilegiados: 1) el testamento verbal; 2) el testamento militar; y 3) el testamento marítimo.

Solemnidades comunes a todo testamento privilegiado.

1) Presencia de testigos hábiles. En este caso, las inhabilidades son menos que en los testamentos solemnes.

Art. 1031. En los testamentos privilegiados podrá servir de testigo toda persona de sano juicio, hombre o mujer, mayor de dieciocho años, que vea, oiga y entienda al testador, y que no tenga la inhabilidad designada en el número 8 del artículo 1012. Se requerirá además para los testamentos privilegiados escritos que los testigos sepan leer y escribir.

Bastará la habilidad putativa, con arreglo a lo prevenido en el artículo 1013.

La ley es menos estricta con los testigos del testamento privilegiado.

Excepcionalmente es más estricta en un caso: si concurren 3 testigos en un testamento solemne 1 debe saber leer y escribir, si concurren 5, deberán saberlo 2; en los menos solemnes escritos todos los testigos deben saber leer y escribir.

2) Ciertas solemnidades en el otorgamiento. 1032.

- a) En los testamentos privilegiados el testador declarará expresamente que su intención es testar;
- b) Las personas cuya presencia es necesaria serán unas mismas desde el principio hasta el fin; y
- c) El acto será continuo, o sólo interrumpido en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere.

No serán necesarias otras solemnidades que éstas, y las que en los artículos siguientes se expresan.

Apertura, publicación y protocolización de un testamento privilegiado.

870 CPC dispone que los testamentos privilegiados se someterán en su apertura, publicación y protocolización a las reglas establecidas en el CC respecto de ellos. El 420 del COT señala que una vez protocolizados valdrán como instrumentos públicos los testamentos menos solemnes o privilegiados que no hayan sido autorizados por notario, previo decreto del juez competente.

1. EL TESTAMENTO VERBAL

Es el otorgado por una persona, en caso de peligro inminente para su vida, ante 3 testigos y haciendo de viva voz sus declaraciones y disposiciones testamentarias. (1033 a 1035)

Requisitos:

- a. Peligro inminente de la vida del testador.
- b. Debe haber sido imposible otorgar un testamento solemne.
- c. Concurrencia de 3 testigos.
- d. El testador debe hacer sus declaraciones y disposiciones a viva voz.

Caducidad del testamento verbal.²⁵ 1036

- 1- Si transcurren 30 días de haberse otorgado el testamento, sin que fallezca el testador.
- 2- Si no se pone por escrito el testamento dentro del plazo legal.

Art. 1036. El testamento verbal no tendrá valor alguno si el testador falleciere después de los treinta días subsiguientes al otorgamiento; o si habiendo fallecido antes, no se hubiere puesto por escrito el testamento, con las formalidades que van a expresarse, dentro de los treinta días subsiguientes al de la muerte.

El plazo de 30 días es **fatal**. El trámite de poner por escrito el testamento verbal se compone de 3 etapas:

- a. Examen de los testigos: respecto de la individualización del testador, de los testigos, del lugar y fecha en que fue otorgado. Depondrán sobre: si el testador parecía estar en sano juicio, si el testador manifestó voluntad de testar y sobre cuáles fueron sus declaraciones y disposiciones testamentarias.
- b. Resolución judicial: en caso de que estime que se han observado las solemnidades, y que en la información aparece claramente la última voluntad, mandará que se tengan las declaraciones y disposiciones como testamento del difunto.
- c. Protocolización del decreto que señala lo anterior.

Existen fallos contradictorios respecto a si dentro del plazo de 30 días deben efectuarse las 3 etapas o sólo alguna de ellas.

2. EL TESTAMENTO MILITAR

Es aquel que se otorga en tiempo de guerra por los militares y demás individuos empleados en un cuerpo de tropa de la República y voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecen a dicho cuerpo. (Son limitadas las personas que pueden testar bajo esta modalidad).

Funcionarios ante quienes puede otorgarse.

1. Capitán u oficial de grado superior de éste;
2. Intendente del ejército;
3. Comisario (cargo desaparecido de nuestras FF.AA.);
4. Auditor de guerra;

²⁵ El testamento solemne sólo puede ser dejado sin efecto por su **revocación**. En los privilegiados, además de la revocación existe otra causal de terminación del testamento: **la caducidad**.

5. Si el testador estuviera enfermo o herido, su testamento podrá ser recibido por el capellán, médico o cirujano que lo asista, y si se hallare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aun cuando sea de grado inferior a capitán.

Requisito esencial para testar militarmente: que exista un estado de guerra. Se comprende tanto la internacional como la civil.

- El testamento militar admite la siguiente **clasificación:**

1. Testamento militar abierto

Se realiza ante el funcionario indicado y de los testigos. Se firma, siempre que se pueda, por el testador, el funcionario y los testigos. Somarriva estima, frente al silencio de la ley, en cuanto al número de testigos, que deben ser 3 testigos, por ser este número la RG. El 1045 exige protocolización y señala los trámites previos para llevar a efecto la misma.

Caducidad: 1044: caduca su pasan 90 días desde que cesaron las circunstancias que habilitan para testar militarmente sin haber fallecido el testador.

2. Testamento militar cerrado

Escoge testar cerradamente. Se remite al solemne, modificándose el funcionario (ya nombrados para todo militar), la carátula será visada y rubricada por el jefe superior de la expedición o el comandante de la plaza y la carátula será enviada al Ministerio de Defensa Nacional. También requiere de 3 testigos, pese a que la ley no lo dice expresamente.

Igualmente caduca su pasan 90 días desde que cesaron las circunstancias que habilitan para testar militarmente sin haber fallecido el testador.

3. Testamento militar verbal

Cuando una persona, que puede testar militarmente, se halle en peligro inminente podrá otorgar testamento verbal. Tiene normas especiales respecto a la información de testigos.

Caducidad: si el testador sobrevive al peligro.

3. EL TESTAMENTO MARÍTIMO

Aquel que se otorga en alta mar en un buque de guerra chileno o en un buque mercante que navega bajo bandera chilena.

Puede tener mayor aplicación práctica que el militar, porque permite aplicarlo en tiempo de paz.

En buques de guerra, pueden acogerse a este testamento, cualquier persona que se encuentre a bordo y no sólo la tripulación. En igual sentido, respecto de las naves mercantes.

Clasificación:

a. Testamentos otorgados en nave de guerra:

i. Testamento marítimo abierto (ante el comandante o su 2º en presencia de 3 testigos; el testamento se guardará entre los papeles más importantes de la nave y se dará noticia de su otorgamiento en el diario. Se debe entregar a autoridad chilena en el primer puerto a que llegue la nave). **Caducidad:** 1052.

ii. Testamento marítimo cerrado (aplicación de las normas del cerrado, salvo el funcionario: comandante de la nave o su segundo);

iii. Testamento verbal.

b. Testamentos en naves mercantes: sólo abiertos.

LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS

Del art. 953, podrían definirse como aquellas asignaciones que hace el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes.

Requisitos de las disposiciones (asignaciones) testamentarias.

Se distinguen requisitos subjetivos y objetivos.

I) Subjetivos: aquellos que deben concurrir en la persona misma del asignatario:

1. Capacidad de suceder;
2. Digno de suceder al causante; y
3. Ser persona cierta y determinada.

1. y 2. Ya fueron analizadas.

II) Objetivos: determinan la validez o nulidad de las propias asignaciones.

Certidumbre y determinación del asignatario.

- El asignatario debe ser una persona cierta. 1056 inciso 1º: todo asignatario deberá ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica. En el mismo sentido, el CC insiste en sus artículos 962 y 963: capacidad de suceder.

1065: en el evento de que una asignación esté concebida en términos tales que exista incertidumbre respecto de la persona a quien ha querido el testador referirse, ninguna de las 2 o más personas, entre las cuales existe la duda, tendrá derecho a la asignación. No existe una manifestación clara de la voluntad del testador.

- El asignatario debe estar determinado o ser determinable. La determinación del asignatario en el testamento debe hacerse por el nombre de éste, pero el 1056 declara que la circunstancia de no estar determinado el asignatario en esta forma no trae consigo la ineficacia de la disposición testamentaria, siempre que el testamento contenga indicaciones claras que permitan su identificación (determinable).

Excepcionalmente la ley, en ciertos casos, admite la indeterminación del asignatario:

1. Asignaciones hechas con un objeto de beneficencia, a las cuales se asimilan las asignaciones dejadas para el alma del testador.

Anteriormente el Presidente tenía la facultad de radicar la asignación en determinada entidad de beneficencia. Luego pasó a la Junta Central de Beneficencia, luego al Consejo Nacional de Salud. Hoy, FONASA está facultado para la inversión de las asignaciones dejadas indeterminadamente con un objeto de beneficencia.

El 1056 inciso 4º, asimila las asignaciones dejadas para el alma del testador a las asignaciones recién comentadas.

2. Asignaciones dejadas a los pobres. Lo que en general se dejare a los pobres, se aplicará a los de la parroquia del testador.

3. Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes. 1064. La asignación corresponde a los consanguíneos de grado más próximo, según los órdenes de sucesión intestada y **teniendo lugar el derecho de representación**. Si es que hay un solo pariente en el grado más próximo, también entran a concurrir los de grado posterior.

Requisitos de las asignaciones.

- Las asignaciones al igual que los asignatarios deben estar determinadas o ser determinables.

Art. 1066. Toda asignación deberá ser o a título universal, o de especies determinadas o que por las indicaciones del testamento puedan claramente determinarse, o de géneros y cantidades que igualmente lo sean o puedan serlo. De otra manera se tendrá por no escrita.

Sin embargo, si la asignación se destinare a un objeto de beneficencia expresado en el testamento, sin determinar la cuota, cantidad o especies que hayan de invertirse en él, valdrá la asignación y se determinará la cuota, cantidad o especies, habida consideración a la naturaleza del objeto, a las otras disposiciones del testador, y a las fuerzas del patrimonio, en la parte de que el testador pudo disponer libremente.

El juez hará la determinación, oyendo al defensor de obras pías y a los herederos; y conformándose en cuanto fuere posible a la intención del testador.

- Según Somarriva, para que opere la excepción del inciso 2º, es necesario que al menos esté determinado el asignatario. De lo contrario la disposición se tendrá por no escrita.

- i. En las asignaciones a título universal, basta la determinación del patrimonio del causante.
- ii. En legados de especie la determinación exigida es la máxima.
- iii. En legados de género es menos estricta la individualización, los cuales deberán estar determinados genéricamente o en cantidad, o cuando menos ser determinables en virtud de que el testamento contenga indicios claros al respecto.

El error en las asignaciones testamentarias. El legislador trata del error en los artículos 1057 y 1058 a propósito del error en las asignaciones testamentarias. Esto se explica porque el error sólo vicia la asignación en que inciden, pero no afecta al resto del testamento.

Art. 1057. *El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición, si no hubiere duda acerca de la persona.*

Art. 1058. *La asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita.*

Este último artículo pone en claro que el error sólo afecta a la cláusula testamentaria en que incide, y en base al mismo podemos concluir que el error

vicia la asignación cuando es determinante. Sólo el error de hecho produce el efecto invalidatorio. No así el de derecho.

- Las asignaciones testamentarias son actos intuitu persona. El artículo 1057 es concordante con la norma de la tradición (676 inciso 2º).

Otros requisitos de las asignaciones testamentarias. Las siguientes normas se basan en el principio de que en el testamento debe manifestarse la voluntad libre y espontánea, exenta de vicios e influencias extrañas, del testador. En defensa de ello, la ley establece la invalidez de una serie de disposiciones en que se teme que se ha atentado contra la voluntad del causante.

1. **Nulidad de las disposiciones captatorias.** 1003: el testamento es un acto de una sola persona. En concordancia con esto, el 1059 establece que las disposiciones captatorias no valdrán, entendiéndose que son aquellas en que el testador asigna una parte de sus bienes, a condición de que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos.
2. **Falta de manifestación clara de la voluntad.** 1005 No. 5; 1060, en este sentido.
3. **Elección del asignatario por otra persona.** La facultad de testar, según el art. 1004, es indelegable. El artículo 1063, en este sentido declara que la elección de un asignatario, sea de entre cierto número de personas, sea absolutamente, no depende del puro arbitrio ajeno.
4. **Incapacidad del notario y testigos del testamento.** 1061.
5. **Cumplimiento de una asignación que se deja al arbitrio de un heredero o legatario.** 1067: hay que distinguir si resulta beneficio para el asignatario en rehusar cumplir la asignación o no le reporta provecho dicho incumplimiento.

Art. 1067. *Si el cumplimiento de una asignación se dejare al arbitrio de un heredero o legatario, a quien aprovecharse rehusarla, será el heredero o legatario obligado a llevarla a efecto, a menos que pruebe justo motivo para no hacerlo así²⁶. Si de rehusar la asignación no resultare utilidad al heredero o legatario, no será obligado a justificar su resolución, cualquiera que sea²⁷.*

El provecho de un ascendiente o descendiente, de un cónyuge o de un hermano o cuñado, se reputará, para el efecto de esta disposición, provecho de dicho heredero o legatario.

El 1067 permite hacer lo que prohíbe el 1063: se impide dejar a una persona la elección del asignatario. Somarriva estima que debe primar el 1063.

INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO.

En la interpretación del testamento prevalece la voluntad claramente manifestada del testador.

Art. 1069. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales.

Para conocer la voluntad del testador se estará más a la substancia de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido.

Se busca proteger la **voluntad real** del testador. Es la misma solución que la dada en materia contractual: 1560: debe estarse más a la intención de los contratantes que a lo literal de las palabras. Sin embargo, tal como lo señala la ley y lo ha estimado la jurisprudencia, **la voluntad del testador prevalece siempre que no se oponga a las prohibiciones y requisitos legales.**

²⁶ Por ejemplo, ingratitud del asignatario.

²⁷ Por ejemplo, entrega \$100 a Pedro o al Hogar de Cristo. Puede elegir a Pedro, sin expresar la causa.

- **Interpretar (en este caso buscar desentrañar la voluntad del testador) el testamento es cuestión de hecho.**

- **La calificación jurídica de una disposición es cuestión de derecho.** La errónea calificación queda sujeta a revisión en virtud de la casación en el fondo. Calificar, por ejemplo, es determinar si hay usufructo o fideicomiso; si se trata de un heredero de cuota o se trata de un heredero universal (importancia para el acrecimiento). Asimismo, se ha fallado que procede la casación si los jueces de fondo al interpretar el testamento desnaturalizan la institución creada por el testador.

CLASIFICACIONES DE LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS

Las asignaciones testamentarias pueden ser clasificadas desde diversos ángulos:

- 1. Asignaciones puras y simples y sujetas a modalidades,** según que los efectos de la asignación se produzcan inmediatamente o vayan verse afectados por algunas de las modalidades, las cuales son la condición, el plazo y el modo.
- 2. Asignaciones a título universal o herencias, y asignaciones a título singular o legados;** y
- 3. Asignaciones voluntarias o forzosas.** Las primeras son las que el testador está en libertad de efectuar o no, según su arbitrio o deseo. Las forzosas son las que el testador está obligado a realizar, y el legislador las suple, aun con perjuicio de sus disposiciones expresas.

Asignaciones sujetas a Modalidades

Pueden ser de 3 clases:

- i. Asignaciones testamentarias condicionales;
- ii. Asignaciones testamentarias a día o a plazo;
- iii. Asignaciones modales propiamente tales.

i. Asignaciones testamentarias condicionales;

Art. 1070: *asignación condicional es en el testamento aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto, de manera que según la intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo.*

Las condiciones, están reguladas a propósito de las obligaciones condicionales, de las asignaciones testamentarias condicionales y del fideicomiso. (1493, 1070 y 1079).

La condición debe consistir en un hecho futuro.

Art. 1071. *La condición que consiste en un hecho presente o pasado, no suspende el cumplimiento de la disposición. Si existe o ha existido, se mira como no escrita; si no existe o no ha existido, no vale la disposición.*

Lo pasado, presente y futuro se entenderá con relación al momento de testar, a menos que se exprese otra cosa.

Art. 1072. *Si la condición que se impone como para tiempo futuro, consiste en un hecho que se ha realizado en vida del testador, y el testador al tiempo de testar lo supo, y el hecho es de los que pueden repetirse, se presumirá que el testador exige su repetición; si el testador al tiempo de testar lo supo, y el hecho es de aquellos cuya repetición es imposible, se mirará la condición como cumplida; y si el testador no lo supo, se mirará la condición como cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho.*

Condición de no impugnarse un testamento.

Art. 1073. *La condición de no impugnar el testamento, impuesta a un asignatario, no se extiende a las demandas de nulidad por algún defecto en su forma.*

El legislador busca amparar en todo momento las solemnidades del testamento.

Condición de no contraer matrimonio.

Los artículos 1074 y 1075 establecen que por regla general se tendrán por no escritas las condiciones impuestas al asignatario de no contraer matrimonio o permanecer en estado de viudedad. Esto se explica, según Somarriva, porque el legislador está interesado en la buena constitución de la familia, sólo obteniéndose ello por el matrimonio. Sin embargo, la regla general admite excepciones.

Art. 1074. *La condición impuesta al heredero o legatario de no contraer matrimonio se tendrá por no escrita, salvo que se limite a no contraerlo antes de la edad de dieciocho años o menos.*

Art. 1075. *Se tendrá asimismo por no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad; a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio, al tiempo de deferírsele la asignación.*

Art. 1076. *Los artículos precedentes no se oponen a que se provea a la subsistencia de una persona mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica.*

Art. 1077. *La condición de casarse o no casarse con una persona determinada, y la de abrazar un estado o profesión cualquiera, permitida por las leyes, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio, valdrán.*

- Este último artículo se limita la persona excluida para el matrimonio. Por esa razón vale.

- Asimismo es válida la condición de abrazar un estado o profesión cualquiera que sea incompatible con el estado de matrimonio: abrazar el estado sacerdotal.

Asignaciones condicionales resolutorias y suspensivas.

1. Asignación condicional resolutoria:

A la inversa de lo que ocurren con las obligaciones condicionales, las asignaciones condicionales resolutorias presentan menos interés que las sujetas a condición suspensiva.

- *Pendiente:* El asignatario condicional resolutorio está en calidad de propietario de los bienes dejados bajo condición, pudiendo ejercitar sus derechos como propietario puro y simple.
- *Fallida:* el dominio se consolida, pasando a ser puro y simple.
- *Cumplida:* se extingue la asignación, debiendo restituir lo que se haya recibido, pero conservando los frutos, salvo que el testador o la ley haya dispuesto otra cosa. Las enajenaciones se rigen por el 1490 y 1491.

2. Asignación condicional suspensiva:

- *Pendiente:* se encuentra suspendida la adquisición de la cosa asignada. No confieren derecho alguno al asignatario, mientras pende la condición, sino el de implorar las medidas conservativas necesarias (1078). Lo mismo se aplica para las obligaciones condicionales y para el fideicomisario.

De lo anterior, se derivan consecuencias de suma importancia:

1. El asignatario debe existir al momento de cumplirse la condición (962 inciso 2º).

2. La delación de la asignación, se produce una vez cumplida la condición. Es una excepción a la regla general: la delación se produce al momento de la apertura de la sucesión (art. 956).
3. **El asignatario condicional nada transmite a sus herederos, si fallece antes de cumplirse la condición (1078 inciso 2º). En materia de obligaciones condicionales se aplica la solución inversa (1492). Ni el asignatario condicional ni el donatario condicional transmiten su expectativa a sus herederos; en cambio, el acreedor condicional la traspasa a los suyos.**
4. El asignatario condicional no puede ejercer la acción de partición. 1319. Si los demás coasignatarios proceden a efectuarla, deben asegurar competentemente al condicional lo que cumplida la condición le corresponda.
5. CS: si un acreedor del asignatario condicional embarga los bienes dejados a éste bajo condición suspensiva, es admisible la tercería entablada por lo herederos, pues el acreedor ha embargado un bien que aún no le corresponde al asignatario condicional.

- *Cumplida:* nace el derecho del asignatario condicional, adquiriendo la cosa asignada.

1078 inciso final: cumplida la condición suspensiva, el asignatario condicional no puede solicitar la restitución de los frutos producidos por la cosa asignada antes de cumplirse la condición, salvo que el testador haya dispuesto otra cosa. En igual sentido, el 1388 No. 1, respecto de los legados de especie condicionales. Es uno de los casos en que la condición cumplida no opera con efectos retroactivos.

- *Fallida:* se esfuma la mera expectativa del asignatario. Por ello, si se solicitó alguna medida conservativa, debe alzarse. (1480 y 1481). Existencia de un cumplimiento ficto de la condición, cuando se valgan de medios ilícitos.

ii. Asignaciones testamentarias a día o plazo;

1080: las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o días de que dependa el goce actual o; extinción de un derecho y se sujetarán a las reglas dadas en el título de las obligaciones a plazo, con algunas variantes.

El plazo, suspende el goce actual de un derecho, es decir, su exigibilidad.

Aunque la ley no lo diga, si la asignación a plazo lleva envuelta la constitución de un usufructo, se aplicarán dichas reglas.

Asignaciones a día y asignaciones a plazo. Son expresiones distintas: la asignación a plazo no puede contener incertidumbre de ninguna especie. La asignación a día, puede llevar envuelta cierta incertidumbre respecto del día. Desde que en una asignación sujeta a modalidad, se introduce la incertidumbre, nos encontramos ante una condición. Por ello, las asignaciones a día, podrán ser a plazo o condicionales, según exista o no certidumbre sobre ellas.

Certidumbre y determinación del día. El día en las asignaciones puede ser cierto o incierto, determinado o indeterminado.

- La **certidumbre** de la asignación a día dice relación con la certeza o no de que va a llegar el día fijado.
- La **determinación** de la asignación dice relación con si se sabe o no cuándo va a llegar el día.

Clasificaciones de las asignaciones a día, conforme a su certidumbre y determinación.

1. Asignaciones a día cierto y determinado: necesariamente va a llegar y se sabe cuándo.
2. Asignaciones a día cierto e indeterminado: necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo (muerte de X).
3. Asignaciones a día incierto pero determinado: puede llegar o no, pero suponiendo que haya de llegar, se sabe cuándo. X cumpla 25 años.
4. Asignaciones a día incierto e indeterminado: no se sabe si ha de llegar ni se sabe cuándo.

Asignaciones desde tal día y hasta tal día. (Coincide con la clasificación de plazo suspensivo y extintivo)

1. Asignaciones desde tal día:

- i. Desde día cierto y determinado: es típicamente a plazo. El derecho se adquiere desde el momento del fallecimiento, pero se suspende la exigibilidad. Si el testador, impone expresamente al asignatario la condición de existir ese día, la asignación pasa a ser condicional (introduce elemento de incertidumbre).
- ii. Desde día cierto pero indeterminado: es condicional, porque el asignatario debe existir ese día (la incertidumbre la introduce la ley). Si se sabe que el asignatario va a existir el día fijado, como cuando es a favor de un establecimiento permanente (U. de Chile, por ejemplo), la asignación es a plazo.
- iii. Desde día incierto pero determinado. Es condicional.
- iv. Desde día incierto e indeterminado. Es condicional.

Puede ocurrir, como en las condiciones, que en lo asignado desde tal día, éste llegue antes de la muerte del testador. En tal caso, según el 1082, la asignación se entenderá hecha para después del fallecimiento del testador, y sólo se deberá desde que se abra la sucesión.

2. Asignaciones hasta tal día:

- i. Hasta tal día cierto y determinado. Constituye un usufructo a favor del asignatario.
- ii. Hasta tal día cierto e indeterminado. También habría usufructo. La jurisprudencia ha dicho que la asignación por toda la vida del asignatario es un usufructo.
- iii. Hasta día incierto pero determinado. También se trata de un usufructo. Llama la atención que existiendo incertidumbre, exista un plazo. 1088 se pone en el caso de que se deje una asignación a una persona hasta que un tercero cumpla una edad determinada.
- iv. Hasta día incierto e indeterminado. Es condicional.

Conclusión:

- Las asignaciones desde día son siempre condicionales, a menos que sea desde un día cierto y determinado o desde día cierto e indeterminado a un establecimiento permanente (en ambos casos será a plazo);
- Las asignaciones hasta tal día son siempre a plazo y representan un plazo y un usufructo a favor del asignatario, salvo que sea hasta día incierto e indeterminado, en las que existe una condición.

Lo anterior tiene gran trascendencia para **distinguir el usufructo del fideicomiso**. Si se trata de un plazo, estaremos frente a un usufructo; si se trata de una condición, frente a un fideicomiso.

En muchos casos y apoyados por lo que ha dicho la jurisprudencia, tendremos que atenernos más a la intención del testador: si la intención fue dejar la propiedad, la asignación es un fideicomiso; y si la intención fue dejar a una persona el goce, nos encontramos ante un usufructo.

iii. Asignaciones modales propiamente tales.

Art. 1089. Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada.

Modo: carga que se impone a quien se otorga una liberalidad.

- La asignación modal puede ser una herencia o legado.
- En la asignación modal concurren 2 personas: el asignatario y el beneficiado con el modo. ¿En quién deben concurrir los requisitos para suceder? La CS ha dicho que los requisitos necesarios

para suceder deben concurrir **únicamente en el asignatario modal**, pero no en el beneficiado con el modo. Éste último no es heredero ni legatario, ni tiene vínculo jurídico alguno con el causante. Así no sería nula la asignación si el beneficiado con el modo no goza de personalidad jurídica.

Esta interpretación de la CS puede resultar peligrosa, debido a que las asignaciones hechas a personas incapaces **son nulas**, aun cuando se disfracen de contratos onerosos o se hagan por interpósita persona. La asignación modal puede llevar envuelta la interposición de personas a fin de burlar las prohibiciones sobre incapacidad. En cada caso, habrá determinar si existió o no ánimo fraudulento del testador.

Características del modo.

1. No es una condición suspensiva, por lo que el asignatario modal adquiere desde ya y por el solo fallecimiento la asignación modal.
2. La obligación modal es transmisible por regla general. No será transmisible si se impone en consideración a la persona del asignatario.

Incumplimiento del modo. La cláusula resolutoria.

En caso de que el asignatario modal no cumpla con la carga impuesta por el testador, el beneficiado con el modo tiene 2 derechos:

1. Solicitar la ejecución forzada de la obligación, siempre que concurren los requisitos legales.
2. Derecho de pedir la resolución de la asignación modal. Éste será ejercido en virtud de la **cláusula resolutoria**: es la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo (1090). Por regla general, la cláusula resolutoria no va envuelta en el modo, salvo que el testador la imponga (diferencia con la CRT en los contratos bilaterales).

En caso de que sea un Banco el asignatario modal, y sólo en este caso, se subentiende la cláusula resolutoria.

Quiénes pueden solicitar la resolución. El legislador no lo señala. Aplicando el principio de que es el interés jurídico el que hace nacer la acción, podemos concluir que pueden solicitarlo 2 personas:

- a. El beneficiado con el modo: declarada la resolución de la asignación modal, debe entregársele, en virtud del 1096, una suma proporcionada de dinero;
- b. Los demás asignatarios: declarada la resolución de la asignación modal, esta asignación, con deducción de lo que deba entregársele al beneficiado con el modo, acrece a los herederos.

Prescripción de la acción para pedir la resolución. Sin regla especial, debe aplicarse el 2515: prescribe como acción ordinaria en 5 años contados desde que se incumpla el modo.

Efectos de la resolución de la asignación modal.

1. El asignatario modal debe restituir la cosa y sus frutos (es una nueva diferencia con la CRT: en ella, no se devuelven los frutos, por regla general).
2. Debe entregarse al beneficiado con el modo una suma de dinero proporcionada al objeto y el resto acrece a la herencia, quedando excluido el asignatario modal del beneficio (1096).

Cumplimiento del modo. Cómo debe cumplirse y enunciación de los casos en que puede dejarse de hacerlo.

1094: si el testador no determinare suficientemente el tiempo o la forma especial en que ha de cumplirse el modo, podrá el juez determinarlos, consultando en lo posible la voluntad de aquél, y dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda a lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada. Para los Bancos, no rige el mínimo de remuneración fijado en el precepto.

El legislador, señala 2 casos en que el asignatario modal puede dejar de cumplir la carga que se le ha impuesto:

a. Imposibilidad o ilicitud del modo. 1093

- i- Modo por su naturaleza imposible absolutamente o ilícito. (Ininteligible se incluye). No valdrá la disposición.
- ii- Modo que se hace absolutamente imposible con posterioridad a su establecimiento. Subsiste la asignación sin el gravamen.
- iii- Imposibilidad relativa. Puede cumplirse en forma análoga que no altere la sustancia de la disposición y que en este concepto sea aprobada por el juez, con citación de los interesados.

b. Modo que va en beneficio del propio asignatario modal. 1092. El modo en este caso no impone obligación alguna, a menos que lleve cláusula resolutoria.

El legislador, reguló el modo a propósito de la sucesión por causa de muerte, por ser ésta su ambiente de desarrollo común. Por esa razón, el legislador en materia de contratos, se remite a las normas de las asignaciones testamentarias modales.

ASIGNACIONES A TÍTULO UNIVERSAL O HERENCIAS

Son aquellas en que se deja al asignatario la totalidad de los bienes del difunto o una cuota de ellos.

La asignación recibe el nombre de **herencia**, y el asignatario de **heredero**.

Art. 1097. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos: representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.

Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a determinadas personas.

Características de las asignaciones a título universal.

1. Pueden ser testamentarias o abintestato. (Los legatarios sólo pueden ser testamentarios);
2. Los herederos adquieren la asignación y posesión legal por la muerte del causante;
3. Los herederos pueden adquirir personalmente o en forma indirecta (derecho de representación y derecho de transmisión)
4. Los herederos gozan de ciertas acciones: acción de petición de herencia, reforma de testamento (cuando el heredero sea también legitimario y su legítima haya sido desconocida por el testador).
5. Si existen varios herederos se forma una indivisión hereditaria, a la que se pone fin ejerciendo la acción de partición.
6. El heredero sucede en todo el patrimonio transmisible del causante o en una cuota de él, tanto en su activo como en su pasivo.
7. Los herederos representan a la persona del causante.
Consecuencias de lo anterior:
 - i. Existe cosa juzgada respecto de los herederos, en juicio seguido contra o por el causante. (Existencia de la identidad legal que exige la ley: no la física).
 - ii. Los herederos no podrán alegar la nulidad absoluta si el causante carecía del derecho para hacerlo. 1683 (sabiendo o debiendo saber). No todos están de acuerdo con dicha interpretación, principalmente por el carácter personalísimo del dolo. En todo caso, cuando se trate de burlar a los herederos, por un acto en que el causante supo o debió saber, jamás se les negará la acción.

- iii. En contra de los herederos del deudor hipotecario procede la acción personal y no la de desposeimiento. No son terceros poseedores.

Clasificaciones de los herederos:

I) Universales, de cuota o de remanente.

- A. Universales:** son llamados a la herencia sin determinárseles la cuota que les corresponderá en ella;
- B. De cuota:** se les asigna una porción determinada de la herencia.
- C. De remanente:** van a ser herederos ya universales, ya de cuota.

II) Según si son nombrados por la ley o por el testador:

- A. Herederos testamentarios:** nombrados por el testador.
- B. Herederos abintestato:** nombrados por la ley.

III) Según si son o no elegidos libremente por el testador.

- A. Herederos Voluntarios:** libremente elegidos.
- B. Herederos forzosos:** son los legitimarios.

❖ HEREDEROS UNIVERSALES

1098: Se caracterizan por ser llamados sin designación alguna de cuota. Aunque pareciera que el heredero universal, por su nombre, hereda todos los bienes, es posible y muy común, que existan 2 o más herederos universales, ya que la característica única es que son llamados sin designación de cuota. No es lo mismo asignatario universal que heredero universal, ya que el 1º es el género. Todo heredero universal es asignatario a título universal, pero hay asignatarios a título universal que no son herederos universales, sino de cuotas.

Parte que les corresponde en la herencia a los herederos universales. Si son varios los herederos universales, se dividen entre sí por partes iguales la herencia o la parte que en ella les corresponda. La ley se pone en el caso de que el testador deje herederos de cuota y universales conjuntamente.

❖ HEREDEROS DE CUOTA

Son aquellos que son llamados a una cuota determinada de la herencia. Se caracterizan porque se les determina su cuota en el llamamiento que hace el testador.

Para determinar si nos encontramos frente a un heredero universal o de cuota, no debemos atender al beneficio que en definitiva se llevará en la sucesión, sino a la forma en que son llamados a la herencia.

Importancia de distinguir entre herederos universales y de cuota.

Sólo entre los herederos universales opera el **derecho de acrecimiento**, no así respecto de los de cuota. Si sólo se deja a herederos de cuota y llega a faltar uno, su cuota beneficia a los herederos abintestato.

Razón: el testador manifestó claramente su voluntad, limitando la parte que debía llevar cada heredero de cuota.

Síntesis de los herederos de cuota y universales.

1. Para clasificarlos, hay que atender a la forma del llamamiento y no al beneficio que en definitiva lleve en la herencia;
2. El estatuto jurídico que los rige es igual;
3. La única excepción es que el derecho de acrecimiento sólo opera respecto de los herederos universales.

❖ HEREDEROS DEL REMANENTE

No es una especie aparte, porque en el fondo pertenecen a una u otra categoría.

Es aquel que es llamado por el testador o la ley a lo que queda después de efectuadas las disposiciones testamentarias.

Su principal característica es que llevan lo que resta en la herencia.

Clasificación.

Pueden ser testamentarios o abintestato, según si son llamados a lo que queda de la herencia por la ley o por el testador. Además se clasifican en herederos del remanente de cuotas o universales (el testador sólo instituye legados en el testamento).

1. Herederos del remanente testamentarios universales. El testador sólo instituyó legados y dispone también en el testamento del remanente de sus bienes. "Mi casa a X, mi auto a Y, y el resto para Z".
2. Herederos del remanente testamentarios de cuota. El testador instituye asignaciones de cuota a título universal y asignatarios del remanente. "Dejo 1/3 de mis bienes a Pedro, y el resto de mi patrimonio a Juan".
3. Herederos del remanente abintestato universales. En el testamento sólo hay asignaciones a título singular y el testador nada dice respecto del resto de sus bienes. 1100.
4. Herederos del remanente abintestato de cuota. En el testamento sólo se designan herederos de cuota, y las designadas no alcanzan para completar la unidad.

Caso en que el testador efectúe asignaciones de cuota en el testamento que completen o excedan la unidad, y designe otros herederos. Es necesario distinguir si los herederos son del remanente o si son universales. Si son del remanente, en virtud del 1101, nada llevarán en la herencia. Pero si el heredero es universal no queda excluido. Ej. Dejo 1/2 de mis bienes a A, 1/3 a B, y 1/4 a C, designando heredero universal a D.

¿Por qué la diferencia? Al instituir heredero universal a D, se manifiesta la intención de dejarle algo en la herencia.

La solución está en los artículos 1001 y 1002:

- El heredero universal se entiende instituido en una cuota cuyo numerador es la unidad (o sea, 1) y el denominador es el número total de herederos, incluyendo al universal. Así, a D le corresponde $\frac{1}{4}$ de la herencia. Pero si sumamos este $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$, resulta que las asignaciones se exceden en $\frac{1}{3}$ del 100%. Será necesario hacer desaparecer ese tercio de exceso, mediante una disminución proporcional de las cuotas de cada cual.

Se reducen las fracciones a un mínimo común denominador: 12 en el ejemplo. Con ello, nos resulta de la suma un total de $\frac{16}{12}$. Luego, el numerador (16), pasa a ser el denominador común y se mantienen los anteriores numeradores: así A recibirá $\frac{6}{16}$; B $\frac{4}{16}$; C $\frac{3}{16}$; y D $\frac{3}{16}$.

Lo anteriormente dicho se entiende sin perjuicio del ejercicio de la acción de reforma, cuando proceda. 1103.

- **Herederos forzosos:** legitimarios, es decir, herederos cuyos derechos hereditarios el testador está obligado a respetar, y que se suplen por el legislador aún con perjuicio de las disposiciones testamentarias expresas.

- **Herederos voluntarios:** aquellos que el testador es soberano de instituir o no, pudiendo elegirlos a su arbitrio.

No es lo mismo ser heredero forzoso que heredero abintestato. El término heredero abintestato es más amplio, porque quedan incluidas personas que no son herederos forzosos. Por ejemplo, el Fisco es heredero abintestato, pero no es heredero forzoso.

ASIGNACIONES A TÍTULO SINGULAR O LEGADOS

La asignación es a título singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo.

La asignación se llama legado y el asignatario, legatario.

Características del legatario y los legados.

1. Los legatarios no representan al causante. 1104.
2. Los legatarios suceden en bienes determinados.
3. Los legados constituyen siempre asignaciones testamentarias.

No hay legatarios abintestato. Como consecuencia de ello, a favor de los legatarios no opera el derecho de representación.

4. Los legados pueden adquirirse por transmisión. 957. Pueden adquirirse por transmisión una herencia o legado, pero un legatario no puede adquirir por transmisión, pues el fundamento de este derecho es que se adquiere la universalidad de la herencia en la cual va comprendida la facultad de aceptar o repudiar la asignación respecto de la cual el transmitente no se alcanzó a pronunciar.

La posesión en los legados.

No existe posesión legal ni efectiva de los legados, sino sólo la del artículo 700. El problema de la posesión de los legados, sólo se limita a la posesión de los legados de especie o cuerpo cierto y no en los de género, ya que éstos se adquieren solamente desde que los herederos los cumplen.

En los legados de especie o cuerpo cierto no existe posesión legal, porque los artículos 688 y 722 que la establecen, la refieren sólo a la herencia. Eso es justificable porque los herederos son los continuadores y representantes de la persona del causante. El legatario, no representa al testador.

No hay posesión efectiva, porque la ley en todos los preceptos la refiere sólo a la herencia. Busca determinar frente a los terceros quiénes son los herederos y representantes de la sucesión.

Por tanto, sólo existirá la posesión del 700, cuando concurren corpus y animus.

En los legados de inmueble no es necesaria la inscripción especial de herencia. El legado de inmueble no tiene por qué inscribirse en el CBR a nombre de los herederos, porque él no forma parte de la indivisión hereditaria, siendo adquirido por el solo fallecimiento del causante. Muerto el causante, sale inmediatamente de la universalidad de la herencia.

A fin de mantener la historia de la propiedad raíz, el inmueble deberá inscribirse en el CBR, debiendo realizarse la inscripción directamente a nombre de los legatarios. En la práctica los herederos o el albacea con tenencia de bienes suscriben una escritura de entrega del legado, y con esta escritura se realiza directamente la inscripción a nombre del legatario.

La inscripción no puede considerarse tradición, ya que el legatario adquirió por sucesión por causa de muerte. La jurisprudencia ha sostenido que el legatario no puede entrar en posesión del legado, sin que se le efectúe la entrega, y que tratándose de bienes inmuebles se realiza por la inscripción en el CBR.

El profesor Fernando Mujica ha dicho que ni siquiera es necesaria esta inscripción del legado, porque esto se cumple con la inscripción del testamento y del auto de posesión efectiva.

Clasificación de los legados.

- Legado de especie o cuerpo cierto: la determinación de la cosa legada es máxima.
- Legado de género: la determinación es meramente genérica y en cantidad.

Legado de especie. Es adquirido por el legatario, por el solo fallecimiento del causante (si es de inmueble, no se requiere de inscripción para adquirirlo: sólo se efectúa como medio de mantención de la historia de la propiedad).

1118: el legado de especie se debe en el estado en que existiese a la muerte del testador, comprendiendo los utensilios necesarios para su uso y existentes con él.

El hecho de que el legatario se haga dueño del legado al fallecimiento, trae distintas consecuencias:

- a. Si los herederos se niegan a efectuar la entrega, el legatario puede reclamar la cosa por medio de la **acción reivindicatoria**, siendo propietario desprovisto de posesión.
- b. El derecho del legatario se extingue cuando prescribe su acción reivindicatoria, es decir, cuando el heredero o un tercero adquieran el legado por prescripción adquisitiva.
- c. El legatario de especie o cuerpo cierto se hace dueño de los frutos desde el fallecimiento del causante. 1338.

Legado de género. Por el fallecimiento, no adquiere el asignatario ningún derecho real. Sólo se hace dueño de un derecho personal, para exigir a los herederos o a las personas a quienes se ha impuesto la obligación de pagar el legado, la entrega de éste y el cumplimiento de dicha obligación.

El dominio no se adquiere por sucesión por causa de muerte, sino por tradición. Por ello, la Corte Suprema ha estimado que el asignatario que vende su asignación no está haciendo otra cosa distinta que ceder su crédito, razón por la cual debe cumplir con los requisitos de ésta: entrega de título y notificación o aceptación del deudor (herederos).

En cuanto a los frutos, éstos se deberán desde que los herederos obligados se hayan constituido en mora de entregar. Si el testador ha fijado plazo, no se aplica en 1551 No. 1, ya que éste exige “estipulación” y en el caso habría sólo una declaración unilateral del testador, razón por la cual se requerirá de interpelación judicial.

Cosas susceptibles de legarse. Existe amplia libertad, pudiendo legarse:

- cosas corporales e incorporeales. 1127.
- Cosas muebles e inmuebles (incluso cosa ajena o cuota de un bien).
- Cosa futura con tal que llegue a existir.

No se pueden legar las cosas inmercantiles (1105). Tampoco se pueden legar las cosas que forman parte de un edificio, de manera que no puedan separarse sin deteriorarlo.

Determinación de las cosas que se entienden legadas cuando el testador no lo hace expresamente (1111, 1112 y 1114 a 1117).

1. Caso en que se legue una especie indicando el lugar en el cual se halla guardada. Si no está en dicho lugar, de todos modos debe entregarse. Si no se encuentra en ninguna parte, sólo debe cumplirse cuando haya sido hecho a favor de un ascendiente o descendiente o a su cónyuge. Se cumplirá entregando una especie de mediana calidad del mismo género. En los otros casos, queda sin efecto.
2. Legado de cosa fungible. Es necesario, para que sean válidos, que su cantidad se determine de algún modo.
 - a. Se indica el lugar en que se encuentran las cosas legadas: se debe la cantidad que exista en ese lugar;
 - b. Se indica el lugar y la cantidad:
 - En el lugar existe una cantidad mayor: sólo se debe lo indicado por el testador;
 - En el lugar existe una cantidad menor: sólo se debe la que existe en el lugar.
 - Si nada existe en el lugar, nada se debe, salvo en 2 excepciones:
 - i. Si el legado es a favor de sus ascendientes, cónyuge o descendientes; o
 - ii. Si la cantidad y el lugar no forman una cláusula indivisible.
3. Legado de una especie entre muchas que existen en el patrimonio del testador. Se deberá una especie de calidad mediana o mediano valor entre las comprendidas en el legado. Si se trata de un género, se sigue la misma norma. Si se cree tener muchas cosas de un género y sólo se tiene 1, se debe esa. Si no se tiene ninguna, por regla general no vale el legado, salvo que sea a favor de los mencionados.

Determinación de las cosas que van comprendidas en el legado. 1119 a 1123 (ver normas).

Legado de una misma cosa a varias personas.

1124: se formará una comunidad, pudiendo cualquiera de los comuneros solicitar la partición.

Legado de cuota.

Art. 1110. Si el testador no ha tenido en la cosa legada más que una parte, cuota o derecho, se presumirá que no ha querido legar más que esa parte, cuota o derecho.

Lo mismo se aplica a la cosa que un asignatario es obligado a dar y en que sólo tiene una parte, cuota o derecho.

Art. 1743 es una excepción a esta norma y se explica, porque si no hubiera existido, sólo se legaría la cuota en el inmueble.

Legados de especies o cuerpos ciertos gravados con prenda o hipoteca.

- El legatario deberá pagar la deuda al acreedor prendario o hipotecario. 1125. Sin embargo, hay que realizar una distinción:

a. El testador manifestó su voluntad en el sentido de gravar al legatario con la prenda o hipoteca: deberá soportar el pago, sin derecho a repetición. 1104; 1135 (gravamen tácito: el testador, después de efectuado el legado constituye sobre el bien legado una prenda o una hipoteca).

b. El testador no manifiesta, ni expresa ni tácitamente, la voluntad de gravar: es necesario distinguir: (en todo caso el pago definitivo del gravamen o lo soporta el legatario)

i. El gravamen se constituye para garantizar una deuda del causante: el legatario es subrogado por la ley en la acción del acreedor contra los herederos. 1366.

ii. El gravamen no garantizaba una deuda del causante sino de un tercero: el legatario no tendrá acción en contra de los herederos. 2429: el tercer poseedor de la finca hipotecada (legatario en este caso) que paga la deuda, se subroga en los derechos del acreedor en contra del deudor. Se le niega la acción contra los herederos, pero nada lo priva de dirigirse contra el deudor personal.

Legados con cláusula de no enajenar.

Art. 1126. Si se lega una cosa con calidad de no enajenarla, y la enajenación no comprometiére ningún derecho de tercero, la cláusula de no enajenar se tendrá por no escrita.

Legado de cosa ajena.

Legado de un bien que no pertenecía al testador o al asignatario a quien se impone la obligación de pagarlo.

Por regla general, el legado de cosa ajena es nulo, salvo las siguientes excepciones:

1. El legado de cosa ajena **vale si aparece en el testamento que el testador tuvo conocimiento de estar legando una cosa ajena;** y
2. Es igualmente válido si es a favor de un ascendiente o descendiente legítimo o cónyuge.

En estos casos, se entiende que se impone a los herederos o al asignatario gravado la obligación de adquirir la cosa legada. Si el propietario se negare a enajenarla o pidiera un precio excesivo, el legado se cumplirá por equivalencia: se entregará al legatario el justo valor de la cosa legada.

Art. 1109. El asignatario obligado a prestar el legado de cosa ajena, que después de la muerte del testador la adquiere, la deberá al legatario; el cual, sin embargo, no podrá reclamarla, sino restituyendo lo que hubiere recibido por ella, según el artículo 1106.

Art. 1108. Si la cosa ajena legada pasó, antes de la muerte del testador, al dominio de éste o del asignatario a quien se había impuesto la obligación de darla, se deberá el legado.

3. Asignaciones a título singular de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. Este legado siempre se cumple. Se considera de cosa ajena, pues al instituirse, la especie legada pertenecía a la sociedad conyugal y no al cónyuge causante.

Legado de crédito.

1127-2º: Por el hecho de legarse el título de un crédito, se entenderá que se lega el crédito.

El legislador no señaló en qué situación queda el deudor del crédito: a quién debe pagar. Somarriva considera que podría pagar al legatario o a los herederos, pero si se notifica al deudor de la existencia del legado, se deben aplicar analógicamente las normas de la cesión de créditos y concluir que el deudor tiene que pagar al legatario. No es que exista tradición, porque ya operó la sucesión por causa de muerte. Sólo se aplican las normas por analogía.

Tiene una forma especial de extinción: se entiende revocado tácitamente en caso de que el testador con posterioridad al testamento reciba pago del crédito y sus intereses de parte del deudor. Si el pago es parcial, subsiste el legado en la parte no cancelada del crédito.

Legado de condonación.

El testador dice en su testamento que perdona o remite su obligación al deudor.

Art. 1129. Si el testador condona en el testamento una deuda, y después demanda judicialmente al deudor, o acepta el pago que se le ofrece, no podrá el deudor aprovecharse de la condonación; pero si se pagó sin noticia o consentimiento del testador, podrá el legatario reclamar lo pagado.

Art. 1130. Si se condona a una persona lo que debe, sin determinar suma, no se comprenderán en la condonación sino las deudas existentes a la fecha del testamento.

Legado de cosa empeñada hecho al deudor.

El deudor, para garantizar el cumplimiento de una obligación contraída con el testador, le haya dado una garantía prendaria.

Art. 1128. Si la cosa que fue empeñada al testador, se lega al deudor, no se extingue por eso la deuda, sino el derecho de prenda; a menos que aparezca claramente que la voluntad del testador fue extinguir la deuda.

Legado de confesión de deuda. 1133 (en el mismo sentido 1062).

- No hay principio de prueba por escrito: existencia de legado gratuito: aplicación de las normas de los legados;

- Hay principio de prueba por escrito: hay una deuda confesada en el testamento.

Para el presunto acreedor es de vital importancia determinar si la confesión de deuda será propiamente tal o será un legado, por las siguientes razones:

1. Si existe un principio de prueba por escrito, la confesión será una deuda hereditaria, constituyendo una baja general de la herencia (959), pagándose antes de efectuarse la distribución de los bienes hereditarios. Sin principio de prueba, se pagará con cargo a lo que el testador pudo libremente disponer.
2. Las deudas hereditarias no están sujetas al pago del impuesto de herencia, donaciones y asignaciones. Si es un legado, estará gravado.

El principio de prueba exigido es lógico, porque permite que el testador no burle las asignaciones forzosas.

Art. 1132. Si el testador manda pagar lo que cree deber y no debe, la disposición se tendrá por no escrita.

Si en razón de una deuda determinada se manda pagar más de lo que ella importa, no se deberá el exceso a menos que aparezca la intención de donarlo.

Legado hecho al acreedor.

Lo que se lega aun acreedor del testador no se entiende que sea a cuenta de la deuda, a menos que así se exprese o aparezca la intención del testador de pagar la obligación con el legado.

Art. 1131. Lo que se lega a un acreedor no se entenderá que es a cuenta de su crédito, si no se expresa, o si por las circunstancias no apareciere claramente que la intención del testador es pagar la deuda con el legado.

Si así se expresare o apareciere, se deberá reconocer la deuda en los términos que lo haya hecho el testador, o en que se justifique haberse contraído la obligación; y el acreedor podrá a su arbitrio exigir el pago en los términos a que estaba obligado el deudor o en los que expresa el testamento.

Legado de pensiones alimenticias (voluntarias)

Art. 1134. Si se legaren alimentos voluntarios sin determinar su forma y cuantía, se deberán en la forma y cuantía en que el testador acostumbraba suministrarlos a la misma persona; y a falta de esta determinación, se regularán tomando en consideración la necesidad del legatario, sus relaciones con el testador, y las fuerzas del patrimonio en la parte de que el testador ha podido disponer libremente.

Si el testador no fija el tiempo que haya de durar la contribución de alimentos, se entenderá que debe durar por toda la vida del legatario.

Si se legare una pensión anual para la educación del legatario, durará hasta que cumpla dieciocho años, y cesará si muere antes de cumplir esa edad.

Extinción de los legados. Las asignaciones a título singular y, en especial, las de especie o cuerpo cierto, se extinguen de las siguientes maneras:

- i. Revocación del testamento en que se instituye el legado. (1135 inciso 2º: revocación tácita, esto es cuando se ha enajenado la especie legada en vida del testador.).
- ii. Alteración sustancial de la cosa legada mueble.
- iii. Destrucción de la cosa legada.
- iv. Formas especiales de extinción: el de crédito cuando el testador recibe pago de la deuda; y el de condonación si se acepta o demanda el pago de la obligación.

Parte de la herencia con cargo a la cual se pagan los legados. Los legados se pagan de la parte en que el testador ha podido disponer libremente:

1. Si no dejó herederos forzosos, legitimarios, puede disponer del 100%;
2. En caso contrario, sólo puede disponer del 25%.

DE LAS DONACIONES REVOCABLES.

Las donaciones pueden ser revocables o irrevocables.

- Las donaciones revocables o donaciones por causa de muerte son aquellas que pueden revocarse al arbitrio del donante.
- Las donaciones irrevocables o donaciones entre vivos son aquellas que no pueden ser dejadas sin efecto por la sola voluntad del donante.

La donación irrevocable es un **contrato**. ¿Por qué está regulado en el libro III y no el IV?:

1. Razón histórica: CC francés;
2. La donación constituye, al igual que la sucesión por causa de muerte, un título gratuito.

La donación revocable, en cambio, constituye en el fondo un verdadero testamento y por ello se trata en las asignaciones testamentarias. Este tipo de donaciones carece de aplicación práctica, porque si una persona quiere favorecer gratuitamente a otra puede otorgar un testamento en su favor o efectuarle una donación irrevocable, y no tiene para qué recurrir a la donación revocable, que se sujeta a las formalidades del testamento o de la donación entre vivos.

Donación revocable: acto jurídico unilateral por el cual una persona da o promete dar a otra una cosa o un derecho para después de su muerte, conservando la facultad de revocarlo mientras viva.

Requisitos de las donaciones revocables.

- A) Externos o solemnidades:** conforme al 1137, las donaciones revocables pueden otorgarse de dos formas: con las solemnidades del testamento o de las donaciones entre vivos.
- a. Conforme a las solemnidades del testamento: se justifica ello, porque se trata de una disposición de la última voluntad del testador. (1139 y 1000).
 - b. Conforme a las solemnidades de las donaciones entre vivos: el donante se reserva en el instrumento la facultad de revocar la donación efectuada. En principio, se dice que son consensuales, pero tiene tantas excepciones que en la práctica casi todas las donaciones entre vivos son solemnes. 1137 final: las donaciones de que no se otorgare instrumento alguno, valdrán como donaciones entre vivos en lo que fuere de derecho.

La forma en que se otorguen las donaciones revocables tiene importancia para los efectos de su **confirmación**:

- Si se otorgan sujetándose a las formalidades del testamento, la donación queda confirmada por el fallecimiento del causante ipso jure siempre que éste no haya revocado en vida la donación.
- Si se hace conforme a las reglas de la donación entre vivos y reservándose el donante la facultad de revocarla, para que quede firme **es necesario que el causante en su testamento confirme expresamente la donación que hizo en vida**.

Donación entre cónyuges.

Varios preceptos le niegan el valor a las donaciones irrevocables entre cónyuges. 1137, 1138, 1000. De estos preceptos se infiere que **los cónyuges no pueden pactar donaciones irrevocables**. La ley en ninguna parte señaló si es que son válidos los contratos entre cónyuges. La doctrina concluye que los cónyuges pueden celebrar todo tipo de contratos, salvo aquellos expresamente prohibidos, entre los cuales figuran las donaciones irrevocables. Razones de la prohibición:

1. Peligro para terceros acreedores, sobre todos si los cónyuges están casados en sociedad conyugal;
2. Resguardo de los intereses de la mujer.

B) Internos: capacidad del donante y del donatario.

1138 inciso 1º: son nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos. Son nulas, asimismo, las entre personas que no pueden recibir asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos una de otra.

Este artículo se ha presentado para 2 interpretaciones:

- Mayoritaria: el donante debe tener una **doble capacidad**: para testar y para donar entre vivos; e igualmente el donatario debe tener una **doble capacidad**: para recibir asignaciones testamentarias y donaciones entre vivos.

- **Somarriva** señala que la interpretación anterior, puede ser discutida por dos razones:

1. Relacionándolo con el 1137, debe analizarse si se dona conforme a las normas del testamento o si se hace conforme a las donaciones irrevocables, para atender a los requisitos de las mismas (de uno o de otro, pero no exigir ambas).

2. Se emplea la conjunción disyuntiva "o".

La interpretación de Somarriva no es aceptada por la doctrina.

Efectos de las donaciones revocables.

1. Donación revocable a título singular. Esta donación constituye un legado.

1141: la donación revocable a título singular constituye un legado anticipado, y se sujeta a las reglas de las asignaciones a título singular. Si el testador da en vida al legatario el goce de la cosa legada, la asignación a título singular pasa a ser una donación revocable.

Este legado tiene una particularidad: el donante de la donación revocable a título singular puede haber entregado en vida la especie donada al donatario. En tal caso, se declara que por la donación revocable seguida de la tradición de las cosas donadas, adquiere el donatario los derechos y contrae las obligaciones de **usufructuario**. Es una especie de usufructo legal. Tiene igualmente, caracteres de tenedor fiduciario, ya que en este usufructo especial, se puede poner fin en cualquier momento por la revocación de la donación, terminando el usufructo. Cuando habla de "tradición" es tal si se entiende que se adquieren los derechos y obligaciones de usufructuario, mas no de las especies donadas, las que se adquirirán con la muerte del donante. Este usufructuario especial no está obligado a rendir caución, a menos que el donante así lo señale.

Las donaciones revocables a título singular y los legados en que el testador haya entregado la cosa en vida al donatario o legatario, constituyen **legados preferenciales**. 1141: prefieren en el pago a los legados que no se ha dado el goce a los legatarios en vida del testador.

2. Donación revocable a título universal. Esta donación constituye una herencia. Usufructo especial del donatario.

1142: se mirará como institución de heredero, que sólo tendrá efecto desde la muerte del donante. Sin embargo, si el donante de esta donación revocable a título universal entregó algunos bienes determinados al donatario universal en vida, el donatario tiene el carácter de usufructuario particularísimo respecto de los bienes.

Confirmación de la donación revocable.

- Las donaciones revocables otorgadas conforme a la forma de los testamentos, se confirman automáticamente y dan propiedad del objeto donado por el mero hecho de fallecer el causante sin haber revocado la donación, y siempre que no haya sobrevenido al donatario alguna causal de incapacidad o indignidad. 1144.
- Si la donación revocable se otorgó ciñéndose a las solemnidades de las donaciones entre vivos, debe confirmarse expresamente en el testamento (1137).

Extinción de las donaciones revocables. Causales:

1. Revocación expresa o tácita del donante. 1145.
2. Muerte del donatario antes de la del donante. 1143.
3. Por el hecho de sobrevenirle al donatario alguna causal de indignidad o incapacidad. 1144 a contrario sensu.

Las asignaciones forzosas priman sobre las donaciones revocables. 1146. Al poder menoscabar las asignaciones forzosas, se establecen mecanismos de protección de las mismas, en relación a las donaciones revocables: principalmente la formación de acervos imaginarios.

DERECHOS QUE CONCURREN EN UNA SUCESIÓN

1. Derecho de Transmisión:

Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. 957

2. Derecho de Representación:

Ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y, por consiguiente, el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder.

3. Derecho de Acrecimiento:

Aquel derecho en virtud del cual existiendo dos o más asignatarios llamados a un mismo objeto sin determinación de cuota, la parte del asignatario que falta se junta, se agrega, aumenta la de los otros asignatarios. 1147 y 1148.

Tiene lugar cuando falta un asignatario. Pero no siempre que falte un asignatario va a existir acrecimiento. La regla es la contraria: la ausencia del asignatario que falta beneficia a aquellas personas a quienes perjudicaba la asignación, o bien a los herederos abintestato.

Ej.- Pedro heredero de todos los bienes, Juan legatario de inmueble determinado. Falta Juan, acrece a Pedro, heredero universal a quien el legado perjudicaba.

- Testador deja 1/3 a cada uno de los 3 siguientes asignatarios: Juan, Pedro y Camila. Falta Camila. Acrecerá a los abintestatos, porque Juan y Pedro sólo son de cuota.

Pero existen casos en que faltando el asignatario se presenta el acrecimiento, es decir, la parte del asignatario que no concurre, se junta y aumenta la de los otros asignatarios testamentarios. Ej. Testador deja todos sus bienes a Pedro, Juan y Diego; Diego muere con anterioridad al causante: su porción acrece a

las de Pedro y Juan. Ello ocurrirá siempre que concurran los requisitos que más adelante analizaremos.

Requisitos para que opere el acrecimiento.

1- Que se trate de una sucesión testamentaria.

El acrecimiento no es sino una interpretación de la voluntad del testador. Además su ubicación en el CC así lo explica.

2- Que existan dos o más asignatarios.

Si hay sólo 1 y éste falta, su porción en la herencia no tendría a cuál asignatario acrecer. En tal caso, la sucesión será intestada, aplicándose dichas reglas.

3- Que los asignatarios sean llamados a un mismo objeto.

“Objeto”, se toma en el sentido de asignación. No uso dicha expresión para no caer en redundancias.

El acrecimiento opera tanto en los legados como en las herencias. “Dejo mis bienes a X, Y y Z”; “Dejo mi inmueble a X e Y”.

4- Que los asignatarios hayan sido llamados sin designación de cuota.

- “Dejo 1/3 de mis bienes a Pedro, 1/3 a Juan y otro a Diego”. Falta Diego. No hay acrecimiento, por interpretación de la voluntad del testador, pues éste limitó claramente en su testamento el beneficio que llevarían Pedro y Juan, sin que éste pueda ser ampliado.

- “Dejo la mitad de mi casa a Pedro y la otra a Juan”. Juan no puede suceder. La mitad de Juan no acrecerá a Pedro sino que va a los herederos, porque la voluntad del testador a favor de Pedro está limitada.

Existen 2 casos en el CC que suelen citarse como excepciones al principio de que el asignatario para acrecer no debe ser de cuota. Ambos están en el 1148. En el fondo, según Somarriva, no se trataría de excepciones.

a- Asignatarios llamados por partes iguales. No se justifica la diferencia, porque sólo emana de los términos que usa el testador. En vez de decir dejo mis bienes en 1/3 a Juan, 1/3 a Diego y 1/3 a Pedro, dijo Dejo mis bienes en partes iguales a Juan, Diego y Pedro.

b- Asignatarios llamados a una misma cuota, pero sin determinar la parte que van a llevar en la cuota. Dejo 1/3 a A, 1/3 a B, y el resto a C y a D. La ley dice que existe acrecimiento entre C y D, pues son llamados a un mismo objeto (1/3), sin designación de cuota. Si falta C, D llevará íntegramente 1/3. Si falta A o B o C juntamente a D, pasaran a los abintestato.

Se trata de excepciones aparentes, porque en ninguno de los 2 casos los asignatarios son llamados con designación de cuota.

Asignatarios conjuntos. La ley distingue 3 clases de conjunción:

a. Conjunción verbal o labial. Son llamados en una misma cláusula testamentaria, pero a distintos objetos, por lo que no cabe acrecimiento. En una misma cláusula testamentaria se dice: "Dejo mi casa X a Juan y la casa Y a Pedro".

b. Conjunción real. Dos o más asignatarios son llamados a un mismo objeto en distintas cláusulas del testamento. En la cláusula 1ª dice: Dejo la casa X a Pedro. En la cláusula 4ª dice: Dejo la casa X a Juan. Existe una conjunción real, operando el derecho de acrecimiento, porque han sido llamados a un mismo objeto, sin determinación de cuota.

Si se encuentran las asignaciones en dos testamentos distintos, se entiende revocado el anterior, salvo que el testador diga lo contrario.

c. Conjunción mixta. Es tanto verbal como real. Los asignatarios son llamados a un mismo objeto y en una misma cláusula testamentaria. Cláusula 4ª: Lego mi automóvil a Pedro y a Juan. Opera el acrecimiento.

Forma en que pueden ser llamados los asignatarios conjuntos.

1150: el llamamiento de asignatarios conjuntos puede efectuarse por la conjunción "y", o denominando a los asignatarios como una persona colectiva. "Dejos mis bienes a Pedro y Juan"; "Dejo mi inmueble a los hijos de X" (los hijos son asignatarios conjuntos).

5- Que falte algún asignatario.

Es necesario que al fallecimiento del causante falte alguno de los asignatarios conjuntos, pues si al tiempo de abrirse la sucesión existen todos los asignatarios, no opera este derecho.

El legislador no dijo cuándo se entendía faltar el asignatario. Ante ello, se aplica analógicamente el 1156: Falta el asignatario conjunto, cuando:

1. El asignatario conjunto fallece antes que el testador;
2. El asignatario conjunto sea incapaz o indigno de suceder;
3. El asignatario repudie la asignación; y
4. Siendo asignatario condicional, en el caso de la suspensiva, fallare.

Si el fallecimiento del asignatario conjunto es posterior al del causante, no opera el acrecimiento, sino que opera el derecho de transmisión. 1153: El derecho de transmisión excluye el derecho de acrecer.

Concurrencia del derecho de acrecimiento con el de representación. En principio, no debería existir conflicto, ya que el derecho de representación sólo opera en la sucesión intestada y el de acrecimiento sólo en la testada.

Pero el derecho de representación opera respecto de los legitimarios, porque ellos son representados y excluidos conforme a las reglas de la sucesión intestada. ¿Qué derecho prevalecerá en la mitad legitimaria?

Ej.- La mitad legitimaria de la herencia corresponde a Pedro, Juan y Diego. Diego fallece antes que su padre, dejando 2 hijos (nietos del causante). Muerto el testador, que pasa con la porción de Diego.

1190: si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad, indignidad o desheredamiento, o porque la ha repudiado, y no tiene descendencia con derecho a representarle, dicho todo o parte se agrega a la mitad legitimaria y contribuirá a formar las legítimas rigorosas de los otros.

Por ello, la porción de Diego la llevarán sus descendientes por derecho de representación.

Por ello, en la mitad legitimaria **el derecho de representación prevalece respecto del de acrecimiento.**

6- Que el testador no haya designado sustituto para el asignatario que falta.

Sí ha designado sustituto al asignatario que no concurre, jurídicamente no falta el asignatario conjunto, porque es reemplazado por el sustituto.

7- Que el testador no haya prohibido expresamente el acrecimiento. 1155. Se explica por el fundamento mismo del derecho de acrecer.

Características del acrecimiento.

1. Derecho accesorio. No puede el asignatario repudiar la propia asignación y aceptar la que se defiere por acrecimiento.
2. Derecho renunciable. Se puede aceptar la propia asignación y repudiar la deferida por acrecimiento.
3. Derecho transferible. Por la cesión de derechos hereditarios pasa al cesionario el derecho de acrecer que tenía el cedente, salvo estipulación en contrario.

1152 y 1068: La porción adquirida por acrecimiento lleva consigo todos los gravámenes propios de dicha porción, excepto aquellos que suponen una calidad o aptitud personal del asignatario que falta.

Efectos del acrecimiento.

- Efecto fundamental: la porción del asignatario que falta se junta, se agrega a las de los otros que así se aumentan.
- Los coasignatarios conjuntos se considerarán como una sola persona para concurrir con otros coasignatarios, y la persona colectiva formada por los dos primeros no se entenderá faltar, sino cuando todos éstos faltaren.

El acrecimiento en el usufructo.

Los coasignatarios de usufructo, uso, de habitación o de una pensión periódica, conservan el derecho de acrecer mientras gozan de dicho usufructo, uso, habitación o pensión, y ninguno de estos derechos se extingue hasta que falte el último asignatario. 1154 (780). El fallecimiento de uno de los usufructuarios no hace que esa parte pase al nudo propietario, sino que pasa a los demás

usufructuarios. (No es propiamente un acrecimiento, porque en este caso no falta el asignatario a la muerte del causante, sino después).

4. Derecho de Sustitución:

Supone que en el testamento se designe la persona que reemplazará al asignatario en caso de faltar éste, de modo que si esto ocurre por cualquier causa, pasará a ocupar su lugar el sustituto establecido por el testador.

Clases de sustitución: 1156

a. Vulgar: designar en el testamento la persona que va a reemplazar al asignatario en el caso de que éste falte por cualquier causa legal. (Dejo mi casa a X, y si éste no puede llevarla, corresponde a Y).

b. Fideicomisaria: aquella en que se llama a un fideicomisario que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona posea en propiedad fiduciaria. 1164. (Lego mi casa a X, la que pasará a Y si éste se recibe de abogado).

- Requisitos de la sustitución vulgar.

1. Que se trate de una sucesión testamentaria.

Se extrae dicha conclusión de la ubicación de su regulación y de la necesidad de una manifestación expresa del testador.

2. Que la sustitución sea expresa.

El sustituto debe estar designado expresamente en el testamento, sin que existan sustituciones tácitas, presuntas o legales. 1162: ni los descendientes del asignatario se entienden sustituir al asignatario, salvo que el testador expresamente los designe como tales. Por ello, nunca operará la sustitución en la sucesión intestada.

Formas de la sustitución: Directa o indirecta, es decir de diversos grados: 1º, 2º, etc. 1158 y 1159.

3. Que falte el asignatario que va a ser sustituido.

Art. 1156 enumera los casos en que se entiende faltar un asignatario para los efectos de la sustitución: repudiación y fallecimiento, dando además una regla general: cualquiera otra causa que extinga su derecho eventual (incapacidad, indignidad, el hecho de no ser persona cierta y determinada, el no cumplimiento de la condición suspensiva). Algunos afirman que se incluye el desheredamiento. Ello no es así, pues éste es propio de los legitimarios y, tratándose de éstos, si falta uno de ellos, no hay sustitución, sino representación, o si no la asignación pasa a pertenecer a los demás legitimarios (1190). Sólo a falta de todos los legitimarios personalmente o representados podría operar la sustitución en el caso del desheredamiento.

1157: el testador designa sustituto para el evento que faltara el asignatario por un determinado motivo. En tal caso, la sustitución se entenderá hecha para cualquier otro en que éste llegue a faltar, salvo si el testador manifiesta su voluntad expresa en contrario.

Si el asignatario fallece después que el testador, no hay lugar a la sustitución, pues opera el derecho de transmisión. La sustitución sólo tiene lugar cuando el fallecimiento sea anterior al del causante. 1163: El derecho de transmisión excluye al de sustitución. Igual cosa ocurre con el de acrecimiento (1153).

Concurrencia del derecho de representación con la sustitución. En principio no hay posibilidad de colisión entre la representación y la sustitución, pues la primera opera en la sucesión intestada, y la sustitución en la testamentaria. La dificultad sólo puede presentarse en la mitad legitimaria. En ésta debemos concluir que la representación excluye a la sustitución. Ej. Si el testador dispone que "dejo la mitad legitimaria a mis hijos Pedro y Juan, y si falta Pedro, instituyo heredero a mi hermano Diego". Dicha sustitución no tendrá efecto, porque si falta Pedro, entran a representarlo sus descendientes.

Sustitución fideicomisaria. El CC da algunas normas especiales:

- La sustitución fideicomisaria no se presume, de modo que en caso de duda, la sustitución debe entenderse vulgar. 1166.
- 1165: si para el caso de faltar el fideicomisario antes de cumplirse la condición, se le nombran uno o más sustitutos, estas sustituciones se entenderán vulgares. Ni el fideicomisario de primer grado, ni sustituto alguno llamado a ocupar su lugar, transmiten su expectativa si faltan. Este precepto patentiza la regla de que no se aceptan los fideicomisos sucesivos.

CÓMO CONCURREN LOS DERECHOS EN LA SUCESIÓN.

A. Cómo concurren el derecho de transmisión con el de acrecimiento y sustitución.

Puede presentarse problema entre el derecho de transmisión y el acrecimiento y la sustitución, ya que el primero se aplica en la sucesión testamentaria y en la abintestato, y los dos últimos se aplican en la testamentaria. Todos estos derechos tienen un sector común: la sucesión testada. En ella, pueden jugar los 3 derechos en un mismo momento. La ley soluciona los conflictos en los artículos 1153 y 1163:

- Transmisión excluye a la sustitución;
- Transmisión excluye al acrecimiento;
- Sustitución excluye a acrecimiento.

La transmisión excluye a ambos, porque el acrecimiento y la sustitución suponen que falte el asignatario con anterioridad al fallecimiento del causante. Si el asignatario fallece luego, ya no faltó, y si lo hace sin alcanzar a pronunciarse sobre la asignación, transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar.

La sustitución excluye al acrecimiento, porque jurídicamente si el testador designa un sustituto, ya no falta el asignatario, pues aquél pasa a ocupar su lugar.

El derecho de transmisión y el de representación no concurren entre sí. Si bien también tienen un campo de aplicación común: sucesión intestada, la

verdad es que no es posible su colisión. Para que opere el derecho de transmisión, es necesario que el asignatario fallezca luego del causante, sin alcanzar a pronunciarse sobre la asignación deferida, en cuyo caso transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar. En cambio, en el de representación, el fallecimiento del representado debe haberse producido antes que el del causante. Tampoco se produce cuando el asignatario falte por otro motivo, porque la transmisión sólo opera en caso de fallecimiento. 957.

Concurrencia de Representación con el acrecimiento y sustitución. En principio no puede haber conflicto, porque la representación opera en la sucesión intestada y los otros en la testamentaria. El problema sólo podría darse en la mitad legitimaria, en la cual también existe la representación, primando sobre el acrecimiento y la sustitución. La razón es que, en virtud de la ficción legal que constituye la representación, no faltaría el legitimario, pues sería representado por sus descendientes. No faltando, serían inaplicables los derechos de acrecimiento y sustitución.

LAS ASIGNACIONES FORZOSAS

Admitida la necesidad y legitimidad del derecho sucesorio, surge el problema consistente en determinar si la legislación debe reconocer el derecho absoluto del causante de disponer de sus bienes por causa de muerte en favor de quien desee, o si por el contrario la ley debe imponer que en caso de fallecimiento los bienes se radiquen, ya sea en todo o en parte, en determinadas categorías de parientes.

Dado que la manera que tiene una persona de disponer de los bienes por causa de muerte es mediante el otorgamiento de testamento, al problema descrito se le alude como el problema de la libertad de testar. Al respecto debe recordarse que se reconoce a todo individuo la facultad de otorgar testamento y si no lo hace es la ley, la que suponiendo y supliendo la voluntad del fallecido, dispone la suerte de su patrimonio.

Definir si se reconoce o no la libertad absoluta de disponer post mortem de los bienes es un aspecto de política legislativa en el cual se presentan como principios opuestos la libertad de testar y la sucesión familiar. En virtud del primero, debe reconocerse a todo individuo, como correlato de la libertad de disposición de que goza en virtud de actos entre vivos, la absoluta libertad para disponer de su hacienda post mortem. En aplicación del segundo, la facultad de disponer por causa de muerte se encuentra restringida, no pudiendo mediante el otorgamiento de testamento privar a sus parientes del derecho sobre los bienes del fallecido o al menos sobre parte de ellos.

En los países de derecho anglosajón la libertad de testar es casi absoluta y el causante puede disponer de sus bienes para después de su muerte en favor de quien le plazca. Por el contrario, en la generalidad de los demás países occidentales la libertad de testar es restringida y el causante sólo puede disponer libremente de parte de sus bienes pues, una parte está asignada por ley a determinadas categorías de parientes no pudiendo el causante por testamento privarlos de ella.

En lo que se refiere a nuestro país cabe consignar que Bello era partidario de la libertad de testar²⁸.

Las asignaciones forzosas: 1167 inciso 1º: son aquellas que el testador está obligado a hacer; y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas.

Las asignaciones forzosas constituyen una **limitación a la libertad de testar**. El testador está obligado a hacerlas y en caso contrario, se suplen aun contra de sus disposiciones expresas.

- Cuáles son las asignaciones forzosas.

1. Alimentos que se deben por ley a ciertas personas. Es decir, las asignaciones alimenticias forzosas;
2. Las legítimas; y
3. La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y del cónyuge.

- Evolución histórica de las asignaciones forzosas en nuestra legislación.

No obstante la posición de Andrés Bello, partidario de la libertad en materia testamentaria, se conservó en nuestro Código el concepto de las leyes españolas en

²⁸ Sustraído de Apunte de Derecho Sucesorio de Benjamín Jordán Ibarra.

orden a restringir la libertad de testar. En efecto, de conformidad con nuestro Código, todo ello según se verá en su oportunidad, hasta antes de la reforma introducida por la ley 19.585 existía libertad para disponer de los bienes por causa de muerte sólo respecto de la mitad si no se tenían descendientes, o bien de la cuarta parte si existía descendencia.

Con la reforma introducida por la ley referida, existiendo legitimarios, el causante sólo puede disponer a su arbitrio de la cuarta parte de la herencia, que por ello toma el nombre de cuarta de libre disposición. En las tres cuartas partes restantes, el patrimonio del causante pasa por voluntad de la ley, e incluso contra la voluntad expresada del testador, a determinados parientes que tienen la calidad de asignatarios forzosos.

En consecuencia, sólo el causante que carece de asignatarios forzosos es libre para disponer del total de sus bienes libremente.²²¹ Los únicos casos en que los asignatarios forzosos pueden ser privados de la asignación se producen cuando ellos incurren en determinadas conductas que la ley tipifica y de las cuales se desprende que carecen de mérito para ser beneficiarios de las mismas, pero obviamente dichas situaciones son de carácter excepcional²⁹.

- Las asignaciones forzosas se aplican tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada.

Del 1167 podría entenderse que las asignaciones forzosas sólo se aplican en la testada. Ello no es así. Las asignaciones forzosas operan en la intestada, y si el legislador se refirió sólo al caso del testamento, fue porque esa situación era la única en que podían ser desconocidas las asignaciones forzosas por parte del causante.

- Medios directos e indirectos con que el legislador protege las asignaciones forzosas. Las asignaciones forzosas son de orden público, debiendo ser respetadas por el testador en el testamento. El legislador otorga medios para que los asignatarios forzosos defiendan y amparen sus asignaciones forzosas. Estos medios de protección son de dos clases:

a) Medios indirectos:

- 1- Interdicción por demencia o disipación. Busca proteger tanto al demente o disipador, pero también a los asignatarios forzosos del mismo.
- 2- Insinuación en donaciones irrevocables. 1401: necesidad de sujetarse a autorización judicial, cuando la donación exceda de 2 centavos. Esta autorización se exige a fin de proteger las asignaciones forzosas. Sólo se autorizará cuando el patrimonio del donante es tan fuerte que la donación no perjudicará el derecho futuro de los asignatarios forzosos.
- 3- Limitación de las donaciones por causa de matrimonio entre esposos. 1788 establece que no pueden donarse entre sí efectos que superen la cuarta parte de los bienes que aporta al matrimonio el esposo donante. Ese máximo también rige para la disposición libre en el testamento si existen legitimarios.
- 4- Los acervos imaginarios. 1185 y 1187. Son la forma indirecta más eficaz con que el legislador ampara las asignaciones forzosas de los legitimarios. El 1º acervo los defiende de donaciones hechas a otros

²⁹ Sustraído de apunte de Derecho Sucesorio de Benjamín Jordan Ibarra.

herederos forzosos y el 2º los protege frente a donaciones efectuadas a extraños.

- 5- Prohibición de sujetar las legítimas a modalidades. Art. 1192. La legítima rigurosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno.
- 6- El Causante puede efectuar la partición. Se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno, es decir si afecta el derecho de los asignatarios forzosos dicho acto será ineficaz. Art. 1318 CC.
- 7- El testador puede establecer los bienes con los que se paga la legítima más no tasarlos. Así se evita que con una tasación excesiva de un bien pueda perjudicar al asignatario. Art. 1197

b) Medio directo:

A pesar del testamento, se llevan a cabo dichas asignaciones. Los asignatarios tienen derecho a pedir que se modifique el testamento en toda la parte que perjudica sus asignaciones forzosas. Este derecho se ejerce en virtud de la **acción de reforma de testamento** contemplada en el **artículo 1216**.

- Casos en que el testador no está obligado a respetar las asignaciones forzosas.

El respeto a las asignaciones forzosas cesa cuando la actitud del asignatario con el testador en vida de éste o lo hace acreedor que se le mantenga la asignación. En ciertos casos, el comportamiento poco digno del asignatario con el testador, lo puede hacer perder su asignación.

1. El legitimario puede ser **desheredado. Art. 1207.** Desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Es necesario que concorra causa legal para el desheredamiento. Están establecidas en el 1208 del CC. De tal forma el desheredamiento es una válvula de escape para el principio de la no libertad de testar.
2. Respecto del cónyuge sobreviviente: es indigno para suceder cuando concurre causa legal.
3. Además pierde su dignidad cuando ha dado lugar a la separación judicial por su culpa.
4. Los alimentos debidos por ley a ciertas personas, cesan en caso de injuria atroz (324).
5. No serán legitimarios los ascendientes del causante si la paternidad o la maternidad que constituye o de la que deriva su parentesco, ha sido determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padre o madre, salvo el caso del inciso final del artículo 203 CC. (Caso del restablecimiento)

- Las asignaciones forzosas y la LERL. Art. 18 LERL: las disposiciones testamentarias se rigen por la ley vigente a la época en que fallezca el testador. Prevalecerán sobre las leyes anteriores a su muerte las que reglan la

incapacidad o indignidad de los herederos o asignatarios, las legítimas, mejoras, porción conyugal y desheredaciones.

Por ello, las leyes que modifican las asignaciones forzosas rigen desde su publicación para todas las sucesiones abiertas con posterioridad a ellas.

ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS

Los alimentos que tienen su origen en el fallecimiento del causante, pueden ser voluntarios o forzosos. Los alimentos voluntarios, constituyen un legado (1134 y 1171), razón por la cual, se pagan imputándolo a la cuarta de libre disposición.

-Cómo se pagan las asignaciones alimenticias forzosas. Art. 1168. Los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas, gravan la masa hereditaria; menos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la sucesión.

La regla general, por tanto, será que los alimentos forzosos constituyan una baja general de la herencia. Pero, nada obsta a que el testador imponga a uno o más herederos la obligación de pagar esta asignación. De esto se deduce, que la obligación alimenticia en los alimentos forzosos es intransmisible, sin pasar a los herederos, porque constituye una baja general y la excepción está dada cuando el testador dispone lo contrario.

Cuando constituye una baja general de la herencia, para cumplirla, se separa de la sucesión un capital con cuyas rentas se pagarán dichas pensiones.

- La asignación alimenticia forzosa corresponde a alimentos que por ley debía el causante. "Alimentos que se debían por ley". 1167 y 1168. 4 situaciones pueden presentarse:

- a- Caso en que el causante fue condenado por sentencia ejecutoriada a pagar alimentos. Es evidente que se deben por ley estos alimentos.
- b- Caso en que el causante estaba pagando a la persona que por ley tenía derecho a exigirlos, en forma voluntaria los alimentos, sin condena a hacerlo. Son asignaciones forzosas, pues se debían por ley.
- c- Caso en que el causante fue demandado en vida judicialmente por la persona que tenía derecho a pedirle alimentos, pero la sentencia queda ejecutoriada sólo una vez fallecido el causante. La jurisprudencia ha declarado que nos hallamos ante un caso de asignación forzosa (efecto declarativo).
- d- Caso en que una persona teniendo un título legal para exigir alimentos del causante, no los recibía ni los había demandado. El problema es determinar si estas personas pueden demandar a los herederos por estas pensiones alimenticias, es decir, determinar si estos alimentos son o no una asignación forzosa. Hoy en día, la tendencia jurisprudencial es que se rechacen dichas demandas, dándole una interpretación más restringida al precepto, a fin de evitar problemas a los herederos (de interpretarlo de otra forma quedarían por mucho tiempo en la espera de la demanda de alimentos).

- Los alimentos forzosos no se ven afectados por las deudas de la herencia. Sin embargo, los alimentos futuros pueden rebajarse cuando parezcan desproporcionados a la fuerza del patrimonio del causante. 1170 y 1163.

Las asignaciones que consisten en cantidades periódicas destinadas a la alimentación de personas que el causante estaba obligado por ley a alimentar, están exentas del impuesto. El SII, si le parece que la pensión es excesiva, puede pedir a la justicia ordinaria que determine qué parte está exenta del impuesto.

LAS LEGÍTIMAS Y MEJORAS

1181: La **legítima** es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Son las más importantes asignaciones forzosas. Sin embargo, el concepto de asignatario forzoso, es más amplio que el de legitimario.

- **Los legitimarios son herederos.** 1181 inciso 2º. Son herederos forzosos.

- **Enumeración de los legitimarios. 1182:** Son legitimarios: (precepto taxativo³⁰):

a. **Los hijos personalmente o representados por su descendencia.**

En las legítimas opera el derecho de representación.

b. **Los ascendientes.**

No serán legitimarios los ascendientes del causante si la paternidad o la maternidad que constituye o de la que deriva su parentesco, ha sido determinada judicialmente contra la oposición del respectivo padreo madre, salvo el caso del inciso final del art. 203. En esta materia, el 1182 impone una sanción a los ascendientes de aquél cuya paternidad fue determinada judicialmente, haciendo extensiva la sanción a otras personas distintas. Estaríamos frente a consecuencias más estrictas de las que se derivan de las reglas de la sucesión intestada.

c. **El cónyuge sobreviviente.**

Se pone fin a la porción conyugal, introduciendo al cónyuge como legitimario.

a. *Caso del cónyuge separado judicialmente por su culpa.*

No es legitimario. 1182. Es el mismo principio que señala el 994. Esta causal no puede ser perdonada por el testador en el testamento, sino únicamente mediante la reconciliación. Si quiere dejarle bienes y no ha mediado reconciliación, sólo podrá hacerlo con cargo a la cuarta de libre disposición.

b. *Situación del matrimonio nulo.*

Si fue simplemente nulo, el matrimonio se entiende que jamás existió. La duda se plantea respecto del nulo putativo. El cónyuge en tal caso igualmente carece de legítima. Declarado nulo el matrimonio, deja de producir efectos, porque es imposible que perdure la buena fe.

"Caso de laboratorio": si el matrimonio se anula una vez fallecido el causante, por la causal de vínculo matrimonial no disuelto, en que el matrimonio nulo pueda ser putativo por estar el sobreviviente de buena fe al tiempo de fallecer el cónyuge causante. Se produce la curiosa situación de que 2 cónyuges concurrirán a la legítima debiendo dividirse por mitades.

c. *Situación del cónyuge divorciado con disolución de vínculo.*

El divorcio pone fin al matrimonio y sus efectos, por lo cual los cónyuges dejan de tener este estado, dejando de ser legitimarios. El causante sólo podría asignarle a costas de la cuarta de libre disposición.

³⁰ Recordar incluir al conviviente civil sobreviviente.

- **La legítima se distribuye de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada.** ¿Qué ocurre con la legítima cuando concurren varios legitimarios de los señalados anteriormente? 1183: los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada.

- **La legítima se distribuye entre los legitimarios y no concurren a ella los herederos abintestato.** 1183 señala que la legítima corresponde a los legitimarios según las normas de la sucesión intestada. Son nociones distintas herederos forzosos y herederos abintestato. Sólo los primeros concurren al pago de las legítimas. La mitad legitimaria no se divide entre todos los herederos abintestato, sino que los legitimarios la distribuyen entre sí de acuerdo a las normas de la sucesión intestada.

- **En el resto de la herencia, por regla general, no se aplican las reglas de la sucesión intestada. Excepciones.** Los legitimarios en la cuarta de mejoras o en la parte de libre disposición, no concurren conforme a las normas de la sucesión intestada. La cuarta de mejoras puede ser repartida como mejor le plazca al testador, siendo ella una manifestación expresa de su voluntad. Lo mismo ocurre en la parte de libre disposición.

Por lo anterior, cabe afirmar que el 1183, al afirmar que los legitimarios concurren conforme a las reglas de la intestada, sólo se estaría refiriendo a la mitad legitimaria., refiriéndose únicamente a la legítima rigorosa.

Si el testador no dispone de la cuarta de mejoras o de la parte de libre disposición, o su disposición no tiene efecto. En tal caso, nos encontramos frente a la **legítima efectiva** que establece el 1191, la que distribuirá entre los legitimarios, conforme a las normas de la intestada. En la parte que el testador no dispuso, concurrirán los demás abintestato, debiendo en todo caso enterarse las asignaciones forzosas a quienes rengan derecho a ellas.

- **Análisis de la forma en que se divide la legítima de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada.** Situaciones posibles.

a) Concurrer descendientes personalmente o representados: excluyen a ascendientes. Los descendientes se reparten la mitad legitimaria (o llevan la efectiva) por partes iguales.

Si concurre el cónyuge con ellos:

a. Recibe el doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponde a cada hijo;

b. Si existe un hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo; y

c. En ningún caso corresponderá al cónyuge menos de la cuarta parte de la mitad legitimaria o de la porción de la herencia que se está repartiendo como legítima.

b) Si no concurre descendencia del causante, la legítima rigorosa o efectiva corresponde al cónyuge sobreviviente y a los ascendientes de grado más próximo, según las siguientes reglas:

- a. Concorre cónyuge con ascendientes: la legítima rigurosa o efectiva corresponde en dos tercios al cónyuge y en uno para los ascendientes.
- b. Sin ascendientes, corresponde el 100% de la mitad legitimaria y el 100% de la efectiva, en su caso.
- c. Si no hay cónyuge sobreviviente, corresponderá la legítima rigurosa o la efectiva, al ascendiente de grado más próximo, y si hay varios, se divide por partes iguales.

CLASIFICACIÓN DE LAS LEGÍTIMAS

- 1. Legítima rigurosa:** aquella parte que le cabe al asignatario dentro de la mitad legitimaria.

- **Cómo se determina a cuánto asciende la mitad legitimaria:** 1184: es la mitad de los bienes del difunto deducidas previamente las bajas generales de la herencia, y efectuadas las agregaciones que ordena la ley.

- **La mitad legitimaria se divide por cabezas o estirpes.** Se sucede por cabezas cuando se hereda personalmente, en cuyo caso los asignatarios toman entre todos y por partes iguales la porción a la que los llama la ley. Se sucede por estirpes cuando se hereda por representación, dividiéndose por partes iguales entre los representantes la porción del representado. De tal manera, se dividirá la mitad legitimaria por cabezas cuando el legitimario concurre en ella personalmente, y la división será por estirpes cuando concurra en virtud del derecho de representación.

- **Forma de dividir el resto de la herencia: cuarta de mejoras y parte de libre disposición.** No habiendo descendientes con derecho a suceder, cónyuge sobreviviente, ni ascendientes, la mitad³¹ restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio.

Habiendo tales descendientes, cónyuge o ascendientes, la masa de bienes, previas las referidas deducciones y agregaciones, se dividirá en cuatro partes: dos de ellas, o sea la mitad del acervo, para las legítimas rigurosas; otra cuarta, para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge o a uno o más de sus descendientes o ascendientes, sean o no legitimarios, y otra cuarta, de que ha podido disponer a su arbitrio.

Características de las legítimas rigurosas.

1- Constituyen una asignación forzosa.

1167: las enumera dentro de las asignaciones forzosas; 1226: nulidad absoluta de la renuncia que hace un legitimario al que se le debe la legítima para que pueda testar sin considerarla.

2- No son susceptible de sujetarse a modalidades o gravámenes.

1192: la legítima rigurosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno. Pese a ser un acto patrimonial, no puede sujetarse a modalidades. **Excepción:** 86 No. 7 Ley General de Bancos: pueden dejarse

³¹ Debió decir el 100%.

con la condición de ser administrados por un Banco los bienes que constituyen la legítima rigorosa, durante la incapacidad del legitimario³².

3- El testador puede indicar los bienes con que se van a pagar las legítimas, pero no tasarlos.

1197: El que deba una legítima podrá en todo caso señalar las especies en que haya de hacerse su pago; pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna, ni tasar los valores de dichas especies.

a- Carácter personalísimo de la facultad de testar;

b- Imposibilidad de tasar a fin de que por este medio, no se burle la legítima³³.

4- Tienen preferencia absoluta para su pago.

Del acervo líquido se pagan antes que nada las legítimas. De los artículos 1189, 1193 y 1194 se infiere que si estas asignaciones no alcanzan a pagarse en la mitad legitimaria, el déficit se saca de los bienes restantes con preferencia a toda otra inversión. En el mismo sentido, el 996.

- Caso en que falta un legitimario sin descendencia con derecho para representarlo. 1190: dicho todo o parte se agrega a la mitad legitimaria, y contribuirá a formar las legítimas rigurosas de los otros. Su parte acrece a la de los restantes legitimarios. El acrecimiento se produce sólo dentro de la mitad legitimaria, beneficiando sólo a los demás legitimarios. Para que opere este acrecimiento deben concurrir 2 requisitos:

a. Debe faltar un legitimario: incapaz, indigno, repudió o fue desheredado. Al decir la ley que el legitimario no lleve *en parte* su legítima, se pone (1) en el caso del desheredamiento, siendo éste parcial. 1207. (2) Otro caso en que se pierde *en parte* la legítima, se da cuando un menor se casa sin el consentimiento del ascendiente llamado por ley a prestarlo. El descendiente pierde la mitad de sus derechos de todos sus ascendientes. La otra mitad se distribuye entre los legitimarios restantes. (3) Otro caso se produce en el 1182 inciso 2º: padres cuya paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente con su oposición y cónyuges divorciados por su culpa.

b. El legitimario que falta no debe dejar descendencia legítima con derecho a representarlo. La representación excluye al acrecimiento.

En el caso, la legítima así aumentada **no pasa a ser legítima efectiva**. Continúa siendo rigorosa, pues el acrecimiento se produce siempre dentro de la mitad legitimaria. Pasa a ser efectiva cuando el acrecimiento opera en la cuarta de mejoras o de libre disposición que no se dispuso o que no tuvo

³² Se puede estimar que la regla contenida en el art. 1337 nº 10 CC en los hechos puede constituir un gravamen para los legitimarios. Si es que la cuota que le corresponde al cónyuge o conviviente civil sobreviviente excede del valor de los bienes a los que tiene derecho que se le adjudiquen preferentemente pueden constituirse derechos reales sobre el mismo. En dicho caso la asignación en propiedad a un legitimario puede verse gravada. Ejemplo. Si existe un hijo y el cónyuge del causante y existe en la herencia sólo un bien raíz cuyo valor es de 10 millones, la cuota del cónyuge corresponde a la mitad. Se le otorgarán derechos de habitación al cónyuge respecto al inmueble y la cuota que le corresponde al hijo por legítima en los hechos se verá gravada.

³³ El 1318 permite al testador efectuar la partición de sus bienes. Sin poder tasar, es imposible efectuar la partición. Por ello, Somarriva indica que puede el testador tasar, según lo impone el 1318, siempre que dicha partición no resulte contraria a derecho.

efecto. El 1190 confirma lo anterior al señalar que el todo o parte de la mitad legitimaria del heredero forzoso que falta se agregará a la mitad legitimaria y contribuirá a formar las legítimas rigurosas de los otros.

2. Legítima efectiva: es la legítima rigurosa aumentada con la **parte de mejoras y la parte de libre disposición** de que el testador no dispuso o, si lo hizo, no tuvo efecto su disposición.
1191.

- **La legítima efectiva corresponde hoy en día a todos los legitimarios,** siendo el cónyuge un legitimario más.

- **Primacía de las reglas de la sucesión intestada.** 1191 inciso 3º: si concurren, como herederos, legitimarios con quienes no lo sean, sobre lo preceptuado en este artículo prevalecerán las reglas contenidas en el Título II de este Libro.

- **Síntesis de los principios que gobiernan las sucesiones parte testadas, parte intestadas.** Desde luego, en la parte testada se aplicará el testamento. En cuanto a la intestada, pueden presentarse las siguientes situaciones:

1. Concurren sólo herederos abintestato que no son legitimarios. La parte intestada se rige íntegramente por las reglas de la sucesión abintestato.

2. Concurren sólo legitimarios. Opera íntegramente el acrecimiento del 1191. La parte no testada, acrece a las legítimas rigurosas, que pasan a ser efectivas.

3. Nunca concurren legitimarios con quienes no lo son. En conformidad al inciso final del 1191, en la parte no testada se aplican las reglas de la intestada. Situaciones que pueden presentarse:

i- Existen descendientes: el único otro legitimario que puede concurrir es el cónyuge, pero no hay problemas, pues le beneficia el acrecimiento, formándose las legítimas efectivas.

ii- Concurren cónyuges y/o ascendientes. La parte de libre disposición que quedó intestada se distribuye de acuerdo a las reglas de esta forma de heredar (1/3 ascendientes y 2/3 cónyuge). Si concurre uno u otros solos, les corresponde el 100%.

iii- No concurren legitimarios. Se aplican las normas del 996.

Conclusión: es muy difícil imaginarse la concurrencia de los legitimarios con otros que no lo sean. El único caso de laboratorio sería el del adoptado según la ley 7.613 que no haya celebrado el pacto del 45 de la nueva ley de adopción.

LOS ACERVOS IMAGINARIOS

Es uno de los medios indirectos de proteger las legítimas. Son 2 acervos imaginarios:

- 1º acervo imaginario: defiende al legitimario en presencia de donaciones irrevocables hechas a otro legitimario.

- 2º acervo imaginario: amparar las legítimas en presencia de donaciones irrevocables hechas a extraños.

- **La denominación “acervos imaginarios” no es del todo exacta.** El 1º acervo imaginario contempla una institución denominada colación. El 2º acervo contempla la acción de inoficiosa donación. Las denominaciones de “1º y 2º acervo imaginario” se deben a Amunátegui.

- **COLACIÓN O PRIMER ACERVO IMAGINARIO**

La formación de este acervo tiene por objeto mantener la igualdad entre los legitimarios.

1185: *para computar las cuartas de que habla el artículo precedente, se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables o irrevocables hechas en razón de legítimas o mejoras, según el estado en que se hayan encontrado las cosas donadas al tiempo de la entrega, pero cuidando actualizar prudencialmente su valor a la época de la apertura de la sucesión.*

La acumulación no es imaginaria, sino real. Es como si el causante tuviera un crédito en contra de los legitimarios a quienes donó. Así, la **colación** es la devolución que hace un heredero que concurre con otros en la sucesión, a la masa partible, de las cosas con que el donante lo beneficiara en vida para compartirlas con sus coherederos como si nunca las hubiere tenido.

Requisitos para que proceda la colación.

1. Que al tiempo de abrirse la sucesión existan legitimarios.

Es obvio, ya que precisamente a ellos es que se está protegiendo.

2. Que el causante haya efectuado donaciones a uno o más de los legitimarios.

Se deben acumular:

a. Donaciones irrevocables hechas por el causante.

b. Donaciones revocables, siempre que las cosas donadas hayan sido entregadas al donatario en vida del causante.

Sin haber existido entrega en vida del donante, no hay necesidad de acumular estas donaciones, pues los bienes que comprende la donación están material, física y jurídicamente en el patrimonio del causante. Esto se concluye del mismo texto de la ley: “se acumulan según el estado de las cosas donadas al tiempo de la *entrega*, lo que hace interpretar que el legislador entiende que existió entrega. Esto no quiere decir que dichas donaciones no se consideren para pagar las legítimas. Como están en el patrimonio del causante, deben imputarse para dichos efectos.

La acumulación es distinta de la imputación. Se acumula algo que no está en el patrimonio, a fin de determinar el monto de lo que se repartirá. La imputación es la carga a lo que el legitimario debe recibir a título de legítima. Por RG se imputan las mismas cosas que la ley ordena acumular, pero no pueden confundirse. Se acumula lo que no está en el patrimonio. Así, para pagar la legítima se imputan las donaciones revocables, hayan sido entregadas o no las cosas donadas, pero no se acumulan las que no han sido entregadas.

Sólo se acumulan las donaciones hechas en razón de legítimas o mejoras. 1185. Las donaciones hechas por el causante con cargo a la cuarta de libre disposición, no se acumulan. Así lo falló la CA de Santiago, basada en la letra de la ley y en que la calidad de legitimario en nada juega en estas donaciones. Si se dan los presupuestos, procedería aplicar el segundo acervo imaginario porque es lo mismo que si el legitimario fuere un tercero extraño.

La acumulación de las donaciones irrevocables no aprovecha a la parte de libre disposición, pero beneficia a ésta la de las donaciones revocables.

- c. **Los desembolsos hechos por el causante para el pago de una deuda de un legitimario descendiente suyo; y**
- d. **Los legados, pero únicamente en el caso de que las cosas legadas hayan sido entregadas al legatario en vida del causante.**

Donaciones que no se acumulan para calcular el 1º acervo imaginario.

- 1. Regalos moderados que se hacen según la costumbre y uso: 1188.
- 2. Los presentes hechos a un descendiente con ocasión de su matrimonio: 1198.
- 3. Los gastos de educación de un descendiente, aunque el testador haya expresamente dispuesto que imputen a la legítima.

Acumulación de los desembolsos hechos por el causante para pagar deudas de un descendiente. 1203: los desembolsos hechos por el causante para el pago de las deudas de un legitimario que sea descendiente, se imputarán a su legítima, siempre que ellos hayan sido útiles (extinguen la deuda) para el pago de dichas deudas.

Los legados no se acumulan para calcular el 1º acervo imaginario. Los bienes legados están material y jurídicamente en el patrimonio dejado por el causante. Serán acumulados sólo cuando hayan sido entregados en vida del testador a los legatarios, porque en tal caso constituyen donaciones revocables (salieron del patrimonio del causante).

La acumulación se verifica según el estado de las cosas donadas al tiempo de la entrega. La ley 19.585 sustituyó la expresión "valor" por la expresión "estado" y agregó la frase "pero cuidando de actualizar prudencialmente su valor a la época de la apertura de la sucesión".

Ejemplo de formación de un 1º acervo imaginario. Fallece el testador y deja un acervo líquido de \$1000 y 5 hijos. Las bajas generales suman \$100. Al hijo 1 se le hizo una donación irrevocable de \$50 y al hijo 2 una donación revocable de \$50, que se le entregó en vida del causante.

Acervo líquido= (1000) – (100) Bajas Generales = (900) Acervo líquido + (50) Donación revocable + (50) Donación irrevocable= (1000) 1º acervo imaginario.

1º acervo imaginario= 1000, se divide en la forma señalada en el 1184:

Mitad legitimaria: 500

Cuarta de Mejoras: 250

Cuarta de Libre Disposición: 250

La cuarta libre disposición no podría beneficiarse con la donación irrevocable hecha al hijo 1, por no permitirlo el art. 1199. Debe descontarse la parte en que se están aprovechando de esta donación. Dos cuartos benefician a la mitad legitimaria y un cuarto a la cuarta de mejoras y de libre disposición respectivamente. Debe descontarse de la cuarta de libre disposición la cuarta parte de 50, es decir, 12,5. Estos 12,5 deben distribuirse entre la mitad legitimaria y la cuarta de mejoras en proporción de 2 a 1, ya que la mitad legitimaria es el doble de la cuarta de mejoras. Es decir, la mitad legitimaria llevará 8,33 y la cuarta de mejoras 4,17.

Mitad legitimaria: 508, 33

Cuarta de mejoras: 254, 17

Cuarta de libre disposición: 237, 5

Cada hijo llevaría 101, 66. Los hijos 3, 4 y 5 recibirán dicha suma. Los hijos 1 y 2 sólo recibirán 51, 66, lo que sumado a 50, completan su legítima.

Para quienes opinan que aún la acumulación de las donaciones irrevocables beneficia a la cuarta de libre disposición, la mitad legitimaria, ascendente a 500, se distribuye dándoles en efectivo a los hijos 3, 4 y 5 100 a cada uno, y 50 a los hijos 1 y 2, los cuales sumados a lo recibido como donaciones completan sus legítimas.

- EL SEGUNDO ACERVO IMAGINARIO

Art. 1186. Si el que tenía a la sazón legitimarios hubiere hecho donaciones entre vivos a extraños, y el valor de todas ellas juntas excediere a la cuarta parte de la suma formada por este valor y el del acervo imaginario, tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también imaginariamente al acervo, para la computación de las legítimas y mejoras.

Art. 1187. Si fuere tal el exceso que no sólo absorba la parte de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio, sino que menoscabe las legítimas rigurosas, o la cuarta de mejoras, tendrán derecho los legitimarios para la restitución de lo excesivamente donado, procediendo contra los donatarios, en un orden inverso al de las fechas de las donaciones, esto es, principiando por las más recientes.

La insolvencia de un donatario no gravará a los otros.

El 2º acervo imaginario procederá en presencia de donaciones irrevocables hechas a extraños. Su objeto es defender las legítimas.

Requisitos para que proceda la formación de este acervo.

Que al hacer el donante las donaciones existieran legitimarios.

"El que tenía a la sazón...": debe tener legitimarios al momento de hacer la donación irrevocable. Si luego llega a tenerlos, no procede la formación del 2º acervo imaginario, ya que cuando las hizo no perjudicaba a nadie.

Que al fallecimiento del causante existan legitimarios.

El 2º acervo imaginario se forma para computar las legítimas y mejoras. Si no concurren legitimarios, no existen estas asignaciones forzosas y no procede la formación del acervo imaginario. A este respecto se presenta el problema de determinar si deben ser unos mismos los legitimarios existentes al momento de hacerse las donaciones y los que concurren a la sucesión. Fabres estimaba que debían ser los mismos. El grueso de la doctrina en contrario.

Que el causante haya efectuado donaciones irrevocables a terceros.

Sólo procede en presencia de donaciones irrevocables, dado que el 1186 habla de donaciones entre vivos. Deben haber sido hechas a terceros, porque si se hacen a legitimarios, procede formar el 1º acervo.

Que estas donaciones resulten excesivas.

Cuando el valor de las donaciones exceda de la cuarta parte de la suma formada por las donaciones y el acervo. Se suma por tanto, acervo y donaciones, y la cantidad se divide por cuatro. Si la cantidad resultante es inferior al valor de las donaciones, quiere decir que son excesivas. Se debe entender que las donaciones se sumarán al acervo líquido o al primer acervo imaginario, cuando haya procedido su formación.

Situaciones que pueden derivarse del principio de que las donaciones deben ser excesivas.

1. Que las donaciones no son excesivas: no procede la formación del 2º acervo imaginario.

Se diferencia del 1º acervo imaginario, en el cual procede la acumulación en presencia de toda clase de donaciones.

2. Que las donaciones sean excesivas. Procede la formación del 2º acervo imaginario, y éste va a producir en definitiva el efecto de limitar la parte de libre disposición, es decir, disminuir ésta.

Acervo (líquido o 1º imaginario): 100

Donaciones irrevocables: 60

Total: $160/4 = 40$. Es la suma que legítimamente podía donar. Como donó 60, existe un exceso de 20 y procede formar el 2º acervo imaginario.

1186: el exceso se acumula imaginariamente al acervo para la computación de las legítimas y mejoras. O sea, el segundo acervo imaginario sería de 120.

Mitad legitimaria: 60

Cuarta de mejoras: 30

Cuarta de libre disposición: 30.

Sólo tenemos 100.

Las legítimas y mejoras, como asignaciones forzosas, se pagan íntegramente. Los 60 y los 30 deben cancelarse totalmente. Nos restarían

sólo 10, los cuales pasan a constituir la cuarta de libre disposición. 1º efecto: Se disminuye la cuarta de libre disposición de 30 a 10, limitando la facultad de testar, debido a que en vida ya dispuso de lo que podía asignar libremente por testamento.

Los legados deberán **reducirse** a la cantidad que en definitiva constituye la cuarta de libre disposición. Como no alcanzan a pagarse todos por la reducción, se cancelarán primero los que gozan de una **causal de preferencia** y luego los comunes, y si todos son de igual categoría, se rebajan a prorrata.

3. Que las donaciones sean de tal modo excesivas que lleguen a lesionar las legítimas y mejoras. No sólo procede en este caso la formación del 2º acervo imaginario, sino que nace además la **acción de inoficiosa donación**. 1187.

Acervo (líquido o imaginario): 120

Donaciones irrevocables: 220

Total: 340

Se divide esta cantidad por 4, lo que da como resultado \$85. Esto fue lo que pudo disponer el testador en su cuarta de libre disposición. El exceso es de 135. Se suma dicho exceso al acervo, para calcular el acervo imaginario: 120+135: 255.

El acervo imaginario es de 255.

Mitad legitimaria: 127,5

Cuarta de Mejoras: 63,75

Cuarta de Libre Disposición: 63,75

Sin embargo, sólo existen en efectivo 120. Para completar las asignaciones forzosas faltan 63,75 de las cuartas de mejoras y 7,50 de la mitad legitimaria; en total 71, 25.

Se produce el 2º efecto de este acervo imaginario: **nacimiento de la acción de inoficiosa donación**.

ACCIÓN DE INOFICIOSA DONACIÓN.

Esta acción la tienen los legitimarios y asignatarios de cuarta de mejoras en contra de los donatarios cuando el causante ha hecho en vida donaciones irrevocables excesivas que menoscaban las legítimas rigurosas o mejoras, y que se traduce en la rescisión de dichas donaciones.

Quiénes pueden ejercitar la acción: tanto los legitimarios como los beneficiarios de la cuarta de mejora y, en con contra de los donatarios en orden inverso al de las fechas de las donaciones, esto es, principiando por las más recientes. La acción busca dejar sin efecto las donaciones hasta completar el pago de las legítimas y mejoras. 1187 en relación al 1425.

No está clara la naturaleza jurídica de la acción. Para algunos se trata de una acción de nulidad derivada de la naturaleza rescisoria que le concede el art. 1425 CC. Se critica esta postura al estimar que la donación, al momento de ser

efectuada no incurre en ningún vicio de nulidad. De esta forma la acción tendría un carácter resolutorio, estando sujeta al evento futuro e incierto de no ser excesivas al momento de la muerte del donante.

Para Rodríguez Grez, sería más bien una acción de inoponibilidad, no se pretende dejar sin efecto la donación sino obtener la restitución del exceso donado por el *cujus*.

- Características de la acción de inoficiosa donación:

1. Es una acción personal, pues sólo puede intentarse en contra de los obligados: donatarios.
2. Es una acción patrimonial de los legitimarios o beneficiarios con la cuarta de mejoras para solicitar que queden sin efecto las donaciones efectuadas en menoscabo de sus legítimas o mejoras. Siendo patrimonial, es renunciable, transmisible y transferible (al heredero y a los cesionarios) y prescriptible.

No se señaló expresamente el plazo de prescripción, razón por la cual hay 2 soluciones que dependerán de la postura sobre la naturaleza jurídica de la acción: 1) 2515: prescribe en 5 años, si se estima que tiene una naturaleza resolutoria; 2) Como el 1425 califica esta acción de rescisoria, cabría aplicar la regla del 1691: 4 años.

- Efectos de la acción de inoficiosa donación:

No está claro el efecto específico de la acción. Se relaciona esto con la naturaleza jurídica que se estime tiene la institución. La discusión torna en determinar si hay derecho a exigir restitución *materia*, en especie donadas o un monto correspondiente al exceso de donación. El inciso final del art. 1187 permitiría apoyar esta postura.

- Insolvencia de un donatario.

El artículo 1187 inciso final señala que la insolvencia de un donatario no gravará a los otros. Significa que si el donatario demandado carece de medios para pagar el exceso de la donación, la obligación no pasa contra otros donatarios o contra aquellos a quienes el insolvente haya enajenado la cosa donada. Serán los asignatarios forzosos quienes tengan que soportar el riesgo de dicha insolvencia.

CÓMO SE PAGAN LAS LEGÍTIMAS EN LA SUCESIÓN DEL CAUSANTE.

Este problema está muy ligado con los acervos imaginarios, especialmente con el 1º. Al pagarse las legítimas es necesario distinguir si existían o no imputaciones que hacer a las legítimas. Si el legitimario no ha recibido donaciones ni asignaciones de ninguna especie, no hay nada que imputarle a su legítima y va a recibir entonces ésta en forma íntegra y en efectivo. En cambio, si ha recibido donaciones o asignaciones en el testamento, en este caso procede imputar a las legítimas la parte recibida.

- Cosas imputables a las legítimas.

A- Donaciones revocables e irrevocables hechas por el causante al legitimario.

1198 inciso 1º. En conformidad al 1185 deben imputarse según el estado que tuvieron al tiempo de su entrega, cuidando de actualizar prudencialmente su valor a la fecha de la apertura de la sucesión. Para el pago de las legítimas se imputan todas las donaciones revocables; para calcular el 1º acervo imaginario se acumulan sólo las que han sido entregadas en vida del causante.

B- Legados dejados por el causante al legitimario en el testamento.

1198 inciso 1º. La ley se refiere únicamente a los legados, asignaciones a título singular, pero nada dice respecto de las herencias o asignaciones a título universal. La jurisprudencia resolvió que no procede imputar a las legítimas las asignaciones a título universal, por el tenor literal del 1198. Sin embargo, y pese a lo claro del tenor literal Somarriva cree que deben igualmente imputarse las asignaciones a título universal.

C- Desembolsos hechos por el testador para el pago de las deudas de ciertos legitimarios.

1203. Los desembolsos hechos para el pago de las deudas de un legitimario, que sea descendiente, se imputarán a su legítima; pero sólo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas.

- Cosas que no deben imputarse para el pago de las legítimas.

Los legados, donaciones y desembolsos que el testador expresamente haya imputado a la cuarta de mejoras.

1198: no se imputarán a la legítima cuando en la respectiva escritura de donación en acto posterior auténtico o en el testamento aparezca que el legado o donación ha sido hecho a título de mejoras. Si el testador expresa la intención que el legado o donación se tenga como mejora, el legitimario recibirá íntegramente su legítima y el legado o donación se tendrá como mejora. En igual sentido el inciso 2º del 1203.

Los gastos de educación de un descendiente.

Dichos gastos no se tomarán en cuenta ni para la computación de las legítimas ni de las mejoras, ni de la parte de libre disposición, aun cuando el testador los haya efectuado con la calidad de imputables. Estos gastos de educación no se toman en cuenta para nada en la herencia.

Las donaciones por matrimonio y otras de costumbre. 1198 inciso final.

Los frutos de las cosas donadas.

1205. Pertenecen al donatario desde la entrega de ellas y, si las cosas no se han entregado al donatario, no le pertenecerán los frutos sino desde la muerte del donante, a menos que éste le haya donado irrevocablemente y de un modo auténtico no sólo la propiedad, sino el usufructo de las cosas donadas.

1. RG: los frutos de las cosas donadas no se imputan para el pago de la legítima si ellas han sido entregadas en vida del donante al donatario. Por la entrega de las cosas donadas, el donatario se hizo dueño de ellas y por tanto, a él le pertenecen los frutos, en razón al principio de la accesoriedad.

2. Si las cosas donadas no han sido entregadas al donatario, como no se ha hecho éste dueño de ellas, los frutos sólo le pertenecen desde la muerte del causante. Las cosas se acumulan e imputan por su estado al tiempo de la entrega.

3. En el caso de una donación revocable en que se haya donado no sólo la propiedad, sino el usufructo de las cosas donadas. En tal caso, los frutos pertenecen al donatario desde la fecha de la donación y no se le imputan a su legítima, a pesar de no haber existido entrega.

- No se imputan a las legítimas sino las donaciones o asignaciones hechas al legitimario, pero no las hechas a otros legitimarios. 1202: no se imputarán a la legítima de una persona las donaciones o las asignaciones testamentarias que el difunto haya hecho a otra, salvo el caso del 1200 inciso 3º: en el caso de que un legitimario a quien se le ha hecho donación o asignación llega a faltar por incapacidad, indignidad, desheredamiento o repudiación. Si el donatario ha llegado a faltar de cualquiera de esos modos, las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus descendientes. Es una aplicación del derecho de representación.

SITUACIONES QUE PUEDEN PLANTEARSE EN EL PAGO DE LAS LEGÍTIMAS.

1. Que las imputaciones calcen perfectamente en la legítima.

No hay problema, ya que lo que debe imputar a su legítima es inferior a lo que le corresponde por este concepto.

2. Que excedan la legítima e invadan la cuarta de mejoras y la de libre disposición.

Puede suceder que las imputaciones que deben hacerse a las legítimas excedan a lo que el legitimario le corresponde. 1189 y 1193 inciso 1º: este exceso se imputará al resto de la herencia. El exceso se saca con preferencia a toda inversión del resto de la herencia.

Ej. Causante fallece y deja 2 hijos: Pedro y Juan, con un acervo líquido de 70. El testador había donado revocablemente a Pedro 30, con lo que se forma un acervo imaginario de 100. A cada hijo le corresponde por mitad legitimaria 25, pero como Pedro recibió 30, conserva dicha cantidad, pagándose íntegramente su legítima con un exceso de 5. Juan recibe en efectivo 25. El exceso se imputa a mejoras, quedando reducida la cuarta de mejoras a 20. Estos 20 se dividen en la proporción correspondiente, quedando 10 para cada cual, salvo que el testador le haya dado otra distribución.³⁴

3. Que exista en la mitad legitimaria un déficit para completar la legítima del cónyuge sobreviviente.

Cuando no cabe el mínimo 25% en la mitad legitimaria, esto es, no hay bienes suficientes para enterarla con cargo a ella, se paga con cargo a la cuarta de mejoras y, si aún no puede pagarse, con cargo a la cuarta de libre disposición.

4. Que excedan la legítima y cuarta de mejoras y afecten la cuarta de libre disposición.

1194: el exceso se saca de la parte de libre disposición con preferencia a toda otra inversión.

³⁴ Otros lo interpretan de otra forma: Debe dividirse por 2 la cuarta de mejoras en su integridad. 12,5 para cada cual. Juan los recibe íntegros y Pedro sólo recibe 7,5 porque debe imputar a mejoras los 5 de exceso.

Por ello es que se afirmaba que las legítimas rigurosas tienen preferencia absoluta para su pago, primero en la mitad legítimaria, luego en la cuarta de mejoras y finalmente en la cuarta de libre disposición.

5. Que de todos modos no haya cómo pagar las legítimas y mejoras. 1196: si no hubiere cómo completar las legítimas y mejoras, se rebajarán unas y otras a prorrata.

- Casos en que el legitimario puede exigir un saldo o puede estar obligado a pagarlo él. 1206:

1. Que dentro de la herencia le corresponda al legitimario una parte superior a lo que ha recibido por donaciones, en cuyo caso tiene derecho a exigir el saldo.

El donatario conserva las especies donadas y tiene derecho a exigir el saldo en efectivo. No puede obligar a los demás asignatarios a que le cambien las especies, o le den su valor en dinero.

2. Que dentro de la herencia le corresponda una parte inferior a la que ha recibido por donaciones, en cuyo caso puede verse obligado a restituir el saldo.

Puede a su arbitrio hacer un pago en dinero, o restituir una o más de dichas especies, y exigir la debida compensación pecuniaria por lo que el valor actual de las especies que restituye excediere al saldo que debe.

Según Somarriva, este derecho optativo es de aquellos derechos absolutos a los cuales no cabe aplicarle la doctrina del abuso del derecho.

En caso que restituya en especie, estaríamos frente a una dación en pago legal (la establece la ley) y forzada (los asignatarios están obligados a aceptarla), siendo una situación muy semejante al 1773 CC.

El legitimario puede exigir la compensación pecuniaria porque por la donación él se hizo dueño, por lo que le pertenecen también el aumento del valor experimentado por las cosas.

- Resolución de las donaciones hechas en razón de legítimas a quien al momento de fallecer el causante no era legitimario. 1200: si se hace una donación a título de legítima, la donación se resolverá si el donatario no es legitimario al momento de abrirse la sucesión. Son 2 situaciones:

a- Donación revocable o irrevocable hecha a título de legítima a una persona que al momento de fallecer el causante no era legitimario. Si el donatario no llega a serlo, queda sin efecto la donación.

b- Que se haga alguna de estas donaciones a título de legítima a una persona que al momento de hacerse la donación era legitimario, pero después deja de serlo por incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación, o por haber sobrevenido otro legitimario de mejor derecho. En tal evento, también se resuelve la donación, salvo que el donatario sea descendiente del causante y deje descendientes con derecho de representación, en cuyo caso las donaciones se imputan a la legítima de los representantes.

Es decir, las donaciones hechas en razón de legítimas se entienden efectuadas bajo la condición de que el donatario sea legitimario al momento de fallecer el causante. Si ello no ocurre, la donación queda sin efecto.

LA CUARTA DE MEJORAS

Personas a quienes el testador puede beneficiar con mejoras. 1195

- a. Descendientes
- b. Cónyuge
- c. Ascendientes

Puede asignar a uno o más de ellos toda la cuarta con exclusión de los otros. Puede ocurrir que el beneficiario de las mejoras **no sea legitimario**. Puede dejarse a un nieto o bisnieto, aun cuando concurra el hijo del causante a la herencia.

- La cuarta de mejoras en el orden del cónyuge y los ascendientes.

Hoy no cabe duda que la cuarta de mejoras es asignación forzosa siempre que concurra un legitimario, porque todos ellos pueden ser asignatarios de mejoras. Repetimos sin embargo que, puede ocurrir que el beneficiario de mejoras no sea un legitimario.

- Forma en que el testador puede distribuir la cuarta de mejoras.

Existe entera libertad del testador, siempre que se le asigne a uno de los beneficiarios que establece la ley.

- Características de las mejoras.

1. Constituyen una asignación forzosa.

Está expresamente señalada en el 1167. Del hecho de ser asignaciones forzosas, se concluye que (1) la favorece la formación de los acervos imaginarios y (2) que si el testador dispone de la cuarta de mejoras a favor de otras personas que no sean indicadas en la ley, procede la acción de reforma de testamento. 1220.

2. No se presumen.

Necesitan de declaración expresa del testador. 1198 y 1203. De esto se deduce la siguiente consecuencia: las asignaciones de cuarta de mejoras suponen que haya testamento, requiriendo la declaración de voluntad del testador. Sin testamento, se aplicarán las reglas de la sucesión intestada, pues en este caso, la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición acrecen a la mitad legitimaria y pasan a formar la legítima efectiva. La otra consecuencia derivada de la necesidad de testamento, es que en las mejoras **no opera el derecho de representación**. Si no se dispone de esta cuarta, por haber faltado testamento, opera el derecho de representación.

3. No son susceptibles de sujetarse a modalidades o gravámenes, salvo las excepciones legales.

Respecto de las mejoras la ley en principio no excluye las modalidades, y sólo ha prohibido los gravámenes establecidos en beneficio de personas a quienes el testador no podía beneficiar con mejoras. Las modalidades serán válidas siempre que no importen una violación de las mejoras de los descendientes. La

ley reglamenta especialmente una modalidad a que puede sujetarse la mejora: la administración de un banco, sin que sea necesario que el asignatario sea incapaz³⁵.

Existen otras modalidades a las que puede sujetarse la mejora, **siempre que no importen una violación de esta asignación forzosa**. Por ej. Se puede dejar asignaciones de familia al hijo sujeto a la condición de que no las administre o no tenga el goce de ellas el padre o madre.

En cuanto a los gravámenes, estos sí están **prohibidos por la ley**, salvo cuando estén establecidos en beneficio de personas a quienes el testador podía beneficiar con mejoras. 1195 inciso 2º. Lo que está prohibido es favorecer con estos gravámenes a un extraño que no sea acreedor de la mejora.

- Convención celebrada entre un legitimario y el causante para que éste no disponga de la cuarta de mejoras. 1463 señala que existe objeto ilícito en los pactos sobre sucesiones futuras. Este principio tiene su excepción justamente en el art. 1204.

Art. 1204. *Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes, que a la sazón era legitimario, no donar, ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniera a su promesa, el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovechara.*

Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura, entre un legitimario y el que le debe la legítima, serán nulas y de ningún valor.

Requisitos del pacto de no mejorar.

1. Sólo pueden favorecer a los legitimarios. Asimismo es necesario que al momento de celebrarlo tengan la calidad de legitimarios. Por ejemplo si existe un descendiente, no puede un ascendiente celebrarlo. Pero sí puede el ascendiente celebrarlo si existe cónyuge sobreviviente, ya que concurriría con aquel como legitimario.

2. Se trata de una convención **solemne**, ya que el 1204 exige la escritura pública.

3. Sólo puede tener por objeto el no disponer de la cuarta de mejoras. Cualquier otra estipulación será ineficaz.

El objeto del pacto es imponerle al testador una obligación de no hacer: no disponer de la cuarta de mejoras por donaciones entre vivos o asignaciones por causa de muerte. No se conviene que el causante deje la cuarta de mejoras al "cocontratante". Si el causante viola el pacto, la contraparte tiene derecho a que el asignatario le restituya lo que le hubiera correspondido de no haberse violado el acuerdo.

³⁵ En el caso de la legítima rigurosa, sólo podía ser dejada a un Banco, cuando el legitimario fuese incapaz.

- **Resolución de las donaciones hechas a razón de mejoras a quien al momento de fallecer el causante no tenía derecho a ellas.** 1201: se resolverá la donación hecha a razón de mejoras a una persona que al fallecer el causante, por cualquier motivo no tenga derechos a llevar la asignación de mejoras.

1. Se hace a título de mejoras una donación revocable o irrevocable a una persona que se creía descendiente o ascendiente del donante, y que no lo era realmente. Quedará sin efecto.
2. Que el donatario, descendiente o ascendiente falte por indignidad, incapacidad, desheredación o repudiación. Igualmente se resuelve la donación. Existe una condición de que el donatario tenga derechos a mejoras al fallecimiento del causante.
3. Que se haga una donación revocable a título de mejoras a una persona que se creía cónyuge y no lo era, o ha llegado a faltar por incapacidad, indignidad o repudiación. También se resuelve.

En el último caso sólo se refiere a donaciones revocables, porque entre cónyuges no existe la irrevocable. El precepto olvidó establecer el desheredamiento, debido a que con anterioridad el cónyuge no era legitimario. Hoy siéndolo, puede ser desheredado.

Asimismo, según Somarriva, deben aplicarse las causales de filiación determinada judicialmente y separación judicial por culpa.

EL DESHEREDAMIENTO

Puede ocurrir que el comportamiento del legitimario no lo haga digno de que se le respete su legítima. Ante ello, la ley concede una válvula de escape: **desheredamiento** (también llamado desheredación o exheredación).

Desheredamiento: 1207: *es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima.*

- **Requisitos de eficacia del desheredamiento:**

1. **Que se efectúe por testamento.** El tenor de la ley no acepta otra forma.
2. **Que exista causa legal de desheredamiento**

De no ser así, el testador podría burlar las legítimas simplemente desheredando a sus legitimarios. El 1208 establece **taxativamente** las causales de desheredamiento. Los descendientes pueden ser desheredados por cualquiera de las 5 causales. Los ascendientes, el cónyuge y el conviviente civil sobreviviente sólo por las 3 primeras, que corresponden en general a determinadas causales de indignidad.

Art. 1208. Un descendiente no puede ser desheredado sino por alguna de las causas siguientes:

1ª Por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes;

2ª Por no haberle socorrido en el estado de demencia o destitución, pudiendo;

3ª Por haberse valido de fuerza o dolo para impedirle testar;

4ª Por haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo³⁶;

5ª Por haber cometido un delito que merezca pena aflictiva; o por haberse abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames; a menos que se pruebe que el testador no cuidó de la educación del desheredado.

Los ascendientes y el cónyuge podrán ser desheredados por cualquiera de las tres primeras causas.

3. Que se indique la causal de desheredamiento

1209 requiere especificidad de la causal en el testamento. No se exige que el testador indique a qué número del 1208 corresponde. Basta que indique los hechos constitutivos de la causa.

4. Que se prueben los hechos constitutivos de la causal

Los hechos constitutivos de la causal deben ser probados en vida del testador o con posterioridad a su fallecimiento. En tal caso, la prueba corresponde a las personas interesadas en el desheredamiento.

Excepción: no será necesaria la prueba, cuando el desheredado no reclamare su legítima dentro de los cuatro años subsiguientes a la apertura de la sucesión; o dentro de los cuatro años contados desde el día en que haya cesado su incapacidad de administrar si al tiempo de abrirse la sucesión era incapaz³⁷.

- **Efectos del desheredamiento. 1210:** debe estarse antes que nada a lo que diga el testador en su testamento.

Puede ser total o parcial, debiendo estarse al tenor del testamento. La regla general es que sea total, pudiendo sólo el testador limitar sus efectos.

Los efectos del desheredamiento no se extienden a los alimentos, salvo en caso de injuria atroz. 1210 inciso final en relación con 324. La ley no indica cuándo existe injuria atroz. No hay duda de que se pierde el derecho de alimentos en presencia de las causales 1ª, 2ª y 3ª del 1208, relacionando este precepto con los arts. 968 y 979.

- Revocación del desheredamiento.

Siendo una disposición testamentaria, el desheredamiento puede ser revocado por el testador. 1221. El testador debe otorgar un nuevo testamento en el cual deje sin efecto el desheredamiento hecho anteriormente.

La revocación puede ser total o parcial.

El desheredamiento no se entiende revocado tácitamente por haber intervenido reconciliación. Tampoco se le permite al desheredado probar que existió intención de revocar el desheredamiento, ya que la revocación sólo puede hacerse por testamento.

³⁶ Es concordante con el 114. Puede ser desheredado no sólo por quién debía prestar el asenso, sino por todos los demás ascendientes.

³⁷ En concordancia con el plazo para deducir la acción de reforma de testamento, el cual sería el medio idóneo para reclamar en contra del acto de desheredamiento.

REVOCACIÓN Y REFORMA DEL TESTAMENTO

- Causales por las cuales un testamento puede perder su eficacia.

1. Declaración de nulidad del testamento
2. Violación del sobre en el cual se contiene el testamento cerrado
3. Que todos los asignatarios instituidos en el testamento sean incapaces o indignos de suceder, o bien repudien las asignaciones que se les hacen
4. Caducidad de los testamentos privilegiados
5. Revocación del testamento por parte del testador
6. Acción de reforma de testamento

LA REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO

La revocabilidad del testamento es esencial en este acto jurídico. Así lo señala el 999: "conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.

La facultad de revocar es **de orden público**, razón por la cual el artículo 1001 niega todo valor a cualquier cláusula que envuelva una renuncia de la facultad de revocar el testamento.

-Lo revocable en un testamento son las disposiciones del mismo, mas no las declaraciones. Esta distinción la efectúa tanto la doctrina como la ley. 1034, 1038 y 1039, por ejemplo.

El 999 nos dice que el testador conserva la facultad de revocar las **disposiciones** del testamento, sin referirse a las declaraciones. En el mismo sentido 1001, 1211 y 1215.

Lo anterior se confirma con lo dispuesto en el 189 inciso 2º en relación con 187 No. 4.

- Las disposiciones testamentarias deben ser revocadas por medio de otro testamento. No se consagra en forma explícita, pero se concluye de las distintas normas. A pesar de que el sentido de la ley en su conjunto es clarísimo, han existido fallos contradictorios: se declara revocado un testamento por medio de una escritura pública.

- Un testamento puede ser revocado por otro de distinta naturaleza. 1213: *el testamento solemne puede ser revocado expresamente en todo o parte, por un testamento solemne o privilegiado.*

En el caso de que la revocación se haga en un testamento privilegiado y éste caduque, la revocación no surte efectos, por lo que vale el testamento anterior.

- La revocación de un testamento que a su vez revocó otro anterior no hace renacer a éste, salvo que el testador así lo declare expresamente. 1214. Se sigue el mismo principio que en materia de derogación legal.

- Clasificación de la revocación del testamento.

- a. Total: mediante ella queda sin efecto íntegramente el testamento revocado.
- b. Parcial: el revocado subsiste en las partes que no es dejado sin efecto. Afecta sólo a ciertas cláusulas la revocación.
- c. Expresa: se hace en términos formales y explícitos.
- d. Tácita: existe cuando el segundo testamento, sin decir expresamente que revoca los anteriores, contiene disposiciones inconciliables con las contenidas en ellos. 1215 y 1149.

Jurisprudencia: establecer la incompatibilidad de las disposiciones testamentarias es cuestión de hecho.

Revocación tácita de los legados. Tienen formas especiales de revocación.

1. Si el testador, luego de efectuado el legado, enajena la cosa asignada se entiende que tácitamente revoca el legado;
2. Si el testador altera sustancialmente la cosa legada mueble, se entiende revocado tácitamente;
3. El legado de condonación se entiende revocado si con posterioridad se demanda al deudor o recibe su pago;
4. El legado de crédito se entiende revocado tácitamente cuando con posteridad se cobra al deudor o se acepta el pago.

En estos casos, las disposiciones testamentarias quedan sin efecto, **sin necesidad de otorgar un testamento.**

LA ACCIÓN DE REFORMA DE TESTAMENTO

Es el principal medio directo para proteger las legítimas y las mejoras. 1216.

Acción de reforma de testamento: aquella que corresponde a los legitimarios, o a sus herederos, en caso de que el testador **en su testamento** no les haya respetado las legítimas o mejoras, según los casos, para pedir que se modifique el testamento en todo lo que perjudique dichas asignaciones forzosas.

A diferencia de la acción de nulidad, que le quita eficacia a todo el testamento, la acción de reforma de testamento lo deja subsistente en toda aquella parte que no perjudique las asignaciones forzosas.

- Características de la acción de reforma.

1. Es una acción personal. Debe intentarse en contra de los asignatarios instituidos por el testador en perjuicio de las asignaciones forzosas amparadas por esta acción. En este sentido, difiere de la acción de petición de herencia, que corresponde a los herederos desprovistos de la posesión de la herencia, siendo una acción típicamente **real** que puede dirigirse contra cualquier persona que esté poseyendo la herencia a título de heredero. La CS ha dicho que es posible entablar conjuntamente la acción de reforma con la acción de petición de

herencia. Es perfecta la solución porque no son incompatibles e incluso, la de petición de herencia podrá surgir como consecuencia de la acción de reforma.

2. Es una acción patrimonial. De lo anterior se siguen las siguientes consecuencias:

- a- Es renunciable.
- b- Es transferible al cesionario.
- c- Es transmisible.
- d- Es prescriptible. Su prescripción presenta algunas particularidades: los legitimarios podrán intentar su acción dentro de los 4 años contados desde el día en que (1) tuvieron conocimiento del testamento y (2) de su calidad de legitimarios.

Según Somarriva, le corresponde al asignatario de la donación que eventualmente perjudica la legítima o mejora, probar los hechos constitutivos que hacen comenzar a correr el plazo de prescripción, debido a que ellos alegan la excepción de prescripción de la acción.

Se trata de una prescripción **especial** de aquellas a las que se refiere el 2524, razón por la cual no se suspende a favor de los incapaces. Sin embargo, la acción de reforma hace **excepción** a este principio: 1216 inciso 2º: si el legítimo no tenía la administración de sus bienes, a la apertura de la sucesión, no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de 4 años contados desde el día en que tomare esa administración.

Los plazos son concordantes con aquellos que establecen la innecesidad de acreditar las causales por las cuales se deshereda al legítimo, debido a que es justamente la acción de reforma la encargada de reclamar un desheredamiento ilegal.

- El juicio de reforma de testamento.

Corresponde hincarlo a los legitimarios (1216). Como la ley no ha señalado normas especiales, se sujeta en su tramitación al juicio ordinario.

Para intentar la acción de reforma **no es necesario** que previamente se entable un juicio para acreditar la calidad de legítimo. En el mismo juicio, si se niega por el demandado la calidad de legítimo, se discute este punto fundamental para que prospere la acción de reforma.

Tampoco es necesario que se efectúe previamente la partición de los bienes para acreditar la violación de las legítimas.

- Objeto de la acción de reforma de testamento. Se puede solicitar:

1. La legítima rigorosa o la legítima efectiva 1217.

El legítimo reclamará su legítima rigorosa, cuando sus derechos han sido desconocidos a favor de otros legitimarios de igual derecho, y la efectiva, cuando han sido violados a favor de terceros extraños que no son legitimarios. De esta forma, nunca se podrá reclamar, por medio de esta acción, la parte de libre disposición porque el testador es libre de destinarla a quien quiera.

El legitimario que ha sido indebidamente desheredado, tendrá, además, derecho para que subsistan las donaciones entre vivos comprendidas en la desheredación.

2. La cuarta de mejoras. 1220. Todos los asignatarios de mejoras tienen derecho a la acción de reforma, y pueden intentarla, pero sólo si son legitimarios, explicándose esto en el interés que le cabe: si no tiene efecto las disposiciones de la cuarta de mejoras, les corresponderá a ellos el acrecimiento respecto a la parte del que el testador no dispuso respecto a la cuarta de mejoras.

- **La preterición.** 1218: consiste en haber sido pasado en silencio un legitimario en el testamento. Deberá entenderse como una institución de heredero en su legítima. Conserva además, las donaciones revocables que el testador no hubiere revocado. Como el preterido es instituido heredero por la ley, la acción que debe intentar es la de petición de herencia y no la de reforma del testamento, en virtud de la expresa disposición del 1218. Mediante su acción, el preterido puede reclamar la legítima rigurosa o la efectiva. Reclamará la primera si es preterido en beneficio de otro legitimario de igual derecho, y la efectiva si es preterido en provecho de un extraño³⁸.

DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN Y DE LAS ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LAS ASIGNACIONES

Verificada la muerte del causante, cabe distinguir en toda sucesión las siguientes etapas:

- a. **Apertura de la sucesión:** hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad. Se produce coetáneamente al fallecimiento del causante.
- b. **Delación de las asignaciones:** actual llamamiento de la ley al asignatario para aceptar o repudiar la asignación. También (por regla general) se produce al fallecimiento del causante, un instante después de la apertura de la sucesión.
- c. **El pronunciamiento del asignatario aceptando o repudiando la asignación** deferida.

LA APERTURA DE LA SUCESIÓN

Ya analizamos el 955, determinando cuándo se produce (fallecimiento), dónde se produce (último domicilio) y la ley por la cual se rige.

El CC se ocupa en esta parte de una medida denominada **guarda o aposición de sellos**.

³⁸ Las diferencias entre la acción de petición de herencia y la de reforma en torno a las prescripción a las que están sometidas hacen relevante distinguir si ha operado o no la preterición.

- **Guarda o aposición de sellos:** después de efectuada la apertura de la sucesión y mientras no se hace inventario solemne de los bienes hereditarios, todos los muebles y papeles de la sucesión se guardan bajo llave y sello, a fin de que desaparezcan.

Es una medida conservativa de los acreedores a fin de que los herederos no burlen sus derechos. Por ello, se le menciona entre los derechos auxiliares del acreedor.

- **Bienes que se guardan bajo sello.** 1222: muebles y papeles de la sucesión. No se extiende a inmuebles porque no existe peligro de destrucción y extravío y su identificación siempre es fácil. Respecto de los muebles hay 2 excepciones:

1. No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formará lista de ellos.
2. 874 CPC: puede el tribunal, siempre que lo estime conveniente, eximir el dinero y las alhajas de la formalidad de las guardas y aposición de sellos. En tal caso mandará a depositar estas especies en un Banco o en las arcas del Estado, o las hará entregar al administrador o tenedor legítimo de los bienes de la sucesión.

- **Tramitación de la solicitud de guarda y aposición de sellos.**

Puede solicitarla el albacea, o cualquier persona con interés en ello. Solicitada, el tribunal la decretará y procederá por sí mismo a realizar las diligencias correspondientes, o comisionará al secretario o notario, quienes se asociarán con 2 testigos mayores de 18 que sepan leer y escribir y sean conocidos del secretario o del notario. El tribunal puede decretar las medidas de oficio y ellas se realizan cuando no concurra interesado.

Frente a la solicitud no cabe oposición y la resolución que la concede es apelable en el solo efecto devolutivo.

En caso de que los bienes estén esparcidos, el juez del último domicilio dirigirá exhorto a los otros jueces para que procedan por su parte a la guarda y aposición de sellos.

Las llaves quedan en el oficio del secretario o en manos de una persona de notoria probidad y solvencia.

- **Cesación de la guarda y aposición de sellos.** Termina la medida conservativa cuando se realiza inventario de los bienes, pues entonces queda ya prueba pre constituida de la existencia de éstos.

- **Gastos de la guarda y aposición de sellos.** Grava a todos los bienes de la sucesión, a menos que determinadamente recaigan sobre una parte de ellos, caso en el cual gravarán esa sola parte. Son una baja general de la herencia.

- **Publicidad de la apertura de la sucesión.** 1287: se impone a los albaceas y en subsidio a los herederos, la obligación de advertir la apertura de la sucesión por medio de 3 avisos publicados en el periódico del departamento o en la cabecera de provincia si en aquél no lo hubiere. Se busca comunicar a los acreedores, a fin de que hagan valer sus créditos oportunamente. La omisión obliga al albacea o herederos a **indemnizar los perjuicios causados**.

- **Bienes familiares.** En caso de fallecimiento del cónyuge propietario del bien declarado familiar, deben formular la petición de desafectación los causahabientes del cónyuge fallecido.

ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LAS ASIGNACIONES

Hecha la delación (llamamiento legal) el asignatario debe tomar la decisión de aceptar o repudiar la asignación de que ha sido objeto.

El testamento en que se instituye asignataria a una persona es un acto jurídico unilateral. A fin de que la institución de heredero o legatario de una persona produzca efectos jurídicos, es necesario que el asignatario se pronuncie aceptando la asignación. La ley exige este pronunciamiento por 2 razones:

- a. Nadie puede adquirir derechos sin su voluntad; y
- b. La calidad de heredero impone sobre el asignatario una responsabilidad y para que el heredero la tome sobre sí se requiere el consentimiento suyo.

- **La aceptación de la herencia como cuasicontrato. 1437.** Este artículo ha servido para que algunos estimen que la aceptación de la herencia constituye un cuasicontrato, cuestión que debe descartarse. Lo que ocurre es que la ley equipara sus efectos a los del cuasicontrato, debido a que la aceptación de la herencia o legado es un acto voluntario del heredero o legatario, en que éste toma sobre sí la responsabilidad que significa una herencia o legado. Si la ley la hubiera considerado cuasicontrato, no era necesario que la nombrara³⁹.

- **Diferencia entre los herederos y legatarios, en cuanto a la aceptación o repudiación de las asignaciones.** El legatario frente al legado de que es objeto puede tomar una de dos actitudes: aceptar o repudiar. En cambio, el heredero tiene una tercera posibilidad: además de repudiar o aceptar pura y simplemente, puede aceptar con beneficio de inventario, facultad de que carece el legatario, y en cuya virtud el heredero limita su responsabilidad por las deudas de la herencia a lo que recibe por ésta.⁴⁰

Lapso durante el cual puede el asignatario emitir su pronunciamiento

- **Desde cuándo se puede aceptar:** 1226 inciso 1º: no se puede aceptar asignación alguna, sino después que se ha deferido. Relacionando esto con el 956, tendremos que distinguir:

- a. RG: la asignación se defiende al momento del fallecimiento del causante
- b. Si la asignación está sujeta a una condición suspensiva, la delación se produce una vez cumplida la condición, salvo que se trate de la condición de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, en cuyo caso la asignación se defiende al fallecimiento del causante, siempre que aquél dé caución para el caso de contravenirse la condición.

- **Desde cuándo se puede repudiar.** 1226 inciso 2º: después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata se podrá repudiar toda asignación, aunque sea condicional y esté pendiente la condición.

- **Hasta cuándo puede el asignatario aceptar o repudiar la asignación. ¿Cuándo se extingue su derecho a pronunciarse?** Hay que distinguir:

- a. Si se ha requerido judicialmente al asignatario para que emita su pronunciamiento. 1232. Cualquiera persona interesada en que el asignatario se pronuncie, puede exigir que el asignatario se pronuncie en el plazo de **40 días**. Es el llamado **PLAZO PARA DELIBERAR**. La ley le otorga al asignatario la facultad de inspeccionar el objeto asignado y las cuentas y papeles de la

³⁹ Posición de Somarriva.

⁴⁰ Lo dicho es sin perjuicio de que, la ley ha concedido al legatario una especie de beneficio de inventario de pleno derecho, limitando su responsabilidad a lo que recibe por el legado.

sucesión. Puede implorar medidas conservativas y no puede ser obligado al pago de ninguna deuda hereditaria o testamentaria, las cuales deben ser cobradas al curador de la herencia yacente, al albacea o a los herederos que hayan aceptado.

CS: el plazo es fatal, porque se utiliza la expresión "dentro de" (art. 49). Siendo así, cuando el asignatario deja pasar los 40 días sin pronunciarse, pierde el derecho a pronunciarse. La ley, interpretará su silencio: **1233: el asignatario constituido en mora de declarar su acepta o repudia, se entenderá que repudia.** Es uno de los casos en que la ley le otorga al silencio valor de manifestación de voluntad.

- **Asignatario ausente.** El juez puede ampliar el plazo para deliberar, pero nunca por más de 1 año. Si el asignatario ausente no compareciere por sí o por legítimo representante en tiempo oportuno, se le nombrará curador de bienes que lo represente, y acepte por él con beneficio de inventario. El plazo para deliberar también se puede ampliar hasta 1 año cuando los bienes están situados en lugares distantes o por otro grave motivo.

b. No ha existido requerimiento judicial. Sin requerimiento judicial el asignatario puede aceptar o repudiar libremente mientras conserve su derecho a la asignación. Habrá que distinguir entonces entre el heredero y el asignatario.

i- El heredero podrá aceptar o repudiar mientras un tercero no adquiera la herencia por prescripción adquisitiva de 5 o 10 años.

ii- Respecto del legatario, es necesario hacer una nueva distinción:

a- De especie: se hace dueño por el solo fallecimiento del causante. No podrá aceptar cuando prescriba la acción reivindicatoria de que goza.

b- De género: su acción personal contra los herederos prescribe en 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible. Expirado dicho plazo, no puede aceptar.

Libertad del Asignatario para aceptar o repudiar la asignación

- **Por RG, el asignatario puede aceptar o repudiar libremente** 1225: todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Situaciones especiales:

1. Asignatario que sustrae efectos pertenecientes a la sucesión.

1231: El heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una sucesión, pierde la facultad de repudiar la herencia, y no obstante su repudiación permanecerá heredero; pero no tendrá parte alguna en los en los objetos sustraídos.

El legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión, pierde los derechos que como legatario pudiera tener sobre dichos objetos, y no teniendo el dominio de ellos será obligado a restituir el duplo.

Uno y otro quedarán, además, sujetos criminalmente a las penas que por el delito correspondan.

El precepto tiene la misma lógica que el **1768**, a propósito de la SC.

El 1231 no dice que la sustracción deba ser dolosa. Sin embargo, se estima que para aplicar la sanción es necesario que exista dolo de parte del

sustractor. Habiendo dolo, nos encontramos ante un delito civil, cuya responsabilidad prescribe en 4 años. La sustracción también puede constituir un delito penal, cuestión indicada en el 1231.

La sanción civil es la siguiente:

a. Para el heredero: (1) pierde la facultad de repudiar la asignación y no obstante su repudiación permanece como heredero; y (2) pierde su derecho cuotativo en los efectos sustraídos.

b. Para el legatario:

i- Si sustrae el propio objeto que le fue legado, pierde el derecho que como legatario tenía en ese objeto.

ii- Si el legatario sustrae una cosa sobre la cual no tiene dominio, debe restituir el duplo. El legatario de género queda comprendido en esta situación aun cuando sustraiga el objeto que le fue legado, ya que carece de dominio, mientras no sean entregados por los herederos.

La ley también castiga la ocultación de los bienes hereditarios para eludir el pago del impuesto a la herencia. Multa de un 5% a un 50% de una UTA. Si se trata de una ocultación dolosa, pasa a ser entre un 50% y un 300% del valor del tributo eludido y presidio menor a máximo.

2. La de los asignatarios incapaces. 1225 y 1236

Los incapaces tienen que aceptar o repudiar las asignaciones de que han sido objeto por medio de sus representantes legales. 1250: las asignaciones hechas a personas incapaces deben aceptarse siempre con beneficio de inventario.

Asimismo no se puede repudiar una asignación a título universal, ni una asignación de bienes raíces o muebles que valgan más de 1 centavo, hechas a favor de quienes no tienen la libre administración de sus bienes, sino con autorización judicial dada con conocimiento de causa. Sin ella, adolece de Nulidad Relativa.

3. La de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal.

1225: El marido requerirá el consentimiento de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal para aceptar o repudiar una asignación deferida a ella. Esta autorización se sujetará a lo dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 1749. Puede ser suplida por el juez previo audiencia a la que será citado la mujer, si ésta la negare con justo motivo, y también en caso de algún impedimento de la mujer, como la minoría de edad, demencia, ausencia real o aparente u otro y siempre que de la demora se siguiere perjuicio.

Igualmente se discute si la mujer puede aceptar o repudiar con la autorización del marido.

Somarriva piensa que sí puede hacerlo, y además en caso de negativa injustificada del marido rigen los artículos 138 y 138 bis, por ser generales.

La mujer puede aceptar o repudiar por sí sola las asignaciones que se le han deferido, **porque es plenamente capaz**.

El 138 bis abonaría a la tesis contraria, al disponer que en caso de negativa injustificada del marido, se pueda recurrir a la autorización judicial subsidiaria. Y si puede recurrir al juez, es porque necesita la autorización del marido o del juez en subsidio.

Características de la aceptación y repudiación

El derecho de opción para aceptar o repudiar, tiene las siguientes características:

1. Es un derecho transmisible.

Derecho de transmisión del 957, se funda en la facultad que en vida tuvo el asignatario de aceptar o repudiar la asignación, la cual se transmite. En el patrimonio del causante viene incluida la facultad de aceptar o repudiar la asignación.

2. No puede sujetarse a modalidades

1227: no se puede aceptar o repudiar condicionalmente ni hasta o desde cierto día. Esto se explica en que la aceptación o repudiación de una herencia o legado no sólo involucra el interés del asignatario, sino el de otras personas: demás asignatarios, acreedores hereditarios y testamentarios. La ley requiere que estas personas tengan certidumbre acerca de su situación.

3. Es un derecho indivisible

1228: no se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y repudiar el resto. La facultad de aceptar o repudiar, al transmitirse a los herederos del asignatario, se hace **divisible**. Operando el derecho de transmisión, cada heredero del asignatario que falleció sin pronunciarse puede aceptar o repudiar su cuota.

- Aceptación y repudiación de 2 asignaciones diferentes: 1229: se puede aceptar una y repudiar otra. Pero no se pueden aceptar las asignaciones que estén exentas de gravámenes y repudiar las gravadas, salvo si se concedió al asignatario la facultad de repudiar esta última separadamente, o que la asignación gravada se defiera separadamente por acrecimiento, transmisión, sustitución vulgar o fideicomisaria. 1151 y 1068 en el mismo sentido.

4. Puede ser expresa o tácita

1233: el asignatario en mora de declarar, se presume que repudia.

1230: Si un asignatario vende, dona, o transfiere de cualquier modo a otra persona el objeto que se le ha deferido, o el derecho de suceder en él, se entiende que por el mismo hecho acepta.

Con todo, en virtud del tenor literal del art. 1235 podría estimarse que el acto de repudiación necesariamente requeriría manifestación expresa, tomándose como excepción la hipótesis del art. 1233.

5. Es irrevocable

Siendo un acto jurídico unilateral, queda perfeccionado con la sola voluntad del aceptante o repudiante. 1234: la aceptación, una vez hecha con los requisitos legales, no podrá rescindirse, salvo las excepciones legales. Igual cosa rige para la repudiación.

Hay casos en que, tanto las aceptaciones como las repudiaciones pueden ser dejadas sin efecto⁴¹.

⁴¹ Desde otra perspectiva se puede estimar que tanto la repudiación como la aceptación al ser actos jurídicos deben ser sometidas al tratamiento general y por ende ser anulables no sólo en los casos que se expresa. En

1. Cuando en el pronunciamiento de un incapaz no se cumplen los requisitos legales.

2. Cuando la aceptación o repudiación adolece de un vicio del consentimiento.

1234 y 1237. Puede rescindirse por fuerza o dolo. Respecto de la fuerza deben aplicarse los artículos 1456 y 1457, debiendo ser grave, y viciando el consentimiento tanto si emana del beneficiado como de cualquier otra persona. El dolo también se rige por las reglas generales, salvo en cuanto no se exige que provenga de la contraparte, porque estamos ante un acto jurídico unilateral: aceptación o repudiación. No importa de quién emane el dolo para que vicie el consentimiento.

El error no tiene aplicación como vicio del consentimiento en la aceptación o repudiación.

3. La aceptación puede ser dejada sin efecto cuando en ella ha existido lesión grave.

1234: la lesión es grave cuando disminuye el valor total de la asignación en más de la mitad. Ej. El testador instituye heredero a Pedro como legatario de un inmueble de \$5000. Pedro acepta la asignación, sin conocer de que en un testamento posterior el causante le impuso la obligación de entregar \$3000 a Juan.

4. La repudiación, cuando se efectúa en perjuicio de los acreedores.

1238. La ley faculta a los acreedores para que, autorizados por el juez, acepten la asignación repudiada por el deudor.

La doctrina discute acerca de la naturaleza jurídica de esta acción:

- Mayoría: acción **oblicua**, en la cual los acreedores se sustituyen en los derechos del deudor, ejercitando las acciones que éste no hizo valer.
- Somarriva: **se trata de una acción pauliana**, la cual precisamente busca dejar sin efecto los actos ejecutados por el deudor a fin de burlar los derechos de sus acreedores. Razones:

- a. La acción pauliana tiende a hacer volver al patrimonio del deudor bienes que ya salieron de él. La acción oblicua tiene por objeto hacer ingresar bienes que nunca estuvieron en él. En este caso, el asignatario adquirió los bienes por sucesión por causa de muerte. Por la repudiación salieron de su patrimonio.
- b. El efecto de la acción contenida en el 1238 es el de la acción pauliana. La rescisión del acto ejecutado en fraude de los acreedores beneficia sólo a los acreedores que la solicitan.
- c. Existe mucha similitud entre las situaciones contempladas en el 1238 y en el 2468 No. 1: en ambos casos se trata de actos ejecutados en perjuicio de los acreedores, y en ambos se dice que se rescinden.

virtud de ello podría considerarse que la única excepción sería el error al no estar considerado en el art. 1237 dentro de los vicios que podrían afectar a la aceptación o repudiación. Según Rodríguez Grez esto podría tener sentido excepto respecto al error obstáculo. Ej. Si se acepta un legado sobre un bien raíz x y en rigor la asignación recayó sobre un bien raíz y no podría tener eficacia dicho acto de aceptación.

6. La aceptación o repudiación opera retroactivamente

1239: los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida. En perfecta armonía se encuentra con el 722.

Este efecto retroactivo sólo abarca al heredero y al legatario de especie, pero no al de género. El legatario de especie, en virtud del efecto retroactivo, se hace dueño de los frutos de la cosa legada, desde el fallecimiento del causante. En los legados de género, los frutos se adquieren desde el momento en que la cosa legada fue entregada al legatario o los legatarios se colocaron en mora de entregarla.

Reglas particulares relativas a las herencias

Existen normas especiales respecto a la aceptación o repudiación de una herencia, si la comparamos con la aceptación o repudiación de un legado.

Reglas especiales.

- 1. Herencia yacente.**
- 2. Aceptación tácita de la herencia.**
- 3. Condenación judicial de un heredero como tal.**
- 4. Efectos de la aceptación, que los herederos pueden limitar mediante el BENEFICIO DE INVENTARIO.**

1) Herencia yacente.

1215: si dentro de 15 días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de los parientes, o dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello, o de oficio, declarará yacente la herencia.

Herencia yacente: es aquella que no ha sido aceptada en el plazo de 15 días por algún heredero, siempre que no exista albacea con tenencia de bienes designado en el testamento, o si lo hay, no ha aceptado el albacea el cargo.

- Requisitos para declarar yacente una herencia:

- 1- Que hayan transcurrido 15 días desde la apertura de la sucesión, sin que se haya aceptado la herencia o una cuota de ella;
- 2- Que no exista albacea con tenencia de bienes en la sucesión, ya sea porque en el testamento no se ha nombrado tal albacea, o porque, nombrado, éste haya rechazado el encargo. Esto se explica porque el objeto de declarar yacente una herencia es darle un representante a la sucesión, y si existe albacea con tenencia de bienes, éste cumple dicho cometido.

- Declaración de yacencia de la herencia: la efectúa el juez del último domicilio del causante, a petición del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera

de los parientes, o dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello, o de oficio.

Una vez declarada, se publica esta declaración en un diario de la comuna, o de la capital de provincia o de la capital de la región, si en aquella no hubiere.

Posteriormente se procede a nombrar un curador de la herencia yacente.

Se debe oficiar a la División de Bienes Nacionales del Ministerio de Bienes Nacionales, para que éste determine si la herencia es vacante, es decir, si pertenece al Fisco.

- **Nombramiento de un curador a la herencia yacente.** 1240 lo prescribe. 481: se da curador a la herencia yacente, esto es, a los bienes de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada (el 481 no menciona todos los requisitos para que sea declarada yacente).

- **La curaduría de la herencia yacente es siempre dativa**, es decir, no puede ser legítima ni testamentaria. El juez es quién debe designar al curador de la herencia yacente. Si el difunto a cuya herencia es necesario nombrar curador tuviere herederos extranjeros, el cónsul de la nación de éstos tendrá derecho para proponer al curador o curadores que hayan de custodiar y administrar los bienes. 482 CC. 886 CPC.

- **Facultades del curador de la herencia yacente.**

Se trata de una curaduría de bienes y no de una general, razón por la cual no se extiende a las personas. El curador de la herencia yacente no representa a la sucesión.

Las facultades del curador de la herencia yacente son **meramente conservativas**. Precisamente uno de los objetos es que los acreedores hereditarios tengan contra quién dirigir sus acciones.

- **Facultad del curador de la herencia yacente para vender bienes hereditarios.** 484: después de transcurridos 4 años desde el fallecimiento de la persona cuya herencia está en curaduría, el juez, a petición del curador y con conocimiento de causa, podrá ordenar que se vendan todos los bienes hereditarios existentes, y se ponga su producto a interés con las debidas seguridades, o, si no las hubiere, se deposite en las arcas del Estado.

- **Expiración de la curaduría de la herencia yacente.** 491:

1. Por aceptación de la herencia por alguno de los herederos.
2. Por la venta de los bienes en conformidad al art. 484.
3. Por la extinción o inversión completa de los mismos bienes.

- **Los herederos que van aceptando la herencia administran ésta con las mismas facultades del curador de la herencia yacente.** 1240 incisos 2º y 3º. La ley vela porque siempre exista alguien que administre la herencia y la represente frente a las demandas de los terceros.

- Herencia yacente y herencia vacante.

Herencia yacente: es la que no ha sido aceptada por los herederos y siempre que concurren los demás requisitos ya mencionados.

Herencia vacante: aquella que pertenece al Fisco como heredero abintestato en el último orden de sucesión.

Existe correlación entre ambas, porque la declaración de la herencia yacente es como la antesala de la herencia vacante.

No procede declarar yacente la herencia que ha sido aceptada por el Fisco.

- Premio al denunciante de una herencia yacente. DL 1939 establece un galardón o recompensa a la persona que denuncia al Fisco la existencia de una herencia yacente y que en definitiva se traduzca en que éste adquiera bienes que de otra manera no habrían entrado a su patrimonio. La recompensa asciende a un 30% del valor líquido de los bienes respectivos. Requisitos para el pago de la recompensa:

- a. Ser el primer denunciante;
- b. Que los bienes hayan ingresado legal y materialmente al patrimonio fiscal;
- c. Que los bienes manifestados en la denuncia sean desconocidos para el Fisco y que, de no mediar ésta, la herencia no se hubiere recuperado;
- d. Que se haya practicado la liquidación de la herencia y la deducción de las deudas y demás costas producidas;
- e. No es indispensable que hayan expirado todos los plazos de prescripción de posibles derechos de terceros a la herencia, pero el denunciante debe garantizar la devolución del galardón debidamente reajustado si el Fisco es obligado a restituir la herencia.

- La prescripción adquisitiva ordinaria se suspende a favor de la herencia yacente. 2509. La suspensión cesa desde que un heredero acepta la herencia.

- La herencia yacente no es persona jurídica. Algunos han estimado que sí lo sería en base al 2509 y al 2500 inciso 2º. Sin embargo, esto es errado, en virtud de otro artículo: 2346: se puede afianzar a una persona jurídica y a la herencia yacente.

2) Aceptación tácita de la herencia.

Art. 1241. La aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se toma el título de heredero; y es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar, y que no hubiera tenido derecho de ejecutar, sino en su calidad de heredero.

- Tomar el título de heredero es hacerlo en un instrumento o en un acto de tramitación judicial. 1242. Por ej. Solicitar la posesión efectiva.

- **La enajenación de efectos hereditarios es acto de heredero.** 1244. Sin embargo, el heredero puede declarar ante el juez que no es su intención aceptar la herencia.
- **Los actos conservativos no importan aceptación de la herencia.** 1243.

3) Condenación judicial de un heredero como tal.

Efectos absolutos de la sentencia que declara a una persona heredero. Es esta una **marcada excepción al principio de la relatividad de los fallos** consagrada en el artículo 3 del CC. La excepción debe tomarse en carácter restringido, razón por la cual los efectos de la sentencia que declara que un sujeto no es heredero, no son absolutos.

4) Efectos de la aceptación, que los herederos pueden limitar mediante el BENEFICIO DE INVENTARIO.

Para examinar los efectos que produce la aceptación de una herencia es necesario distinguir si el heredero antes de emitir su pronunciamiento ha efectuado un inventario solemne de los bienes o no.

En caso de no haberlo hecho, se aplica el 1245: El que hace acto de heredero sin previo inventario solemne, sucede en todas las obligaciones transmisibles del difunto a prorrata de su cuota hereditaria, aunque le impongan un gravamen que exceda al valor de los bienes que hereda.

El heredero sucederá tanto en el activo como en el pasivo.

El efecto del beneficio de inventario es **limitar la responsabilidad del heredero por las deudas hereditarias y cargas testamentarias al monto de lo que recibe a título de herencia.**

- Beneficio de inventario (1247): consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que ha heredado.

Tiene por fundamento la **equidad**: no perjudicar al heredero. El acreedor no se ve perjudicado porque contrató teniendo a la vista el patrimonio del causante y no el del heredero.

Nuestro CC, le permite acogerse a este beneficio a la RG de los herederos. Sólo les exige para ello **un inventario solemne** de los bienes, a fin de precaver fraudes.

El beneficio de inventario sólo favorece a los herederos, mas no a los legatarios: 1247 así lo deja claro. Los legatarios no tienen la opción de aceptar su asignación con beneficio de inventario.

Inventario Solemne

El único requisito del beneficio de inventario es el inventario solemne que debió haber confeccionado el heredero respecto de los efectos hereditarios. No es necesaria una declaración expresa del heredero en orden a que acepta con beneficio de inventario. Por el solo hecho de confeccionarse el inventario solemne, el heredero limita su responsabilidad a lo que recibe a título de herencia, y goza del beneficio. 1245.

- Normas que rigen los inventarios solemnes.

Art. 1253. En la confección del inventario se observará lo prevenido para el de los tutores y curadores en los artículos 382 y siguientes, y lo que en el Código de Enjuiciamiento se prescribe para los inventarios solemnes.

Se rigen por las normas del inventario solemne para las tutelas y curadurías (382 y siguientes); 1254 a 1256 a propósito del inventario solemne; y por los artículos 858, 860 y 865 del CPC.

Inventario solemne: es inventario solemne el que se hace previo decreto judicial, por el ministro de fe y dos testigos, previa publicación de 3 avisos en el periódico y citación de los interesados, y protocolizado en una notaría. (858 del CPC da otra definición).

- Requisitos del inventario solemne:

1. Presencia de un notario, quien con autorización judicial, puede ser reemplazado por otro ministro de fe o por el juez de letras respectivo, y de 2 testigos mayores de 18 años que sepan leer y escribir y sean conocidos del ministro de fe.
2. El funcionario debe dejar constancia, en el inventario, de la identidad de la persona que hace la manifestación de los bienes inventariados, si no la conoce;
3. Debe citarse a todos los interesados conocidos y que según la ley tengan derecho a asistir al inventario. 1255: tendrán Art. 1255. Tendrán derecho de asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o abintestato, los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. Las personas antedichas podrán ser representadas por otras que exhiban escritura pública o privada en que se les cometa este encargo, cuando no lo fueren por sus maridos, tutores, curadores o cualesquiera otros legítimos representantes.
Todas estas personas tendrán derecho de reclamar contra el inventario en lo que les pareciere inexacto;
4. Debe dejarse constancia en el inventario, en letras, del lugar, día, mes y año en que comienza y concluye cada parte del inventario;
5. Antes de cerrar el inventario, el tenedor de los bienes o el que hace la manifestación de ellos jurará que no hay otros bienes que manifestar y que deban figurar en el inventario;
6. El inventario será firmado por el tenedor o manifestante, los interesados que hayan asistido, el ministro de fe y los testigos;
7. Concluido el inventario se le protocoliza en el registro del notario que lo haya firmado o en el que designe el tribunal cuando intervino otro ministro de fe.

El inventario solemne es instrumento público.

- Inventario solemne en las posesiones efectivas que se tramitan ante el Registro Civil.

Para entender que el solicitante acepta la herencia con beneficio de inventario deberá así declararlo en el formulario de la solicitud. Esta excepción entonces, sólo se aplicará a los inventarios solemnes que se lleven a cabo en el trámite de posesión efectiva ante el Registro Civil.

- Bienes que comprende el inventario.

Art. 382. El inventario hará relación de todos los bienes raíces y muebles de la persona cuya hacienda se inventaría, particularizándolos uno a uno, o señalando colectivamente los que consisten en número, peso o medida, con expresión de la cantidad y calidad; sin perjuicio de hacer las explicaciones necesarias para poner a cubierto la responsabilidad del guardador.

Comprenderá asimismo los títulos de propiedad, las escrituras públicas y privadas, los créditos y deudas del pupilo de que hubiere comprobante o sólo noticia, los libros de comercio o de cuentas, y en general todos los objetos presentes, exceptuados los que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad, o que sea necesario destruir con algún fin moral.

Conforme al 384 el inventario debe comprender aun las cosas que no le fueran propias a la persona cuyo patrimonio se inventaría, si se encuentran entre las que lo son, pero la mera aserción hecha en el inventario de pertenecer a determinadas personas los objetos enumerados no hace prueba en cuanto al verdadero dominio de ellos.

1254: si el difunto ha tenido parte en una sociedad y por una cláusula del contrato ha estipulado que la sociedad continúe con sus herederos después de su muerte, no por eso en el inventario que haya de hacerse dejarán de ser comprendidos los bienes sociales; sin perjuicio de que los asociados sigan administrándolos hasta la expiración de la sociedad, y sin que por ellos se les exija caución alguna.

- **Bienes ubicados en distintos territorios jurisdiccionales.** Pueden existir en el inventario bienes ubicados en otro territorio jurisdiccional que aquel del tribunal en el cual se confecciona el inventario. En tal caso se dirigen exhortos a los jueces respectivos, a fin de que hagan inventariar dichos bienes y remitan originales de las diligencias realizadas para unirlos a las principales.

- **Agregaciones al inventario.** 383 CC: si luego de hecho el inventario, se encuentran bienes de los cuales no se tuvo noticia al efectuarlo, o por cualquier título acrecieren nuevos bienes a la hacienda inventariada, se hará un inventario solemne de ellos, el cual se agrega al anterior.

- **Inexactitudes del inventario.**

Art. 386. Si el tutor o curador alegare que por error se han relacionado en el inventario cosas que no existían, o se ha exagerado el número, peso, o medida de las existentes, o se les ha atribuido una materia o calidad de que carecían, no le valdrá esta excepción; salvo que pruebe no haberse podido evitar el error con el debido cuidado de su parte, o sin conocimientos o experimentos científicos.

Art. 387. El tutor o curador que alegare haber puesto a sabiendas en el inventario cosas que no le fueron entregadas realmente, no será oído, aunque ofrezca probar que tuvo en ello algún fin provechoso al pupilo.

- **Interpretación del inventario.** 1253 se remite al 382 y ss.: se aplica el 388: los pasajes oscuros o dudosos del inventario se interpretarán a favor del pupilo (**heredero**, para este caso), a menos de prueba en contraria.

- **Tasación de los bienes.**

865 CPC: Art. 865. (1044). Cuando la ley ordene que al inventario se agregue la tasación de los bienes, podrá el tribunal, al tiempo de disponer que se inventarién, designar también peritos para que hagan la tasación, o reservar para más tarde esta operación.

Si se trata de objetos muebles podrá designarse al mismo notario o funcionario que haga sus veces para que practique la tasación.

La ley no exige expresamente en el beneficio de inventario que se efectúe la tasación de los bienes hereditarios. Pero según la propia definición del art. 1247, el heredero es responsable sólo hasta el "valor" de los bienes heredados. Dicho valor debe determinarse por tasación. No se ve cómo puede eximirse de un pago que excede de su responsabilidad, sin exhibir la tasación.

La ley 19.903 modificó el 880, disponiendo que los inventarios deban incluir una valorización de los bienes.

Quiénes están obligados y quiénes no pueden aceptar con Beneficio de Inventario

RG: El heredero puede siempre a su arbitrio aceptar o no con beneficio de inventario. Ni siquiera el testador puede coartar dicha libertad. 1249: el testador no podrá prohibir a un heredero el aceptar con beneficio de inventario.

Limitaciones: personas obligadas a aceptar con beneficio de inventario; y personas que no pueden acogerse a este beneficio.

- Personas obligadas a aceptar con beneficio de inventario.

1. Coherederos, cuando los demás herederos quieren aceptar con beneficio de inventario. 1248. Prima la voluntad de los que desean acogerse al beneficio.
2. Herederos fiduciarios. 1251: se explica porque el legislador vela por el derecho del fideicomisario, ya que la herencia del asignatario fiduciario, cumplida la condición, pasa a pertenecer a aquél.
3. Personas jurídicas de derecho público (incluye al Fisco y las demás personas jurídicas de derecho público). 1250.
4. Incapaces. 1250 inciso 2º.

-Caso en que las personas jurídicas de derecho público o los incapaces no acepten con beneficio de inventario. 1250 inciso final: No cumpliéndose con lo dispuesto en este artículo, las personas naturales o jurídicas representadas, no serán obligadas por las deudas y cargas de la sucesión sino hasta concurrencia de lo que existiere de la herencia al tiempo de la demanda o se probare haberse empleado efectivamente en beneficio de ellas.

La ley le otorga el beneficio **de pleno derecho**, a pesar de que no se acepte con dicho beneficio.

- Personas que no pueden aceptar con beneficio de inventario.

1. El que hizo acto de heredero, sin previo inventario solemne. 1252
2. El que en el inventario omitiere de mala fe mencionar determinados bienes. 1256. Se trata de un heredero doloso que omite señalar ciertos bienes o que incluye deudas inexistentes, a fin de disminuir su responsabilidad. A pesar de haber confeccionado inventario, se le sanciona con no poder acogerse al beneficio.

Efectos del Beneficio de Inventario

1247: EFECTO PRINCIPAL: limitar la responsabilidad del heredero hasta el monto de lo que recibe en su calidad de tal.

- ¿Produce separación de patrimonios? Si la respuesta es sí: los acreedores hereditarios sólo pueden perseguir sus créditos en los bienes del causante. Si la respuesta es negativa: los acreedores hereditarios pueden hacer efectivos sus derechos tanto en los bienes de uno como de otro, pero sólo hasta el monto de lo recibido por el heredero.

Somarriva considera que no se produce una separación de patrimonios, basado en las siguientes razones:

1. El 1247 limita la responsabilidad al monto de lo recibido y no a los bienes adquiridos de dicha forma.
2. El 1260 inciso 2º, al ponerse en el caso de pérdida de algún bien hereditario por caso fortuito, hace responsable al heredero de los valores en que dichos bienes hubieren sido tasados.

3. Si el beneficio de inventario generara una separación de patrimonios, el legislador debió haber limitado la facultad de disposición de los herederos respecto de los bienes hereditarios, cuestión que no hizo.
4. 520 No. 4 del CPC: en conformidad a los artículos 1261 y 1262, se extingue la responsabilidad del heredero beneficiario, cuando se haga entrega de los bienes de la sucesión a los acreedores hereditarios, o por haberse agotado lo que recibió en la herencia en el pago de las deudas hereditarias y testamentarias. En el precepto citado, el CPC dispone que los herederos, si se les embargan bienes propios para pagar deudas del causante, pueden oponerse a la ejecución conforme al procedimiento de las tercerías, o bien en el escrito de oposición, alegando como excepción la extinción de su responsabilidad por el beneficio de inventario.

Norma que va en contra de la interpretación de Somarriva. 1610 No. 4: pago con subrogación a favor del heredero beneficiario que paga con sus dineros propios deudas de la herencia. Esta disposición no tendría explicación si no se produjera la separación de patrimonios.

La escasa jurisprudencia determina que el beneficio de inventario no produce la separación de patrimonios.

- **Límite a la responsabilidad del heredero:** El problema es determinar si el límite está en el valor de los bienes al momento de recibirse la herencia o el que adquieran al tiempo de ser demandado el heredero por el acreedor.

Somarriva: debe considerarse el valor de los bienes al momento en que se defiere la herencia. El aumento del valor beneficiaría al heredero y lo perjudicaría su disminución. Es lógico, porque el heredero beneficiario se hace dueño de los bienes hereditarios y, en consecuencia, a él le pertenece el aumento y él debe sufrir el menoscabo.

- **El beneficio de inventario como excepción perentoria.** Es una excepción que el heredero puede oponer a los acreedores hereditarios, cuando éstos le cobren deudas de la herencia más allá de donde alcanza su responsabilidad. Art. 1263. El heredero beneficiario que opusiere a una demanda la excepción de estar ya consumidos en el pago de deudas y cargas los bienes hereditarios o la porción de ellos que le hubiere cabido, deberá probarlo presentando a los demandantes una cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que haya hecho.

- **El beneficio de inventario impide que las deudas y créditos del heredero se confundan con los del causante.** 1259: Las deudas y créditos del heredero beneficiario no se confunden con las deudas y créditos de la sucesión.

Es decir, el beneficio de inventario impide que opere el MEO confusión.

- **Responsabilidad del heredero beneficiario por los bienes hereditarios.** El heredero beneficiario se hace dueño de los bienes adquiridos, pero su dominio se sujeta a algunas modalidades especiales. 1260: el heredero

beneficiario será responsable hasta por culpa leve de la conservación de las especies o cuerpos ciertos que se deban.

Es de cargo del heredero beneficiario el peligro de los otros bienes de la sucesión, y sólo será responsable de los valores en que hubieren sido tasados. Así, si un bien de la herencia se destruye por caso fortuito o fuerza mayor, el heredero siempre responde de dicho bien. El heredero entonces responderá hasta de caso fortuito, caso en el cual responderá por el valor de los bienes destruidos. Es lógico que así sea porque los bienes perecen para su dueño.

Art. 1257. El que acepta con beneficio de inventario se hace responsable no sólo del valor de los bienes que entonces efectivamente reciba, sino de aquellos que posteriormente sobrevengan a la herencia sobre que recaiga el inventario.

Se agregará la relación y tasación de estos bienes al inventario existente con las mismas formalidades que para hacerlo se observaron.

- Responsabilidad del heredero beneficiario por los créditos de la sucesión.

Art. 1258. Se hará asimismo responsable de todos los créditos como si los hubiese efectivamente cobrado; sin perjuicio de que para su descargo en el tiempo debido justifique lo que sin culpa suya haya dejado de cobrar, poniendo a disposición de los interesados las acciones y títulos insolutos.

Extinción de la Responsabilidad del Heredero Beneficiario

La responsabilidad del heredero beneficiario se puede extinguir de 2 formas:

- a. Por el hecho de abandonar éste a los acreedores hereditarios los bienes de la sucesión que deba entregar en especie (1261). Aprobada la cuenta por el juez o por los acreedores, se extingue su responsabilidad. No señaló la ley si se trataría de un abandono de los bienes para su realización o si se trataría de una dación en pago. Somarriva se inclina por la segunda tesis, porque el legislador no ha exigido la realización de los bienes.
- b. Por haberse consumido todos los bienes recibidos en el pago de las deudas de la herencia (1262). El heredero beneficiario rinde cuenta a los acreedores que resulten impagos, y aprobada la cuenta, queda libre de toda responsabilidad.

LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA

Art. 1264. El que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorpóreas; y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubieren vuelto legítimamente a sus dueños.

Acción de petición de herencia: aquella que compete al heredero para obtener la restitución de la universalidad de la herencia, contra el que la está poseyendo, invocando también la calidad de heredero.

- Características de la acción de petición de herencia.

1. Es una acción real
2. Es una acción divisible
3. Es una acción universal en cuanto a su objeto
4. Es una acción patrimonial

1. Es una acción real

La acción de petición de herencia emana de un derecho real, cual es, precisamente el derecho real de herencia. Presenta las características propias de toda acción real, ya que no se dirige contra determinada persona, sino en contra de quien perturbe el ejercicio del derecho real, sin estar determinada previamente la persona del demandado.

2. Es una acción divisible

Le corresponderá a cada heredero por separado. Si existe un solo heredero, él exigirá toda la masa hereditaria por medio de esta acción. Si existen varios herederos, cada uno de ellos, por su cuota en la herencia, podrá deducir e invocar la acción de petición de herencia.

3. Es una acción universal en cuanto a su objeto

Se trata de una acción mueble, por recaer en una universalidad jurídica, distinta de los bienes que la componen.

4. Es una acción patrimonial

Persigue un beneficio pecuniario: la masa hereditaria. De ello, se derivan las siguientes consecuencias:

- a- Es renunciable.
- b- Es transmisible.
- c- Es transferible. Hay quienes han negado dicho carácter afirmando que los cesionarios no adquieren la calidad de herederos en sí mismo. Puede que así sea, pero es indudable que en la cesión de derechos hereditarios se cede todo el beneficio económico que ellos significan, dentro del cual va incluida la acción de petición de herencia. El texto de la ley abona a esta tesis: "el que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero".
- d- Es prescriptible. 1269: el derecho de petición de herencia expira en 10 años. Pero el heredero putativo en el caso del inciso final del 704, puede oponer a esta acción la prescripción de 5 años. Así existen 2 plazos de prescripción de la acción de petición de herencia:
 - A- 5 años respecto del heredero a quien se ha concedido la posesión efectiva de la herencia. En tal caso se produce una prescripción adquisitiva por el heredero putativo. Se aplica en tal sentido, el 2517. Se trataría de una prescripción adquisitiva de carácter **ordinario**, porque la ley en el caso de la prescripción de 10 años habla de prescripción extraordinaria y porque se refiere al justo título. Siendo ordinaria, se suspende a favor de los enumerados en el 2509. Es necesario, para que sea ordinaria, que el heredero esté de buena fe.
 - B- 10 años en el caso de que al falso heredero no se le haya concedido la posesión efectiva. Se presenta el problema de determinar si se trata de una prescripción extintiva o si es adquisitiva. Es decir, si basta que transcurran los 10 años para la extinción de la acción de petición de

herencia, o si además es necesario que un tercero haya adquirido esta herencia por prescripción adquisitiva de 10 años.

CS: la prescripción es extintiva, basado en el texto de la ley: "expira" en 10 años.

Somarriva critica el fallo:

- A- No se divisa la razón del por qué si la prescripción de 5 es adquisitiva, esta de 10 sea de otra naturaleza;
- B- 2512 dispone que el derecho de herencia se adquiere por prescripción extraordinaria de 10 años.
- C- 2517: toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. Si se interpretara de otra forma, el precepto sólo se aplicaría a la reivindicatoria, cuestión inaceptable debido a la ubicación en las normas generales de prescripción.
- D- **Conclusión:** la prescripción de 10 años también es adquisitiva, sólo extinguiéndose cuando otra persona adquiere la herencia por prescripción extraordinaria de 10 años.

- **Quiénes pueden ejercitar la acción de petición de herencia.**

1264: compete al que probare su derecho en la herencia: quedan comprendidos:

1. Los herederos: se entiende que cualquiera que sea su calificación, el heredero puede interponerla. Salvedad: el heredero condicional, cuyos derechos están sujetos a condición suspensiva, no puede entablarla, pues el efecto propio de la condición suspensiva es suspender la adquisición del derecho.
2. Los donatarios de una donación revocable a título universal. 1142: se entiende que este caso es una institución de heredero.
3. Cesionario de un derecho de herencia.

Los legatarios no pueden ejercerla, porque les corresponde otras acciones: a los de especie, les corresponderá, en su debido tiempo, la reivindicatoria, sin perjuicio de poder interponer también la personal; a los de género, sólo les corresponde la personal.

- **Contra quiénes debe dirigirse la acción de petición de herencia.**

Se entabla en contra del que está ocupando la herencia, invocando la calidad de heredero. Es decir, se demanda al **falso heredero**.

Problema: demanda en contra del cesionario de los derechos hereditarios del falso asignatario. La letra del precepto negaría dicha opción, porque señala que se debe demandar al que la esté poseyendo invocando la calidad de heredero, y en este caso el cesionario no la invoca.

Somarriva considera que sí procedería, ya que aunque el cesionario no la ocupe en calidad de heredero, no es menos cierto que la cesión de derechos hereditarios, hace que el cesionario entre a reemplazar al cedente, existiendo una especie de **subrogación personal**.

- **Objeto de la acción de petición de herencia: Reclamar la universalidad de los bienes pertenecientes al causante.** 1264. La voz "adjudique" no se usa en su verdadero sentido técnico jurídico, de radicación del dominio en el comunero.

Esta acción es tan amplia como lo indica el 1264. El 1265 amplía aún más su objeto: Se extiende la misma acción no sólo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia.

Efectos de la acción de Petición de Herencia

- El primer efecto y principal es que el falso heredero vencido en el pleito debe restituir al verdadero el haz hereditario. No se señaló el plazo para restituir la herencia.

- En el intertanto, en que el heredero falso tuvo la cosa, ésta pudo haber mutado para bien o para mal o cambiado de manos.

- **Respecto de los frutos y mejoras se aplican las normas de prestaciones mutuas,** en virtud del 1266.

1. Restitución de los frutos. La buena fe del falso heredero consistirá en estar poseyendo la herencia con la creencia de ser verdadero heredero. Permanecerá de buena fe hasta la demanda del heredero peticionario. Se aplica también el 913: la buena o mal fe del poseedor se refiere, relativamente, a los frutos, al tiempo de la percepción.

- El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el verdadero heredero hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder. Si no existen los frutos, el falso heredero deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo de la percepción: se considerarán como no existentes los que se hayan deteriorado en poder del falso heredero vencido.

- El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda: en cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores.

En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos ordinarios que ha invertido en producirlos. El verdadero heredero para obtener los frutos, también hubiera debido efectuar dichos gastos. Por ello, resulta lógica la indemnización.

2. Abono de las mejoras. El verdadero heredero va a estar obligado a abonar ciertas mejoras al poseedor vencido.

a- Necesarias: todo poseedor tiene derecho para que se le abonen, ya que el verdadero heredero igualmente hubiera tenido que efectuarlas.

b- Útiles: el poseedor de buena fe tiene derecho a que se le abonen, pero el heredero puede elegir la forma de pagarlas, según el 909. El poseedor de mala fe no tiene derecho a que se le abonen, pero puede llevarse los materiales en que consistan las mejoras, siempre que sea posible sin detrimento de la cosa.

c- Voluptuarias: el verdadero heredero nunca está obligado a abonarlas. El poseedor, de buena o de mala fe tiene el derecho que tiene el poseedor de

mala fe en las útiles, es decir, llevarse los materiales siempre que no exista detrimento.

3. Indemnización de los deterioros. No rigen las normas de las prestaciones mutuas, debido a que existe una norma especial: **1267**.

a- El que de buena fe ocupó la herencia no será responsable de los deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hubieran hecho más rico. No se detuvo el legislador a explicar cuando se entiende hacerse más rico, razón por la cual se aplica por analogía el 1688: el falso heredero se hizo más rico cuando: (1) deterioros fueron útiles; (2) sin ser útiles, los conserva al momento de la demanda e insiste en retenerlos.

b- El que de mala fe ocupó la herencia, responde de todo el importe del deterioro. El 1267, a diferencia del 906 (dispone que sólo responde de los deterioros culpables), no limita los deterioros por los cuales responde, razón por la cual, responderá de todos los perjuicios, incluso los fortuitos.

4. Situación de las enajenaciones realizadas por el falso heredero.

1268: el heredero podrá hacer uso de la acción reivindicatoria sobre las cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros, y no hayan sido prescritas por ellos.

De esta manera, la enajenación en principio es válida, pero queda a salvo el derecho del verdadero heredero. Así, el verdadero heredero dirigirá la acción de petición de herencia contra el falso heredero y la acción reivindicatoria contra el poseedor.

La prescripción de la acción de petición de herencia puede haber prescrito. Sin embargo, ello no obsta al heredero para hacer valer la reivindicatoria cuando la cosa enajenada por el falso no se hubiera adquirido por prescripción.

Responsabilidad del falso heredero por las enajenaciones efectuadas. 1287.

- El que estaba de buena fe no responde de las enajenaciones, a menos que ellas lo hayan hecho más rico.

- Si estaba de mala fe, responde de todo el importe de las enajenaciones, se haya hecho o no más rico.

El verdadero heredero, en virtud del 1268, puede reivindicar contra el tercero adquirente, pero también puede dirigirse en contra del heredero putativo para que lo indemnice ampliamente.

ACCIÓN DE REFORMA DE TESTAMENTO	ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA
1. Procede cuando el testador desconoce ciertas asignaciones forzosas.	Procede cuando la herencia es poseída por un falso heredero.
2. Sólo procede en la testada.	Procede en ambas sucesiones.
3. Es una acción personal: procede contra los asignatarios instituidos por el testador en perjuicio de las asignaciones forzosas,	Es una acción real: puede dirigirse contra todo aquél que esté poseyendo la herencia sin ser el verdadero heredero.

principalmente de las legítimas.	
4. Corresponde sólo a los legitimarios.	Corresponde a todo heredero.
5. Objeto: modificar el testamento en la parte que perjudica las asignaciones forzosas.	Objeto: restitución de las cosas hereditarias.
6. Prescribe en 4 años contados desde que los asignatarios tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de tales, o desde que cesa su incapacidad.	Se extingue cuando el falso heredero adquiere la herencia por prescripción adquisitiva de 5 o 10 años.

A pesar de las diferencias, **no son acciones incompatibles**. Entablada la acción de reforma y acogida luego, quedará ocupada por un no heredero, siendo reclamada por la acción de petición de herencia.

Cuando un asignatario es obligado a devolver por resolución judicial de término todo o parte de una asignación recibida, tiene derecho a que la persona a cuyo favor se dictó el fallo le reintegre íntegra o proporcionalmente la suma que hubiere satisfecho en pago del impuesto.

LOS ALBACEAS O EJECUTORES TESTAMENTARIOS

1270: los ejecutores testamentarios o albaceas son aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones.

- **Naturaleza jurídica del albaceazgo.** Ha sido discutida. Parece evidente, para Somarriva, que el albacea es una especie de mandatario. Abonando a lo anterior, la expresión "encargo" de la definición. Asimismo el 2169 señala que no se extingue por la muerte del mandante el mandato destinado a ejecutarse después de ella. El albaceazgo es un mandato típico destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante.

Sin perjuicio de lo anterior, el albaceazgo, es un mandato muy especial, difiriendo del mandato ordinario:

1. Es solemne, debiendo otorgarse en el testamento mismo.
2. Aceptado el cargo de albacea, éste es irrevocable.
3. El albacea requiere plena capacidad.

Características del albaceazgo.

1. Es intransmisible
2. Es indelegable
3. El albacea no tiene otras atribuciones que las indicadas por la ley
4. El albaceazgo es remunerado
5. Es una institución a día cierto y determinado
6. Pueden existir varios albaceas
7. El albacea no está obligado a aceptar el cargo

1. Es intransmisible

1279. No se transmite a los herederos del albacea. Es la misma razón del 2163 No. 5, que hace expirar el mandato por la muerte del mandatario. Es lógico, por tratarse de un cargo intuitu persona.

2. Es indelegable

1280: el albaceazgo es indelegable, a menos que el testador haya concedido expresamente la facultad de delegarlo. El carácter indelegable del albaceazgo no se opone a que el albacea designe mandatarios en el desempeño de sus gestiones. 1280: el albacea, sin embargo, podrá constituir mandatarios que obren a sus órdenes, pero será responsable de las operaciones de éstos.

3. El albacea no tiene otras atribuciones que las indicadas por la ley

El legislador lo considera en ciertos aspectos como materia de orden público. 1298: El testador no podrá ampliar las facultades del albacea, ni exonerarle de sus obligaciones, según se hallan unas y otras definidas en este título.

4. El albaceazgo es remunerado

1302: corresponde, en primer lugar, al testador señalar la remuneración que va a corresponder al albacea. A falta de dicha determinación por el testador, el juez, tomando en consideración el caudal hereditario y el mayor o menor trabajo que ha demandado al albacea el desempeño de su cargo, deberá determinar la remuneración correspondiente. La remuneración constituye una **baja general de la herencia** (Art. 4 No. 2 Ley 16.271). CS: aun cuando el testamento sea declarado nulo, deben pagarse al albacea los gastos en que incurrió y la remuneración.

5. Es una institución a día cierto y determinado

Es un cargo a plazo fijo. Corresponde en primer lugar designar el plazo al testador. Frente al silencio de éste, la ley fija el plazo de 1 año contado desde el día en que el albacea comienza a ejercer el cargo. El juez, puede aumentar el plazo fijado por la ley o por testador, en ciertos casos.

6. Pueden existir varios albaceas

Siendo muchos, dicta normas para ver cómo deben actuar. Dichas normas son muy similares a las que establece el Código cuando existe pluralidad de guardadores.

- Los albaceas pueden dividir las funciones que les correspondan.
- Pueden obrar separadamente en virtud de autorización del testador.
- Si no han dividido sus funciones entre sí, deben obrar de consuno: uno de ellos lo hace a nombre de los otros, en virtud de un mandato.
- Existiendo pluralidad de albaceas, la responsabilidad entre ellos es solidaria, a menos que el testador los haya exonerado de esta responsabilidad solidaria, o que el mismo testador o juez hayan distribuido sus atribuciones y cada uno se ciña a las que le incumben.
- Cuando obran de consuno, subsiste la responsabilidad solidaria de los albaceas.
- También subsiste cuando el testador los autoriza a obrar separadamente, pero no divide sus funciones.

7. El albacea no está obligado a aceptar el cargo

1277: el albacea nombrado puede rechazar libremente el cargo. Es una diferencia con los tutores y curadores. Las guardas son cargos impuestos a ciertas personas; el albaceazgo no es una imposición.

Si el albacea, siendo a la vez asignatario del testador, rechaza el encargo sin probar inconveniente grave para desempeñarlo, se hace indigno para suceder al causante. 1277 y 971.

- **Determinación de plazo para que el albacea acepte el cargo.** 1276: el juez, a petición de interesado, fijará un plazo razonable dentro del cual comparezca el albacea a ejercer su cargo, o excusarse de servirlo, y podrá el juez, en caso contrario, ampliar por una sola vez el plazo. Si el albacea estuviere en mora de comparecer, caducará su nombramiento.

- **La aceptación del cargo de albacea puede ser expresa o tácita.** 1278. La aceptación tácita corresponde a la ejecución de cualquier acto que el albacea no podría haber ejecutado sino en su calidad de tal (aplicación analógica de la aceptación tácita de la herencia). Distinta es la situación del partidario, quien debe aceptar su cargo formal y expresamente.

- Capacidad para ser albacea.

1. Por regla general, sólo las personales naturales pueden ser albaceas.

Excepción: los Bancos pueden ser albaceas con o sin tenencia de bienes.

2. No pueden ser albaceas los menores de edad.

1272. Siendo incapaz de administrar sus propios bienes, mal podría administrar los ajenos.

3. Son incapaces las personas designadas en los artículos 497 y 498.

Estos preceptos establecen incapacidades para ser tutor o curador, y por ende para ser albacea.

1º Los ciegos;

2º Los mudos;

3º Los dementes, aunque no estén bajo interdicción;

4º Los fallidos mientras no hayan satisfecho a sus acreedores;

5º Los que están privados de administrar sus propios bienes por disipación;

6º Los que carecen de domicilio en la República;

7º Los que no saben leer ni escribir;

8º Los de mala conducta notoria;

9º Los condenados por delito que merezca pena aflictiva, aunque se les haya indultado de ella;

10º SUPRIMIDO

11. El que ha sido privado de ejercer la patria potestad según el artículo 271;

12. Los que por torcida o descuidada administración han sido removidos de una guarda anterior, o en el juicio subsiguiente a ésta han sido condenados, por fraude o culpa grave, a indemnizar al pupilo.

498: 3º Los que tienen que ejercer por largo tiempo, o por tiempo indefinido, un cargo o comisión pública fuera del territorio chileno.

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS ALBACEAS

Los albaceas sólo pueden ser testamentarios. La designación del albacea, sólo puede hacerse por testamento. 1271: no habiendo el testador nombrado albacea, o faltando el nombrado, el encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador, pertenece a los herederos.

Se clasifican en albaceas con y sin tenencia de bienes, y en fiduciarios y generales.

- **Albaceas generales:** propiamente tales: son los que estamos estudiando.
- **Albaceas fiduciarios:** designados para ejecutar los encargos secretos y confidenciales del testador.
- **Albaceas con tenencia de bienes**
- **Albaceas sin tenencia de bienes**

Las atribuciones y facultades difieren en uno y otro caso. Las facultades del albacea con tenencia de bienes son más amplias de las de quienes carecen de ella.

Atribuciones del Albacea

1298: el albacea no tiene más derechos ni obligaciones que las determinadas expresamente por la ley, no pudiendo ser ampliadas ni restringidas por el testador.

- Albacea sin tenencia de bienes.

A. Velar por la seguridad de los bienes de la sucesión.

Se refiere sobre todo a los muebles, dinero y papeles. 1284: Toca a el albacea velar sobre la seguridad de los bienes; hacer que se guarde bajo llave y sello el dinero, muebles y papeles, mientras no haya inventario solemne, y cuidar de que se proceda a este inventario, con citación de los herederos y de los demás interesados en la sucesión; salvo que siendo todos los herederos capaces de administrar sus bienes, determinen unánimemente que no se haga inventario solemne.

Al igual que el 1766 permite que no se haga inventario solemne. La solemnidad no se requerirá por la cuantía de los bienes, sino por la presencia de incapaces en la sucesión. Sin embargo, siempre es más conveniente la confección de inventario solemne, por 2 razones:

- a- Así los herederos gozarán del beneficio de inventario; y
- b- El inventario simple no tiene valor en juicio, sino en contra de las personas que lo hubieren debidamente aprobado y firmado (1766 es de aplicación general). El solemne, como es instrumento público, tiene valor contra terceros.

B. Pagar las deudas y legados.

1286: Sea que el testador haya encomendado o no a el albacea el pago de sus deudas, será éste obligado a exigir que en la partición de los bienes se señale un lote o hijuela suficiente para cubrir las deudas conocidas.

El albacea debe preocuparse que en la partición se forme la hijuela de deudas, o sea, que se indiquen los bienes con los cuales se van a pagar las deudas hereditarias.

Además el 1285 impone al albacea la obligación de dar noticia de la apertura de la sucesión por medio de 3 avisos, los cuales buscan informar del suceso a los acreedores, a fin de que hagan valer sus créditos que tenían contra el causante.

Los deberes de formar la hijuela pagadora de las deudas y de dar los avisos, pesa también sobre los herederos presentes que tengan la libre administración de sus bienes, o sobre los respectivos tutores y curadores, y el marido de la mujer heredera, que no está separada de bienes. Por no cumplirse con dichos deberes, deberán indemnizar todos los perjuicios que dichas omisiones irroguen a los acreedores.

Art. 1288. El albacea encargado de pagar deudas hereditarias, lo hará precisamente con intervención de los herederos presentes o del curador de la herencia yacente en su caso.

Art. 1289. Aunque el testador haya encomendado al albacea el pago de sus deudas, los acreedores tendrán siempre expedita su acción contra los herederos, si el albacea estuviere en mora de pagarles.

- **Pago de los legados.** El albacea no sólo debe encargarse del pago de las deudas hereditarias, sino que también del de los legados, a menos que el testador los haya impuesto a determinado heredero o legatario. Para ello, exigirá a los herederos o al curador de la herencia yacente el dinero que sea menester y las especies muebles o inmuebles en que consistan los legados, si el testador no le hubiere dejado la tenencia del dinero o de las especies.

Art. 1292. Si no hubiere de hacerse inmediatamente el pago de especies legadas y se temiere fundadamente que se pierdan o deterioren por negligencia de los obligados a darlas, el albacea a quien incumba hacer cumplir los legados, podrá exigirles caución.

En todo caso, los herederos pueden exonerarse de estas obligaciones, pagando ellos mismos los legados. 1290 inciso final: Los herederos, sin embargo, podrán hacer el pago de los dichos legados por sí mismos, y satisfacer a el albacea con las respectivas cartas de pago; a menos que el legado consista en una obra o hecho particularmente encomendado a el albacea y sometido a su juicio.

1291: pago de legados especiales.

- 1) Legados con objeto de beneficencia. El albacea debe dar conocimiento de ellos al ministerio público, quien perseguirá judicialmente a los herederos, legatarios o curador de la herencia yacente que, estando obligados a cumplir dicho legado, no lo hicieren. El ministerio público puede delegar esta función en el defensor de obras pías.
- 2) Legados destinados a obras de piedad religiosa. También el albacea debe dar cuenta de ellos al ministerio público y al ordinario eclesiástico, pudiendo este último implorar de la autoridad civil las providencias judiciales necesarias para que se cumplan los legados.
- 3) Legados de utilidad pública en que tenga interés el vecindario de una municipalidad. También debe advertir el albacea su existencia, pudiendo aquéllas perseguir su cobro.

- Enajenación por el albacea de bienes de la sucesión.

Art. 1293. Con anuencia de los herederos presentes procederá a la venta de los muebles, y subsidiariamente de los inmuebles, si no hubiere dinero suficiente para el pago de las deudas o de los legados; y podrán los herederos oponerse a la venta, entregando a el albacea el dinero que necesite al efecto.

En principio, los albaceas no están facultados para enajenar bienes de la sucesión, a menos que ello sea indispensable para el pago de las deudas y legados, y los herederos no los provean de los fondos necesarios para ello.

Art. 1294. Lo dispuesto en los artículos 394 y 412 se extenderá a los albaceas.

La venta debe hacerse en pública subasta.

C. Ciertas atribuciones judiciales.

1295: el albacea no podrá parecer en juicio en calidad de tal, sino para defender la validez del testamento, o cuando le fuere necesario para llevar a efecto las disposiciones testamentarias que le incumban; y en todo caso lo hará con intervención de los herederos presentes o del curador de la herencia yacente.

Sus facultades judiciales son reducidas, pues sólo puede comparecer en juicio por motivos muy calificados, siendo sólo 2:

- a- Defender la validez del testamento; y
- b- Cuando fuere necesario para llevar a cabo las disposiciones testamentarias que le incumban.

En todo caso, deberá hacerlo con la intervención de los herederos presentes o del curador de la herencia yacente.

- Los acreedores y legatarios no pueden demandar al albacea el pago de las deudas y legados, sino que deben dirigirse en contra de los herederos.

- Albacea con tenencia de bienes.

1296: el testador podrá dar a los albaceas la tenencia de cualquier parte de los bienes o de todos ellos.

1297: confiere ciertas facultades a los asignatarios, pues establece que los herederos, legatarios o fideicomisarios, en el caso de justo temor sobre la seguridad de los bienes de que fuere tenedor el albacea, y a que respectivamente tuvieren derecho actual o eventual, podrán pedir que se le exijan las debidas seguridades.

1296 incisos 2º y final: El albacea tendrá en este caso las mismas facultades y obligaciones que el curador de la herencia yacente; pero no será obligado a rendir caución sino en el caso del artículo 1297.

Sin embargo, de esta tenencia habrá lugar a las disposiciones de los artículos precedentes.

Así, el albacea con tenencia de bienes tiene un doble tipo de derechos y obligaciones:

1- Los del curador de la herencia yacente. El albacea ejercerá las mismas funciones que tendría el curador de la herencia yacente. Sin embargo, a diferencia de los curadores, el albacea con tenencia de bienes no está obligado a rendir caución, salvo el caso en que los herederos o legatarios lo exijan.

2- Los del albacea sin tenencia de bienes.

- **Facultades judiciales del albacea con tenencia de bienes.** Los curadores de la herencia yacente tienen facultades judiciales más amplias que los de los albaceas sin tenencia de bienes. El primero puede cobrar créditos y ser demandado por el pago de las deudas hereditarias. Por la aplicación de lo anterior, el albacea con tenencia de bienes ¿Tendrá las facultades judiciales del curador de la herencia yacente, o del albacea sin tenencia de bienes? El problema se presenta por la letra del 1296, ya que señala que aunque el albacea tenga la tenencia de los bienes, rigen para él los artículos precedentes.

Sin embargo, a pesar de la letra de la ley, Somarriva piensa que el albacea con tenencia de bienes tiene en materia judicial las facultades del curador de la herencia yacente. De no ser así, los acreedores hereditarios no tendrían contra quién dirigirse.

Prohibiciones a las que están sujetos los albaceas.

1. Llevar a cabo disposiciones testamentarias contrarias a la ley.

1301: Se prohíbe a el albacea llevar a efecto ninguna disposición del testador en lo que fuere contraria a las leyes, so pena de nulidad, y de considerársele culpable de dolo.

Es contrario a la RG: en este caso se presume el dolo. La importancia de considerarse doloso al albacea, está en el 1300: puede ser removido de su cargo. Los herederos o el curador de la herencia yacente estarán eximidos de probar el dolo, siendo una presunción simplemente legal.

2. Celebrar ciertos actos con la sucesión.

Se aplica a los albaceas la prohibición contenida en el 412: impide a los tutores y curadores celebrar determinados actos en los que tenga interés el pupilo.

Los albaceas, por tanto, no pueden celebrar con la sucesión ningún acto o contrato en que él tenga interés, sin autorización de los demás albaceas que no estén implicados de la misma manera o del juez en subsidio. Se extiende a los intereses del cónyuge del albacea, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes o de sus hermanos, o de sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o alguno de sus socios de comercio.

Respecto de los inmuebles de la sucesión, existe norma especial: el albacea no puede comprarlos o tomarlos en arrendamiento ni aun con autorización de los demás albaceas o del juez, extendiéndose la prohibición a su cónyuge, y a sus ascendientes o descendientes. La jurisprudencia ha establecido que esta prohibición no rige cuando el albacea es heredero. En dicho caso, puede comprar bienes de la sucesión y puede adjudicársele al albacea heredero inmuebles en pago de sus derechos hereditarios.

- Sanción en caso de que el albacea compre bienes de la sucesión.

Existe conflicto entre dos preceptos del Código.

- 412: prohíbe a los albaceas ejecutar ciertos actos o contratos, entre los que se encuentra la compraventa. Siendo una prohibición, su contravención acarrea la nulidad absoluta.

- 1800: los albaceas están sujetos al 2144. El precepto prohíbe al mandatario comprar bienes del mandante, salvo si éste lo ha autorizado para ello. En tal caso, si se actúa en contra de este precepto, no sería sancionado con la nulidad (no es absoluta, porque no es prohibitivo; la jurisprudencia ha estimado que sea la relativa), sino con la inoponibilidad.

Somarriva cree que debe aplicarse el 1800 con relación al 2144, por las siguientes razones:

- Es verdad que el albaceazgo no es un mandato, pero tiene gran analogía con él.
- La prohibición absoluta del 412 es explicable por la incapacidad del pupilo. No se ve inconveniente para que el albacea adquiera bienes de la herencia, con el consentimiento de los herederos.
- El 1800 es especial, por referirse únicamente a la compraventa y no como el 412, que se refiere a una serie de actos.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ALBACEA

- La primera obligación del albacea es llevar a cabo el encargo que le ha hecho el testador de hacer ejecutar las disposiciones testamentarias. 1278-1º.
- Las obligaciones en el desempeño de su encargo las analizamos anteriormente: velar por la seguridad de los bienes y por la confección de inventario solemne; avisar la apertura de la sucesión; exigir la formación de la hijuela pagadora de deudas; pago de los legados.

- **Responsabilidad del albacea. 1299:** el albacea es responsable hasta de culpa leve en el desempeño de su cargo. RG respecto del que administra bienes ajenos. En caso de ser plurales los albaceas, responderán solidariamente: se trata de un caso de **solidaridad pasiva legal**.

- **Rendición de cuentas por el albacea. 1309:** el albacea, luego que cese en el ejercicio de su cargo, dará cuenta de su administración, justificándola. No puede el testador relevarle de esta obligación. Esto último no debió decirlo la ley, ya que el 1298 señala que el testador no puede ampliar ni restringir las obligaciones del albacea.

El albacea puede rendir cuentas de 2 formas:

1- Por propia iniciativa: puede hacerlo a su arbitrio ante la justicia ordinaria, o si existe juicio de partición, ante el partidor. La rendición de cuentas la hará a los herederos, y si la herencia es yacente, al curador de ésta.

2- Puede ser obligado judicialmente a rendirla, por los herederos o por los legatarios, según lo ha dicho la jurisprudencia.

- Saldo a favor o en contra del albacea. 1310: El albacea, examinadas las cuentas por los respectivos interesados, y deducidas las expensas legítimas, pagará o cobrará el saldo, que en su contra o a su favor resultare, según lo prevenido para los tutores y curadores en iguales casos. Se aplicará según el 424: el tutor o curador pagará los intereses corrientes del saldo que resulte en su contra, desde el día en que su cuenta quedare cerrada o haya habido mora en recibirla, y cobrará a su vez los del saldo que resulte a su favor, desde el día en que cerrada su cuenta, los pida.

Así, los intereses corren en contra del albacea de pleno derecho, siendo necesario el requerimiento judicial del albacea para que corran en contra de los herederos.

EXTINCIÓN DEL ALBACEAZGO

El albaceazgo puede terminar de varias maneras, principalmente:

1. Llegada del plazo.

El albaceazgo es un cargo a día cierto y determinado. El plazo se determina en primer lugar por el testador, y en su silencio lo determina la ley (1 año desde que comienza a ejercerlo). El 1305 autoriza al juez para prorrogar, tanto el plazo del testador como el legal subsidiario, cuando por dificultades graves no pudiere el albacea evacuar dentro de él, el encargo que se le ha confiado. La jurisprudencia ha dicho que los herederos no pueden prorrogar el plazo.

1306: El plazo prefijado por el testador o la ley, o ampliado por el juez, se entenderá sin perjuicio de la partición de los bienes y de su distribución entre los partícipes.

2. Cumplimiento del encargo.

Art. 1307. Los herederos podrán pedir la terminación del albaceazgo, desde que el albacea haya evacuado su cargo; aunque no haya expirado el plazo señalado por el testador o la ley, o ampliado por el juez para su desempeño.

Art. 1308. No será motivo ni para la prolongación del plazo, ni para que no termine el albaceazgo, la existencia de legados o fideicomisos cuyo día o condición estuviere pendiente; a menos que el testador haya dado expresamente a el albacea la tenencia de las respectivas especies o de la parte de bienes destinados a cumplirlos; en cuyo caso se limitará el albaceazgo a esta sola tenencia.

Lo dicho se extiende a las deudas, cuyo pago se hubiere encomendado a el albacea, y cuyo día, condición o liquidación estuviere pendiente; y se entenderá sin perjuicio de los derechos conferidos a los herederos por los artículos precedentes.

3. Remoción del albacea por culpa o dolo.

Art. 1300. Será removido por culpa grave o dolo, a petición de los herederos o del curador de la herencia yacente, y en caso de dolo se hará indigno de tener en la sucesión parte alguna, y además de indemnizar de cualquier perjuicio a los interesados, restituirá todo lo que haya recibido a título de retribución.

Es una excepción al principio general de que la culpa grave se equipara al dolo, ya que si incurre en culpa grave, es removido de su cargo, y si incurre con dolo, además de lo anterior queda sujeto a las otras sanciones designadas en el artículo.

4. Incapacidad sobreviniente del albacea.

1275: la incapacidad sobreviniente pone fin al albaceazgo. Es decir, cuando le sobreviene alguna casual de incapacidad, termina el albaceazgo.

5. Muerte del albacea.

1279: el albaceazgo no se transmite a los herederos del albacea.

6. Renuncia del albacea.

1278: se desprende que el albacea puede renunciar a su cargo. La dimisión del cargo con causa legítima le priva sólo de una parte proporcionada de la asignación que se le haya hecho recompensa del servicio.

7. Por la no aceptación del cargo en el plazo fijado por el juez.

1276: el juez, a petición de interesado en la sucesión, procede a fijar plazo para que el albacea acepte el cargo. Si éste no lo hace en el plazo, caduca el albaceazgo.

EL ALBACEAZGO FIDUCIARIO⁴²

1311: El testador puede hacer encargos secretos y confidenciales al heredero, a el albacea, y a cualquiera otra persona, para que se invierta en uno o más objetos lícitos una cuantía de bienes de que pueda disponer libremente.

El encargado de ejecutarlos se llama albacea fiduciario.

Albacea fiduciario: es aquella persona a quien el testador le encarga cumplir algunas disposiciones secretas suyas.

- **El albacea fiduciario no es un asignatario modal.** En la asignación modal el asignatario no lo es la persona favorecida con el modo, sino aquella a quien se impone la carga de cumplirlo. En el albaceazgo fiduciario ocurre lo contrario: el albacea fiduciario no es él asignatario en cuanto a albacea (aunque nada impide que sea a la vez asignatario del causante), sino que los asignatarios son las personas favorecidas con los encargos secretos.

- **No es necesario que el asignatario en el albaceazgo fiduciario sea persona cierta y determinada.** 1056 exige que todo asignatario testamentario sea persona cierta y determinada. Pero por la naturaleza secreta de la institución, en el albaceazgo fiduciario no se aplica este requisito.

- **Requisitos del albaceazgo fiduciario.** 1312: los indica:

1. **Debe designarse en el testamento la persona del albacea fiduciario.** 1312 regla 1ª.
2. **El albacea fiduciario debe cumplir las exigencias para ser albacea y legatario.** 1312 regla 2ª: debe cumplir 2 requisitos: (a) reunir las calidades necesarias para ser albacea; y (b) reunir las calidades necesarias para ser legatario. De no ser así, se dejaría paso a que el testador dejara encargos secretos inexistentes a un albacea fiduciario incapaz de sucederle.
3. **Deben individualizarse en el testamento los bienes que han de entregarse al albacea fiduciario para el cumplimiento de los encargos secretos.** 1312 regla 3ª. Deben expresarse en el testamento las especies o sumas de dinero que el testador destina al cumplimiento de los encargos secretos.

Faltando cualquiera de los 3 requisitos, no vale la disposición. **1312 inciso final.**

- **Cantidad máxima que puede destinarse a encargos secretos.**

1313: No se podrá destinar a dichos encargos secretos, más que la mitad de la porción de bienes de que el testador haya podido disponer a su arbitrio.

Por tanto, hay que distinguir:

a- Si el testador no tiene legitimarios, puede disponer de la mitad de sus bienes para los encargos secretos; y

b- Si existen legitimarios, sólo podrá disponer de 1/8 a encargos secretos.⁴³

La jurisprudencia ha dicho que lo dejado en contra de las reglas precedente, vicia la disposición en el exceso, siendo válida hasta el límite máximo legal.

- **¿Puede dejarse una asignación a título universal para destinarla a encargos secretos? O sólo se pueden dejar legados?** La jurisprudencia ha sido vacilante en torno a la validez de las asignaciones a título universal para destinarla a encargos secretos. Al parecer pareciera orientarse en el sentido de que no pueden destinarse para encargos secretos y confidenciales asignaciones a título universal, basados en 2 argumentos:

a- No cumplirse con la regla 3ª del 1312 que señala que deben indicarse las especies o la suma de dinero que se destina a los encargos secretos.

b- Porque la regla 2ª señala que el albacea fiduciario debe reunir los requisitos de albacea y de legatario.

- **Juramento del albacea fiduciario.** 1314: obligación fundamental: juramento del albacea fiduciario. El albacea fiduciario deberá jurar ante el juez **(1)** que el encargo no tiene por objeto hacer pasar parte alguna de los bienes del testador a una persona incapaz⁴⁴, o **(2)** invertirla en un objeto ilícito.

Jurará al mismo tiempo **(3)** desempeñar fiel y legalmente su cargo sujetándose a la voluntad del testador.

La prestación del juramento deberá preceder a la entrega o abono de las especies o dineros asignados al encargo.

Si el albacea fiduciario se negare a prestar el juramento a que es obligado, caducará por el mismo hecho el encargo.

⁴² A diferencia de los albaceas generales (cuyo origen está en el derecho español), los albaceas fiduciarios tienen su antecedente en el derecho romano.

⁴³ Somarriva señala que puede destinar 1/4 de la cuarta parte de la herencia a los encargos secretos, es decir, sería 1/16. Creo que va en contra del tenor literal.

⁴⁴ No se refiere al indigno, porque se entiende que si el testador lo instituye al indigno, estaría perdonándolo.

- El albacea fiduciario no puede ser obligado a revelar el encargo ni a rendir cuenta.

Art. 1316. El albacea fiduciario no estará obligado en ningún caso a revelar el objeto del encargo secreto, ni a dar cuenta de su administración.

Se diferencian en ello de los generales, quienes siempre están obligados a rendir la cuenta.

- Caso en que el albacea fiduciario está obligado a rendir caución. La única obligación del albacea fiduciario es prestar juramento. Sin embargo, el albacea fiduciario podrá ser obligado, a instancia de un albacea general, o de un heredero, o del curador de la herencia yacente, y con algún justo motivo, a dejar en depósito, o afianzar la cuarta parte de lo que por razón del encargo se le entregue, para responder con esta suma a la acción de reforma o a las deudas hereditarias, en los casos prevenidos por ley.

Podrá aumentarse esta suma, si el juez lo creyere necesario para la seguridad de los interesados.

Expirados los cuatro años subsiguientes a la apertura de la sucesión, se devolverá a el albacea fiduciario la parte que reste, o se cancelará la caución.

El objeto de lo anterior, es **proteger a los legitimarios y a los acreedores testamentarios**, de los encargos secretos.

- Aplicación de las reglas de los albaceas generales a los fiduciarios. Aun cuando la ley no lo dice expresamente, Somarriva considera que en lo que no se oponga a la naturaleza misma del albaceazgo fiduciario, deben aplicarse las normas de los albaceas generales. El mismo criterio sostiene la jurisprudencia: el albacea fiduciario no puede comparecer en juicio para cobrar un crédito de la sucesión.

LA PARTICIÓN DE BIENES

Existiendo varios herederos, se forma entre ellos, al fallecimiento del causante, un estado de indivisión respecto a los bienes dejados por éste. La **partición** viene a poner fin a dicho estado, asignando a cada cual bienes equivalentes a sus derechos en la indivisión.

La indivisión no sólo se presenta en la sucesión por causa de muerte. Se produce en general, cuando tienen derecho de cuota sobre una misma cosa dos o más personas, siendo los derechos de los titulares de análoga naturaleza.

La indivisión se clasifica en: 1) a título singular; y 2) a título universal. Dicha clasificación emana del artículo **1317**: “ninguno de los coasignatarios de una *cosa universal o singular* estará obligado”. Generalmente cuando la indivisión recae en una cosa singular se habla de **copropiedad**, y si lo hace sobre una universalidad –como es el caso de la indivisión hereditaria- se habla de **comunidad**⁴⁵.

Andrés Bello era reacio a la mantención del estado de indivisión. Se opina que el mantener bienes en comunidad generaba dificultades respecto a la administración de la cosa, impedía maximizar la productividad de los bienes en virtud de la incertidumbre sobre su destino final y propendía a que los mismos se descuidaran, distinto el caso o al resguardo que se tiene sobre las cosas que se detentan individualmente.

El CC trata de la indivisión en numerosos artículos, pero principalmente a propósito del cuasicontrato de comunidad. Estas normas han sido

⁴⁵ Peñailillo distingue entre los conceptos de copropiedad para definir a los casos de indivisión en que se encuentran dos o más sujetos respecto al derecho de dominio sobre una misma cosa y de comunidad para designar a la indivisión que se produce respecto a otros derechos reales distintos del dominio.

complementadas especialmente por las normas del **CPC** al tratar del Juicio de Partición de Bienes, donde incluso se dan **normas de carácter sustantivo**, como lo son por ejemplo, las que tratan de la administración de los bienes comunes.

El CC concibe la indivisión como un estado de transición hacia el dominio individual.

El indivisario, durante la indivisión, tiene un derecho de cuota sobre bienes indivisos, que no se radica en bienes determinados, sino que está "flotante" o indeterminado. Por medio de la partición, esa cuota ideal y abstracta pasa a radicarse en bienes determinados.

CS: partición de bienes: conjunto complejo de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión mediante la liquidación y distribución entre los copartícipes del caudal poseído proindiviso en partes o lotes que guarden proporción con los derechos cuotativos de cada uno de ellos.

- El CC trata de la partición en los artículos 1317 y siguientes.
- El CPC, lo reglamenta en los artículos 645 a 666, incluyendo preceptos sustantivos.

La partición se va a aplicar cada vez que exista un estado de indivisión, razón por la cual las normas de partición, se aplicarán no solamente a la partición de bienes hereditarios como podría pensarse por su ubicación. Así las reglas de la partición de bienes se aplicarán:

1. A la liquidación de la **comunidad hereditaria**;
2. A la liquidación de la **sociedad conyugal**: 1776: la división de los bienes sociales se sujetará a las reglas dadas para la partición de los bienes hereditarios.
3. A la partición de las cosas comunes en caso que exista un **cuasicontrato de comunidad**. 2313 establece que a la división de las cosas comunes se aplican las normas del Libro III.
4. A la liquidación de las **sociedades civiles**. 2115 hace aplicables las reglas del Libro III.

Conclusión: las reglas del Título X, del Libro III, son de aplicación general para toda clase de indivisión, sea cual sea su origen.

DE LA PARTICIÓN EN GENERAL

La partición pueden efectuarla:

1. El causante
2. Los coasignatarios de común acuerdo
3. Un árbitro de derecho denominado partidador

La Acción de Partición

La partición de bienes es provocada por el ejercicio de la acción de partición. La denominación "acción de partición" parece estar indicando la exigencia de un juicio para poder verificar la liquidación y distribución de los bienes comunes. Ello **no es exacto**. La partición puede hacerse sin intervención de la justicia, ya sea por el propio causante o por los coasignatarios de común acuerdo. Por ello, Somarriva considera que es más propio hablar del **derecho a pedir la partición**, sin perjuicio de permitirse la denominación "acción de partición" por su larga data.

La acción de partición está consagrada en el **inciso 1º del art. 1317**: "ninguno de los coasignatarios de la cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión: la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario".

Acción de partición: aquella que compete a los coasignatarios para solicitar que se ponga término al estado de indivisión.

De esta forma, el ejercicio de la acción de partición es la forma de poner en marcha ésta.

- Características de la acción de partición.

1. Es una acción personal.

Deberá entablarse en contra de todos y cada uno de los restantes comuneros. Si se efectúa con exclusión de alguno, no afectará al excluido, siéndole inoponible.

2. Es imprescriptible e irrenunciable.

A pesar de ser patrimonial, presenta las características mencionadas por el tenor del artículo 1317: "podrá siempre pedirse". No corre prescripción alguna en su contra y, por estar comprometido el interés público, no puede renunciarse.

3. El ejercicio de la acción de partición es un derecho absoluto.

No cabe hablar de la relatividad del mismo ni aplicar la doctrina del abuso del derecho. El legislador no miró con buenos ojos la indivisión, principalmente por ser fuente fecunda de dificultades entre los comuneros. Asimismo por una razón de eficiencia: quien tiene un derecho en una cosa común jamás tendrá el mismo interés de aquél que es dueño absoluto.

4. La acción de partición no viene, como ocurre generalmente con las acciones judiciales, a declarar una situación existente, pero

controvertida, sino que produce una verdadera transformación de la situación jurídica anterior: el derecho de los coasignatarios sobre los bienes indivisos se radica en cosas determinadas.

- Hechos que impiden el ejercicio de la acción de partición.

1. Pacto de indivisión

1317 señala que siempre puede pedirse la partición "con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario". 1317 inciso 2º: "No puede estipularse proindivisión por más de 5 años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto".

El legislador sigue mirando con malos ojos la indivisión, a pesar de permitirla:

- Art. 57 de la Ley 16.271: para que la sucesión pueda pactar la indivisión, es necesario que se haya pagado o asegurado, suficientemente el impuesto correspondiente.

- Fijación de un plazo máximo por el cual puede celebrarse el pacto de indivisión. Si se estipula un plazo que supere los 5 años, será inoponible en el exceso: no obligaría a los comuneros a seguir indivisos.

- El testador no puede imponer a los herederos la indivisión. En virtud del 1317 sólo los coasignatarios pueden estipular la indivisión y como éste es excepcional, no admite interpretación analógica. Asimismo se habla de "estipulación", y el testador estaría haciendo una declaración unilateral.

2. Casos de indivisión forzada

1317 inciso final: Las disposiciones precedentes no se extienden a (1) los lagos de dominio privado, ni (2) a los derechos de servidumbre (826 y 827), ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como (3) la propiedad fiduciaria (751).

Al decir "como", establece a la propiedad fiduciaria como un ejemplo de las cosas que la ley manda a mantener indivisas. Otros casos son:

(4) La medianería: 858: si el propietario de un muro medianero quiere eximirse de los gastos de conservación del cerramiento, deberá abandonarlo. Además está tratada dentro de las servidumbres, que son indivisibles.

(5) Copropiedad inmobiliaria, respecto de los bienes necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio, los que permitan a todos y cada uno de los copropietarios el uso y goce de las unidades de su dominio exclusivo, y los terrenos y espacios de dominio común colindantes con una unidad del condominio.

(6) Tumbas y mausoleos: su naturaleza jurídica ha sido discutida.

3. Indivisión de ciertos predios rústicos. DL 3516

4. Indivisión del hogar obrero. Es un antecedente de la llamada propiedad familiar, que fue definitivamente establecida por la Ley 19.335. Hoy no hay indivisión forzada

- Quiénes pueden ejercitar la acción de partición:

1. **Comuneros o indivisarios.** En el caso que nos convoca se trata de los herederos, cualquiera que sea su categoría: universales, de cuota, de remanente, testamentarios o abintestato, voluntarios o forzosos. El legatario no puede ejercerla, ya que el legislador no se la otorga en ningún sentido.
2. **Herederos de los coasignatarios.** 1321: si falleciere uno de varios coasignatarios, después de habérsele deferido la asignación, cualquiera de los herederos de éste podrá pedir la partición; pero formarán en ella una sola persona, y no podrán obrar sino todos juntos o por medio de un procurador común. Está en estrecha relación con el 957 que establece el derecho de transmisión.
3. **El cesionario de los derechos de algún coasignatario.** 1320: Si un coasignatario vende o cede su cuota a un extraño, tendrá éste igual derecho que el vendedor o cedente para pedir la partición e intervenir en ella.
El cesionario pasa a ocupar el mismo lugar jurídico que el cedente, pasando a reemplazarlo en todos sus derechos y obligaciones. Así vimos que, debe otorgársele la posesión efectiva, puede entablar la acción de reforma de testamento y la acción de petición de herencia y también la partición. La ley no hace distinción en cuanto al título que antecede a la cesión.

Existe un fallo aislado que declara que los cesionarios de cuotas mínimas de un heredero no son partes en el juicio de partición, pudiendo actuar sólo como coadyuvantes.

- Situación del asignatario sujeto a condición suspensiva.

Art. 1319. Si alguno de los coasignatarios lo fuere bajo condición suspensiva, no tendrá derecho para pedir la partición mientras penda la condición. Pero los otros coasignatarios podrán proceder a ella, asegurando competentemente al coasignatario condicional lo que cumplida la condición le corresponda. Si el objeto asignado fuere un fideicomiso, se observará lo prevenido en el título De la propiedad fiduciaria.

En el caso del fideicomiso, la acción de partición sólo corresponderá al propietario fiduciario y no al fideicomisario, porque su derecho está sujeto a condición. Ej. Dejo 1/3 a Juan, 1/3 a Pedro y 1/3 a Diego, pasando la cuota de éste último a Antonio cuando se reciba de abogado. La acción de partición la puede ejercer Diego por ser el fiduciario.

En caso de que sean todos propietarios fiduciarios, no se puede solicitar la partición, por tratarse de un caso de indivisión forzada. Ej. Dejo mis bienes a Pedro, Juan y Diego, con la condición de que ellos pasen a Antonio cuando se reciba de abogado.

- ¿Pueden los acreedores de los herederos solicitar la partición? 524 y 519 CPC

519 inciso 1º: los demás comuneros se oponen a la ejecución haciendo valer sus derechos en la indivisión.

524: en el caso del inciso 1º del 519, el acreedor puede dirigir su acción sobre la parte o cuota de en la comunidad que corresponda al deudor para que enajene sin previa liquidación, o bien exigir que, con intervención suya, se liquide la comunidad.

De esta manera, el acreedor podría pedir a su arbitrio a enajenación de la cuota del deudor, o la liquidación de la comunidad, lo que parece estar indicando que puede ejercer la acción de partición.

Sin embargo, según el propio 524, no puede hacerlo en 2 casos: si existe motivo legal que impida la partición, o cuando, de llevarla a cabo, se siguiere grave perjuicio. En dichos casos, los comuneros pueden oponerse a la solicitud del acreedor.

- Capacidad para ejercitar la acción de partición.

Los incapaces, para deducir la acción de partición, deberán hacerlo por intermedio o con autorización de sus representantes legales. En ello, se siguen las reglas generales.

La acción de partición no es en sí misma un acto de enajenación, pero significa, en todo caso, un cambio radical en los derechos de los coasignatarios. Por ello, el legislador sujeta a los representantes legales a una **limitación** para solicitar la partición de los bienes del pupilo.

Art. 1322. Los tutores y curadores, y en general los que administran bienes ajenos por disposición de la ley, no podrán proceder a la partición de las herencias o de los bienes raíces en que tengan parte sus pupilos, sin autorización judicial.

La omisión de este requisito produce la **nulidad relativa** de la partición, por tratarse de una formalidad exigida en atención a la calidad de incapaz de la persona.

- Situación especial de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal.

1322 inciso 2º: Pero el marido no habrá menester esta autorización para provocar la partición de los bienes en que tenga parte su mujer: le bastará el consentimiento de su mujer, si ésta fuere mayor de edad y no estuviere imposibilitada de prestarlo, o el de la justicia en subsidio.

La divorciada y la separada judicialmente podrán ejercer la acción por sí solas.

Si el marido la solicita sin el consentimiento de la mujer, la sanción sería la nulidad relativa.

Hoy se pueden presentar las siguientes situaciones:

- a- Negativa injustificada del marido a solicitar la partición de la herencia de la mujer. Se aplica el **138 bis**: el juez, con citación del marido, puede autorizar a la mujer para actuar por sí misma, caso en el cual, ésta obligará sus bienes propios y los activos de sus patrimonios especiales, sin obligar los bienes del haber social

ni los propios del marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubieran reportado del acto.

- b- Impedimento del marido. Se aplica el **138**: si es de larga o indefinida duración el impedimento, se suspende la administración del marido y se aplican las normas de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Si no fuere de larga o indefinida duración, la mujer puede actuar con autorización judicial con conocimiento de causa, cuando de la demora se siga perjuicio. En tal situación obliga los bienes del marido y los sociales, tal como si fuera un acto del marido. También obliga los suyos propios, hasta la concurrencia del beneficio particular.
- c- Actuación de la mujer con autorización del marido. Aunque la ley no contemple esta situación, Somarriva estima que si puede actuar la mujer con autorización del marido.
- d- ¿Puede la mujer pedir por sí sola la partición sin autorización del marido? No hay solución expresa en la ley. Somarriva cree que si es posible, debido a que la mujer casada en sociedad conyugal es plenamente capaz. El efecto sería que sólo obligaría los bienes que ella administra.

- Los representantes legales requieren de la aprobación judicial y el marido del consentimiento de la mujer, sólo cuando sean ellos quienes ejerciten la acción de partición. Así se desprende del 1322 que habla de **provocar la partición**, y del 396. Si otro comunero la provocó no es necesario.
- La jurisprudencia es uniforme en torno a que si se hace la partición de común acuerdo entre los coasignatarios, ni se requiere de la autorización judicial, porque en tal caso no se provoca la partición, es decir, no se ejercita propiamente la partición.

Formas de Hacer la Partición

Como ya lo señaláramos, la partición puede hacerse de 3 formas:

1. Puede hacerla el propio testador
2. Pueden hacerla los coasignatarios de común acuerdo
3. Puede efectuarse mediante la designación de un juez árbitro, llamado partidador

1. Partición hecha por el propio causante.

Art. 1318. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. En especial, la partición se considerará contraria a derecho ajeno si no ha respetado el derecho que el artículo 1337, regla 10ª, otorga al cónyuge (y al conviviente civil sobreviviente en virtud de la ley 20.830 de acuerdo de unión civil.).

Por tanto, el testador puede hacer la partición en 2 ocasiones:

- I- Por acto entre vivos. El legislador no sujeta la partición a solemnidad alguna en este caso. Hay quienes piensan que debe hacerse por

escritura pública, porque si el legislador, en el 1324, exige este requisito para que el causante nombre partidador por acto entre vivos, con mayor razón se requerirá dicho instrumento para hacer la partición. Pero como las solemnidades son de derecho estricto, es preciso concluir que no se requiere escritura pública ni solemnidad alguna.

II- Por testamento. Deberá cumplir las solemnidades propias del acto testamentario.

Se pasará por la partición hecha por el causante **en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno**. Esta frase quiere decir que el testador, al efectuar la partición, no puede menoscabar las asignaciones forzosas y en especial las legítimas.

El inciso final quiere decir que se considerará especialmente contraria a derecho la partición que no ha respetado el derecho preferente del cónyuge sobreviviente (y a partir de la ley 20680 al conviviente civil sobreviviente) de adjudicarse el inmueble en que reside.

Art. 1342. Siempre que en la partición de la masa de bienes, o de una porción de la masa, tengan interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderados, o personas bajo tutela o curaduría, será necesario someterla, terminada que sea, a la aprobación judicial.

Somarriva considera que este precepto, por su carácter general se debe aplicar también al caso en que el testador efectúe la partición.

2. Partición hecha de común acuerdo por los coasignatarios.

Anteriormente no podía efectuarse cuando entre los coasignatarios hubiere incapaces. La ley 10.271 modificó el 1325, ya modificado tácitamente por el 645 del CPC.

Art. 1325. Los coasignatarios podrán hacer la partición por sí mismos si todos concurren al acto, aunque entre ellos haya personas que no tengan la libre disposición de sus bienes, siempre que no se presenten cuestiones que resolver y todos estén de acuerdo sobre la manera de hacer la división.

Serán, sin embargo, necesarias en este caso la tasación de los bienes por peritos y la aprobación de la partición por la justicia ordinaria del mismo modo que lo sería si se procediere ante un partidador.

Los coasignatarios, aunque no tengan la libre disposición de sus bienes, podrán nombrar de común acuerdo un partidador. Esta designación podrá recaer también en alguna de las personas a que se refiere el artículo anterior, con tal que dicha persona reúna los demás requisitos legales.

Los partidadores nombrados por los interesados no pueden ser inhabilitados sino por causas de implicancia o recusación que hayan sobrevenido a su nombramiento.

Si no se acuerdan en la designación, el juez, a petición de cualquiera de ellos, procederá a nombrar un partidador que reúna los requisitos legales, con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Civil.

Requisitos para que los indivisarios efectúen la partición de común acuerdo:

a- No debe existir cuestiones previas que resolver.

No debe existir controversias respecto a quiénes son los interesados, a los derechos de cada cual y sobre cuáles son los bienes comunes que se van a partir.

b- Las partes deben estar de común acuerdo sobre la forma de realizar la partición.

c- Tasación de los bienes.

Es necesaria la tasación de los peritos y la aprobación de la partición por la justicia ordinaria del mismo modo que lo serían su se procediera ante un partidor.

En conformidad al 1335 del CC la tasación de los bienes tenía que hacerse ante peritos, y sólo podían hacerla de común acuerdo los coasignatarios cuando todos fueran capaces. No podía omitirse la tasación pericial si había incapaces interesados en la partición. El artículo **657 CPC** modificó esta situación y establece una serie de casos en que aun existiendo incapaces, puede omitirse la tasación pericial y hacerse ésta de común acuerdo por los interesados. Se trata de 3 casos:

- a- Cuando se trata de tasar bienes muebles. Esta tasación pueden hacerla libremente los interesados de común acuerdo.
- b- Cuando se trata de bienes raíces, siempre que se trate de fijar un mínimo para la subasta del mismo. No existe peligro para los intereses de los incapaces, ya que el valor final estará dado por la puja de los licitadores en la subasta pública.
- c- Cuando aun tratándose de inmuebles existan en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes. (Es necesario que exista más de 1 antecedente: "antecedentes"). Naturalmente que en este caso no figurarán en los "autos", porque no existe juicio, sino en la respectiva escritura en que se haga la partición.

Jurisprudencia: la sanción por la omisión de la tasación es la nulidad relativa. Otro fallo señaló que, tratándose de normas procesales, deben hacerse valer como vicios del procedimiento en el juicio.

d- Aprobación judicial de la partición.

El 1325 se remite al 1342, que exige aprobación judicial en 2 casos: cuando en la partición tengan interés personas sujetas a tutelas o curaduría, o personas ausentes que no han nombrado mandatario que las represente.

- La partición hecha de común acuerdo ¿requiere de escritura pública?

Ni el CC ni el CPC exigen que la partición hecha de común acuerdo se reduzca a escritura pública. La ley 16.271, discurre sobre la base de que se ha otorgado escritura pública. Sin embargo, la escritura pública no es una exigencia legal de fondo para la validez de la partición. La partición es consensual, sin perjuicio de regir para ella las limitaciones de la prueba

testimonial. Sin embargo, lo corriente es que la partición hecha de común acuerdo se reduzca a escritura pública.

Lógicamente, si en ella se han efectuado adjudicaciones de inmuebles, deberá otorgarse por escritura pública, a fin de inscribir en el CBR.

3. Partición hecha ante un partidor.

Se realiza la partición ante un juez árbitro de derecho que recibe el nombre de partidor, caso en el cual, nos encontramos ante un **juicio particional**.

EL PARTIDOR

- El partidor es por regla general un árbitro de derecho.

227 COT: señala que son materia de arbitraje forzoso la liquidación de una comunidad, la de la sociedad conyugal, la de las sociedades colectivas civiles y la partición de bienes.

Por ello, cabe concluir que el conocimiento del juicio particional no corresponde a la justicia ordinaria, sino a la arbitral, cuestión justificada por la naturaleza del juicio.

El partidor, por regla general, será un **árbitro de derecho**. El 235 del COT señala que si las partes no señalan con qué calidad es nombrado el árbitro, se entiende que es con la de árbitro de derecho. Los artículos 224 COT y 628 CPC se ponen en el caso de que a los árbitros se les dé el carácter de mixtos o de arbitradores, confirmando que la regla general es que sean de derecho.

224 COT: las partes, siendo todas ellas plenamente capaces, pueden dar al árbitro el carácter de arbitrador o mixto.

Existiendo incapaces, el partidor **jamás puede ser arbitrador**. Podrá ser mixto, previa autorización judicial dada por motivos de manifiesta conveniencia.

Designación de Partidor

1323: Sólo pueden ser partidores los abogados habilitados para ejercer la profesión y que tengan la libre disposición de sus bienes.

Por tanto, los requisitos son 2:

- 1- Ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión; y
- 2- Tener la libre disposición de los bienes (no pueden ser partidores ni los relativa ni los absolutamente incapaces).

Si el partidor no cumple con alguno de estos 2 requisitos, su nombramiento adolecerá de nulidad absoluta.

Hoy los requisitos del partidor son los que el CC señala (y no los del COT, como antes ocurría, aumentándose el número de éstos).

- 1323 inciso 2º: Son aplicables a los partidores las causales de implicancia y recusación que el Código Orgánico de Tribunales establece para los jueces.

Lo anterior es sin perjuicio de que, en ciertos casos, se pueda nombrar partidor a un coasignatario, como luego veremos.

- Quiénes pueden nombrar al partidor.

El causante

Los coasignatarios de común acuerdo

La justicia ordinaria

Existe una especie de orden de prelación. En algunos casos, los coasignatarios no están obligados a obedecer el nombramiento que hace el causante. En subsidio nombra la justicia, como última ratio.

1. Nombramiento del partidor por el causante.

Puede hacerlo en 2 oportunidades: 1234

Por acto entre vivos: se exige que la disposición se haga por instrumento público. La ley debió haber dicho escritura pública, porque no se divisa qué otro instrumento público sea apto para dicho objeto.

Por testamento: se puede realizar en cualquier clase de testamento, porque la ley no distingue.

En ambos casos el causante puede revocar el nombramiento. En el primero, lo puede hacer por escritura pública o en el testamento. En el segundo es necesario que lo haga por testamento.

- **Requisitos del partidor nombrado por el causante.** 1324: comunes a todo partidor: ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y tener la libre disposición de los bienes.

En este caso, la designación hecha por el causante podrá incluso recaer en un coasignatario, en el albacea, o en alguna persona comprendida en las causales de impugnancia y recusación establecidas en el COT, siempre que cumplan los requisitos señalados.

¿Cómo conciliar lo anterior con el 1323, que dispone que los partidores pueden ser inhabilitados por las causales del COT?: la respuesta la da el 1324: si el causante designa partidor a un coasignatario, albacea o persona inhabilitada, cualquiera de los interesados podrá pedir al juez en donde debe seguirse el juicio de partición, que declare inhabilitado al partidor por alguno de tales motivos, tramitándose conforme a las reglas de las recusaciones del CPC.

De tal forma, los **coasignatarios no están obligados a aceptar la designación que haga el causante**, quedándoles a salvo su acción para reclamar por la vía de la recusación. No se declara de pleno derecho inhabilitado, porque los interesados pueden tener la plena confianza en la persona designada por el causante, a pesar de las causales de impugnancia o recusación.

2. Nombramiento del partidor por los coasignatarios.

El nombramiento puede recaer en la persona que ellos deseen, siempre y cuando sea abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y tener la libre disposición de los bienes. 1325 inciso 3º.

1325 inciso final: Los partidores nombrados por los interesados no pueden ser inhabilitados sino por causas de impugnancia o recusación que hayan sobrevenido a su nombramiento.

Es decir, si la causal existía al momento del nombramiento, no puede ser recusado después.

El nombramiento de partidor deberá ser hecho por todos los coasignatarios **de común acuerdo**. De no procederse de dicha forma, la designación será inoponible a aquél de los coasignatarios que fue excluido del acuerdo.

La ley no establece ninguna formalidad especial para el nombramiento del partidor hecho por los interesados. Cabe aplicar el 234 COT: el nombramiento de árbitro debe hacerse por escrito, bastando cualquier clase de escritura.

3. Nombramiento del partidor por la justicia ordinaria.

Se dará este supuesto cuando no lo haya hecho el causante, no los coasignatarios se hayan puesto de acuerdo respecto de la persona del partidor.

1325 inciso final: Si no se acuerdan en la designación, el juez, a petición de cualquiera de ellos, procederá a nombrar un partidor que reúna los requisitos legales, con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Civil.

Debe ser abogado y plenamente capaz. El juez no puede nombrar partidor a un coasignatario ni a una persona afecta a una causal de inhabilidad legal. Si así lo hiciere, los demás indivisarios pueden inhabilitar al partidor alegando la correspondiente causal de implicancia o recusación.

El 1325 no excluye al albacea. Podría entonces ser designado, cumpliendo los demás requisitos legales. Sin embargo, no es claro porque el no ser albacea podría ser uno de los requisitos para ser nombrado partidor por el juez.

- Citación a comparendo para designar al partidor.

1325: ...procederá a nombrar un partidor que reúna los requisitos legales, con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Civil. El art. 646 del CPC dispone que "Cuando haya de nombrarse partidor, cualquiera de los comuneros ocurrirá al tribunal que corresponda, pidiéndole que cite a todos los interesados a fin de hacer la designación, y se procederá a ella en la forma establecida para el nombramiento de peritos".

El hecho de pedir al juez que cite a comparendo, a fin de nombrar el partidor, significa lisa y llanamente el ejercicio de la acción de partición. Es ésta, la forma práctica de hacer valer esta acción.

El juez citará a comparendo, y siendo esta resolución la 1ª del juicio, deberá ser notificada personalmente a las partes o en la forma indicada en el 44 del CPC. Se ha discutido la sanción por falta de citación a algún interesado. Lo más lógico es pensar que, en tal caso, el nombramiento del partidor, es inoponible al interesado no citado. Así lo ha fallado la CS.

Se discute si se trata de una gestión de carácter contencioso, existiendo fallos en ambos sentidos.

Asimismo se ha discutido en torno a la tramitación que debe darse a la oposición de algún asignatario para que se nombre un partidor. Al parecer sería la tramitación de **juicio sumario**. La jurisprudencia ha estimado que puede tramitarse en forma incidental, en forma de juicio ordinario, e incluso algunos señalan que es el propio partidor el que debe conocer de la existencia de un motivo que obste a la partición.

- Comparendo de nombramiento. Cuándo el juez nombra al partidor.

Al nombramiento del partidor, se aplican las normas de la designación de peritos, es decir el 414 del CPC: para proceder al nombramiento, el tribunal citará a las partes a una audiencia, que tendrá lugar con sólo los que asistan y en la cual fijará previamente por acuerdo de las partes o, en su defecto, por el tribunal, el número de partidores que debe nombrarse, y la calidad, aptitudes o títulos que deban tener.

Luego las partes se pondrán de acuerdo sobre la designación de la persona del partidor. Sin acuerdo, procede el tribunal a nombrar, no pudiendo recaer el nombramiento en ninguna de las 2 primeras personas que hayan sido propuestas por las partes.

Se entiende que no hay acuerdo entre las partes, cuando:

1. Concurriendo todos los interesados no llegan a un acuerdo sobre la persona que debe ser designada;
2. Se presume que no hay acuerdo cuando falta cualquiera de los interesados a la audiencia de nombramiento del partidor.

El juez tiene algunas **limitaciones** para nombrar partidor.

- a- Sólo puede nombrarlo como árbitro de derecho.
- b- No puede recaer en ninguna de las dos primeras personas designadas por las partes.
- c- El juez puede designar un solo partidor, a menos que las partes hayan acordado otra cosa.

La resolución que nombra a un partidor es **sentencia interlocutoria**, pudiendo atacarse por la vía de la nulidad procesal mientras esté pendiente el juicio particional.

- Aprobación judicial del nombramiento del partidor cuando él no ha sido hecho por la justicia ordinaria.

Art. 1326. Si alguno de los coasignatarios no tuviere la libre disposición de sus bienes, el nombramiento de partidor, que no haya sido hecho por el juez, deberá ser aprobado por éste.

Sanción: nulidad relativa.

- Situación de la mujer casada bajo sociedad conyugal: basta el consentimiento de la mujer o el de la justicia en subsidio. 1326 inciso 2º: Se exceptúa de esta disposición la mujer casada cuyos bienes administra el marido; bastará en tal caso el consentimiento de la mujer, o el de la justicia en subsidio.

Somarriva considera que la mujer puede concurrir por sí sola al nombramiento de partidor sin necesidad de autorización del marido, por su plena capacidad, sin perjuicio de que no comprometerá los bienes sociales.

- Aceptación y juramento del partidor. Art. 1327. El partidor no es obligado a aceptar este encargo contra su voluntad; pero si, nombrado en testamento, no acepta el encargo, se observará lo prevenido respecto del albacea en igual caso.

Quiere decir que si el partidor nombrado en testamento, repudia el cargo, se hace indigno para suceder. Lo corriente es que aceptará el cargo, porque es muy bien remunerado.

A diferencia del albacea, que puede aceptar expresa o tácitamente, el partidor, en conformidad al 1328, al aceptar el encargo deberá declararlo así y jurará desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible.

¿Qué ocurre si el partidor no acepta expresamente y jura desempeñar fielmente su cargo? En un principio la jurisprudencia fue vacilante, pero se uniformó en el sentido de que nos encontramos ante un defecto de **carácter procesal**, pues habría incompetencia del tribunal. La forma de reclamar lo anterior, será formulando el correspondiente **incidente de nulidad** o entablando **el recurso de casación en la forma**. De esta forma, no se podría reclamar la falta de aceptación y juramento del partidor una vez terminado el juicio, porque nos encontramos ante una nulidad procesal y no civil.

Competencia del Partidor

- Plazo que tiene el partidor para desempeñar el cargo.

Art. 1332. La ley señala al partidor, para efectuar la partición, el término de dos años contados desde la aceptación de su cargo.

El testador no podrá ampliar este plazo.

Los coasignatarios podrán ampliarlo o restringirlo, como mejor les parezca, aun contra la voluntad del testador.

- El testador sólo puede reducir el plazo de 2 años. La prohibición de ampliar el plazo, es concordante con el hecho de que le está prohibido pactar la indivisión.
- El juez, al designar el partidor, no podrá ampliar ni restringir este plazo sin consentimiento unánime de las partes.

- **Suspensión del plazo.** No se suspende por la interposición de feriados, en conformidad al 50 CC. En cambio, en conformidad al 647 del CPC dispone que el término que la ley, el testador o las partes concedan al partidor para el desempeño de su cargo se contará desde que éste sea aceptado, deduciendo el tiempo durante el cual, por la interposición de recursos o por otra causa, haya estado totalmente interrumpida la jurisdicción del partidor.

De tal manera, suspendida la jurisdicción del partidor por cualquier causa, se suspende también el plazo que tiene éste para fallar.

- **Fallo dictado por el partidor una vez dictado vencido el plazo.** No puede dictar fallo, sin que las partes le prorroguen su jurisdicción. Sin ella, el fallo podría ser atacable por el recurso de casación en la forma, por incompetencia del tribunal.

- **Asuntos que son de competencia del partidor.** 651, 653 y 654 del CPC y 1330 y 1331 del CC.

En términos generales, se puede decir que corresponde al partidor conocer de todas las cuestiones que deban servir de base a la realización de la partición y que la ley no entrega expresamente a la justicia ordinaria.

Reglas que da Somarriva para determinar la competencia:

1) La competencia del partidor está señalada por la voluntad de las partes

El juicio de partición es especial, debido a que tiene gran importancia la voluntad de los coasignatarios. La voluntad de las partes es la primera y suprema regla de la partición, pues ella prima en todo y por todo.

La partición efectuada ante un partidor es un **híbrido: juicio y contrato**. 1348 así lo reconoce: las particiones se anulan o rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos.

La voluntad de las partes es lo primero que determina la facultad del partidor.

2) La competencia sólo se extiende a las personas que han pactado compromiso

El compromiso es un contrato y obliga por tanto, sólo a quienes lo han celebrado. En principio, el partidor sólo conocerá de cuestiones que se susciten entre indivisarios. Excepciones:

a- Los terceros acreedores que tengan derechos que hacer valer sobre bienes comprendidos en la partición podrán ocurrir al partidor o a la justicia ordinaria a su elección. Tienen una competencia optativa.

b- Los albaceas, comuneros, administradores y tasadores pueden ocurrir al partidor a rendir cuentas y cobrar sus honorarios (651 inciso 2º). También tienen el derecho optativo de llevarlo a la justicia ordinaria, siempre que dichos sujetos (albaceas, administradores, etc.) no hayan aceptado el compromiso. En todo caso, corresponderá a la justicia ordinaria, en caso de que el compromiso haya caducado o no se haya constituido aún.

3) El partidor conoce de aquellas materias que la ley expresamente le encomienda

651 CPC: corresponde al partidor lo relativo a la formación –sin perjuicio, en este caso, de la intervención de la justicia ordinaria- e impugnación de inventarios solemnes y de todo aquello que la ley expresamente le encomiende. Dentro de ellas, hay 2 cuestiones de suma importancia:

A- Relativas a la Administración de los bienes comunes.

La administración de los bienes en la indivisión corresponde al albacea con tenencia de bienes, o si no lo hay, a los herederos que hayan aceptado la herencia, y si no hay quien acepte, al curador de la herencia yacente.

En seguida, corresponderá a los indivisarios, de común acuerdo, arreglar lo referente a la administración de los bienes comunes y al nombramiento de los administradores. Si no se ponen de acuerdo respecto de dichos puntos, pueden recurrir al partidor o a la justicia ordinaria. Organizado el compromiso y mientras subsista la jurisdicción del partidor, a él le corresponden

estas cuestiones y de las relativas a las medidas dictadas por la justicia para la administración de los bienes comunes. Es decir, la justicia ordinaria conoce de este punto en 3 casos:

- i- Cuando no se ha constituido el juicio de partición;
- ii- Cuando falta el partidor por renuncia, fallecimiento, extinción del plazo, etc.;
- iii- Cuando no subsiste la jurisdicción del partidor, lo que ocurrirá, por ejemplo, cuando algún interesado alega derechos exclusivos en los bienes comunes.

En los demás casos, conocerá el partidor. Asimismo, y haciendo excepción al principio de la radicación, el partidor continuará conociendo de aquellas cuestiones que empezó a conocer la justicia ordinaria o que se promuevan con ocasión de las medidas dictadas por ésta.

Art. 654 CPC. Para acordar o resolver lo conveniente sobre la administración pro-indiviso, se citará a todos los interesados a comparendo, el cual se celebrará con sólo los que concurren.

No estando todos presentes, sólo podrán acordarse, por mayoría absoluta de los concurrentes, que represente a lo menos la mitad de los derechos de la comunidad, o por resolución del tribunal a falta de mayoría, todas o algunas de las medidas siguientes:

- 1a. Nombramiento de uno o más administradores, sea de entre los mismos interesados o extraños;
- 2a. Fijación de los salarios de los administradores y de sus atribuciones y deberes;
- 3a. Determinación del giro que deba darse a los bienes comunes durante la administración pro-indiviso y del máximo de gastos que puedan en ella hacerse; y
- 4a. Fijación de las épocas en que deba darse cuenta a los interesados, sin perjuicio de que ellos puedan exigirlos extraordinariamente, si hay motivo justificado, y vigilar la administración sin embarazar los procedimientos de los administradores.

Por sí solos los indivisarios únicamente pueden acordar lo relativo a la administración, **por unanimidad**. En cambio, ante el partidor o la justicia ordinaria, **basta la mayoría absoluta de los concurrentes que representen, a lo menos, la mitad de los derechos en la comunidad**. A falta de ella, decide el juez o el partidor.

B- Cesación del goce gratuito de los comuneros en alguna de las cosas comunes.

Los comuneros pueden usar, con ciertas limitaciones, las cosas comunes en propio beneficio. Sin embargo, el 655 CPC dispone: Para poner término al goce gratuito de alguno o algunos de los comuneros sobre la cosa común, bastará la reclamación de cualquiera de los interesados; salvo que este goce se funde en algún título especial.

Aunque la ley no lo diga expresamente, por la ubicación de la norma, se extrae que el conocimiento de estas cuestiones corresponde al partidor si está constituido el juicio de partición.

- 4) El partidor conoce también de aquellas cuestiones que, debiendo servir de base a la partición, la ley no las somete expresamente a la justicia ordinaria. 651 CPC.

Son diversas las cuestiones que caben dentro de esta facultad. El 652 del CPC establece que el partidor puede fijar a las partes un plazo para que formulen sus peticiones respecto de estas cuestiones que han de servir de base a la partición.

- 5) El partidor **no tiene competencia** para determinar cuáles son los indivisarios, cuáles son los derechos de cada uno y cuáles son los bienes comunes.

Conforme a los artículos **1330 y 1331 del CC**, hay 3 cuestiones que nunca pueden ser conocidas por el partidor, por ser de competencia exclusiva de la justicia ordinaria:

- 1- Quiénes son los interesados en la partición;
- 2- Cuáles son los derechos que corresponden a cada cual en la sucesión;
- 3- Cuáles son los bienes comunes a partirse.

En principio, la partición no se suspende debido a la discusión sobre cuáles son los bienes comunes. La partición sigue adelante, y si la justicia ordinaria decide que el bien es común, se procede conforme al 1349, esto es, se reparte entre los partícipes con arreglo a sus respectivos derechos. Esto es denominado **suplemento de la partición**.

Sin embargo, por excepción, la partición se suspende en el caso del inciso final del 1331: cuando la alegación de que los bienes no son comunes recayere sobre una parte considerable de la

masa partible, lo pidieren así asignatarios a quienes corresponda más de la mitad de ésta, y el juez ordenare la suspensión. Somarriva consideraba que es el juez ordinario quién debe decretar la suspensión, por cuanto cuando la ley quiere referirse al partidor, lo nombra así y no como juez.

Las 3 cuestiones señaladas –interesados, derechos de cada cual y bienes comunes- son de aquellas que, en conformidad al 651 CPC, a pesar de servir de base a la partición, no corresponde conocer al partidor, sino a la justicia ordinaria.

6) El partidor carece de facultades conservadoras, disciplinarias y económicas, y de imperio.

Todas estas facultades corresponden a la justicia ordinaria. Respecto de la facultad de imperio, es decir, de hacer ejecutar lo juzgado, el 635 del CPC, refiriéndose a los árbitros en general, dispone que para el cumplimiento de la sentencia definitiva se puede recurrir ya al árbitro, ya a la justicia ordinaria; del cumplimiento de las demás resoluciones sólo conoce el primero. Sin embargo, cuando el cumplimiento de la sentencia arbitral exija procedimientos de apremio o empleo de otras medidas compulsivas, deberá ocurrir a la justicia ordinaria para la ejecución de lo resuelto.

En base a este artículo se ha fallado que los árbitros en general, **no pueden conocer de un juicio ejecutivo.**

Responsabilidad y Remuneración del Partidor

- **El partidor responde de la culpa leve.** 1329. Es una aplicación del 1547.

- **Prevaricación del partidor.** Es la falta dolosa o culpable cometida por ciertos funcionarios a los deberes que les imponen su autoridad o cargo. El 1329 CC se pone en el caso de prevaricación del partidor declarada por juez competente, imponiéndole 3 tipos de sanciones:

1. Sanciones penales del delito correspondiente;
2. Indemnizar los perjuicios causados a las partes; y
3. El partidor se hace indigno de tener parte alguna en la sucesión del causante.

- **Responsabilidades especiales del partidor:**

- A- Responsabilidad disciplinaria por los abusos o faltas cometidos en el desempeño de sus funciones. El recurso de queja que se interponga en contra de sus resoluciones, deberá ser conocido por la Corte de Apelaciones respectiva.
- B- 1336 CC: aun cuando el causante haya hecho la partición, y aunque no sea requerido a ello por el albacea o herederos, estará obligado el partidor a formar lote o hijuela de deudas, es decir, señalar los bienes con los cuales van a ser éstas pagadas, so pena de responder de todo perjuicio a los acreedores. El precepto se pone en el caso de que el causante haya hecho la partición, y de todas formas impone la obligación al partidor. Ello ocurrirá cuando aparezcan bienes respecto de los cuales el causante no dispuso en su partición.
- C- El partidor, bajo pena de multa, debe velar porque se reúnan los fondos en la partición a fin de pagar los impuestos que gravitaren sobre la herencia. Asimismo, está obligado a velar porque los comuneros formulen la correspondiente declaración de impuesto a la renta.

- **El partidor NO puede adquirir bienes comprendidos en la partición.**

1798: prohíbe a los jueces, abogados, etc., comprar los bienes en cuyo litigio han intervenido, aun cuando la venta se haga en pública subasta.

La CS en un fallo criticable, había resuelto que esta prohibición no se aplicaba al partidor, porque la ley habla de "litigio", sin ser la partición propiamente un litigio.

Esta interpretación, según Somarriva, no es correcta: el partidor es un juez, el objetivo en este caso sería el mismo (que el partidor no perjudique a la masa), el 321 COT prohíbe al juez comprar las cosas que se litiguen en los juicios que él conozca y el CP castiga a los árbitros cuando realizan actos relativos a los bienes en cuya partición intervinieron.

Si el partidor es un coasignatario, podría hacerlo, pero en tal caso no existiría compraventa sino adjudicación.

- **Remuneración del partidor.** Constituyen una baja general de la herencia.

Pueden ser fijados por el propio causante, pero en dicho caso el partidor no está obligado a respetar tal fijación. Puede ser fijada por el partidor y los indivisarios de común acuerdo. A falta de acuerdo, al dictar su sentencia final, que recibe el nombre de **laudo y ordenata**, puede fijar sus honorarios.

Art. 665 CPC En el Laudo podrá hacer el partidor la fijación de su honorario, y cualquiera que sea su cuantía, habrá derecho para reclamar de ella. La reclamación se interpondrá en la misma forma y en el mismo plazo que la apelación, y será resuelta por el tribunal de alzada en única instancia.

Así, la parte del laudo en que se fija la remuneración, deja de ser sentencia y pasa a ser una proposición que hace a las partes del monto. Si no están de acuerdo, pueden intentar el recurso de reclamación ante la CA en el plazo de 15 días, recurso que será fallado en única instancia. La CA fijará la remuneración.

DESARROLLO DE LA PARTICIÓN

Cuestiones de carácter previo en la partición

Antes de efectuar la partición de los bienes comunes en muchos casos será necesario cumplir determinados trámites previos:

1. Apertura y publicación del testamento.

2. Posesión efectiva de la herencia.

Aunque la ley no lo exige, para proceder a la partición es necesario que se haya otorgado a los herederos la posesión efectiva, ya que sin ella es prácticamente imposible la partición.

3. Facción de Inventario de los bienes comunes.

Tampoco es exigido perentoriamente por la ley. En la práctica el inventario se efectuará antes de comenzar la partición, siendo un trámite esencial para inscribir el auto de posesión efectiva.

4. Tasación de los Bienes.

Sólo cuando los bienes estén tasados, se puede determinar cuánto se entregará a cada indivisario. La tasación puede hacerse durante el curso de la partición o antes de ella. Siempre debe hacerse ante peritos, salvo que las partes sean todas plenamente capaces y aún en ciertos casos si no lo son.

5. Designación de un curador al incapaz.

Puede suceder que el incapaz y su representante legal tengan interés en la partición, es decir, que ambos sean comuneros. En dicho caso, no es posible que el representante actúe en la partición por sí y en representación del incapaz, siendo necesario nombrar al incapaz un curador especial para que lo represente tanto en la designación del partidor como en la partición misma. La ley no lo dice pero se extrae del principio de que la representación termina donde empieza el conflicto de interés.

- **Diligencias previas de la partición. Separación de patrimonios.**

Efectuado los trámites anteriores, el partidor entra a conocer de la partición misma, contando con una base segura, ya que la justicia ordinaria deberá resolver quiénes son los indivisarios, cuáles son sus derechos y cuáles son los bienes comunes a partirse. Sin embargo, para determinar los bienes comunes a partirse, el partidor tendrá que determinar cuál es el acervo que se repartirá entre los coasignatarios. Para ello, primero deberá **separar del patrimonio del causante aquellos bienes que pertenecen a otras personas**. Estará formando el ACERVO ILÍQUIDO. En seguida, **deducidas las bajas generales**, determinará el ACERVO LÍQUIDO. Finalmente, cuando proceda, calculará los acervos imaginarios. Estas últimas operaciones forman parte de la liquidación de bienes.

Separación de patrimonios: lo primero que se debe hacer es separar los patrimonios confundidos con el fin de establecer cuáles son en definitivas los bienes dejados por el causante. El caso más común es cuando muere uno de los cónyuges casados en SC. Primero deberá liquidarse ésta, a fin de determinar cuánto le correspondería al cónyuge causante en la misma. No hay inconveniente para que un mismo partidor conozca de la partición de la SC y de la indivisión hereditaria. En el caso de que el causante haya nombrado partidor en el testamento, no se entiende que éste lo es también para conocer de la partición de la SC. Requiere el consentimiento del cónyuge supérstite.

En el caso del régimen de participación en los gananciales, podría darse una operación previa, que es su liquidación para determinar si la sucesión tiene crédito o débito respecto del cónyuge sobreviviente. Esta materia no está sometida a arbitraje, sino que se resuelve por la justicia ordinaria en juicio breve y sumario.

El Juicio de Partición

Comienza con la aceptación expresa y el juramento que hace el partidor de desempeñar fielmente su cargo, y continúa con la celebración de las distintas audiencias verbales y la solución de las cuestiones que se planteen. La principal de las operaciones de la partición es la liquidación y distribución de los bienes comunes. El juicio de partición termina con la dictación de la sentencia del partidor, denominada laudo y ordenata de partición.

- **Características del Juicio de Partición.**

1. **Importancia fundamental de la voluntad de las partes.** La partición es un híbrido: juicio-contrato.
2. **Es un juicio doble.** En el juicio de partición no queda determinado a priori quiénes son los demandantes y quiénes son los demandados. Cada comunero puede asumir el rol de demandante o de demandado, según los casos.
3. **Es un juicio complejo.** En él se pueden presentar tantos juicios simples cuantas sean las cuestiones que se planteen y cuya resolución deba servir de base a la partición y distribución de bienes.
4. **Es un juicio de cuantía indeterminada,** aun cuando se conozca el valor de los bienes partible.

- **Lugar dónde se sustancia el juicio de partición y designación de actuario.**

Se tramita en el lugar que las partes designen y, a falta de esta determinación, en aquél donde se celebró el compromiso.

Las resoluciones judiciales siempre deberán ser autorizadas por un ministro de fe. Respecto de los árbitros en general, este ministro de fe es un actuario. Puede serlo un secretario de los Tribunales Superiores de Justicia o un notario o un secretario de un juzgado de letras.

Los honorarios de los actuarios son bajas generales de la herencia.

- Tramitación del juicio de partición. Los Comparendos.

Art. 649 CPC. Las materias sometidas al conocimiento del partidor se ventilarán en audiencias verbales, consignándose en las respectivas actas sus resultados, o por medio de solicitudes escritas, cuando la naturaleza e importancia de las cuestiones debatidas así lo exijan. Las resoluciones que se dicten con tal objeto serán inapelables.

Las audiencias verbales reciben el nombre de **comparendos**. Cabe distinguir los siguientes comparendos:

1. Primer Comparendo
2. Comparendos Ordinarios
3. Comparendos Extraordinarios

1. Primer Comparendo

El primer comparendo es citado por el partidor. Tiene por objeto, organizar la partición. Debe notificarse personalmente o por el 44 CPC, por ser la primera del juicio. En el primer comparendo los acuerdos deben tomarse por la unanimidad de los interesados. Generalmente se trata de dejar constancia sobre (1) quiénes son las partes del juicio; (2) si actuarán personalmente o representados; (3) domicilio de las partes; (4) concesión de la posesión efectiva y de su inscripción y de las especiales de herencia efectuadas; (5) se aprueba el inventario que se haya hecho de los bienes; (6) se fija la forma de las notificaciones: sin acuerdo, se hará personalmente o por cédula; (7) se fija la fecha y la hora de los comparendos ordinarios.

2. Comparendos Ordinarios

650 CPC: Cuando se designen días determinados para las audiencias ordinarias, se entenderá que en ellas pueden celebrarse válidamente acuerdos sobre cualquiera de los asuntos comprendidos en el juicio, aun cuando no estén presentes todos los interesados, a menos que se trate de revocar acuerdos ya celebrados, o que sea necesario el consentimiento unánime en conformidad a la ley, o a los acuerdos anteriores de las partes.

Modificada la designación de día para las audiencias ordinarias, no producirá efecto mientras no se notifique a todos los que tengan derecho de concurrir.

3. Comparendos Extraordinarios

Pueden existir materias que por la importancia, por la premura en resolverlas, o por exigir la unanimidad de los pareceres la resolución que se adopte, exijan de un **comparendo especial o extraordinario**. Corresponde al partidor de oficio, o a petición de parte, citar a comparendos extraordinarios. Es necesario notificar a las partes la citación a comparendo y no es posible que en ellos se tomen acuerdos sin la concurrencia de la totalidad de los interesados.

- Cuadernos en que se sustancia la partición.

1. El de actas: nunca puede faltar, porque en él se deja constancia de los acuerdos celebrados en los distintos comparendos o audiencias verbales.

2. El de documentos: puede omitirse, si no hay tantos documentos como para justificar su existencia. En él se agregan los distintos instrumentos que digan relación con la partición. Ej. Testamento.

3. Cuaderno de incidentes. En él se sustanciarán los incidentes que se promuevan durante la partición.

- Cuestiones que deben servir de base a la partición.

El conocimiento de ellas, corresponde al partidor. 652 CPC: el partidor puede fijar a las partes un plazo para que formulen sus peticiones sobre las cuestiones que deban servir de base a la partición.

Cada cuestión que se promueva será tramitada separadamente, con audiencia de todos los que en ella tengan intereses, sin entorpecer el curso de las demás y sin que se paralice en unas la jurisdicción del partidor por los recursos que en otras se deduzcan. Podrán, sin embargo, acumularse dos o más de dichas cuestiones cuando sea procedente la acumulación en conformidad a las reglas generales.

Las cuestiones parciales podrán fallarse durante el juicio divisorio o reservarse para la sentencia final.

Estas cuestiones **no son incidentes** de la partición, sino que se trata de otros tantos juicios separados dentro del complejo juicio de partición. Los incidentes serán todas aquellas cuestiones que se plantean, cuya resolución no sirve de base a la partición.

- **Costas de la partición.** 1333: las costas comunes de la partición serán de cuenta de los interesados en ella a prorrata. Son una baja general de la herencia.

Liquidación y Distribución de los Bienes Comunes

Art. 1337. “El partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios se deba, y procederá a la distribución de los efectos hereditarios, teniendo presentes las reglas que siguen”.

La partición se descompone en 2 actos:

- a- Liquidación de los bienes: se determina cuánto le corresponde a cada interesado; y
- b- Distribución de los bienes: los bienes comunes son adjudicados a cada asignatario en forma tal que correspondan a los derechos que cada uno tenga en la partición. Se traduce en la **formación de hijuelas de cada interesado**.

- Liquidación de los bienes comunes.

Determinar a cuánto ascienden los bienes comunes, y la cuota o parte que en esta suma le corresponde a cada indivisario. Es necesario, para proceder a la liquidación, que previamente se determinen por la justicia ordinaria, en caso de conflicto, los derechos de los comuneros y cuáles son los bienes comunes. También es previa la separación de patrimonios.

Hecho lo anterior, el partidor procede a liquidar el acervo efectuando las bajas generales de la herencia. Luego, si es del caso, deberá formar los acervos imaginarios. Al final de lo anterior, calculará, en conformidad a las disposiciones del testamento o de la ley, cuánto corresponde a cada indivisario.

- Distribución de los bienes.

Su objeto es repartir los bienes indivisos entre los comuneros hasta enterar la cuota de cada cual. El legislador señala, a fin de distribuir los bienes, las siguientes reglas:

- 1- En primer lugar, deberá estarse a la voluntad de las partes
- 2- A falta de acuerdo de las partes, entran a jugar las 11 reglas del 1337. Si los bienes admiten cómoda división, se aplican las reglas 7ª, 8ª y 9ª del precepto.
- 3- Si los bienes no admiten cómoda división se sacan a remate.
- 4- Reglas sobre la división de los predios.
- 5- Constitución de usufructos, usos o habitaciones.
- 6- Ley 19.585: Regla 10ª agregada: preferencia a favor del cónyuge sobreviviente respecto del inmueble en el que residía (hoy se le confiere también al conviviente civil sobreviviente)

- 7- Las adjudicaciones parciales no requieren aprobación judicial, aun cuando existan incapaces.

1- En primer lugar, deberá estarse a la voluntad de las partes

1344: el partidor se conformará en la adjudicación de los bienes a las reglas de este título, salvo que los asignatarios acuerden legítima y **unánimemente** otra cosa.

2- A falta de acuerdo de las partes, entran a jugar las 11 reglas del 1337. Si los bienes admiten cómoda división, se aplican las reglas 7ª, 8ª y 9ª del precepto.

7ª En la partición de una herencia o de lo que de ella restare, después de las adjudicaciones de especies mencionadas en los números anteriores, se ha de guardar la posible igualdad, adjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad que a los otros, o haciendo hijuelas o lotes de la masa partible.

8ª En la formación de los lotes **se procurará no sólo la equivalencia sino la semejanza de todos ellos**; pero se tendrá cuidado de no dividir o separar los objetos que no admitan cómoda división o de cuya separación resulte perjuicio; salvo que convengan en ello unánime y legítimamente los interesados.

9ª Cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de composición de los lotes, antes de efectuarse el sorteo.

Ej. Si existe un Fundo de 3 cuadra, 3 acciones de X S.A. y \$3, y existen 3 herederos por partes iguales, a cada uno se le deberá formar una hijuela con 1 cuadra del fundo, 1 acción y \$1. El legislador busca que los bienes se dividan en naturaleza.

3- Si los bienes no admiten cómoda división se sacan a remate.

Puede suceder que no pueda cumplirse el anhelo del legislador, de dividir en naturaleza los bienes, por imposibilidad en la división, porque no sea cómoda o porque haga desmerecer el valor del bien.

1ª Entre los coasignatarios de una especie que no admita división, o cuya división la haga desmerecer, tendrá mejor derecho a la especie el que más ofrezca por ella; cualquiera de los coasignatarios tendrá derecho a pedir la admisión de licitadores extraños; y el precio se dividirá entre todos los coasignatarios a prorrata.

El remate puede ser: 1) en privado entre los coasignatarios; o 2) con admisión de postores extraños. Basta que 1 indivisario lo pida para que deba hacer con admisión de postores extraños.

Si se hace en privado, la especie siempre corresponderá a un asignatario, y por tanto, siempre existirá adjudicación de ella. Si se hace con admisión de extraños, podrá corresponder a un asignatario o a un tercero extraño. En el primer caso hay adjudicación, en el 2º hay compraventa.

2ª No habiendo quien ofrezca más que el valor de tasación o el convencional mencionado en el artículo 1335, y compitiendo dos o más asignatarios sobre la adjudicación de una especie, el legitimario será preferido al que no lo sea.

El producto de la subasta viene a reemplazar en la indivisión al bien subastado y se reparte entre los comuneros a prorrata de sus cuotas. Pero si el bien es adjudicado a un comunero, éste no lo paga en dinero, sino se le imputa su valor a su cuota en la comunidad.

- Formas de hacer el remate.

CPC entrega normas especiales respecto de la manera en que debe ser hecha la licitación de los bienes comunes.

Art. 658. Para proceder a la licitación pública de los bienes comunes bastará su anuncio por medio de avisos en un diario de la comuna o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquélla no lo hubiere.

Cuando entre los interesados haya incapaces, la publicación de avisos se hará por cuatro veces a lo menos, mediando entre la primera publicación y el remate un espacio de tiempo que no baje de quince días. Si por no efectuarse el remate, es necesario hacer nuevas publicaciones, se procederá en conformidad a lo establecido en el artículo 502.

Los avisos podrán publicarse también en días inhábiles, los que no se descontarán para el cómputo del plazo señalado en el inciso anterior.

Si los bienes están en otra comuna, el remate se anunciará también en ella, por el mismo tiempo y en la misma forma.

Art. 659. En las enajenaciones que se efectúen por conducto del partidor se considerará a éste representante legal de los vendedores, y en tal carácter suscribirá los instrumentos que, con motivo de dichas enajenaciones, haya necesidad de otorgar. Podrá también autorizar al comprador o adjudicatario o a un tercero para que por sí solo suscriba la inscripción de la transferencia en el conservador respectivo.

Todo acuerdo de las partes o resolución del partidor que contenga adjudicación de bienes raíces se reducirá a escritura pública, y sin esta solemnidad no podrá efectuarse su inscripción en el conservador.

4- Reglas sobre la división de los predios.

3ª Las porciones de uno o más fundos que se adjudiquen a un solo individuo, serán, si posible fuere, continuas, a menos que el adjudicatario consienta en recibir porciones separadas, o que de la continuidad resulte mayor perjuicio a los demás interesados que de la separación al adjudicatario.

4ª Se procurará la misma continuidad entre el fundo que se adjudique a un asignatario y otro fundo de que el mismo asignatario sea dueño.

5ª En la división de fundos se establecerán las servidumbres necesarias para su cómoda administración y goce.

5- Constitución de usufructos, usos o habitaciones.

6ª Si dos o más personas fueren coasignatarios de un predio, podrá el partidor con el legítimo consentimiento de los interesados separar de la propiedad el usufructo, habitación o uso para darlos por cuenta de la asignación.

Es uno de los casos en que estos derechos tienen origen en la partición.

6- Ley 19.585: Regla 10ª agregada: preferencia a favor del cónyuge sobreviviente respecto del inmueble en el que residía(a partir de la ley 20.830 también detenta este derecho el conviviente civil sobreviviente).

10ª Con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria se entere con preferencia mediante la adjudicación en favor suyo de la propiedad del inmueble en que resida y que sea o haya sido la vivienda principal de la familia, así como del mobiliario que lo guarnece, siempre que ellos formen parte del patrimonio del difunto.

Si el valor total de dichos bienes excede la cuota hereditaria del cónyuge, éste podrá pedir que sobre las cosas que no le sean adjudicadas en propiedad, se constituya en su favor derechos de habitación y de uso, según la naturaleza de las cosas, con carácter de gratuitos y vitalicios.

El derecho de habitación no será oponible a terceros de buena fe mientras no se inscriba la resolución que lo constituye en el Registro del Conservador de Bienes Raíces. En todo lo no previsto, el uso y la habitación se regirán por lo dispuesto en el Título X del Libro II.

El derecho a la adjudicación preferente de que habla esta regla no puede transferirse ni transmitirse.

Justificación de esta norma (incluida por ley 19.585)

a- Se puede pedir la desafectación de un bien familiar cuando el matrimonio termina por muerte de alguno de los cónyuges. Con ello, se puede perder el hogar familiar.

b- Al aumentarse los derechos de la familia extramatrimonial y con la facilidad de probar la filiación, cualquier sujeto ajeno a la familia, podría provocar alteraciones al hogar común.

- Se trata de un derecho personalísimo, de carácter **renunciable**.

- Este derecho opera en los casos en que la partición se efectúa sin contar necesariamente con el consentimiento del cónyuge. En el caso que sea de común acuerdo, dependerá de la voluntad del cónyuge. Si la hace el testador, se considerará contraria a derecho si no se respeta el derecho preferente del cónyuge.

7- Las adjudicaciones parciales no requieren aprobación judicial, aun cuando existan incapaces.

11ª Cumpliéndose con lo prevenido en los artículos 1322 y 1326, no será necesaria la aprobación judicial para llevar a efecto lo dispuesto en cualquiera de los números precedentes, aun cuando algunos o todos los coasignatarios sean menores u otras personas que no tengan la libre administración de sus bienes.

- **Adjudicaciones a comuneros.** A los comuneros se les pueden adjudicar bienes comunes en el curso de la partición. Los coasignatarios no pagan el precio de las especies en dinero, sino que ellas se imputan a la cuota que tienen en la comunidad. ¿Deben pagar intereses por dichas adjudicaciones?

Art. 661. CPC. Los valores que reciban los comuneros durante la partición a cuenta de sus derechos devengarán el interés que las partes fijen, o el legal

cuando tal fijación no se haya hecho, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes.

El asignatario puede resultar **alcanzado** con las adjudicaciones que se le hagan. Se llama **alcances en la participación** aquella suma de dinero que en virtud de adjudicaciones hechas al asignatario exceda de la cuota que en definitiva le correspondía a éste. Frente a esto, nace para el asignatario alcanzado, la obligación de pagar el alcance. Para garantizar el pago de ellos, el CPC establece algunas medidas, entre ellas, **la hipoteca legal**.

- La hipoteca legal en la partición.

Art. 660 CPC. Salvo acuerdo unánime de las partes, los comuneros que durante el juicio divisorio reciban bienes en adjudicación, por un valor que exceda del ochenta por ciento de lo que les corresponda percibir, pagarán de contado dicho exceso. La fijación provisional de éste se hará prudencialmente por el partidor.

El alcanzado debe pagar el exceso del 80% de su probable cuota. Si el asignatario no realiza el pago en contado, el artículo 662 CPC dispone que en las adjudicaciones de propiedades raíces que se hagan a los comuneros durante el juicio divisorio o en la sentencia final, se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas, para asegurar el pago de los alcances que resulten en contra de los adjudicatarios, siempre que no se pague de contado el exceso a que se refiere el artículo 660. Al inscribir el conservador el título de adjudicación, inscribirá a la vez la hipoteca por el valor de los alcances.

Podrá reemplazarse esta hipoteca por otra caución suficiente calificada por el partidor.

El laudo y ordenata determinará que se cancele la hipoteca cuando los bienes adjudicados calcen en la cuota o que el asignatario resulte alcanzado. El valor de los alcances se anotará al margen de la inscripción hipotecaria.

Es necesario que la hipoteca se inscriba para que adquiera existencia, porque no existe de pleno derecho.

- Reglas para la partición de los frutos. Los bienes comunes pueden haber producido frutos. Ellos pertenecen en común e indivisos a los comuneros. Será necesario liquidarlos y dividirlos.

Norma relativa a los frutos percibidos desde la apertura de la sucesión hasta la partición de la herencia. Art. 1338. Los frutos percibidos después de la muerte del testador, durante la indivisión, se dividirán del modo siguiente:

1. Los asignatarios de especies tendrán derecho a los frutos y accesiones de ellas desde el momento de abrirse la sucesión; salvo que la asignación haya sido desde día cierto, o bajo condición suspensiva, pues en estos casos no se deberán los frutos, sino desde ese día, o desde el cumplimiento de la condición; a menos que el testador haya expresamente ordenado otra cosa.

2. **Los legatarios de cantidades o géneros no tendrán derecho a ningunos frutos**, sino desde el momento en que la persona obligada a prestar dichas cantidades o géneros se hubiere constituido en mora; y este abono de frutos se hará a costa del heredero o legatario moroso.

3. **Los herederos tendrán derecho a todos los frutos y accesiones de la masa hereditaria indivisa, a prorrata de sus cuotas**; deducidos, empero, los frutos y accesiones pertenecientes a los asignatarios de especies.

El haber de cada asignatario consta de 2 partidas: la cuota de los bienes hereditarios y la cuota de los frutos en ella. La distinción tiene importancia, por 2 razones: a) los frutos no pagan impuestos; y 2) ingresan al haber social en la SC.

4. Recaerá sobre los frutos y accesiones de toda la masa la deducción de que habla el inciso anterior, siempre que no haya una persona directamente gravada para la prestación del legado: habiéndose impuesto por el testador este gravamen a alguno de sus asignatarios, éste sólo sufrirá la deducción.

Norma relativa a los frutos pendientes al momento de hacerse las adjudicaciones. Art. 1339. Los frutos pendientes al tiempo de la adjudicación de las especies a los asignatarios de cuotas, cantidades o géneros, se mirarán como parte de las respectivas especies, y se tomarán en cuenta para la estimación del valor de ellas.

- Distribución de las deudas hereditarias en la partición.

1354: respecto de las deudas hereditarias no se forma indivisión de ninguna especie, sino que ellas se dividen de pleno derecho entre los herederos por el solo fallecimiento del causante y a prorrata de las cuotas de cada cual.

Las deudas hereditarias se pagan generalmente antes de distribuir los bienes, puesto que constituyen una baja general de la herencia.

Lo anterior, es sin perjuicio de lo dispuesto en el 1359: los herederos pueden dividir las deudas hereditarias de una forma distinta, pudiendo tomarse este acuerdo en la partición. 1340. Un heredero podrá pagar más de lo que le corresponda por el prorrateo. Dicho acuerdo no le empece a los acreedores.

Fin del Juicio de Partición: LAUDO Y ORDENATA DE PARTICIÓN

Una vez finalizadas la tramitación del juicio de partición y la liquidación y distribución de los bienes comunes, frutos y deudas, el partidor citará a las partes a oír sentencia. Una vez ejecutoriada esta resolución, el partidor queda en situación de dictar su sentencia final, denominada **laudo y ordenata de partición**.

Art. 663. CPC. Los resultados de la partición se consignarán en un Laudo o sentencia final, que resuelva o establezca todos los puntos de hecho y de derecho que deben servir de base para la distribución de los bienes comunes, y en una Ordenata o liquidación, en que se hagan los cálculos numéricos necesarios para dicha distribución.

La ley fue exacta al calificar al laudo de sentencia **final** y no simplemente de definitiva, dado el carácter universal y complejo del juicio, ya que los diversos juicios simples pueden fallarse durante su tramitación y ser definitivos.

Cabe distinguir 2 aspectos dentro de la sentencia final:

- **Laudo:** debe contener las exigencias del 170 CPC como sentencia definitiva: parte expositiva, considerativa y resolutive.

- **Ordenata:** cálculo numérico necesario para la distribución de los bienes. "Es el laudo reducido a número". Se forma el cuerpo común de bienes y se establece el acervo líquido.

Establece las hijuelas de los comuneros, las cuales constan de 2 partes: el ha de haber y el entero. Ej. Hijuela de X: Ha de haber por derechos en la sucesión de su padre: 500. Entero: (cómo se pagan sus 500): 100 en efectivo, de acuerdo al comparendo de fecha tanto, 300 por adjudicación de tales acciones según comparendo de fecha tanto, etc., hasta que se completa la hijuela de X. Si resulta alcanzado, se dirá en su hijuela que ha quedado alcanzado en cierta cantidad, que pagará a tal persona en la forma que se dirá en la hijuela de dicha persona.

En la ordenata se forma también el cuerpo común de frutos y las bajas de este cuerpo común.

- **Aprobación judicial de la partición.**

1342: la partición, una vez terminada, deberá someterse a aprobación judicial en dos casos:

a- Cuando en la partición tenga interés un ausente que no haya nombrado mandatario o procurador, es decir, que haya actuado representado por un curador de bienes; y

b- Cuando tenga interés en ella personas sujetas a tutela y curaduría.

Por ello, **no** es exacto afirmar que la partición requiere de aprobación judicial cuando existan incapaces interesados en la misma⁴⁶.

Conforme al 148 COT es competente para aprobar la partición, cuando proceda, el juez del último domicilio del causante, el cual se limitará a constatar que se ha cumplido con los requisitos legales.

- **Notificación del laudo y ordenata.**

a- Si no requieren de aprobación judicial. Como el laudo es una sentencia definitiva, de aplicarse las normas generales, hubiera debido notificarse por cédula, notificación que debe contener copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. Sin embargo, el laudo y la ordenata son de gran extensión generalmente, lo que haría muy difícil su notificación por cédula. Por ello, el 664 CPC establece una modalidad especial: Se entenderá practicada la notificación del Laudo y Ordenata desde que se notifique a las partes el hecho de su pronunciamiento, salvo el caso previsto en el artículo 666. Los interesados podrán imponerse de sus resoluciones en la

⁴⁶ Como sería en el evento de que uno de los comuneros fuera un hijo sujeto a patria potestad.

oficina del actuario y deducir los recursos a que haya lugar dentro del plazo de 15 días.

b- Si requieren de aprobación judicial. Lo que se notifica es la resolución del juez que aprueba o modifica el fallo del partidor. Desde el momento de la notificación comienza a correr el plazo para intentar los recursos legales, siendo también de 15 días.

Si no acontece la aprobación del juez a la partición, la misma no se encuentra cerrada, razón por la cual los plazos de los recursos no han empezado a correr.

- Recursos que proceden contra el laudo y ordenata.

Plazo de 15 días, contados en la forma ya estudiada.

Recursos: de apelación y de casación en la forma. Contra la sentencia de 2ª proceden los recursos de casación en la forma y en el fondo.

- Entrega de los títulos.

Art. 1343. Efectuada la partición, se entregarán a los partícipes los títulos particulares de los objetos que les hubieren cabido.

Los títulos de cualquier objeto que hubiere sufrido división pertenecerán a la persona designada al efecto por el testador, o en defecto de esta designación, a la persona a quien hubiere cabido la mayor parte; con cargo de exhibirlos a favor de los otros partícipes, y de permitirles que tengan traslado de ellos, cuando lo pidan.

En caso de igualdad se decidirá la competencia por sorteo.

EFFECTOS DE LA PARTICIÓN

1. Efecto declarativo y retroactivo de la partición: 1344
2. Obligación de garantía que pesa sobre los indivisarios: 1345 a 1347.

La Adjudicación y el Efecto Declarativo de la Partición

Adjudicación: acto por el cual se entrega a uno de los indivisarios un bien determinado que equivale a los derechos que le correspondían en su cuota ideal o abstracta en la comunidad⁴⁷.

Por medio de la adjudicación, el comunero, de codueño de un bien pasa a ser propietario exclusivo del mismo.

- La adjudicación supone la calidad de comunero. El único requisito que se exige para que exista adjudicación es que el adjudicatario tenga previamente la calidad de comunero en el bien que se le adjudica. En ello, se diferencia de la compraventa.

⁴⁷ Este es el concepto que se usa a propósito de la partición. El CC y el CPC lo utilizan en distintos sentidos: ej. el acreedor prendario tiene derecho a que se le adjudique la prenda; adjudicación como equivalente a dación en pago.

- **La partición con alcances no obsta a que exista adjudicación.** El hecho de que el adjudicatario deba pagar un alcance con dinero efectivo, no obsta a la existencia de la adjudicación, pues el adjudicatario era previamente comunero respecto del bien adjudicado.

- **El efecto declarativo o retroactivo de la partición y adjudicación.** El efecto declarativo de la partición y de la adjudicación, se encuentra consagrado en el 1344, a propósito del dominio, y en el 718, a propósito de la posesión.

Efecto declarativo: considerar que el adjudicatario ha sucedido inmediata y directamente al causante en los bienes adjudicados, y no ha tenido parte alguna en los bienes adjudicados a otros asignatarios.

El efecto declarativo viene a ser un efecto retroactivo. De ahí que la adjudicación y la partición sean títulos declarativos de dominio, como lo dice sin mucha claridad el 703 CC.

La adjudicación se opone a la enajenación. El adjudicatario adquiere por sucesión por causa de muerte y no porque los coasignatarios le efectúen la tradición.

En Roma, tenía efecto traslativo de dominio. En Francia tuvo su origen el efecto en estudio. Se estableció basado en 2 razones:

1. Tributaria: si era traslativa de dominio, debían pagarse los impuestos al señor feudal.

2. Civil: si a un heredero se le embargaba un bien hereditario, o éste lo daba en hipoteca, y el bien luego era adjudicado a otro, éste debía soportar los gravámenes.

- **Campo de aplicación del efecto declarativo de la partición.**

A) El efecto declarativo se aplica siempre que exista adjudicación, aplicándose por tanto, cuando existan particiones en naturaleza, adjudicaciones en remate, etc. También respecto del dinero producido por la licitación de un bien común.

B) El efecto declarativo se aplica a los indivisarios y a los cesionarios de la cuota parte.

- **¿Cómo se dividen los créditos de la sucesión?**

1344: problema interpretativo. ¿Qué ocurre con los créditos que tenía el causante?

A primera vista podría afirmarse que no habría problema, porque siendo los créditos parte del activo, deben seguir la misma suerte de éste. Lo que genera el problema es la aparente contradicción entre el 1344 inciso 1º y el inciso final del No. 4 del Art. 1526.

1344 inciso 1º: Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión.

La expresión "efectos" es muy amplia. Los créditos no se dividirían de pleno derecho, toda vez que ellos podrían ser objeto de partición y de incluirse en el lote de cualquiera de los herederos.

1526 No. 4 inciso final: Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente su acción, no podrán exigir el pago de la deuda, sino a prorrata de sus cuotas.

En otros términos, el precepto faculta a los herederos para exigir su cuota en el crédito, lo que indicaría que éste, al igual que las deudas hereditarias, se ha dividido de pleno derecho por el solo fallecimiento.

Algunos simplemente optan por darle preferencia a uno por sobre otro. La mayoría, a fin de darles aplicación a ambos preceptos, señala que el 1526 reglamenta las relaciones de los herederos con el deudor; y el 1344 la de los herederos entre sí. De tal forma, respecto del deudor, los créditos se dividen de pleno derecho entre los herederos al fallecer el causante. Entre los herederos el crédito permanece indiviso hasta la partición.

- Principales Consecuencias del efecto declarativo de la partición.

1. 1344 inciso 2º: si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa ajena.
2. 2147: si un comunero hipoteca un inmueble de la sucesión, para verificar la suerte de dicha hipoteca, es necesario esperar las resultas de la partición. Sin embargo, nada obsta a que los coasignatarios consientan en la hipoteca, la que producirá sus efectos cuando el consentimiento del adjudicatario conste en escritura pública y se tome razón al margen de la inscripción.
3. A la partición no se le aplica el 1464, porque la adjudicación no constituye enajenación.
4. Los derechos reales constituidos por un indivisario sólo subsisten si el bien gravado le es adjudicado. 718.
5. Si un bien común es embargado durante la indivisión por el acreedor de un heredero, para determinar la suerte del embargo también hay que esperar las resultas de la partición.
6. Aun cuando los herederos no hayan efectuado las inscripciones del decreto o resolución de posesión efectiva y especial de herencia, puede efectuar la adjudicación, por no existir enajenación.
7. A la adjudicación de bienes raíces no se aplican los requisitos exigidos para la enajenación de los inmuebles de los incapaces, porque no constituye tradición.
8. Si se encuentra casado en SC el indivisario, el bien adjudicado entra a su haber propio si es inmueble y al relativo si es mueble.

La Obligación de Garantía en la Partición

- **Evicción en la partición.** La obligación de garantía es propia de los contratos onerosos y conmutativos. Comprende fundamentalmente el saneamiento de los vicios redhibitorios y de la evicción.

En la partición NO se aplican los vicios redhibitorios, sino sólo la evicción.

Art. 1345. El partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que le cupo en la partición, o que haya sufrido evicción de él, lo denunciará a los otros partícipes para que concurran a hacer cesar la molestia, y tendrá derecho para que le saneen la evicción.

Esta acción prescribirá en cuatro años contados desde el día de la evicción.

El bien adjudicado a X, no pertenecía al causante, sino a un tercero que se lo reivindica al adjudicatario.

- **Fundamento de la acción de evicción:** obtener la igualdad de los comuneros.

- **Casos en los cuales no procede la evicción. 1346**

1. Cuando la evicción o molestia proviene de causas sobrevinientes a la partición.
2. Cuando la acción de saneamiento se hubiere expresamente renunciado.
3. Cuando el partícipe ha sufrido la molestia o evicción por su culpa.
4. Cuando la acción ha prescrito. 1345 inciso 2º.

- **Efectos de la evicción.** A semejanza de lo ocurrido en la compraventa, la evicción en la partición tiene dos etapas: hacer cesar las molestias y una vez que ésta se ha consumado, indemnizar la evicción.

Las molestias deben ser de derecho. A diferencia de lo que ocurre en la compraventa, y por no haberlo exigido la ley, no es necesario que el adjudicatario cite a los demás asignatarios.

1347 inciso 1º: el pago del saneamiento se divide entre los partícipes a prorrata de sus cuotas. La porción del insolvente grava a los demás, incluso al que debe ser indemnizado (se busca la igualdad)

ACCIONES Y RECURSOS QUE PUEDEN HACERSE VALER CONTRA LA PARTICIÓN

- **La nulidad en la partición.**

1348 inciso 1º: las particiones se anulan o rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos.

La afirmación es plenamente aplicable a la partición hecha por el causante o los coasignatarios de común acuerdo, pero tratándose de la partición hecha ante partidor, debe completarse diciendo que, junto a las nulidades de carácter civil, existen en la partición nulidades procesales.

- **La nulidad en la partición puede ser total o parcial, absoluta o relativa.** "Se anula o rescinde", señala el 1348.

Asimismo existen casos de **inoponibilidad por falta de concurrencia**: ej. Se hace la partición por los coasignatarios de común acuerdo y se omite a uno de los interesados.

Conclusión: en la partición pueden presentarse todas las sanciones propias de los actos y contratos: nulidad, rescisión e inoponibilidad.

- **Suplemento de partición.** 1349: El haber omitido involuntariamente algunos objetos no será motivo para rescindir la partición. Aquella en que se hubieren omitido, se continuará después, dividiéndolos entre los partícipes con arreglo a sus respectivos derechos.

- **Nulidades procesales en la partición. Importancia de distinguir entre nulidad civil y procesal.** Será de carácter procesal, cuando se sigue un juicio particional. Será nulo procesalmente hablando cuando se omita una ritualidad del juicio particional (por ej. Partidor no jura).

Importancia de la distinción: la nulidad procesal debe alegarse durante el mismo juicio de partición por medio de los recursos legales. Terminada la partición y ejecutoriada la resolución del partidor, no se podrá pedir la nulidad de lo obrado. Las nulidades civiles pueden hacerse valer durante el juicio particional o después de él.

- **Rescisión de la partición por LESIÓN.** Su fundamento es la igualdad que se busca entre los coasignatarios.

1348 inciso 2º: La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota.

Declarada judicialmente la rescisión, ésta quedará sin efecto y será necesario proceder a realizar una nueva partición para darle al lesionado lo que de derecho le corresponde.

Como la partición es un proceso muy complejo, el Art. 1350 dispone que: Podrán los otros partícipes atajar la acción rescisoria de uno de ellos, ofreciéndole y asegurándole el suplemento de su porción en numerario.

- **No puede solicitar la nulidad o rescisión el partícipe que haya enajenado su porción en todo o parte.** Art. 1351. No podrá intentar la acción de nulidad o rescisión el partícipe que haya enajenado su porción en todo o parte, salvo que la partición haya adolecido de error, fuerza o dolo, de que le resulte perjuicio.

- **Prescripción de la acción de nulidad. Art. 1352.** La acción de nulidad o de rescisión prescribe respecto de las particiones según las reglas generales que fijan la duración de esta especie de acciones.

- **Otros recursos para obtener sólo indemnización de perjuicios.**

Art. 1353. El partícipe que no quisiere o no pudiese intentar la acción de nulidad o rescisión, conservará los otros recursos legales que para ser indemnizado le correspondan.

El legislador, por este medio busca evitar la nulidad de la partición.

- **La acción resolutoria no se aplica a la partición.** Aplicación a las deudas alcances.

1. Se opone a dicha acción el efecto declarativo de la partición, porque se supone que el adjudicatario ha sucedido directamente al causante, y no ha adquirido sus derechos de los otros coasignatarios.

2. El legislador, en el 1348, expresamente hace aplicables las acciones de nulidad y rescisión sin indicar la resolución.

3. El 1489 se limita a los contratos bilaterales.

4. El 1489 es doblemente excepcional: establece una condición como elemento de la naturaleza y en forma tácita.

5. El legislador otorga otro medio de defensa a los coasignatarios: la hipoteca legal.

6. No cabe la acción resolutoria en el 1353: "otros recursos legales".

Sin perjuicio de lo anterior, no existe problema para que en la partición se pacten condiciones resolutorias: se dice expresamente que si el asignatario alcanzado no paga el alcance, se resuelve la adjudicación. Al parecer el problema sería con la condición resolutoria tácita.

DEL PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS Y TESTAMENTARIAS Y DEL BENEFICIO DE SEPARACIÓN

Las deudas hereditarias son aquellas que tenía en vida el causante. Deudas o cargas testamentarias son las que emanan del testamento. La principal de las cargas testamentarias está representada por los legados. El modo es también una carga testamentaria.

- Responsabilidad de los herederos por las deudas de la herencia.

En principio, las deudas de la herencia corresponden sólo a los herederos. Así lo señala el 951 y el 1097.

La responsabilidad de los herederos por las deudas hereditarias es amplia y se extiende a todas las obligaciones transmisibles del causante, cualquiera sea su origen o fuente. Así, incluso responderán por el delito o cuasidelito del causante: 2316.

Esta amplia responsabilidad de los herederos, tiene algunas limitaciones:

1. No pasan a los asignatarios las obligaciones intransmisibles del causante.
2. Los herederos pueden limitar su responsabilidad mediante el beneficio de inventario.

- **Contra los herederos puede procederse ejecutivamente, cuando podía hacerse en igual forma en contra del causante, pero previa notificación a aquéllos del título respectivo.** Art. 1377. Los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los herederos; pero los acreedores no podrán entablar o llevar adelante la ejecución, sino pasados ocho días después de la notificación judicial de sus títulos.

El precepto contempla una especie de preparación de la vía ejecutiva, para que pueda entablarse o seguirse adelante un juicio ejecutivo contra los herederos. El plazo de los 8 días tiene por objeto que los herederos tomen conocimiento de una deuda ejecutiva que pueden haber ignorado.

El precepto está en contradicción aparente con el Art. 5 del CPC: Si durante el juicio fallece alguna de las partes que obre por sí misma, quedará suspenso por este hecho el procedimiento, y se pondrá su estado en noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso de su derecho en un plazo igual al de emplazamiento para contestar demandas, que conceden los artículos 258 y 259.

Se ha pretendido decir que el CPC derogaría al CC. Sin embargo, Somarriva cree que el CPC deroga parcialmente el 1377. Los herederos tendrán el término de emplazamiento para comparecer a la ejecución cuando el causante falleció mientras se sustanciaba el proceso. Pero si aún no se había entablado, o el causante actuaba representado, se aplica el plazo de 8 días, ya que estas situaciones no se contemplan en el CPC.

- Fundamento de la responsabilidad de los herederos.

Hay quienes buscan fundamentar la obligación de los herederos en el cuasicontrato de aceptación de herencia, basándose en el tenor del 1437. Sin embargo, es errónea dicha asimilación de la aceptación de la herencia a un cuasicontrato. De tal forma, la explicación más generalizada es que la responsabilidad de los herederos emana de la ley, la cual concibe a los herederos como representantes del difunto. Como tales, les pasa no sólo el activo, sino también el pasivo.

CÓMO SE DIVIDEN LAS DEUDAS HEREDITARIAS ENTRE LOS HEREDEROS

- Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos de pleno derecho y a prorrata de los derechos de cada cual. 1354: las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas.

Existe una marcada diferencia entre la división del activo y la del pasivo. La división del pasivo se produce de pleno derecho, mientras que el activo, genera una comunidad entre los herederos, que es necesario partir.

- Consecuencias principales del hecho de que las deudas se dividan a prorrata.

1. La obligación entre los herederos es conjunta.

Sólo se puede demandar a cada uno de los deudores su parte o cuota en la deuda. Se trata de una conjunción derivativa.

2. La insolvencia de un heredero no grava a los otros.

Art. 1355. La insolvencia de uno de los herederos no grava a los otros; excepto en los casos del artículo 1287, inciso segundo.

La excepción se refiere a que se extiende a los herederos la obligación de los albaceas en orden a avisar la apertura de la sucesión y cuidar que se forme la hijuela pagadora de deudas en la partición, so pena de responder

solidariamente de los perjuicios a los acreedores. En tal caso la obligación es solidaria, y la insolvencia de un deudor, en dicho caso, grava a los otros.

3. Se extingue la solidaridad, con la muerte del deudor solidario.

La obligación de los herederos será conjunta. Puede cobrarse del todo demandando a los herederos en su conjunto o cobrar la cuota de cada uno de ellos (o cobrar el todo en los otros codeudores).

4. Se produce confusión parcial entre las deudas y créditos del causante y los del heredero.

Art. 1357: Si uno de los herederos fuere acreedor o deudor del difunto, sólo se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en este crédito o deuda le quepa, y tendrá acción contra sus coherederos a prorrata por el resto de su crédito, y les estará obligado a prorrata por el resto de su deuda.

- Excepciones al principio de que las deudas se dividen a prorrata.

1. Caso del heredero beneficiario.

El heredero beneficiario no es obligado al pago de ninguna cuota de las deudas hereditarias, sino hasta la concurrencia de lo que valga lo que hereda. Recibió 100 y por deudas le correspondían 200, según el prorrateo.

2. Obligaciones indivisibles.

La obligación del causante era indivisible: 1526. La indivisibilidad de pago es una excepción al principio de la división de las deudas hereditarias a prorrata entre los herederos, porque la indivisibilidad, a diferencia de la solidaridad, se transmite a los herederos del deudor, pudiendo exigirse el total del crédito en el patrimonio de uno de los herederos del deudor.

3. Caso del usufructo.

En conformidad al 1356, los herederos usufructuarios dividen las deudas hereditarias con los herederos propietarios, según el 1368: si el testador deja el usufructo de una parte de sus bienes o de todos a una persona y la desnuda propiedad a otra, el propietario y el usufructuario se considerarán como una sola persona para la distribución de las obligaciones hereditarias o testamentarias que cupieren a la cosa fructuaria, y las obligaciones que unidamente les quepan se dividirán entre ellos.

- Debe pagar las deudas hereditarias que corresponden unidamente al propietario y usufructuario el primero de ellos. El acreedor deberá dirigirse contra el propietario. El usufructuario estará obligado a pagarle al propietario nudo los intereses corrientes de la cantidad pagada, durante todo el tiempo que continuare el usufructo.

- Si el propietario no se allana a pagar, el usufructuario puede pagar, y a la expiración del usufructo tendrá derecho a que el propietario le reintegre el capital pagado, pero sin intereses.

- Si se vende la cosa fructuaria para cubrir una hipoteca o prenda constituida en ella por el difunto, se aplicará al usufructuario la disposición del artículo 1366.

- Al usufructo constituido durante la partición se le aplican las mismas reglas estudiadas. 1371.

4. Caso del fideicomiso.

1356 señala que los herederos fiduciarios y fideicomisarios dividen entre sí las deudas de la herencia, conforme al 1372: El propietario fiduciario y el fideicomisario se considerarán en todo caso como una sola persona respecto de los demás asignatarios para la distribución de las deudas y cargas hereditarias y testamentarias, y la división de las deudas y cargas se hará entre los dos del modo siguiente:

El fiduciario sufrirá dichas cargas con calidad de que a su tiempo se las reintegre el fideicomisario sin interés alguno.

Si las cargas fueren periódicas, las sufrirá el fiduciario sin derecho a indemnización alguna.

5. Caso en que existan varios inmuebles sujetos a hipoteca.

1365: Si varios inmuebles de la sucesión están sujetos a una hipoteca, el acreedor hipotecario tendrá acción solidaria contra cada uno de dichos inmuebles, sin perjuicio del recurso del heredero a quien pertenezca el inmueble contra sus coherederos por la cuota que a ellos toque de la deuda.

Aun cuando el acreedor haya subrogado al dueño del inmueble en sus acciones contra sus coherederos, no serán cada uno de éstos responsables sino de la parte que le quepa en la deuda.

Pero la porción del insolvente se repartirá entre todos los herederos a prorrata.

No está bien usado el término "solidaria". Lo que ocurre es que se trata de un caso de indivisibilidad de la acción hipotecaria consagrada en el 2408.

Será de esta forma una excepción, sólo cuando el acreedor entable la acción hipotecaria y no cuando haga uso de la personal.

6. Caso en que se acuerde una división distinta de las deudas.

Esta división distinta puede tener su origen:

a- En la voluntad del testador. 1358.

b- En la partición. 1340 y 1359: al hacerse la liquidación de los bienes, algún heredero puede tomar a su cargo una parte mayor de las deudas que le correspondían a prorrata.

c- En un convenio de los herederos. 1359.

El acreedor no se ve afectado por esta nueva división, por no haber sido parte de ella. Por ello, tiene un derecho de opción. 1358, 1359 y 1526 No. 4

RESPONSABILIDAD DE LOS LEGATARIOS POR LAS DEUDAS DE LA HERENCIA

En principio, la responsabilidad por las deudas de la herencia pertenece a los herederos, pero en ciertos casos pueden verse afectados por ellas los legatarios. La responsabilidad de éstos, respecto de las deudas hereditarias, puede emanar de 3 factores:

1. Del pago de las legítimas y mejoras.

2. Responsabilidad por las deudas de la herencia en subsidio de los herederos.
3. Del hecho de que el bien legado esté gravado con prenda o hipoteca.

1. Del pago de las legítimas y mejoras.

Será responsable el legatario, en este evento, cuando el testador haya destinado a legados más de la suma de que podía disponer libremente. 1362 inciso 1º: Los legatarios no son obligados a contribuir al pago de las legítimas, de las asignaciones que se hagan con cargo a la cuarta de mejoras..., sino cuando el testador destine a legados alguna parte de la porción de bienes que la ley reserva a los legitimarios o a los asignatarios forzosos de la cuarta de mejoras.

2. Responsabilidad por las deudas de la herencia en subsidio de los herederos.

El propio 1362 así lo establece. Para que los legatarios tengan responsabilidad por las deudas de la herencia, deben concurrir 2 requisitos:

- a- Que al tiempo de abrirse la sucesión no haya habido en ella lo bastante para pagar las deudas hereditarias; y
- b- En todo caso, la responsabilidad de los legatarios es en subsidio de los herederos.

Los legatarios tienen una especie de beneficio de excusión.

- **¿Tiene límites la responsabilidad del legatario?** ¿Está limitado a lo recibido a título de legado o es ilimitado?

No existe norma expresa. Somarriva cree que su responsabilidad se limita al valor recibido, gozando de una especie de *beneficio de inventario otorgado por la ley*. Razones:

- i) 1364 limita su responsabilidad en el pago de una carga testamentaria. Debemos aplicar igual principio a la cancelación de las deudas hereditarias.
- ii) 1367.

- **Orden en que los legados concurren al pago de las legítimas y mejoras y deudas hereditarias.** Existe un orden de prelación, que surge de la relación de los artículos 1363, 1170, 1194 y 1141.

En primer lugar, responden los legados comunes, y agotados éstos, van respondiendo los legados preferenciales, según el grado de privilegio de que gocen. Para estos efectos, los legados se agrupan en 6 categorías:

- 1) Los legados estrictamente alimenticios, que el testador debe por ley. Es una impropiedad del 1363 hablar de "legados", porque en este caso, se trata de una asignación forzosa. En todo caso, la idea no se ve afectada: las pensiones alimenticias, como asignación forzosa, se pagan antes que cualquier legado. El 1363 los hace contribuir y el 1170 indica que no están sujetos a devolución. Somarriva concluye que, la forma en que las pensiones alimenticias contribuyen al pago de las deudas, es rebajándose los alimentos futuros.

2) El exceso de las legítimas y mejoras. 1194, 1189 y 1193. Las asignaciones a título de legítima o de mejora que excedan la parte de mejoras o legítimas de la herencia, se pagan con preferencia. No se trata propiamente de legados, pero la idea es la misma que en el punto 1).

3) Los legados expresamente exonerados por el testador. 1363 inciso 2º: No contribuirán, sin embargo, con los otros legatarios aquellos a quienes el testador hubiere expresamente exonerado de hacerlo. Pero si agotadas las contribuciones de los demás legatarios, quedare incompleta una legítima o insoluta una deuda, serán obligados al pago aun los legatarios exonerados por el testador.

4) Los legados de obras pías o de beneficencia pública. 1363 inciso 3ª: Los legados de obras pías o de beneficencia pública se entenderán exonerados por el testador, sin necesidad de disposición expresa, y entrarán a contribución después de los legados expresamente exonerados.

El legislador presume la exención de responsabilidad.

5) Las donaciones revocables y legados entregados en vida por el testador. 1141 inciso final: las donaciones revocables y legados entregados en vida por el testador a los beneficiados por ellos, preferirán a los legados de que no se ha dado el goce en vida del testador, cuando los bienes dejados por éste a su muerte no alcanzan a cubrirlos todos.

6) Los legados comunes. Están en el último orden, no gozando de preferencia alguna para su pago. El acreedor se dirigirá en primer lugar contra ellos y luego irá subiendo por la escala antes señalada. Luego de los comunes irá contra los del 5º orden.

- La responsabilidad de los legatarios es a prorrata de sus legados.
Existe una obligación conjunta entre ellos.

- Legados con causa onerosa.

Art. 1367. Los legados con causa onerosa que pueda estimarse en dinero, no contribuyen sino con deducción del gravamen, y concurriendo las circunstancias que van a expresarse:

1ª Que se haya efectuado el objeto.

2ª Que no haya podido efectuarse sino mediante la inversión de una cantidad determinada de dinero.

Una y otra circunstancia deberá probarse por el legatario, y sólo se deducirá por razón del gravamen la cantidad que constare haberse invertido.

Ej. Dejo \$1000 a X, con la obligación de pagar \$100 al acreedor del causante. El legado de X sólo entra a contribución luego de pagados los \$100.

3. Del hecho de que el bien legado esté gravado con prenda o hipoteca.

1366: El legatario que en virtud de una hipoteca o prenda sobre la especie legada ha pagado una deuda hereditaria con que el testador no haya expresamente querido gravarle, es subrogado por la ley en la acción del acreedor contra los herederos.

Si la hipoteca o prenda ha sido accesorio a la obligación de otra persona que el testador mismo, el legatario no tendrá acción contra los herederos.

DEL PAGO DE LAS CARGAS TESTAMENTARIAS O LEGADOS

Son las deudas establecidas por el testador en su testamento. La principal de ellas son los legados, y también el modo.

- Quiénes deben pagar los legados.

Distintas situaciones:

1. **Situaciones contempladas en el 1360. (a)** El testador en su testamento impone el pago del legado a determinada persona, pudiendo ser éste un heredero o legatario (si es legatario goza de pleno derecho del beneficio de inventario) o bien **(b)** indica en el mismo la forma en que ellos deben ser pagados, o, **(c)** no dice nada en el testamento, en cuyo evento se aplica la regla general de que las deudas testamentarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas. 1373.
2. **Que los herederos dispongan la división de los legados.** En la partición o por convenio. Los acreedores testamentarios tienen el mismo derecho que el de los acreedores hereditarios, esto es, el **derecho de opción**: pueden aceptar el acuerdo o perseguir a cada heredero a prorrata de su cuota.
3. **Que las cargas testamentarias recaigan en un usufructo.** 1369 y 1370.
 - a. Art. 1369. Las cargas testamentarias que recayeren sobre el usufructuario o sobre el propietario, serán satisfechas por aquel de los dos a quien el testamento las imponga y del modo que en éste se ordenare; sin que por el hecho de satisfacerlas de ese modo le corresponda indemnización o interés alguno.
 - b. Art. 1370. Cuando imponiéndose cargas testamentarias sobre una cosa que está en usufructo, no determinare el testador si es el propietario o el usufructuario el que debe sufrirlas, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1368.

Pero si las cargas consistieren en pensiones periódicas, y el testador no hubiere ordenado otra cosa, serán cubiertas por el usufructuario durante todo el tiempo del usufructo, y no tendrá derecho a que le indemnice de este desembolso el propietario.
4. **Que incidan en un fideicomiso.** Se aplican las mismas normas que para el pago de las deudas hereditarias. El fiduciario corre con las cargas testamentarias, para que, a su tiempo, se las reembolse el fideicomisario sin interés alguno. No tiene derecho a reembolso si las cargas fueren periódicas.

- **Forma y oportunidad de pago de los legados. Los acreedores hereditarios se pagan antes que los testamentarios.** 1374. La regla es lógica porque las deudas hereditarias son una baja general de la herencia y los legados, sólo se pagan de la parte de que el testador pudo disponer libremente.

- **Casos en que los legados pueden pagarse inmediatamente.**

1372 incisos 2º y 3º: Pero cuando la herencia no apareciere excesivamente gravada, podrá satisfacerse inmediatamente a los legatarios que ofrezcan caución de cubrir lo que les quepa en la contribución a las deudas.

Ni será exigible esta caución cuando la herencia está manifiestamente exenta de cargas que puedan comprometer a los legatarios.

- **Gastos para la entrega de los legados.** 1375: se miran como parte de los legados.

- **Caso en que no haya lo suficiente para el pago de todos los legados.**

1376: No habiendo en la sucesión lo bastante para el pago de todos los legados, se rebajarán a prorrata.

Esto debe ser entendido para los legados comunes, ya que los privilegiados se pagan antes que todos los demás.

- **Obligaciones de los albaceas respecto del pago de los legados.** El CC les otorga ciertas funciones a los ejecutores testamentarios en relación con el pago de legados.

- **Pago de legados de pensiones periódicas.**

1361: Los legados de pensiones periódicas se deben día por día desde aquel en que se defieran, pero no podrán pedirse sino a la expiración de los respectivos períodos, que se presumirán mensuales.

Sin embargo, si las pensiones fueren alimenticias, podrá exigirse cada pago desde el principio del respectivo período, y no habrá obligación de restituir parte alguna aunque el legatario fallezca antes de la expiración del período.

Si el legado de pensión alimenticia fuere una continuación de la que el testador pagaba en vida, seguirá prestándose como si no hubiese fallecido el testador.

Sobre todas estas reglas prevalecerá la voluntad expresa del testador.

EL BENEFICIO DE SEPARACIÓN

Art. 1378: Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero; y en virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero.

Beneficio de separación: facultad que le compete a los acreedores hereditarios y testamentarios a fin de que los bienes hereditarios no se confundan con los bienes propios del heredero, con el objeto de pagarse en dichos bienes hereditarios con preferencia a los acreedores personales del heredero.

- **Fundamento:** equidad. El heredero pudo tener un pasivo muy alto y la herencia estando cargada de activos, beneficiaría a los acreedores del heredero. Concurrirían en iguales condiciones los acreedores hereditarios y los personales del heredero. No se viola ningún derecho de los acreedores del

heredero, porque al contratar, ellos sólo tuvieron a la vista el patrimonio del heredero y no el del causante.

- **Quiénes pueden solicitar el beneficio de separación.** 1378: concede el beneficio a los acreedores hereditarios y a los testamentarios indistintamente. Según el 1379, también puede ser invocado por el acreedor condicional, cuestión que se explica por ser este beneficio una medida conservativa. Dentro de este marco, es que se cataloga al beneficio de separación como un derecho auxiliar del acreedor.

- **Los acreedores del heredero no gozan del beneficio de separación.** El heredero tiene un modo de evitar el perjuicio de sus acreedores personales: aceptar la herencia con beneficio de inventario.

- **Casos en que los acreedores hereditarios y testamentarios no pueden solicitar el beneficio de separación.** 1380: no tendrán este derecho:

1. Cuando sus derechos han prescrito.
2. Cuando hayan renunciado a él.
3. Cuando los bienes de la sucesión han salido de manos del heredero.
4. Cuando los bienes de la sucesión se han confundido con los de los herederos, de manera que no sea posible reconocerlos.

- **El beneficio de separación obtenido por uno de los acreedores hereditarios o testamentarios favorece a todos los demás,** siempre que sus derechos no hayan prescrito ni hayan renunciado a solicitarlo. 1382.

- **Procedimiento del beneficio de separación.**

La ley no ha señalado el procedimiento al cual acogerse, ni en contra de quien debe ella presentarse. Respecto de esto último, pueden darse 2 soluciones:

- a) Debe pedirse en contra de los herederos; o
- b) Debe demandarse contra los acreedores personales de los herederos.

La última solución es la más jurídica, porque ellos serán los afectados. Sin embargo, es muy dificultosa en la práctica, razón por la cual debemos inclinarnos por la primera opción.

Como no se señala procedimiento, podría pensarse que se tramita conforme a las normas del juicio ordinario. Pero bien podría sostenerse que se tramita conforme a las normas del juicio sumario, por la necesidad de rapidez.

En caso que sea declarada la quiebra, los acreedores del difunto gozarán del beneficio.

- **Efectos del beneficio de separación. Desde cuándo se producen.**

- a. Respecto de los muebles, el beneficio de separación produce sus efectos desde que se dicta la sentencia que lo concede.
- b. Respecto de los inmuebles, además es necesaria la inscripción de la sentencia en el Registro del CBR. 52 No. 4 del Reglamento del CBR.

- **El beneficio de separación, a diferencia del de inventario, sí produce separación de patrimonios.** Ese es precisamente su objeto. 520 CPC así lo demuestra.

- **Efectos del beneficio de separación entre los acreedores hereditarios y testamentarios entre sí.** Los acreedores hereditarios y testamentarios se pagan en los bienes de la sucesión con preferencia a los personales de los herederos. Los acreedores hereditarios y los testamentarios concurren conforme a las normas antes estudiadas: 1º se pagan los hereditarios.

- **Efectos del beneficio de separación entre los acreedores hereditarios y testamentarios de una parte y los acreedores personales del heredero de otra.**

Art. 1382. Obtenida la separación de patrimonios por alguno de los acreedores de la sucesión, aprovechará a los demás acreedores de la misma que la invoquen y cuyos créditos no hayan prescrito, o que no se hallen en el caso del número 1º del artículo 1380.

El sobrante, si lo hubiere, se agregará a los bienes del heredero, para satisfacer a sus acreedores propios, con los cuales concurrirán los acreedores de la sucesión que no gocen del beneficio.

Art. 1383. Los acreedores hereditarios o testamentarios que hayan obtenido la separación, o aprovechándose de ella en conformidad al inciso 1º artículo precedente, no tendrán acción contra los bienes del heredero, sino después que se hayan agotado los bienes a que dicho beneficio les dio un derecho preferente; más aun entonces podrán oponerse a esta acción los otros acreedores del heredero hasta que se les satisfaga en el total de sus créditos.

Existe armonía entre ambas normas: 1382: en los bienes hereditarios se pagan primero los acreedores hereditarios y testamentarios; y el 1383 dispone que en los bienes propios del heredero, se pagan primero sus acreedores personales.

- **A pesar del beneficio de separación, los herederos se hacen dueños de los bienes hereditarios, pero tienen ciertas limitaciones respecto de su dominio.**

Art. 1384. Las enajenaciones de bienes del difunto hechas por el heredero dentro de los seis meses subsiguientes a la apertura de la sucesión, y que no hayan tenido por objeto el pago de créditos hereditarios o testamentarios, podrán rescindirse a instancia de cualquiera de los acreedores hereditarios o testamentarios que gocen del beneficio de separación. Lo mismo se extiende a la constitución de hipotecas o censos.

A pesar de que la ley habla de actos que se "rescindan", esta acción especial tiene mucho de acción pauliana.

Las que se hagan luego de los 6 meses serían atacables por la acción pauliana del 2468, probando los requisitos de ella.

DE LAS DONACIONES IRREVOCABLES O ENTRE VIVOS

La ubicación que el CC le otorga a esta materia (al final del Libro III) es criticable, debido a que las donaciones entre vivos son contratos, razón por la cual deberían estar ubicadas en el Libro IV.

Se ha defendido la ubicación, por las siguientes razones:

- a. Fuera de la sucesión por causa de muerte, la otra forma de adquirir bienes a título gratuito, es precisamente por la donación.
- b. Muchas normas de la Sucesión por causa de muerte se aplican a la donación.
- c. Razón histórica: el CC las trata conjuntamente a la sucesión por causa de muerte.

- Normas por las cuales se rigen las donaciones.

- a. Título XIII del Libro III: 1386 a 1436;
- b. En virtud del 1416 inciso 1º, se aplican también las siguientes normas de las asignaciones testamentarias:
 - 1. Las normas sobre interpretación de éstas;
 - 2. Las disposiciones sobre condiciones, plazos y modos;
 - 3. Las reglas concernientes al derecho de acrecer y las sustituciones.
- c. Normas de la sucesión por causa de muerte, en virtud de preceptos como el 1411 inciso final o el 1391.
- d. En conformidad al 1416 inciso 2º "en lo demás que no se oponga a las disposiciones de este Título, se seguirán las reglas generales de los contratos".
- e. Ley 16.271: materia tributaria.

CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LAS DONACIONES

Art. 1386. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta.

- Queda establecida la irrevocabilidad de la donación entre vivos. 1136 nos había dicho que son denominaciones sinónimas las de donaciones irrevocables y donaciones entre vivos.

- Críticas a la definición:

- a. Debió haber señalado que es un contrato y no que es un acto, ya que dicha expresión generalmente se reserva para actos unilaterales. De la propia definición se extrae que es un acto, porque requiere de la aceptación de la otra parte: donatario.
- b. La causa del error está en el CC francés y la causa del error de éste está en la persona de Napoleón Bonaparte: señaló éste, que la donación no podía calificarse como un contrato, porque en la donación sólo se obligaba una de las partes. Confundía lo que son los actos unilaterales, con lo que son los contratos bilaterales.

- Características de las donaciones:

1. Es un contrato gratuito: el donante es quién sufre el gravamen y el donatario quién recibe el beneficio.
2. Es un contrato unilateral: del contrato de donación sólo surgen obligaciones para el donante.
3. Es un contrato principal
4. Es un contrato nominado
5. Generalmente es consensual: aun cuando sea la RG, existen tantas excepciones que en la práctica, la regla es la contraria.
6. Es un contrato de ejecución instantánea: hace excepción a lo anterior, las donaciones de pensiones periódicas.
7. Es un contrato entre vivos. Es la única forma de adquirir a título gratuito por acto entre vivos.
8. Es un contrato de excepción, porque nunca se presume: 1393: la donación entre vivos no se presume, sino en los casos que expresamente hayan previsto las leyes. En aplicación de esta norma, encontramos el artículo 2299.
9. Es irrevocable. La propia definición la establece, para diferenciarlas de las donaciones revocables estudiadas a propósito de la sucesión por causa de muerte.
No es raro que la donación entre vivos sea irrevocable, ya que esa es la regla general en los contratos: 1545. Existe una causal de revocación propia de las donaciones: **ingratitud del heredero**: 1428.
10. La donación es siempre a título singular: en las donaciones sólo se ceden bienes determinados, salvo el caso en que se done un derecho de herencia.
11. Es un título traslativo de dominio. 675 y 703.

Hay quienes discuten lo anterior, afirmando que la donación en sí misma es un modo de adquirir el dominio, basándose en los siguientes argumentos:

a- La definición señala que ésta es un acto por el cual una persona "transfiere". A diferencia de lo que ocurre con los términos del contrato de compraventa (se obliga a dar una cosa), en el de donación se establece que por ella misma se transfiere.

b- Por la ubicación que da el Código a la materia. Si el CC la reglamentó luego de la Sucesión por causa de muerte -MAD- y no la trató con los contratos, fue porque la consideró un MAD. Es debilitado este argumento, por las razones antes señaladas.

c- La donación de bienes raíces requiere de inscripción en el CBR. Se afirma que esta inscripción es solemnidad y tradición, quedando en dicho acto perfeccionado el contrato.

Se descarta este argumento, porque la inscripción es sólo la tradición del derecho.

De los 3 argumentos, sólo es medianamente lógico el 1º, pero sin llegar a destruir el tenor literal del 675 y 703.

Asimismo el 1417, sólo faculta al donatario para exigir la entrega de las cosas donadas, de lo cual extraemos que nace sólo un derecho personal para exigir la entrega. El 588, además, no enumera dentro de los MAD a la donación.

- Requisitos de las donaciones:

1) Consentimiento: la definición así lo establece.

Sin embargo, este consentimiento presenta algunas características particulares:

a- **Formación del consentimiento en la donación:** se forma por la notificación al donante de la aceptación del donatario, a diferencia de lo que ocurriría si se aplicaran las normas del CC, que se rigen por la teoría de la aprobación o declaración. En materia de donaciones, se sigue la teoría del conocimiento, en virtud de la disposición del 1412. El donante puede revocar a su arbitrio la donación, mientras el consentimiento no se forma. Se ha fallado que dicha revocación puede incluso ser tácita y que si muere el donante antes de que acepte el donatario, se extingue la donación.

b- **Aceptación del donatario:** la RG es que los actos jurídicos puedan celebrarse mediante mandatarios y representantes. El único que hace excepción marcada a este principio es el testamento. La donación, en cambio, no escapa a la regla general y puede celebrarse mediante mandatarios. 1411. El inciso 2º del 1411 establece un caso curioso de Representación legal: Pero bien podrá aceptar por el donatario, sin poder especial ni general, cualquier ascendiente o descendiente suyo, con tal que sea capaz de contratar y de obligarse.

Las reglas dadas sobre la validez de las aceptaciones y repudiaciones de herencias y legados se extienden a las donaciones.

- **En las donaciones no opera el derecho de transmisión.** Art. 1415. El derecho de transmisión establecido para la sucesión por causa de muerte en el artículo 957, no se extiende a las donaciones entre vivos.

2) Capacidad: la ley es más estricta respecto del donante que del donatario, por la lógica razón de que el primero se está desprendiendo de su patrimonio, siendo para el donatario un acto que no involucre peligro alguno.

- Capacidad del donante: 1387: Es hábil para donar entre vivos toda persona que la ley no haya declarado inhábil.

1388: Son inhábiles para donar los que no tienen la libre administración de sus bienes; salvo en los casos y con los requisitos que las leyes prescriben.

- De esta manera, para donar, se requiere de la más amplia capacidad: capacidad de enajenar.

- Los incapaces deberá donar por medio de sus representantes legales.

- Los hijos y los sujetos a tutela y curaduría se sujetan a una situación especial: 255 y 402: sus representantes legales jamás pueden donar sus bienes raíces, y para donar los muebles requieren autorización judicial.

- El marido no puede disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales, salvo el caso del 1735: el cónyuge que administre la sociedad podrá hacer donaciones de bienes sociales si fueren de poca monta, atendidas las fuerzas del haber social.

- 1792-15: en el régimen de participación en los gananciales, se forma una especie de acervo imaginario al que se acumulan las donaciones irrevocables que no correspondan al cumplimiento proporcionado de deberes morales o de usos sociales, en consideración a la persona del donatario.

- Capacidad del donatario: 1389: Es capaz de recibir entre vivos toda persona que la ley no ha declarado incapaz.

Art. 1390. No puede hacerse una donación entre vivos a persona que no existe en el momento de la donación.

Si se dona bajo condición suspensiva, será también necesario existir al momento de cumplirse la condición; salvo las excepciones indicadas en los incisos 3º y 4º del artículo 962. (eclesiástico confesor, notario y testigos)

Art. 1391. Las incapacidades de recibir herencias y legados según los artículos 963 y 964 se extienden a las donaciones entre vivos.

El donatario debe requerir la misma capacidad que se requiere para suceder, lo que es plenamente justificable: de lo contrario el testador podría burlar las incapacidades para suceder, mediante la transferencia en vida.

3) Objeto

Es amplio. La ley no hace distinciones al respecto. Lo único que NO puede ser objeto de donaciones son los hechos, las obligaciones de hacer.

Art. 1396. Los servicios personales gratuitos no constituyen donación, aunque sean de aquellos que ordinariamente se pagan.

Esto se explica porque es requisito para que haya donación, que exista **empobrecimiento en un patrimonio y enriquecimiento para otro**. Tratándose de los hechos no existe empobrecimiento en el patrimonio del que presta el hecho, sino que simplemente deja de obtener una ganancia.

4) Causa

Es el mero espíritu de liberalidad, siendo concordante con el 1467 que señala que la pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.

Es precisamente a propósito de la donación, donde ha hecho crisis la doctrina clásica, que considera a la causa como algo inmutable en todo contrato, abriéndose paso la doctrina de la causa como la del móvil psicológico que se tuvo para contratar. Esto tiene importancia para analizar la licitud de la causa.

5) Solemnidades

Jurídicamente se entiende que la donación es consensual. En los hechos, se patentiza el hecho de que la donación es solemne. Se analizan las distintas solemnidades a propósito de los distintos tipos de donaciones.

6) Requisito especial de la donación: enriquecimiento y empobrecimiento recíproco de los patrimonios.

La donación supone un desplazamiento de bienes: bienes que salen del patrimonio del donante, significándole un empobrecimiento y van a radicarse en el del donatario, reportándole un enriquecimiento.

1398: no hay donación si habiendo, por una parte, disminución de patrimonio, no hay, por otra, aumento.

- Aplicaciones de este requisito especial de la donación:

1. No hay donación en la repudiación de una herencia, legado o donación, ni en dejar de cumplir la condición a que está subordinado un derecho eventual, aunque se hagan para beneficiar a un tercero. Sin embargo, los acreedores podrán ser autorizados por el juez para sustituirse a un deudor que así hace. 1394.
2. No hay donación en el comodato de un objeto cualquiera, aunque su uso o goce acostumbre a darse en arriendo. 1395.
3. Tampoco la hay en el mutuo sin interés. 1395.
4. No la hay en la remisión o cesión del derecho de percibir los réditos de un capital colocado a interés o censo. 1395.
5. No hace donación a un tercero el que a favor de éste se constituye en fiador o constituye una prenda o hipoteca; ni el que exonera de sus obligaciones al fiador, o remite una prenda o hipoteca, mientras está solvente el deudor; pero hace donación el que remite una deuda, o el que paga a sabiendas lo que en realidad no debe. 1397, 1653 y 2299.

En caso de que esté insolvente el deudor, habrá donación.

6. No hay donación en dejar de interrumpir la prescripción. 1399.
7. Los servicios personales gratuitos no constituyen donación, aunque sean de aquellos que ordinariamente se pagan. 1396.
8. La jurisprudencia también ha señalado, por ejemplo, que la renuncia en los gananciales no constituye donación.

CLASIFICACIÓN DE LAS DONACIONES

A través de la clasificación, estudiaremos las distintas solemnidades a que puede estar sujeta una donación.

A) DONACIONES ENTERAMENTE GRATUITAS

1. Donaciones enteramente gratuitas de bienes muebles de valor inferior a 2 centavos.

Este tipo de donación es totalmente consensual, siendo el único en que sea enteramente consensual una donación.

2. Donaciones enteramente gratuitas que excedan de 2 centavos.

Requieren de insinuación. 1401: la donación entre vivos que no se insinúa, sólo tendrá efecto hasta el valor de dos centavos, y será nula en el exceso.

- La insinuación en las donaciones. Es un requisito de las donaciones, y se define como la autorización de juez competente, solicitada por el donante o el donatario.

La jurisprudencia ha resuelto que no es necesario que la donación y la insinuación se hagan simultáneamente, porque la insinuación puede ser posterior a la donación e incluso posterior a la aceptación de la donación.

CPC regula la insinuación de la donación entre los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa. Ver artículos 889 y 890.

Debe ser presentada ante juez competente, y por tratarse de un asunto no contencioso, es juez competente el del domicilio del interesado (donante o donatario). El juez autorizará las donaciones en lo que no contravenga ninguna disposición legal. De esta manera y recordando lo dicho anteriormente, la insinuación es uno de los modos indirectos con que el legislador defiende las legítimas y mejoras.

Sanción por no existir insinuación: sólo tendrá efecto hasta el valor de dos centavos y será nula en el exceso. La CS ha declarado que dicha nulidad es absoluta, por tratarse de un requisito establecido en atención a la naturaleza del acto en sí mismo.

- **Insinuación en las donaciones de pensiones periódicas.** 1402: cuando lo que se dona es el derecho de percibir una cantidad periódicamente, será necesaria la insinuación, siempre que la suma de las cantidades que han de percibirse en un decenio excediere de dos centavos.

3. Donaciones de bienes raíces.

Siempre requerirán de insinuación, porque es imposible que hoy en día un inmueble valga menos que el precio límite del 1401. En seguida, esta donación requiere de escritura pública, inscrita en el respectivo Registro del Conservador. 1400: no valdrá la donación entre vivos de cualquiera especie de bienes raíces, si no es otorgada por escritura pública e inscrita en el competente Registro.

Respecto al rol de la inscripción:

- Somarriva: al igual que en la hipoteca, la inscripción en este caso, es la tradición. No se debe confundir el título con el modo de adquirir.
- Mayoría: es la solemnidad del contrato, de modo que éste se perfecciona mediante ella. En el mismo sentido la jurisprudencia, que determina que se puede revocar mientras no se haya practicado la inscripción.

4. Donaciones a título universal.

1407: existe impropiedad en el lenguaje, ya que la donación siempre es a título singular, según pone de manifiesto la propia definición del 1368. Esta donación es la más solemne de todas, sometida a 4 solemnidades:

- 1- Insinuación
- 2- Escritura pública
- 3- Inscripción en el CBR si comprende inmuebles
- 4- Inventario solemne de los bienes

La omisión de cualquiera de estos requisitos trae consigo la nulidad de la donación.

1407 inciso 2º: Si se omitiere alguna parte de los bienes en este inventario, se entenderá que el donante se los reserva, y no tendrá el donatario ningún derecho a reclamarlos.

Además estas donaciones están sujetas a una serie de gravámenes:

a- Las donaciones a título universal no se extenderán a los bienes futuros del donante, aunque éste disponga lo contrario. 1409.

b- El que hace una donación de todos sus bienes deberá reservarse lo necesario para su congrua subsistencia; y si omitiere hacerlo, podrá en todo tiempo obligar al donatario a que, de los bienes donados o de los suyos propios, le asigne a este efecto, a título de propiedad, o de un usufructo o censo vitalicio, lo que se estimare competente, habida proporción a la cuantía de los bienes donados. 1408.

Así se ve cómo el legislador no mira con buenos ojos los actos a título universal (compraventas, sociedades, por ejemplo). En este caso, la donación no tiene mucho de universal, por la exigencia del inventario y por la sanción en caso de omitirlo: reserva.

Podría afirmarse que existe donación a título universal cuando se dona un derecho de herencia. Aún así, algunos argumentan que lo donado es el derecho de herencia específicamente considerado.

5. Donaciones con cargo a restituir.

Son donaciones fideicomisarias. 1413 y 1414.

En cuanto a las solemnidades, está sujeta, a insinuación si es superior a 2 centavos. La ley nada más dijo, pero como se trata de un fideicomiso, debemos aplicar el 735, en conformidad al cual el fideicomiso por acto entre vivos se constituirá por escritura pública.

- **Aceptación de la donación fideicomisaria o con cargo de restituir.** Se hacen irrevocables con la aceptación del fiduciario. 1413. El fideicomisario no puede aceptar la donación sino al momento de la restitución, pero puede repudiar antes de entonces. Es la misma regla que da el 1226 para las asignaciones condicionales.

- **Derecho del fiduciario y del donante a alterar la donación.**

Art. 1414. Aceptada la donación por el fiduciario, y notificada la aceptación al donante, podrán los dos de común acuerdo hacer en el fideicomiso las alteraciones que quieran, substituir un fideicomisario a otro, y aun revocar el fideicomiso enteramente, sin que pueda oponerse a ello el fideicomisario.

Se procederá para alterar en estos términos la donación, como si se tratase de un acto enteramente nuevo.

- **Evicción en las donaciones enteramente gratuitas.** El donatario puede ser privado de la cosa donada, en todo o en parte de ella por sentencia judicial. En tal evento, el donatario NO tiene acción de evicción contra el donante. 1422. La evicción, como obligación de garantía que es, es propia de los contratos onerosos, en los cuales el acreedor incurrió en desembolsos. En este caso, el donatario no incurrió en gastos.

- **El beneficio de competencia y el derecho de alimentos del donante.**
1626 No. 5 en relación al 1417. El 1417 limita el beneficio al donante de una donación gratuita.

321 No. 5: se deben alimentos al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.

¿Cuándo es cuantiosa? Algunos creen que es cuantiosa, la que requiere insinuación, es decir, la que supera los 2 centavos. Somarriva cree que debe determinarse caso a caso.

B) DONACIONES QUE NO SON ENTERAMENTE GRATUITAS

1. Donaciones con causa onerosa.

Art. 1404. Las donaciones con causa onerosa, como para que una persona abrace una carrera o estado, o a título de dote o por razón de matrimonio, se otorgarán por escritura pública, expresando la causa; y no siendo así, se considerarán como donaciones gratuitas.

Las donaciones con causa onerosa, de que se habla en el inciso precedente, están sujetas a insinuación en los términos de los artículos 1401, 1402 y 1403.

Las donaciones con causa onerosa son aquellas que se sujetan a una determinada condición impuesta al donatario.

Deben otorgarse por escritura pública, expresándose en ella la causa. Sin ello, vale como gratuita.

Además requiere cumplir con los requisitos generales de toda donación: insinuación si es superior a 2 centavos e inscripción en el CBR si se trata de inmuebles.

- **Evicción en las donaciones con causa onerosa.** Tampoco dan derecho a evicción, salvo que el donante haya dado una cosa ajena a sabiendas. 1423.

2. Donaciones con gravamen.

No es sino una categoría de donaciones con causa onerosa.

Art. 1405. Las donaciones en que se impone al donatario un gravamen pecuniario o que puede apreciarse en una suma determinada de dinero, no están sujetas a insinuación, sino con descuento del gravamen.

- Si existe un inmueble, es necesaria la inscripción.

- Es necesaria la escritura pública, pese a que no se exija, porque este tipo de donación no es sino una donación con causa onerosa. Si no se otorga por escritura pública, se considerará gratuita.

- Evicción en las donaciones con gravamen.

1423 incisos 2º y 3º: Con todo, si se han impuesto al donatario gravámenes pecuniarios o apreciables en dinero, tendrá siempre derecho para que se le reintegre lo que haya invertido en cubrirlos, con los intereses corrientes, que no parecieren compensados por los frutos naturales y civiles de las cosas donadas.

Cesa en lo tocante a este reintegro el beneficio de competencia del donante.

3. Donaciones sujetas a modalidades.

Son las donaciones sujetas a plazo, condición o modo. Estas modalidades, respecto de las donaciones, se rigen por las mismas normas que en la sucesión por causa de muerte. 1416.

Art. 1403. La donación a plazo o bajo condición no producirá efecto alguno, si no constare por escritura privada o pública en que se exprese la condición o plazo; y serán necesarias en ella la escritura pública y la insinuación e inscripción en los mismos términos que para las donaciones de presente.

1- Requieren de escritura pública o privada, en que se exprese la condición o plazo, so pena, de nulidad. Si requiere escritura pública, por tratarse de un bien inmueble, no valdrá la privada.

2- Si es superior a 2 centavos, requiere de insinuación.

3- Si se trata de bienes raíces, requiere inscripción.

4. Donaciones remuneratorias. 1433 a 1436.

Son aquellas que expresamente se hicieren en remuneración de servicios específicos, siempre que éstos sean de los que suelen pagarse.

Ej. Amigo otorga un regalo a su abogado, cuando éste no le cobró honorarios. Como puede observarse, estas donaciones no tienen mucho de gratuitas, porque equivalen a una forma de remuneración del servicio prestado.

De la misma definición, se colige que, si la donación es de aquéllas que se hicieren respecto de servicios que no suelen pagarse, la donación sería enteramente gratuita.

- **Solemnidades:** estas donaciones deben otorgarse por escritura pública o privada, según la clase de donación de que se trate. En dicha escritura debe especificarse que la donación ha sido remuneratoria y los servicios pagados con ella. Si no se cumplen estos requisitos, la donación es enteramente gratuita.

Tratándose de inmuebles, en conformidad al 1400, requerirán de inscripción en el Conservador.

Sólo están sujetas a insinuación en cuanto excedan al valor de los servicios remunerados.

- Las donaciones remuneratorias y la Sociedad Conyugal. 1738.

A) Donaciones referidas a Bienes Inmuebles

i- Por servicios que daban acción contra la persona servida: no es sino un salario o emolumento. Por ello cabe dentro del 1725 No.1, ingresando al haber absoluto, siempre que sea devengado durante el matrimonio. Las donaciones remuneratorias por servicios prestados antes de la sociedad conyugal no entran al haber social. 1738.

ii- No daban acción para exigir su pago: se trata de una donación enteramente gratuita y, como se trata de bienes raíces, pasa a formar parte del haber propio de cada cónyuge.

B) Donaciones referidas a Bienes Muebles: dicha donación aumenta el haber de la sociedad, la que deberá recompensa al cónyuge donatario si los servicios

no daban acción contra la persona servida o si los servicios fueron prestados antes de la sociedad.

-La Evicción de las donaciones remuneratorias. 1435: el donatario que sufre evicción de la cosa que le ha sido dada en remuneración, tendrá derecho a exigir el pago de los servicios que el donante se propuso remunerarle con ella, en cuanto no aparecieren haberse compensado con los frutos.

La diferencia de esta donación, en cuanto a la evicción, se explica, porque en el fondo la donación remuneratoria no es gratuita, sino una forma de pagar los servicios prestados.

1436: en lo demás rigen las reglas generales de las donaciones.

5. Donaciones por causa de matrimonio.

No se encuentran reguladas en el Libro III, sino en el Libro IV, referido a las convenciones matrimoniales y a la sociedad conyugal.

Donaciones por causa de matrimonio: aquéllas que un esposo hace a otro antes de celebrarse el matrimonio, y en consideración a él, y las donaciones que un tercero hace a cualquiera de los esposos antes o después de celebrarse el matrimonio y en consideración a él.

Es decir, **son aquéllas que se hacen en consideración al matrimonio del donatario.**

En conformidad al 1404, las donaciones por causa de matrimonio son donaciones con causa onerosa.

- Las donaciones por causa de matrimonio las puede hacer un esposo a otro o un tercero a uno de los esposos. Diferencias.

1. Únicamente los esposos pueden hacerse donaciones por causa de matrimonio, pero no los cónyuges. **1786.** En cambio, los terceros pueden hacer esta donación tanto a los esposos como a los cónyuges. La razón de lo anterior, es que los cónyuges no pueden celebrar ente sí donaciones irrevocables, y las donaciones por causa de matrimonio son una especie de donación entre vivos.
2. Los requisitos de la donación, difieren según quién la efectúe.
 - a- Si la hacen los esposos entre sí: 1406: no requieren insinuación, ni otra escritura pública que las mismas capitulaciones matrimoniales, cualquiera que sea la clase o valor de las cosas donadas.
 - b- Si la efectúa un tercero: quedan sujeta a las reglas generales de la donación con causa onerosa.
3. En las donaciones entre esposos se presume la causa de matrimonio. 1790-final. Cuando un tercero las efectúa, debe expresar que las hace por causa del matrimonio. De no ser así, se aplica el 1404, sobre donaciones con causa onerosa, y la donación pasa a ser enteramente gratuita.
4. Las donaciones que se hagan los esposos entre sí están sujetas a ciertos límites. 1788: ninguno de los esposos podrá hacer donaciones al otro

por causa de matrimonio, sino hasta el valor de la cuarta parte de los bienes de su propiedad que aportare. Es un modo de **amparar las legítimas y las mejoras**. Esta limitación no rige para terceros⁴⁸.

- **Estipulaciones que pueden hacerse en las donaciones por causa de matrimonio. 1789:** las donaciones por causa de matrimonio, sea que se califiquen de dote, arras o con cualquiera otra denominación admiten plazos, condiciones y cualesquiera otras estipulaciones lícitas, y están sujetas a las reglas generales de las donaciones. **1791:** en las donaciones entre vivos o asignaciones testamentarias por causa de matrimonio, no se entenderá la condición resolutoria de faltar el donatario o asignatario sin dejar sucesión ni otra alguna que no se expresa en el respectivo instrumento o que la ley no prescriba.

La única condición que se subentiende en las donaciones por causa de matrimonio es, la de **celebrarse el matrimonio en forma válida**.

- **Las donaciones por causa de matrimonio se hacen en consideración a éste. Caducidad de ellas.** 1786. 1789: en todas las donaciones por causa de matrimonio se entiende la condición de haberse celebrado o de celebrarse el matrimonio.

En realidad, las donaciones por causa de matrimonio no son condicionales, sino que eventuales, por estar sujetas al evento futuro e incierto, pero esencial, de la celebración del matrimonio. De no celebrarse el matrimonio, **caducan las donaciones otorgadas en consideración a él**. Art. 100: puede demandarse la restitución de las cosas donadas y entregadas bajo la condición de un matrimonio que no se ha efectuado, aun en el caso de ruptura de esponsales, institución que no genera obligación alguna.

- **Efectos de la anulación del matrimonio en las donaciones por causa del matrimonio.**

A) Matrimonio simplemente nulo: se pueden revocar, siempre que la donación y su causa se hayan expresado por escritura pública. Pero, cuando son hechas por uno de los esposos, se presume la causa. Los cónyuges, sin embargo, cuando ambos están de mala fe no pueden revocar las donaciones que se han hecho.

B) Matrimonio putativo: los terceros sólo pueden revocar las donaciones efectuadas al que contrajo el matrimonio de mala fe, y siempre que conste la donación y la causa en escritura pública. El cónyuge de buena fe puede, asimismo, revocar las donaciones hechas al de mala fe. El de mala fe no puede hacerlo respecto de las hechas al de buena fe. 1790 y 122.

- **Efectos del divorcio y de la separación judicial en las donaciones por causa de matrimonio.** 172 fue modificado por la NLMC.

⁴⁸ En esto existe cierta impropiedad, debido a que la limitación, aun cuando legalmente no se encuentra expresamente consagrada, sí lo está dentro del contexto de las legítimas y mejoras y precisamente dentro de la formación de los acervos, más específicamente respecto de la acción de inoficiosa donación que los herederos del 3º que donó por causa del matrimonio, podrían ejercer respecto del cónyuge beneficiado.

La sentencia firme de separación judicial o divorcio autoriza, por su parte, a revocar todas las donaciones que por causa del matrimonio se hayan hecho al cónyuge que dio motivo a la separación judicial o al divorcio por su culpa verificada la condición de que la donación y la causa consten en escritura pública. **Es una falla no haber derogado el 172.**

- **1792:** se refiere a las donaciones por causa de matrimonio frente al matrimonio no consumado. **Este artículo se entiende derogado por la NLMC**, ya que dicha institución es propia del matrimonio religioso.

Responsabilidad del Donatario por las deudas del donante. 1418 a 1421

A- **Donaciones a título universal.** El donatario de esta clase de donaciones, tendrá respecto de los acreedores del donante, las mismas obligaciones que los herederos. Pero esta responsabilidad sólo se extiende a 2 clases de deudas:

1. Las contraídas por el donante con anterioridad a la donación;
2. Las posteriores a ella, con tal que no excedan de una suma específica determinada por el donante en la escritura de donación.

Es lógica la amplia responsabilidad que la ley le atribuye al donatario. Respecto de las deudas anteriores a la donación, a fin de proteger a los acreedores. En todo caso, los acreedores tienen las acciones que les correspondan contra el **donante**, según lo prescribe el 1419, a menos que acepten como deudor al donatario, expresamente o en los términos del 1380 inciso 1º. En tales casos, cesa la responsabilidad del donante. Existe una verdadera **novación por cambio de deudor**, la cual requiere, para hacer cesar la obligación primitiva, del consentimiento del acreedor. Es ahí donde se encuentra el fundamento de la subsistencia de la responsabilidad del donante, mientras el acreedor no lo dé por libre.

B- **Donaciones a título singular.** El donatario no tiene sino la responsabilidad que le imponga el donante. 1420 inciso 1º: se puede imponer al donatario el gravamen de pagar las deudas del donante, con tal que se exprese una suma determinada hasta la cual se extienda este gravamen. Los acreedores conserva, no obstante lo anterior, su acción en contra del donante, mientras no acepten expresa o tácitamente al donatario como nuevo deudor.

- **Límite de la responsabilidad del donatario.** 1421: la ley le otorga un beneficio de inventario al donatario. Su responsabilidad no se extiende sino hasta concurrencia de lo que, al tiempo de la donación, hayan valido las cosas donadas, constando este valor por inventario solemne u otro instrumento auténtico, lo cual se aplica también a su responsabilidad por los gravámenes que en la donación se le hayan impuesto.

En conclusión, el donatario no puede ser obligado a pagar más de lo que ha recibido a título de donación, siempre que compruebe dicho valor por instrumento público.

EXTINCIÓN DE LAS DONACIONES

Las donaciones se extinguen de 2 maneras: por las causales generales de extinción de las obligaciones, y por causales propias de extinción.

Las causales especiales, se contienen en el artículo 1424 son las siguientes:

1. Rescisión de la donación por la acción de inoficiosa donación.

Ejercicio de la acción de inoficiosa donación. El exceso de lo donado por el causante a terceros es de tal magnitud que pasa a afectar las legítimas y mejoras calculadas en conformidad al 2º acervo imaginario.

2. Resolución de las donaciones. 1426 y 1427.

Están afectas a resolución cuando son donaciones con causa onerosa o sujetas a un gravamen. Si no se cumple la condición o el gravamen impuesto en la condición, ésta se resuelve. A pesar de que el 1426 y el 1427 hablan de "rescisión", debemos entender que se trata de una condición resolutoria tácita. El donante puede exigir el cumplimiento o la resolución. Lo curioso es que la persona favorecida con el gravamen no puede exigir su cumplimiento.

1326: en caso de resolverse la donación, el donatario será considerado como poseedor de mala fe para restituir lo donado y los frutos. Se le abonará al donatario lo invertido hasta entonces en el desempeño de su obligación, de lo cual se aprovechará el donante.

La acción resolutoria, conforme al 1427, tiene un plazo especial de prescripción: 4 años contados desde el día en que el donatario haya sido colocado en mora de cumplir la obligación. No se suspende.

3. Revocación de las donaciones en caso de ingratitud del donatario. 1428 a 1431.

Siendo un contrato, la donación es generalmente irrevocable. La principal excepción es la **revocación por ingratitud**.

1428: se tiene por acto de ingratitud cualquier hecho ofensivo del donatario que le hiciere indigno de heredar al donante. 968 y 115.

- Quiénes pueden pedir la revocación:

- En principio le corresponde al propio donante.
- Si el donante, por haber perdido el juicio o por otro impedimento, se hallare imposibilitado de pedir la revocación, el 1431 establece una especie de representación legal. Mientras viva el donante, puede pedir la revocación su guardador, y también cualquiera de sus ascendientes o descendientes y el cónyuge.

Si el donante ha fallecido, no se podrá pedir la revocación, salvo en 3 casos: (en estos casos se transmite a los herederos la acción revocatoria).

- a- Cuando se ha intentado la acción revocatoria en vida del donante;
- b- Cuando el hecho ofensivo ha producido la muerte del donante; y
- c- Cuando el hecho ofensivo ha ocurrido después de la muerte del donante.

- **Prestaciones mutuas en la revocación.** El donatario se considera poseedor de mala fe desde el momento de perpetrar el hecho ofensivo.

- **Prescripción de la acción revocatoria.** 4 años contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho ofensivo. No se suspende (por lo mismo se establece la representación legal antes vista).

- Como el legislador no fijo procedimiento especial para las acciones rescisoria, resolutoria y revocatoria, se aplica **el juicio ordinario**.

- Las donaciones remuneratorias no son rescindibles ni revocables. 1434. Esto se explica por el hecho de que la donación remuneratoria no son gratuitas en el fondo. En el exceso, a las donaciones remuneratorias se les aplican las reglas generales: insinuación, son rescindibles y revocables.

- **Efectos de la rescisión, resolución y revocación respecto de terceros. 1432**

El donatario enajenó las cosas donadas o las gravó. Por regla general, la rescisión, resolución y revocación no afectan a las enajenaciones ni a los gravámenes. Sólo empecerán a los terceros, en los 3 casos de excepción del 1432:

a- Cuando en escritura pública de donación, inscrita en el competente Registro, si se trata de inmuebles, se ha prohibido al donatario enajenar las cosas donadas o se ha expresado la condición.

Es uno de los preceptos en que se permite pactar la cláusula de no enajenar. A diferencia de lo que ocurre en los legados, en este caso no se requiere el compromiso de un derecho de un tercero.

No bastaría, según Somarriva, la condición resolutoria tácita, por la exigencia de la expresión.

b- Afectará a terceros cuando antes de las enajenaciones o gravámenes, se ha notificado a los terceros interesados que el donante u otra persona a su nombre propone intentar dichas acciones contra el donatario. Aunque la ley no lo exija, se requiere de notificación judicial.

c- Afectará a terceros cuando se ha procedido a enajenar o gravar sobre los bienes donados, después de intentada la rescisión, resolución o revocación.

Jurisprudencia: el 1432 se refiere a la revocación por ingratitud y no a la mencionada en el 1412: la realizada por el donante antes de haberle sido notificada la aceptación al donatario.

- **En todo caso el donante puede exigir al donatario el valor de las cosas enajenadas.** 1432 inciso final.

Existen otras causales especiales de extinción de las donaciones:

4. **Formas especiales de determinadas donaciones.** Por ej. Las donaciones por causa de matrimonio caducan si no se celebra éste y se revocan si se declara nulo o el divorcio.
5. **1210:** los efectos del desheredamiento, si el testador no los limita en forma expresa, se extienden a las donaciones hechas por el desheredador al desheredado.
6. **1200 y 1201:** las donaciones hechas en razón de legítimas o mejoras se resuelven si al fallecer el causante el donatario no era legitimario o no tenía derecho a mejoras.